

리담상표법
객관식 문제집 (제4판)
(주제별)

속표지

기출문제는 공부의 나침반입니다. 변리사 1차 시험의 합격을 위해 방대한 상표법·디자인보호법의 이론을 공부함에 있어, 정리의 방향성을 알고 있는 수험생과 그렇지 않은 수험생의 차이는 매우 크다고 생각합니다. 기본강의를 완강한 후에는 기출문제를 풀이하면서 기본서의 회독수를 늘려가는 것이 가장 효율적인 1차 시험 공부일 것입니다.

이번 4판에서는 그동안의 기출문제를 연도별이 아닌 주제별로 다시 정리하였습니다. 같은 쟁점을 다루는 문제들을 한데 모아 배치함으로써, 하나의 주제가 시험에서 어떤 방식으로 반복·변형되어 출제되는지를 한눈에 파악할 수 있도록 하였습니다. 이를 통해 수험생 여러분은 개별 문제를 푸는 데 그치지 않고, 각 주제의 출제 경향과 논점을 체계적으로 익힐 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 해설을 한층 더 상세하게 보강하였습니다. 단순히 정답의 근거만을 제시하는 데서 나아가, 각 지문이 왜 옳고 그른지를 관련 조문·판례와 함께 풀어냄으로써, 해설만으로도 해당 주제의 이론을 정리할 수 있도록 하였습니다. 또한, 이름을 숙지할 필요가 있는 판례는 이름을 표기하였습니다.

기출문제를 반복적으로 풀이한다는 것은 매우 중요한 과정이니, 미처 이론이 완전히 정리되지 않아 정답을 맞히는 것이 힘들더라도 꾸준히 반복하여 풀이하시기 바랍니다. 기출문제 풀이는 각 문제의 정답을 골라내는 것이 핵심이 아닙니다. 각 지문의 정오를 확실히 구분할 수 있는냐의 관점에서 풀이하여야 합니다. 비록 해당 문제의 정답을 맞혔더라도 개별 지문의 정오가 확실하지 않다면, 해당 지문을 표시하고 정오를 확실히 구분할 때까지 반복하여 보아야 합니다. 주제별로 재정리된 이번 4판이 이러한 반복 학습에 한층 도움이 되기를 바랍니다.

본 교재를 활용하여 공부하시는 모든 수험생들의 1차 합격을 기원합니다. 또한 본 교재의 발간을 위해 힘써주신 리담학원 임직원분들께 큰 감사의 마음을 전합니다.

제1편 총칙/보칙

제1장 총칙규정	3
제1절 목적 1	3
제2절 정의 2	4
• 상표법상 상품	4
• 상표의 식별력	6
• 상표의 사용	12
• 특수한 표장	25
제3절 행위능력 4, 5, 9	29
제4절 대리인 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15	45
제2장 상표의 동일·유사	31
제3장 상품의 동일·유사	42

제2편 등록요건

제1절 상표등록의 요건 33	47
• 본질적 식별력이 없는 상표(法 33①)	47
• 사용에 의한 식별력을 취득한 상표(法 33②)	61
제2절 상표등록을 받을 수 없는 상표 34	68
• 제34조 제1항 제1호 내지 제6호	68
• 제34조 제1항 제7호	82
• 제34조 제1항 제9호 내지 제13호	89
• 제34조 제1항 제15호	106
• 제34조 제1항 제20호 및 제21호	107
제3절 선출원 35	109
제4절 상표등록을 받을 수 있는 자 및 없는 자 3	111

제3편 출원

제1절 상표등록출원 36	115
---------------------	-----

제4편 이익제도

제1절 실체의 보정 40, 41, 42, 43	119
제2절 출원의 분할 45	120
제3절 조약에 따른 우선권 주장 46	121
제4절 출원 시의 특례 47	123

제5편 심사

제1절 심사 또는 소송 절차의 중지 70	127
제2절 부분거절 54	128
제3절 재심사의 청구 55의 2	131
제4절 손실보상청구 58	132
제5절 이의신청 60-66, 71	136

제6편 상표권

제1장 효력	139
제1절 상표권의 효력 89, 91, 96, 108	139
제2절 상표권의 효력 제한	159
• 법률에 따른 제한(法 77③, 90, 161)	161
• 권리소진	166
• 진정상품병행수입	170
• 권리남용	174
제3절 타인의 디자인권 등과의 관계 92	176
제4절 상표권자의 보호 107-114	178
제5절 벌칙 230-237	189
제2장 변동	194
제6절 상표권의 이전 및 공유 93	194
제7절 상표권의 분할 94	198
제8절 사용권 일반 95, 97, 100	199
제9절 법정사용권 98, 99, 104의2	208
제10절 질권 104, 105	210
제3장 소멸	210
제11절 상표권의 소멸 106	210
제4장 관련제도	215
제12절 존속기간 갱신등록 84, 85, 88①	215
제13절 지정상품 추가등록 86, 87, 88②	221

제7편 **심판**

제1절 일사부재리 150	225
제2절 취하에 의한 종료 148	226
제3절 거절결정에 대한 심판 116, 123, 154, 156	227
제4절 상표등록의 무효심판 117, 122①	230
제5절 상표등록의 취소심판 119, 122②	237
• 제119조 제1항 제1호 및 제2호	237
• 제119조 제1항 제3호	242
• 제119조 제1항 제6호	260
제6절 사용권 등록의 취소심판 120, 122②	262
제7절 권리범위 확인심판 121	264
제8절 재심 157-161	277

제8편 **소송**

제1절 심결 등에 대한 소 162-165	281
------------------------------	-----

제9편 **국제출원 및 국제조약**

제1장 마드리드의정서에 따른 국제출원	291
제1절 국제출원 일반	291
제2절 지식재산처를 통한 국제출원 등 167-179	297
제3절 국제상표등록출원에 관한 특례 180-204	298
제2장 국제조약	306

제10편 상표 외의 권리

제1절 단체표장	311
제2절 증명표장	313
제3절 지리적표시 단체표장	314
제4절 업무표장	314

제1편

총칙/보칙

주 · 제 · 별

리담상표법 객관식 문제집

- 총칙규정

- 상표의 동일·유사

- 상품의 동일·유사

제1장 총칙규정

제1절 목적

1

01 산업재산권 제도에 관한 다음의 비교 설명 중 옳지 않은 것은?

03 기출

- ① 공중의 위생을 해할 염려가 있는 디자인이나 상표는 부등록요건에 해당하지 않는다.
- ② 공지 또는 공연실시발명의 지역적 기준은 국내에 한정되지만 공지 또는 공연실시디자인의 지역적 기준은 외국까지 포함된다.
- ③ 디자인 및 실용신안 등록출원에 있어서는 도면의 제출이 필수적으로 요구된다.
- ④ 디자인보호법상 정정심판제도나 정정무효심판제도가 존재하지 않는다.
- ⑤ 설정등록된 디자인 및 특허는 모두 등록공고되며 등록공고된 양 권리에 대하여 누구든지 이의신청을 할 수 있다.

해설

- ① [○] 특허법과 실용신안법은 '공중의 위생을 해할 염려가 있는 것'은 등록받을 수 없다고 규정하고 있으나, 상표법과 디자인보호법에서는 이러한 부등록 사유가 없다.
- ② [×] 40회 당시에는 맞는 지문이었으나 2006년 10월 1일 시행 특허법은 공자공연실시의 판단기준에 국외를 포함시켰으므로 현재로는 틀린 지문이 된다.
- ③ [○] 디자인과 실용신안 등록출원에서는 도면이 필수 제출서류이다. 이와 비교하여 특허는 필요한 경우에 제출하며, 상표는 출원서류에 도면이 포함되어 있지 않다.
- ④ [○] 디자인은 등록 후 권리를 정정하는 제도(정정신청, 정정심판, 정정무효심판)가 존재하지 않는다.
- ⑤ [×] 특허의 경우 이의신청제도가 폐지되었으며, 디자인의 경우도 디자인일부심사 이의신청만이 존재한다.

정답 ②, ⑤

제2절 정의

2

상표법상 상품

02 상표등록을 받을 수 없는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 18 기출

- ㄱ. 직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업을 지정상품(서비스)으로 하는 ‘알바천국’
- ㄴ. 가정/사무실용품물분배기, 산업용품물분배기, 냉수기를 지정상품으로 하는 ‘WATERLINE’
- ㄷ. 장미를 지정상품으로 하는 ‘Red Sandra’
- ㄹ. 호텔업, 모텔업, 레스토랑업, 관광숙박업을 지정상품(서비스)으로 하는 ‘SUPER8’
- ㅁ. 금속절단공구, 절단공구, 도구 및 절단장치의 형상화와 관련한 기술상담업을 지정상품(서비스)으로 하는 ‘engineering your competitive edge’

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

해설

- ㄱ. [○] ‘아르바이트를 하기에 좋은 곳’을 소개알선하거나 이와 관련된 정보를 제공한다는 암시를 줄 수 있는 하나, 이를 넘어서 일반 수요자에게 ‘아르바이트를 소개알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소’ 등과 같이 위 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없다(대법원 2016.1.14. 선고 2015후1911 판결).
- ㄴ. [x] 일반수요자나 거래자들이 그 지정상품인 ‘가정, 사무실용 물 분배기 등’과 관련하여 “WATERLINE”을 볼 때 원시 판시의 여러 사전적 의미 중 ‘물이 흐르는 통로 또는 도관(송수관)’의 의미로 인식할 것이어서, 그 지정상품의 주요 부품을 나타내거나 그 주된 기능의 하나인 도관을 따라 필요한 곳으로 물을 흐르게 하는 기능을 나타내고 있으므로, 이 사건 출원상표는 기술적 표장에 해당한다고 봄이 상당하다(대법원 2007.11.29. 선고 2007후3042 판결).
- ㄷ. [x] “장미”를 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표 “Red Sandra”는 이 사건 등록상표의 지정상품을 취급하는 거래계(생산자, 판매자 및 수요자)에서 장미의 한 품종의 일반적 명칭으로 사용되고 인식되어져 있어 결국, 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다(대법원 2002.11.26. 선고 2001후2283 판결).
- ㄹ. [x] ‘SUPER’ 부분은 ‘최고급의, 특등품의’ 등의 뜻을 가진 영어 단어로서 지정서비스업과의 관계에서 그 우수성을 나타내는 것으로 직감되므로 지정서비스업의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, ‘8’ 부분은 아라비아 숫자 한 글자에 불과하여 간단하고 흔히 있는 표장으로서 식별력이 없으며, 또한 이들 각 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니다(대법원 2011.3.10. 선고 2010후3226 판결).
- ㅁ. [○] 이 사건 출원상표는 “engineering your competitive edge”와 같이 4개의 영어단어가 한 데 어우러진 영어 문구로 구성된 것으로서 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래자가 그 의미를 직감할 수 있다고 하기 어려워 그 의미에 기하여 식별력을 부정하기 어렵다(대법원 2007.11.29. 선고 2005후2793 판결).

정답 ④

03 상표법상 상품에 해당되는 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'21 기출

- ① 다른 상품의 판매촉진이나 광고를 하기 위하여 무상으로 제공되는 볼펜
- ② 마약 등 거래가 금지되는 물품
- ③ 인터넷에서 다운로드의 형태로 판매되는 컴퓨터프로그램
- ④ 대리점에서 판매되는 즉석건강식품의 원재료를 보여주기 위해서 곡물마다 별도로 유리 용기에 담은 상품의 견본
- ⑤ 종전부터 발행하여 오던, 영화·음악·연예인 등에 관한 정보를 담은 월간잡지 “ROADSHOW, 로드쇼”의 독자들에게 보답하기 위하여 사은품으로 제공한 외국의 영화배우들 사진을 모은 “WINK”라는 제호의 책자

해설

- ① [x] 상표법상의 ‘상품’이란 ‘그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품’을 말한다(대법원 1999.6.25. 선고 98후58 판결). 따라서 부동산과 같이 운반할 수 없거나 열·향기와 같은 무체물, 반복거래의 대상이 될 수 없는 골동품, 거래가 금지되어 유통성이 없는 금제품(禁制品), 광고매체가 되는 물품 및 유가증권 등은 상표법상의 상품이라 할 수 없다.
- ② [x] 거래가 금지되어 유통성이 없는 금제품(禁制品)에 해당하여 상품으로 인정될 수 없다.
- ③ [○] 이른바 ‘디지털상품(digital goods)’으로서 최근의 거래실정상 상표실무 및 판례는 유체물체의 화체(化體) 여부를 묻지 않고 상표법상의 상품으로 인정하고 있다.
- ④ [x] 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결
- ⑤ [x] WINK 사건, 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결

정답 ③

상표의 식별력

04 강학상의 주지상표와 저명상표에 관한 설명 중 옳은 것만으로 바르게 묶인 것은? 09 기출

- ㄱ. 출원상표가 저명상표와 저촉되는지 여부는 상표등록출원을 한 때(상표등록출원시)를 기준으로 판단하며, 착오로 등록된 경우 제척기간이 있는 무효사유에 해당한다.
- ㄴ. 희석화침해이론은 주지의 정도를 넘어 저명한 정도에 이른 상표를 보호하기 위한 이론이다.
- ㄷ. 상표가 직접 상품에 사용되고 있지 않다면 신문, 잡지, 라디오 등을 통하여 광고된 결과 수요자에게 널리 인식되더라도 주지상표가 될 수 없다.
- ㄹ. 등록된 저명상표의 침해금지청구권의 범위는 주지상표와 달리 이종상품이나 이종 영업에까지 미친다.
- ㅁ. 부정사용으로 인한 상표등록의 취소심판(상표법 제119조 제1항 제1호)은 주지·저명상표를 간접적으로 보호하기 위한 제도로 볼 수 있다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

해설

- ㄱ. [x] 제34조 제1항 제11호의 판단은 출원시를 기준으로 한다. 다만, 착오로 등록된 경우 제척기간 없는 상표등록의 무효사유에 해당한다.
- ㄴ. [○] 희석화란 저명상표의 식별력이나 명성을 손상하는 경우를 말한다는 점에서 옳은 지문이고 대법원 판례도 동일한 입장이다.
- ㄷ. [x] 상표가 직접 상품에 표시되어 유통되지 않았다 하더라도 광고·선전 등에 의하여 수요자에게 널리 인식되었다면 주지상표가 될 수도 있다.
- ㄹ. [x] 저명상표가 등록된 경우라도 침해금지청구권의 범위는 동일 또는 유사한 상품에 한한다.
- ㅁ. [○] 제119조 제1항 제1호는 등록상표와 유사한 실사용상표의 사용으로 대상상표와의 관계에서 출처혼동을 초래한 경우 그 등록상표를 취소하는 제도이고, 본 규정의 대상상표는 주지·저명하지 않아도 무방함은 물론이나(판례는 주지하거나 저명하지 않아도 무방하나 특정인의 출처로서는 알려져 있어야 한다고 보았다), 현실적으로 보았을 때는 대상상표가 주지·저명한 경우 이에 편승하고자 등록상표를 변형한 실사용상표를 사용하는 경우가 대부분으로서, 이 경우 일반수요자의 이익과 대상상표의 신용을 함께 보호하고자 함이 그 취지이므로 제119조 제1항 제1호는 주지·저명상표를 간접적으로 보호하기 위한 제도로 볼 수 있다. 따라서, 옳은 지문이다.

정답 ③

05 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 12 기출

- ① 기술적 문자로 구성된 상표 중 일부의 도안화 정도가 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도하여 일반인의 특별한 주의를 끌 정도의 상표라 할지라도 상표법 제33조(상표등록의 요건)의 기술적 표장에 해당하므로 식별력이 인정되지 않는다.
- ② 간단하고 흔한 도형의 조합이 반복되는 표장이라도 흔히 사용될 수 있는 것이라고 볼 수 없고, 지정상품의 특성을 기술하지 않는 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다.
- ③ 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제7호에 해당하는 상표는 상표등록출원전에 사용에 의해 식별력을 취득한 경우라도 상표등록을 받을 수 없다는 것이 판례의 입장이다.
- ④ 그 상품의 산지 표시라 함은 해당 상품이 해당 지방에서 현실적으로 생산되고 있어야 하므로 과거에 생산되었거나 과거에 생산된 것으로 일반수요자가 인식하고 있는 것만으로는 산지 표시에 해당한다고 할 수 없다.
- ⑤ 상표등록 후에 기술적 표장으로 된 상표라도 상표권 존속기간 갱신등록은 가능하나 상표권 존속기간 갱신등록 후 기술적 표장이라는 이유로 상표권 갱신등록무효심판에 의해 무효로 될 수 있다.

해설

- ① [x] 기술적 표장이 문자 인식력을 압도할 정도로 도안화되어 일반인의 특별한 주의를 끌 정도라면 식별력이 인정된다.
- ② [○] 대법원 2010.4.15. 선고 2010후210 판결: 즉, 간단하고 흔한 도형의 조합이 반복되는 표장이라는 이유만으로 식별력을 부정할 수는 없으므로 간단하고 흔한 도형의 조합이 반복되는 표장이라 하여도 그것이 흔히 사용될 수 있는 것이라고 볼 수 없고, 지정상품의 특성을 기술하지 않는 경우에는 식별력이 인정될 수 있음은 당연하다.
- ③ [x] 객관적으로는 제33조 제1항 제7호에 해당하는 상표라 할지라도 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 제33조 제1항 제7호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않게 되고 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 제33조 제2항에 동조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003.7.11. 선고 2001후2863 판결). 이러한 판례의 태도를 반영하여 2023년 개정법은 법 제33조 제2항에 동조 제1항 제7호를 명시적으로 포함시켰다.
- ④ [x] 상품의 산지 표시라 함은 해당 산지에서 과거에 생산되었거나 현실적으로 생산되는 경우는 물론 실제 생산되지 아니하여도 일반 수요자가 그 곳에서 생산되는 것으로 인식할 수 있는 경우를 포함한다.
- ⑤ [x] 존속기간갱신등록은 실체심사가 수행되지 아니하므로 상표등록 후에 기술적 표장으로 된 상표라도 존속기간의 갱신등록이 가능하다. 또한, 갱신등록의 무효사유는 i) 상표권의 존속기간갱신등록이 제84조 제2항의 규정에 위반된 경우(시기 위반), ii) 해당 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)가 아닌 자가 상표권의 존속기간갱신등록신청을 한 경우에 한하므로(法 118), 존속기간의 갱신등록 이후 기술적 표장이라는 이유로 갱신등록이 무효로 될 수는 없다.

정답 ②

06 본래 식별력이 있던 X상표를 상표등록 한 甲이 상표관리를 소홀히 한 결과 지정상품의 효능을 표시하는 표장(일명 성질표시 상표)이 되어 등록상표 X가 식별력을 상실한 경우에 대한 법적 취급으로 옳은 것은?

16 기출

- ① 상표등록에 원시적 흠결이 있는 것이 아니므로 무효심판 청구의 대상이 되지 않는다.
- ② 이해관계인은 X상표의 식별력 상실을 이유로 취소심판을 청구할 수 있으며 그 심판청구에 대하여 인용한다는 심결이 확정되면 甲의 상표권은 그 때부터 소멸한다.
- ③ 상표권은 무효가 확정되기 전에는 유효하게 존속하는 것이므로 아직 무효심결 확정 전이라면 경쟁업자 乙이 X상표와 동일·유사한 표장을 지정상품의 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 경우라도 등록상표권의 보호범위에 속하므로 甲의 상표권 침해가 성립한다.
- ④ X상표가 지정상품의 성질표시 상표로 되었더라도 甲이 다시 상표관리에 만전을 기한다면 X상표에 대한 사용에 의한 식별력을 다시 취득할 수도 있다.
- ⑤ 甲이 등록상표에 대한 존속기간 갱신등록을 신청한 경우 심사관은 그 식별력을 심사하여 이를 거절결정할 수 있다.

해설

- ① [x] 후발적 무효심판의 대상이 된다(法 117①(6)).
- ② [x] 후발적 무효사유를 이유로 무효심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 그 사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(法 117④). 다만, 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시된 때부터 없었던 것으로 본다(法 117⑤).
- ③ [x] 비록 甲의 상표가 무효심결이 확정되기 전이라 하여도 乙이 X상표와 동일·유사한 표장을 지정상품의 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우라면 제90조 제1항 제2호에 따라 침해가 아니다.
- ④ [○] 어떠한 표장이 상표로서 식별력이 있는지 여부는 결국 지정상품에 관한 일반수요자의 인식을 기준으로 할 것으로 본래 식별력이 있었던 X상표가 성질표시상표가 된 후 다시 사용에 의한 식별력을 취득할 수도 있음은 당연하다.
- ⑤ [x] 상표권의 존속기간 갱신등록신청은 실체심사를 하지 않고, 따라서 식별력이 없다는 이유로 거절할 수 없다.

정답 ④

07 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) '20 기출

- ① 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관계없이 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사여부를 판단할 수 있다.
- ② 상품의 성질, 품질 등의 특성에 대한 정보를 직감하게 하는 표장을 기술적 표장이라 하고, 상품의 특성을 파악하기 위하여 상상, 사고, 지각 등의 사고과정을 요하는 표장을 암시적 표장이라 한다.
- ③ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표라 하더라도 식별력을 취득하면 등록을 받을 수 있다.
- ④ 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다.
- ⑤ 협의의 식별력이란 자신과 타인의 상품을 구별하여 인식하게 하는 힘을 의미한다.

- 해설**
- ① [x] 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 '사용된 상품에 관하여' 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다(알파 사건, 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결).
 - ② [○] 기술적 표장은 식별력이 인정되지 않고, 암시적 표장은 식별력이 인정된다.
 - ③ [○] 제33조 제2항
 - ④ [○] 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007후2834 판결; 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등
 - ⑤ [○] 상표의 '식별력'이란 i) 협의의 의미로는 이른바 '자타상품식별력(自他商品識別力)'으로서 거래상 자타 상품을 식별케 하는 힘을 의미하며, ii) 광의의 의미로는 이에 더하여 자유사용의 필요성을 뜻하는 '독점적응성(獨占適應性)'의 유무를 포함하는 개념으로 사용된다.

정답 ①

- 08** 甲은 2017년 1월 7일경부터 본인이 판매하는 자동차 용품에 붙여 사용한 A(기술적 표장)를 2018년 11월 26일 출원하였고, 출원 전부터 활발하게 사용된 A상표는 2019년 4월경 거래사회에서 일반수요자나 거래자에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되었으며, 2020년 1월 8일 등록결정 되었다. 이와 관련하여 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

20 기출

- ㄱ. A 상표는 출원 후에 특정인의 상품출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되었으나 출원 시 식별력 없는 기술적 표장에 불과하므로 등록결정을 받을 수 없다.
- ㄴ. 식별력 없는 기술적 표장이라고 할지라도 사용에 의한 식별력을 취득하면 예외적으로 상표등록을 인정해 주는 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제2항의 적용은 출원경제 등을 이유로 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단하여야 하므로 A 상표는 등록결정을 받을 수 있다.
- ㄷ. 일반수요자의 A 상표에 대한 상품표지로서의 인식은 익명의 존재로서의 추상적 출처이면 족한 것이지 구체적으로 甲의 성명이나 명칭까지 인식할 필요는 없다.
- ㄹ. A 상표는 출원 시 비록 기술적 표장에 불과하였지만 등록여부결정 전까지 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 이상 식별력 있는 표장으로서 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제2호에 의한 상표권 효력제한을 받지 않는다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설

- ㄱ [x] 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득여부의 판단은 '상표등록여부결정을 할 때'를 기준으로 한다. 따라서, 출원 시 식별력 없는 표장에 불과하더라도 등록여부결정 시에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우라면 등록결정을 받을 수 있다.
- ㄴ [O] 'ㄱ' 해설 참조. '출원경제'의 의미는 출원시를 기준으로 판단한다고 가정하여 'ㄴ' 상황의 상표를 거절하더라도 다시 출원하게 되면 출원시를 기준으로 사용에 의한 식별력을 갖춘 꼴이 되므로 어차피 상표등록을 해주어야 한다는 의미이다.
- ㄷ [O] 특정인의 상품표지로서의 인식은 익명의 존재로서의 추상적 출처이면 족하지, 구체적으로 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야 하는 것은 아니다(대법원 1990. 11. 27. 선고 90후410 판결).
- ㄹ [O] 제33조 제2항에 의하여 식별력을 취득한 상표는 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권의 효력 제한을 받지 아니한다.

정답 ⑤

09 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) '21 기출

- ① 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 상표를 독점 시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다.
- ② 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.
- ③ 결합상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그 중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.
- ④ 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있고, 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.
- ⑤ 수요자를 기만할 염려가 있는 상표가 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다고 인정되려면 선사용상표가 국내 전역에 걸쳐 수요자와 거래자에게 알려져야 하고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.

해설

- ① [○] 로레알 사건, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등
- ② [○] VICTORIA 사건 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결 등
- ③ [○] GLIATAMIN 사건, 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결 등
- ④ [○] AMERICAN UNIVERSITY 사건, 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결
- ⑤ [×] 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록 상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 하여야 한다. 여기서 '특정인의 상표나 상품이라고 인식'되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다(웨딩클 사건, 대법원 2020.9.3. 선고 2019후11688 판결).

정답 ⑤

상표의 사용

10 상표의 사용에 관한 다음 설명 중 옳지 못한 것은?

02 기출

- ① 상품의 포장에 상표를 표시하는 것은 상표의 사용이다.
- ② 상품에 표시된 등록상표를 그대로 둔 채 그 상품을 수리, 가공 등을 하여 판매한 경우, 그 수리, 가공된 상품이 본래의 상품과 품질이 달라질 정도로 변경된 것이라면, 이러한 행위는 수리 또는 가공한 별개의 상품에 상표를 표시한 것이 되므로 상표권을 침해한 것으로 볼 수 있다.
- ③ 지정상품과 무관하게 신문잡지에서 등록상표가 사용되는 경우에도 상표의 사용으로 보아야 한다.
- ④ 상품에 관한 광고에 상표를 표시한 것만으로는 상표의 사용으로 볼 수 없다.
- ⑤ 비교광고 등에서 자기의 상품에 관한 광고의 문장중에 동종상품에 관한 타인의 등록상표를 기재하였다고 하더라도 상품의 출처를 표시하는 것으로 사용 되었다고 볼 수 없는 경우에는 상표권침해를 구성하지 아니한다고 본다.

해설

- ① [○] 지문④ 해설 참조
- ② [○] 권리소진이론은 오로지 '당해상품'에 대하여만 그 적용이 있다. 따라서, 단순한 수리, 가공의 정도를 넘어 '원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선'을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이다(대법원 2003.4.11. 선고 2002도3445 판결).
- ③ [×] 상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 대하여 사용하는 표장(法 2①1)이므로, 지정상품과 무관하게 신문잡지에서 등록상표가 사용되는 경우에는 상표의 사용으로 볼 수 없다.
- ④ [○] 상표법상 상표의 사용이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위이다(法 2①11가목). 그러나 상품에 관한 광고에 상표를 표시한 것만으로는 상표의 사용으로 볼 수 없고, 이와 같이 표시한 것을 전시 또는 반포하여야 상표의 사용이 된다(法 2①11라목). 따라서 ①, ④는 타당하다.
- ⑤ [○] 비교광고 등에서 자기의 상품에 관한 광고의 문장 중에 동종상품에 관한 타인의 등록상표를 기재한 경우, 형식적으로는 상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 이를 전시·반포한 행위로서 제2조 제1항 제11호 라목에 해당한다고 할 것이나, 실질적으로 그것이 상품에 대한 출처표시로서의 사용이라고 볼 수 없는 경우라면 상표법상 상표의 사용으로 인정할 수 없으므로 상표권의 침해를 구성하지 아니한다.

정답 ③

11 상표의 사용에 대한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

'03 기출

- ① 상표의 사용은 상표 그 자체가 상표로서의 기능을 발휘하도록 사용하는 것을 의미하므로, 비록 문리적으로 상표의 사용에 해당하는 것으로 보이더라도 실제로 당해 표지가 상표로서의 기능을 발휘하는지를 검토하여 상표의 사용 여부나 상표권의 침해 여부를 판단하여야 한다.
- ② 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'에 상표가 표시되어 있다고 하더라도 원칙적으로 상표의 사용이라고 볼 수 있다.
- ③ 상품의 포장지에 상표를 표시한 것을 양도의 목적으로 전시·수출·수입하는 행위는 상표의 사용으로 볼 수 있다.
- ④ 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 포장의 형상으로 하는 행위는 상표의 사용의 일태양(一態樣)이다.
- ⑤ 상표의 광고기사가 게재된 외국 발행의 잡지가 국내에 수입, 반포되었을 경우에 있어서, 이러한 외국에서 발행된 간행물을 통한 국내에서의 상표의 선전광고 행위는 상표의 사용에 포함된다.

해설

- ① [○] 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것이고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(후지필름, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결).
- ② [×] '상표의 사용'이기 위해서는 법상 상품에 상표를 사용하였을 것을 요구하는데 광고매체는 독립거래의 대상이 아니므로 법상 상품이 아니다. 따라서 광고매체가 되는 물품에 상표를 표시하여도 상표의 사용은 아니다(대법원 1999.6.25. 선고 98후58).
- ③ [○] 제2조 제1항 제11호 나목(유통행위)
- ④ [○] 제2조 제2항에 따라 맞는 지문이다.
- ⑤ [○] 제2조 제1항 제11호에 의하여 상표의 사용행위에 포함되는 행위, 즉 상표의 선전광고는 국내에서 이루어질 것을 요한다고 할 것이나, 간행물을 통한 선전광고의 방법에 있어서는 반드시 우리나라에서 발행된 간행물에 한정되는 것이 아니라 외국에서 발행된 간행물이라 하더라도 우리나라에 수입, 반포되고 있다면 이러한 외국에서 발행된 간행물을 통한 국내에서의 상표의 선전·광고행위는 소정의 상표의 사용에 포함된다(대법원 1991.12.13 선고 91후356).

정답 ②

12 다음은 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 '상표의 사용'에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 대법원 판례에 의함) '06 기출

- ① 상표권자의 승낙없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 '상표의 사용'에 해당한다.
- ② 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 '상표의 사용'에 해당한다.
- ③ 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 인도할 목적으로 수출하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 '상표의 사용'에 해당한다.
- ④ 타인의 등록상표와 유사한 표장을 사용한 경우라고 하더라도 순전히 디자인(의장)적으로만 사용된 경우에는 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 '상표의 사용'에 해당한다고 볼 수 없다.
- ⑤ 상표법 제2조 제1항 제11호에서 '상표의 사용'이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다.

해설

- ① [×] 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 상표의 사용에 해당하지 아니한다(대법원 2004.9.24. 선고 2002다58594).
- ② [○] 제2조 제1항 제11호 라목의 광고행위이다.
- ③ [○] 제2조 제1항 제11호 나목의 유통행위에 해당한다.
- ④ [○] 아가타 사건, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등
- ⑤ [○] CASS 사건, 서울지방법원 1995. 10. 24. 선고 95카합3529 결정

정답 ①

13 상표법상 상표의 사용 등에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

'07 기출

- ① 상표의 사용행위 중 선전, 광고행위는 지정상품에 관련하여 행하여져야 하는 것일 뿐만 아니라, 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 상표의 사용이라고 할 수 있다.
- ② 상표법 제2조 제1항 제11호 라목 소정의 '거래서류'에는 납품서, 물품영수증, 카탈로그 등이 포함되며, 세관에 제출한 수입신고서도 거래서류에 해당하므로 그 수입신고서에 상표를 표시한 경우 라목 소정의 상표의 사용행위라 할 수 있다.
- ③ 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표의 사용이라고 할 수 있다.
- ④ 상표법상 상품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진을 위해 고객에게 무상으로 배부되는 이른바 '광고매체가 되는 물품'에 상표를 표시한 것은, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 상표의 사용이라고 할 수 없다.
- ⑤ 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우에는 누구든지 등록상표에 대한 취소심판을 청구할 수 있다.

해설

- ① [○] 등록상표를 지정상품에 관하여 광고할 당시 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 않았고, 단순히 등록상표에 대한 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 지나지 않은 경우, 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(아구용 배트 사건, 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 [등록취소(상)]).
- ② [×] 세관에 제출하는 수입신고서는 거래당사자 간에 교부되는 거래서류라고 보기 어려우므로 수입신고서에 상표를 표시하였다고 하여 상표법상 상표의 사용행위라고 할 수는 없다(대법원 2002. 11. 13. 선고 2000마4424 결정).
- ③ [○] 페라가모 사건, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007후2834 판결 [권리범위확인(상)]
- ④ [○] WINK 사건, 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 [상표등록취소]
- ⑤ [○] 제119조 제1항 제1호

정답 ②

14 상표의 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 10 기출

- ① 자동차부품인 에어컨리너를 제조하면서 그 포장상자에 자동차 제작회사의 등록상표의 표시를 하였더라도 제반 사정에 비추어 그 출처표시가 명백하고 부품 등의 용도설명이나 에어컨리너가 사용되는 적용차종을 밝히기 위하여 사용한 것에 불과한 경우에는 그 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.
- ② 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표로서의 사용에 해당한다.
- ③ 명함의 이면에 상표를 표시하는 행위도 상표법상 상표의 사용행위에 해당할 수 있다.
- ④ 상표가 표시된 수입신고서를 세관에 제출하는 행위는 상표법상 상표의 사용행위에 해당하지 않는다.
- ⑤ 상표권자가 통상사용권을 설정하는 행위는 상표의 사용에 해당한다.

해설

- ① [○] 신일 ENG 사건, 대법원 2001.7.13. 선고 2001도1355 판결
- ② [○] 버버리 사건, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결
- ③ [○] 제2조 제1항 제11호 라목의 '거래서류'는 구체적인 서류명에 구매받을 것이 아니라 실제 거래에 있어서 제공되는 서류인지 여부를 기준으로 판단하여야 한다. 이에 대법원은 "명함 이면(裏面)에 상표를 수기(手記)로 써서 구매자에게 교부한 경우 이 때의 명함 이면은 판매된 물품을 확인해주는 거래서류에 해당한다."고 판시한바 있다(대법원 2002. 11. 13. 선고 2000마4424 결정). 따라서, 명함의 이면, 거래명세서에 상표를 표시하는 행위는 상표법상 상표의 사용행위에 해당할 수 있다.
- ④ [○] 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000마4424 결정
- ⑤ [×] 통상사용권의 설정은 단순히 등록상표의 사용허락을 통한 상표권의 수익행위에 불과하지 통상사용권 설정행위 자체가 상표의 사용이 될 수 없음은 당연하다.

정답 ⑤

15 상표법상 상표의 사용 또는 상품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

11 기출

- ① 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.
- ② 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없다.
- ③ 상표권자 등이 완구에 대하여 관련 행정법규에서 규정하는 안전검사 등을 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 당해 완구가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하였다고 볼 수 없으므로, 당해 등록상표가 그 완구에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정하는 데 아무런 장애가 되지 아니한다.
- ④ 약사법에서 규정하는 보건복지부장관의 품목별 허가를 받지 않은 의약품을 지정상품으로 하는 등록상표라도 이를 선전·광고하거나 지정상품에 부착하여 판매 하는 것은 정당한 상표사용에 해당하여 상표등록의 취소를 면할 수 있다.
- ⑤ 불사용으로 인한 상표등록취소의 요건과 관련하여 판단할 때, 타인의 저작권을 침해하는 등록상표의 사용이라도 상표의 정당한 사용으로 인정될 수 있다.

해설

- ① [○] 레이싱카 사건, 대법원 2006.9.22. 선고 2005후3406 판결
- ② [○] 상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(WINK 사건, 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결).
- ③ [○] 지문④ 해설 참조
- ④ [x] 행정법규 등에서 요구하는 허가나 검사 등을 받지 않았다 하여 무조건적으로 제119조 제1항 제3호에 있어 등록상표의 정당한 사용이 아니라고 단정해서는 안되고, 행정법규의 목적·특성, 그 상품의 용도·성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여 '개별적으로 판단'하여야 하는데(대법원 2006.9.22. 선고 2005후3406 판결), 구체적 사안에 있어 대법원은 i) '화장품'과 '의약품'의 경우에는 허가를 받지 않고 판매한 경우 정당한 사용으로 보지 않았고, ii) '완구'와 '보온병'의 경우에는 안전검사 등을 받지 않고 판매한 경우라도 정당한 사용으로 보았다. 다음의 판례 참조 : "피고가 레이싱카완구에 대하여 품질경영 및 공산품안전관리법에서 규정하는 안전검사를 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 레이싱카완구가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하였다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 레이싱카 완구에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정하는 데 아무런 장애가 되지 아니한다(대법원 2006.9.22. 선고 2005후3406 판결)." "지정상품이 의약품인 경우 그 등록상표를 지정상품에 법률상 정당히 사용하기 위하여는 그 제조나 수입에 관하여 보사부장관의 품목별 허가를 받아야 하므로 그러한 허가를 받지 아니하였다면 신문지상을 통하여 1년 못미쳐 한차례씩 그 상표를 광고하였거나 국내의 일부 특수지역에서 판매되었다고 하더라도 상표의 정당한 사용이라고 볼 수 없다(1990. 7. 10. 선고 89후1240,1257 판결)." 따라서, ③의 지문은 옳은 지문이고, ④의 지문은 틀린 지문이다.
- ⑤ [○] 크로커다일 키즈 사건, 대법원 2001.11.27. 선고 98후2962 판결

정답 ④

16 상표 및 상표의 사용에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 12 기출

- ① 상표법 제108조(침해로 보는 행위) 제1항 제1호에 규정된 등록상표와 유사한 상표에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표까지도 포함하는 것으로 한다.
- ② “상표의 사용”이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위를 말하므로 상품 또는 상품의 포장 자체를 포장의 형상으로 하는 것은 상표로서 사용에 포함되지 아니한다.
- ③ 소송 등을 통하여 상표권을 행사하는 경우 상표법 제2조(정의) 제1항 제11호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 수 없을 뿐만 아니라 방위적 목적의 상표라고 하여 상표권 침해자에 대하여 상표권을 행사하여 온 것만으로는 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 없다.
- ④ 등록상표와 동일·유사한 상표가 표시되어 있고, 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도하기 위하여 소지하는 행위는 상표의 사용에 포함된다.
- ⑤ 주문자상표 부착방식(이른바 OEM 방식)에 의한 상표의 사용이나 수출자유지역 내에서 수출 목적으로만 등록상표가 부착된 상품을 제조하는 것은 국내에서의 상표 사용이라고 볼 수 없다.

해설

- ① [×] 제108조 제1항 제1호 및 제119조 제1항 제1호에 따른 “등록상표와 유사한 상표”에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표가 ‘포함되지 아니하는 것’으로 한다(法 225②).
- ② [×] 제2조 제2항의 규정에 따라 상품 또는 상품의 포장 자체를 포장의 형상으로 하는 것은 상표의 사용에 포함된다.
- ③ [○] 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결: 소송을 통한 상표권의 행사와 상표의 사용은 전혀 별개의 문제이다.
- ④ [×] 양도하기 위하여 소지하는 행위 자체는 상표의 사용이라고 할 수 없다. 다만, 법 제108조 제1항 제4호 소정의 간접침해 행위에 해당하여 이러한 행위에 대한 권리를 행사할 수 있다.
- ⑤ [×] 상표권자가 외국인인 경우 국내 하청업자의 주문자상표 부착방식(OEM방식)에 의한 수출은 국내 사용으로 인정된다. 또한, 수출자유지역 내에서 수출 목적으로만 등록상표가 부착된 상품을 제조한 것이라 하더라도 국내에서의 상표 사용행위라고 볼 수 있다(송가네 냉면 사건, 대법원 2002. 5. 10. 선고 2012후740 판결).

정답 ③

17 상표 및 상표의 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 14 기출

- ① 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 상표법상의 상표라 할 수 없다.
- ② 불사용취소심판에 관한 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호의 적용 시, 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표를 사용한 바 없다면, 그 상품이 제3자에 의해 국내에 수입되어 정상적인 거래가 이루어졌다고 하더라도 상표권자의 상표사용으로 볼 수 없다.
- ③ 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다.
- ④ 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’에 상표가 표시되어 있는 것은 특별한 사정이 없는 한 상표의 사용이라고 할 수 없다.
- ⑤ ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록 받을 수 있다’라는 상표법 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)를 위반한 경우에는 거절이유에 해당된다.

해설

- ① [○] 오성전자(소니) 사건, 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결
- ② [×] 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리 나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2003.12.26. 선고 2002후2020 판결).
- ③ [○] 페라가모 사건, 대법원 2008.10.9. 선고 2007후2834 판결 등
- ④ [○] WINK 사건, 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 등
- ⑤ [○] 2012년 개정법은 제3조 제1항 본문을 거절이유 및 무효사유로 규정하였다.

정답 ②

18 상표법상 상표의 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 19 기출

- ① 제과점업에 대하여 상표등록을 받은 자가 해당 등록상표가 표시된 나무상자에 즉석으로 구운 빵을 담아 판매한 행위는 제과점업에 대한 상표의 사용행위에 해당한다.
- ② 상표법 제2조 제1항 제11호 라목에서 말하는 상품에 관한 광고에는 시각으로 인식할 수 있는 것이 포함되어야 하므로 그 광고에는 상품명이나 제조원이 표시되어야 상표의 사용으로 인정된다.
- ③ 명함의 뒷면에 상표를 표시하고, 이를 거래상대방에게 교부한 행위는 상표법상 상표의 사용행위에 해당한다.
- ④ 인터넷 포털사이트 운영자에게서 특정 단어나 문구의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서의 홈페이지 주소가 나타나는 경우에 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 상표로서의 사용에 해당한다.
- ⑤ 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 도메인이름의 사용행위를 상표의 사용으로 볼 수 있다.

해설

- ① [○] ‘제과점업’에 대하여 상표 등록을 받은 자가 해당 제과점업에 대한 상표가 표시된 나무상자 등에 즉석으로 구운 빵을 담아 판매한 경우 이 때의 즉석으로 구운 빵은 유통과정에 놓이는 것이 아니어서 상표법상의 상품에 해당하지 않고, 따라서 위와 같은 사용은 ‘제과점업에 대한 상표’로 정당하게 사용한 것이지 ‘빵에 대한 상표’로 사용한 것이라 볼 수는 없다(묵촌옥 사건, 대법원 2011.7.28. 선고 2010후3080 판결).
- ② [×] 제2조 제1항 제11호 (라)목에서 말하는 ‘광고’에는 신문잡지, 팸플릿, 카탈로그, 전단지, 달력, 간판, 가두네온사인, TV 등에 의한 시각으로 인식할 수 있는 것이 포함되며, 그 ‘광고’의 내용 및 형식에 관하여 상표법이 특별히 규정하는 바가 없으므로, 상품에 관한 정보를 일반소비자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 위 광고로서의 요건을 충족하고, 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야만 하는 것이라고는 할 수 없다(보온용기 사건, 대법원 2007.1.26. 선고 2005후179 판결).
- ③ [○] 대법원은 “명함 이면(裏面)에 상표를 수기(手記)로 써서 구매자에게 교부한 경우 이 때의 명함 이면은 판매된 물품을 확인해주는 거래서류에 해당한다.”고 판시하였는바(대법원 2002. 11. 13. 선고 2000마4424 결정), 명함의 뒷면에 상표를 표시하고 이를 거래상대방에게 교부한 경우 제2조 제1항 제11호 라목 소정의 상표의 사용에 해당한다.
- ④ [○] VSP 사건, 대법원 2012.5.24. 선고 2010후3073 판결.
- ⑤ [○] 장수온돌 사건, 대법원 2008.9.25. 선고 2006다51577 판결.

정답 ②

19 상표법상 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

19 기출

- ① 사과주스에 사용하는 원재료를 표시한 '사과'라는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사과주스에 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 사과주스를 지정상품으로 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ② 상품에 상표를 표시한 것을 인도할 목적으로 수출하는 행위는 상표의 사용에 해당하지 아니한다.
- ③ 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 순전히 디자인적으로만 사용하여 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표권 침해로 볼 수 없다.
- ④ 증명표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 증명표장과 동일·유사한 표장을 상표로 등록을 받을 수 없다.
- ⑤ 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다.

해설

- ① [○] 제33조 제2항
- ② [×] 제2조 제1항 제11호 나목의 상표의 사용에 해당한다.
- ③ [○] 쌍학문 사건, 대법원 2004.10.28. 선고 2003후2027 판결.
- ④ [○] 제3조 제5항.
- ⑤ [○] 증명표장은 타인의 상품이 정하여진 품질 등을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 경우이어야 하므로, '자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우'에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다(法 3③단서).

정답 ②

20 상표의 사용에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

20 기출

- ① 신문에 등록상표의 등록번호와 상표를 기재하고, 그 상표에 대하여 ‘타사의 컴퓨터 및 전자오락기구를 오인, 혼동하여 현혹 없기를 바란다’고 기재한 것은 지정상품에 대한 광고로 볼 수 있으므로 상표법 제2조(정의)상 상표의 사용으로 볼 수 있다.
- ② 소관부처로부터 등록상표의 지정상품인 의약품의 제조나 수입에 관한 품목별 허가를 받지 아니한 상태에서 신문에 1년 못미쳐 한차례씩 그 상표를 광고하였거나 국내의 일부 특정 지역에서 해당상표를 부착한 지정상품이 판매된 경우라면 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서의 정당한 사용이 있었다고 볼 수 없다.
- ③ 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되는 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’은 비록 그 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없더라도 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표법 제2조(정의)상 상표의 사용으로 볼 수 있다.
- ④ 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산방식(이른바 OEM방식)에 의한 수출의 경우, 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단하는데 있어서는 특단의 사정이 없는 한 국내에서 실제로 상품 또는 상품을 제조하면서 포장에 상표를 표시하였는지 여부를 가지고 판단하여야 하므로 국내의 생산자에 의해 상표가 사용된 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하고 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 그 상품을 거래한 바 없이, 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 그 상품이 제3자에 의하여 정상적으로 국내로 수입되어 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우라도 상표권자가 직접 유통시킨 것이 아니므로 특단의 사정이 없는 한 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 불사용한 것으로 볼 수 있다.

해설

- ① [×] 상표에 대한 선전, 광고행위는 지정상품에 관련하여, 즉 지정상품이 특정되어 행하여져야 하는 것인데, 지문의 경우 그 광고문안의 취지상 지정상품과 관련하여 광고된 것이라 보기 어렵다. 따라서, 제2조 제1항 제11호 소정의 광고행위로서의 상표의 사용이라 보기 어렵다. [본 지문은 “등록상표를 선전, 광고한 신문에 등록상표의 등록번호와 상표를 기재하고 그 상표에 대하여 컴퓨터 및 전자오락기구를 오인, 혼동하여 현혹 없기를 바란다고 기재하고 있어서, 그 광고문안의 취지를 지정상품에 관한 광고라고 하기 어렵고 또 광고 당시 그 지정상품이 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에 있었다고 보기도 어렵다고 보이므로 그 신문광고만으로는 지정상품에 관한 광고에 상표를 붙인 행위라고 할 수 없다는 대법원 1992. 8. 18. 선고 92후209 판결(불사용취소심판 사건으로 1990. 1. 13. 개정 전의 구법당시의 사건임)]
- ② [○] 의약품의 경우 허가를 받지 않고 유통하였다면 행정법규의 목적·특성, 그 상품의 용도·성질 및 판매 형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등을 고려해 볼 때 오로지 불사용취소를 면하기 위한 형식적 사용에 불과하다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240,1257 판결).
- ③ [×] 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(WINK 사건, 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결).
- ④ [×] 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단하면서도 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(송가네 냉면 사건, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결).
- ⑤ [×] 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(Manhatan passage 사건, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결).

정답 ②

특수한 표장

21 다음 중 색채상표의 등록과 사용에 관한 설명 중 옳은 것은?

04 기출

- ① 식별력이 약한 상표에 색채가 가미되더라도 등록자격에 영향을 미치지지는 못한다.
- ② 미국의 경우와는 달리 우리 상표법상 색채는 상표의 부수적인 구성요소이므로 색채만의 상표는 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 등록불가하다.
- ③ 등록상표는 등록된 대로 표시하여야 하므로 등록상표와 색채만이 다른 유사상표를 등록상표로 표시하면 거짓 표시의 금지(상표법 제224조) 대상이 된다.
- ④ 등록상표의 전용권의 효력은 유사범위에는 미치지 아니하므로 등록상표와 색채만이 다른 유사상표에까지 상표권의 적극적 효력(전용권)이 인정되는 것은 아니다.
- ⑤ 상표권자는 정당사용의 의무가 있고 색채만이 다르더라도 동일한 상표는 아니므로 등록상표에서 색채만 변경하여 사용하게 되면 부정사용을 이유로 하는 취소심판(상표법 제119조 제1항 제1호)의 대상이 된다.

해설

- ① [x] 색채도 상표의 구성요소이므로 식별력이 약한 상표에 색채가 결합되어 식별력이 인정된다면 등록될 수 있다.
- ② [x] 2007년 개정에 따라 우리 상표법도 색채 또는 색채의 조합만으로 구성된 상표를 등록대상인 표장으로서 인정하고 있고, 색채만의 상표가 본질적 식별력이 있거나 사용에 의한 식별력을 취득하였다면 당연히 등록이 가능하다.
- ③ [x] 지문 ⑤ 해설 참조
- ④ [x] 지문 ⑤ 해설 참조
- ⑤ [x] 상표법은 등록상표와 색채만이 다른 유사상표를 동일상표로 간주해 주는 특칙(法 225)을 두고 있다. 따라서 ③의 경우 거짓 표시 금지의 대상이 아니고, ④의 경우 적극적 효력이 인정되며, ⑤의 경우 이른바 전용권 범위의 사용으로 제119조 제1항 제1호의 대상이 되지 않는다.

정답 없음

22 소리·냄새상표출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

13 기출

- ① 상품의 특성으로부터 발생하는 맥주병의 병뚜껑 따는 소리 또는 타이어의 고무향처럼 상품의 기능을 확보하는데 불가결한 소리 또는 냄새만으로 된 소리·냄새상표는 등록받을 수 없다.
- ② 소리·냄새상표출원은 원칙적으로 식별력을 인정받을 수 없으므로 상표등록을 받기 위해서는 사용에 의한 식별력을 인정받아야 한다.
- ③ 소리·냄새상표에 있어서 선등록상표와의 동일·유사 판단은 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단한다.
- ④ 일반수요자에게 널리 알려진 음악(노래)의 일부 또는 타인의 상표를 정당한 권한이 없는 자가 소리상표로 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우에는 법 제34조 제1항 제12호를 적용한다.
- ⑤ 소리·냄새 등은 그 출원서에 첨부된 소리파일 또는 냄새견본을 기준으로 요지변경을 판단한다.

해설

- ① [○] 상표심사기준 제5부 제15장, 제8부 제6장 5.3 / 구체적인 예시) 자동차 수리업에 사용되는 자동차 엔진소리, 맥주병에 사용하는 맥주병의 병뚜껑 따는 소리, 타이어를 지정상품으로 하는 타이어의 고무향
- ② [○] 비전형 상표의 주요 등록요건은 이하와 같다.

	사용에 의한 식별력(法 33②)	기능성(法 34①15)
입체상표	원칙) 실무상 엄격히 판단하나, 반드시 필요한 것은 아님 예외) 형상만으로 된 상표는 출원시 식별력 취득 증거 제출 요구	요구
색채만의 상표	요구	요구
홀로그램 상표	불요	무관
동작상표	불요	무관
위치상표	요구(判例)	실무상 제15호 유추적용 → 요구
소리상표	원칙) 요구, 예외) 식별력 있는 단어의 발음인 경우	요구
냄새상표	요구	요구

- ③ [○] 소리상표는 원칙적으로 소리상표 상호간에 상표의 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단하도록 한다. 다만, 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악할 수 없으므로 제출된 소리파일(악보가 제출된 경우에는 악보 포함)을 참고하여 유사여부를 판단하도록 한다(상표심사기준 제8부 제6장 6.1).
냄새상표는 원칙적으로 냄새상표 상호간에 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단하도록 한다. 다만, 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악할 수 없으므로 제출된 냄새견본을 참고하여 유사여부를 판단하도록 한다(상표심사기준 제8부 제7장 6.1).
- ④ [○] 일반수요자에게 널리 알려진 음악(노래)의 일부 또는 타인의 상표를 정당한 권한이 없는 자가 소리상표로 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우에는 제34조 제1항 제12호를 적용하고, 부정한 목적을 가진 출원으로 인정되는 경우에는 제34조 제1항 제13호를 적용한다(상표심사기준 제8부 제6장 4.5).
- ⑤ [×] '시각적 표현'을 기준으로 하여 요지변경 여부를 판단한다.

정답 ⑤

23 위치상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'18 기출

- ① 위치상표는 표장이 사용되는 위치에 식별력이 인정되는 것이기는 하나 표장의 위치가 요부라고는 볼 수 없다.
- ② 위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다.
- ③ 특정 위치에 부착된 표장은 수요자의 입장에서선 상표가 아니라 디자인적 요소로 보는 것이 일반적이므로 위치상표로 등록받기 위해서는 그 표장이 수요자들에게 상품의 출처표시로 인식된다는 것을 입증하여야 한다.
- ④ 위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다.
- ⑤ 위치상표란 '기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장'을 말한다.

해설

- ① [x] 위치상표는 그 본질상 위치에 의하여 식별력이 인정되며, 따라서 표장의 위치가 요부로 작용함은 당연하다.
- ② [○] 아디다스 3선 줄무늬 사건 대법원 2012.12.20. 선고 2010후2339 판결.
- ③ [○] 아디다스 3선 줄무늬 사건 대법원 2012.12.20. 선고 2010후2339 판결.
- ④ [○] 아디다스 3선 줄무늬 사건 대법원 2012.12.20. 선고 2010후2339 판결.
- ⑤ [○] 아디다스 3선 줄무늬 사건 대법원 2012.12.20. 선고 2010후2339 판결.

정답 ①

24 상표법령에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

18 기출

- ① 입체적 형상만으로 이루어진 상표를 출원하는 경우 출원인은 심사관이 출원상표를 정확히 파악할 수 있도록 표장에 관한 설명을 출원서에 반드시 기재하여야 한다.
- ② 지정상품의 입체적 형상으로 된 상표의 경우에, 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하여 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도에 이르지 못하였다면 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제3호에 해당한다.
- ③ 상표법 제107조(권리침해에 대한 금지청구권 등)에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 하고, 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다는 것이 판례의 입장이다.
- ④ 입체적 형상과 문자가 결합된 상표에 있어, 입체적 형상 자체에는 식별력이 없더라도 식별력이 있는 문자가 결합하여 상표가 전체적으로 식별력이 있다면 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.
- ⑤ 소리상표의 상표등록출원서에 적는 '상표에 관한 설명'의 기재사항을 고치는 것은 요지변경에 해당하지 아니한다.

해설

- ① [x] 입체상표에 있어 해당 상표에 대한 설명서는 필수적 제출사항이 아니라, 임의적 제출사항에 해당한다(施行規則 28①).
- ② [○] 비아그라 사건, 대법원 2015.10.15. 선고 2013다84568 판결.
- ③ [○] 제107조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 '사실심 변론종결 당시'를 기준으로 하여야 하고, 제109조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은 '침해행위 당시'를 기준으로 하여야 한다. (대법원 2008.11.13. 선고 2006다22722 판결)
- ④ [○] BIOLOX 사건, 대법원 2015.2.26. 선고 2014후2306 판결.
- ⑤ [○] 상표법 시행규칙 제33조 제1호.

정답 ①

제3절 행위능력

4, 5, 9

25 상표에 관한 절차에 대한 설명으로 옳은 것은?

23 기출

- ① 미국에 주소를 두고, 미국과 유럽에만 영업소를 가지고 있던 회사 甲의 대표자가 직접 국내에 거주하면서 한국 내 자회사의 임원 등을 선발하기 위한 면접을 하더라도 자회사 설립 전인 경우에는 상표에 관한 대리인으로서 국내에 주소나 영업소가 있는 자에 의해서만 상표출원을 할 수 있다.
- ② 미성년자가 행한 상표출원행위에 대하여 법정대리인의 추인에 의한 출원행위의 효력발생 시점은 미성년자의 상표 출원시점부터가 아닌 법정대리인의 추인행위를 한 시점부터 그 효력이 발생한다.
- ③ 상표에 관한 절차를 밟는 자로부터 출원을 위임받은 대리권자의 대리권은 반드시 서면에 의하여 증명해야 하고, 심판절차에서 위임한 위임인과 동시에 출석하여 구두로 대리권을 증명할 수는 없다.
- ④ 심판을 청구하는 자가 책임질 수 없는 불가항력으로 인하여 심결의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 심결에 관한 소를 제기하지 못한 경우에는 그 불가항력 사유가 소멸한 날로부터 2개월 이내에 소를 제기할 수 있다.
- ⑤ 미성년자의 법정대리인의 사망으로 대리권이 소멸하여 상표에 관한 절차가 중단된 경우에 성년이 된 미성년자는 절차를 수계할 수 없다.

해설

- ① [x] 회사 甲이 재외자이고, 그 대표자가 국내에 체류 중인 경우에 해당하므로 상표 관리인에 의하지 않고서도 상표출원 행위를 할 수 있다.
- ② [x] 무효행위의 추인은 소급효가 있으므로 추인행위를 한 때부터가 아닌 출원시부터 효력이 발생한다.
- ③ [○] 상표에 관한 절차를 밟는 자의 대리인의 대리권은 서면으로 증명하여야 한다(法 8). 서면으로 증명하여야 하고 구두로 진술할 수 없다. 따라서 옳은 지문이다.
- ④ [x] 제19조 규정에 따른 절차의 추후보완의 대상은 거절결정불복심판, 보정각하결정불복심판 또는 재심 청구기간에 한하고, 심결 등에 대한 소는 추후 보완의 대상이 아니다.
- ⑤ [x] 성년이 된 미성년자는 행위 능력이 있는 자로서 절차를 수계할 수 있다(法 23(3)).

정답 ③

제4절 대리인

6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15

26 상표법 제7조(대리권의 범위)에 따라 특별수권을 받아야 하는 행위에 해당하지 않는 것은?

23 기출

- ① 지정상품추가등록출원을 상표등록출원으로 변경하는 경우
- ② 상표등록출원을 그 지정상품마다 분할하여 이전하는 경우에 유사한 지정상품을 함께 이전하지 않아 상표등록을 할 수 없다는 이유로 된 거절결정에 대하여 불복하여 심판을 제기하는 경우
- ③ 이해관계인이 등록상표가 식별력이 없는 상표라는 이유로 제기한 상표등록의 무효심판에 대하여 답변서를 제출하는 경우
- ④ 보정각하결정불복심판을 대리하고 있던 변리사 甲이 구술심리기일에 출석하기 어렵게 되자 변리사 乙에게 그 특허심판원의 심리기일에 출석을 위해 대리권을 다시 위임하는 경우
- ⑤ 당사자가 사망하여 중단된 상표에 관한 절차의 수계신청을 취하하는 경우

해설

- ① [○] 지문③ 해설 참조
- ② [○] 지문③ 해설 참조
- ③ [x] 상표등록의 무효심판이 제기된 경우 피청구인(등록권리자)은 소정의 기간 이내에 답변서를 제출하여야 하고 제출하지 않을 시 직권심리 등에 따라 불이익을 얻을 수 있다. 따라서 답변서를 제출하는 것은 오히려 피청구인에게 이익이 되는 행위에 해당하므로 특별수권사항(등록 권리자에게 해가 되는 것에 대하여 특별히 위임 여부를 묻는)에 해당하지 않는다. <제7조에 규정된 특별수권 사항 : 출(취포변), 취(존지상), 신, 청, 불, 복, 권>
- ④ [○] 지문③ 해설 참조
- ⑤ [○] 지문③ 해설 참조

정답 ③

제2장 상표의 동일·유사

27 판례에 따른 경우 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

02 기출

- ① 상표 상호간에 유사한 부분이 있다 하더라도 요부를 이루는 부분이 서로 달라 이를 전체적으로 관찰할 때 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없으면 유사상표가 아니라고 보아야 한다.
- ② 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호나 관념이 타인의 상표의 칭호나 관념과 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 수 있다.
- ③ 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 외관, 칭호, 관념을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 양 상표의 외관, 칭호, 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 양 상표는 유사한 것이라고 할 수 없다.
- ④ 선등록상표권자가 후출원상표의 상표등록에 동의하였다면 양 상표가 다같이 동종상품에 사용된다 하더라도 수요자에게 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 없으므로 이들 양 상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 이러한 사실을 참작하여야 한다.
- ⑤ 상표의 유사 여부는 그 상표가 사용될 지정상품의 주된 수요계층과 기타 그 상품의 거래실정을 고려하여 평균수요자의 주의력을 기준으로 하여 판단한다.

해설

- ① [○] 나쇼날 사건, 대법원 1983.3.8 선고 82후2 판결
- ② [○] Lacoste 사건, 대법원 1987.3.24 선고 86후109 판결
- ③ [○] HAPPYFRIEND 사건, 대법원 1996.9.6 선고 96후344 판결
- ④ [×] 상표법은 다른 산업재산권법과 달리 특히 수요자의 이익(공익)의 보호를 목적으로 하므로(法 1), 상표의 유사판단에 있어서 선등록 상표권자의 동의 여부에 불문하고 전체적·객관적으로 판단한다. 다만, 상표공존동의제도의 도입으로 인하여 선출원인이나 선등록 상표권자가 후출원의 등록을 동의하는 경우 선출원·선등록의 유사범위의 후출원은 상표등록을 받을 수 있으나, 이러한 상표공존동의제도가 유사 여부 판단에 영향을 미치는 것은 아니다.
- ⑤ [○] GINKO 사건, 대법원 1995.9.26 선고 95후439 판결

정답 ④

28 상표의 유사 여부 판단에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 대법원 판례에 의함)

'06 기출

- ① 대비되는 두 개의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 외관, 호칭 및 관념 중 어느 한 가지에 있어서라도 유사하면 원칙적으로 유사상표이다.
- ② 외국인의 성과 이름을 합쳐서 구성한 상표인 경우, 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받게 되는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 한다.
- ③ 도메인이름의 형태로 구성된 상표의 유사성 판단은 도메인이름에 공통적으로 쓰이는 부분을 포함하여 도메인이름 전체로 판단을 하여야 한다.
- ④ 색채는 그 자체만으로는 상표의 구성요소가 될 수 없지만 색채가 다른 구성요소와 결합한 경우에는 상표의 외관유사를 판단하는 중요한 요소가 될 수 있다.
- ⑤ 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소이다.

해설

- ① [○] 나비파 사건, 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결 [등록무효(상)]
- ② [○] 상표의 유사 여부 판단의 한 방법으로서 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것이지, 상표가 외국에서 유명한 사람의 성명에서 유래된 것이라거나, 외국에서 그 사람의 성과 이름을 합쳐서 구성한 표장으로 상표등록이 되었다거나, 외국에서 상품에 대한 광고시에 성과 이름을 포함하는 전체 표장으로만 사용되고 외국의 신문, 잡지 등의 기사에서도 상품이나 그 브랜드를 지칭할 때에 성과 이름이 포함된 전체 명칭만을 사용하며 성이나 이름을 분리하여 사용된 일이 없다는 사정만을 가지고 바로 국내에 출원된 상표도 성과 이름 부분이 분리관찰될 수 없다고 단정할 수는 없는 것이다(대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 참조).
- ③ [x] 도메인이름에 공통으로 쓰이는 부분(http, co.kr 등)은 식별력이 없고 일체불가분적으로 결합되었다 볼 수도 없으므로 요부관찰 법리에 따라 식별력 없는 부분을 제외하고 판단한다.
- ④ [x] 2007년 개정에 따라 색채는 그 자체만으로 상표의 구성요소가 될 수 있다. 따라서, 현재는 ④번 지문이 오히려 더 명백하게 틀린 지문이다.
- ⑤ [○] M&S 사건, 대법원 2000.2.25. 선고 97후3050 판결 등

정답 ③, ④

29 상표의 유사여부 판단에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

'07 기출

- ① 상표의 유사여부를 판단함에 있어 고려되는 요소는 상표의 외관·호칭·관념이며 원칙적으로 위 세 가지 요소 가운데 하나가 동일하거나 유사하다면 유사하다고 판단될 가능성이 높지만 전체로서 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.
- ② 문자상표의 유사여부 판단에 있어서는 그 호칭의 유사여부가 가장 중요한 요소로 취급된다.
- ③ 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념이 발생할 때는 그 중 어느 하나의 호칭이나 관념이 타인 상표의 호칭 또는 관념과 동일하거나 유사한 경우에는 전체적으로 유사한 상표라고 할 수 있다.
- ④ 외국문자 상표에 관한 호칭의 유사여부 판단에 있어서 내국인 관례상의 호칭은 물론 해당 외국인의 대표적인 호칭도 함께 고려되어야 한다.
- ⑤ 상표의 유사여부의 관찰방법은 전체적, 객관적 관찰과 양 상표를 동시에 보았을 때를 기준으로 하는 대비적 관찰을 원칙으로 하되 상표의 구성 중 인상적인 부분에 대하여 중점적으로 비교하는 것으로 한다.

해설

① [○] 지문② 해설 참조.

② [○] 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관·칭호·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이고, 한편 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 참조).

③ [○] 상표는 각 구성부분을 분리하여 관찰함이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아니라면 때에 따라 그 구성부분 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념이 발생할 수도 있는 것인바, 이와 같이 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭, 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인 상표의 그것과 유사하다면 결국 두 상표는 유사하다고 할 것이다(대법원 1991. 6. 28. 선고 90후2010 판결 [거절사정]).

④ [○] 상표심사기준 제5부 제7장 2.2.2 (i)

⑤ [×] 상표의 유사판단은 두 개의 상표를 '같은 시간과 장소'에서 나란히 놓고 대조하여 유사감을 일으키는 지 여부(대비관찰)로 유사판단을 하여서는 안되며, '별도의 기회와 장소'에서 유사감을 불러일으킬 수 있는지 여부(이격적 관찰)에 의하여 판단하여야 한다.

정답 ⑤

30 상표의 유사 판단에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) '08 기출

- ① 상표의 유사 여부는 판단자의 주관에 따라 결론이 달라질 수 있는 상대적, 불확정적 개념이다. 예컨대 외관은 비슷하나 칭호가 다른 상표인 경우, 외관에 중점을 두어 판단하면 양 상표는 유사한 것으로 되고 칭호를 중시하면 양 상표는 비유사한 것으로 된다. 따라서 상표의 유사여부는 상표법의 목적에 비추어 합목적적, 가치론적으로 판단되어야 한다.
- ② 상표보호의 목적은 상표모용(冒用)으로 인한 오인 또는 혼동 내지 상품출처혼동 행위의 방지에 있으므로 상표의 유사여부 판단은 출처혼동 우려가 있는지 여부를 기준으로 결정한다.
- ③ 지정상품추가등록출원에 대하여 상표법 제34조 제2항 단서 소정의 '상표등록출원을 한 때(상표등록출원시)'를 적용하는 경우에는 그 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표 또는 상표등록출원의 상표등록출원을 한 때를 기준으로 한다.
- ④ 어떤 상표(지리적 표시 단체표장을 제외한다)가 선출원의 지위에 있으려면 선출원 상표와 후출원 상표가 동일 또는 유사하여야 하며, 지정상품 또한 동일 또는 유사하여야 한다는 점에서 상표법 제34조 제1항 제7호의 부등록 사유와 동일하다.
- ⑤ 상표법상 상품류 구분은 상표등록심사의 편의상 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정하는 것이 아니므로 지정상품의 유사여부 판단에 있어서는 상품의 원료, 품질, 형상, 속성 등 상품의 성질, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

해설

- ① [○] 지문② 해설 참조
- ② [○] 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결, 대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후1769 판결 등 참조).
- ③ [×] 지정상품추가등록출원은 그 실질에 있어서는 신규의 출원과 다를 바가 없으므로 지정상품추가등록출원에 대하여 제34조 제2항 소정의 '상표등록출원을 한 때(상표등록출원시)'를 적용함에 있어서는 그 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표 또는 상표등록출원의 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하는 것이 아니고 그 지정상품추가등록출원의 상표등록출원을 한 때를 기준으로 한다.
- ④ [○] 제35조와 제34조 제1항 제7호의 상표 및 상품의 후출원 배제의 범위는 모두 동일·유사 범위라는 점에서 같다.
- ⑤ [○] 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로 상품구분표의 같은 유별에 속한다고 하여 바로 동일 또는 유사상품이라고 단정할 수는 없다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후5045 판결 참조).

정답 ③

31 유사여부 판단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 13 기출

- ① 한글 문자상표의 호칭은 글자를 읽을 때 소리에 의하여 결정되므로 두음법칙이나 자음접 변현상도 고려하여야 한다.
- ② 지리적 명칭과 업종명이 결합한 상호상표는 동일한 지리적 명칭이 결합되어 있는 때에도 업종이 다른 때에는 비유사하다고 보는 것이 원칙이다.
- ③ 유사판단에 있어서 침해금지청구소송에서는 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하고 불법행위를 원인으로 하는 손해배상청구소송에서는 침해행위시를 기준으로 판단한다.
- ④ 판례에 의하면 ‘휴대용 통신기계기구’와 ‘MP3 플레이어’는 유사하며, ‘일반의료기계기구’와 ‘치과용 의료기계기구’도 유사하다.
- ⑤ 상표법 제34조 제1항 제7호(선등록상표와 동일, 유사)와 관련하여 등록상표와 인용상표의 유사여부를 판단하는 경우 등록상표 또는 인용상표의 각 구성부분 중 일부가 자타상품의 식별력이 없는지 여부는 등록상표의 등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

- ① [○] 심사기준 제5부 제7장 보충기준 2.2.2.
 ② [○] 심사기준 제5부 제7장 3.1.6. 이는 지리적 명칭은 일반적으로 식별력이 인정되기 어렵기 때문이다.
 ③ [○] 식별력 판단의 기준 시기를 정리하면 이하와 같다.

내용	관련절차	판단시점
法 33①의 등록요건의 판단	심사단계	등록여부결정시
	거절결정에 대한 심판	심결시
	등록무효 심판	등록여부결정시
유사판단의 전제로서의 식별력 유무의 판단	유사판단이 필요한 등록요건의 판단	法 34①11, 13, 14, 20, 21은 출원시 / 나머지는 등록여부결정시(거절복은 심결시)
	권리범위확인의 심판	심결시
	침해금지청구 소송	사실심변론종결시
	손해배상청구 소송	침해시 but, 사실심변론종결시 사건도 有

- ④ [x] 출원상표의 지정상품인 'AM/FM 라디오 수신기, MP3 플레이어' 등과 선등록상표의 지정상품인 '휴대용 통신기기'는 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등이 일치하므로, 양 상표의 지정상품에 동일 또는 유사한 상표가 사용될 경우 동일한 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인·혼동될 염려가 있다(대법원 2008.10.9. 선고 2008후1470 판결). 따라서, 앞부분은 옳은 지문이다. 다만, 대법원 판례는 '일반적으로 의료기기' 등의 수요자는 의사, 의료기사 등 의료 관계 종사원이고 일반의사와 치과의사의 전문 분야가 확연히 구별되고 있는 우리의 현 실정에 비추어 볼 때 일반의료기기와 치과용 의료기기의 수요자와 용도는 다른 것이 보통이라고 할 것이고, 의료보조기구와 치과용 기기의 품질이나 구체적인 용도, 수요자 등도 반드시 같은 것은 아니다.'라고 판시하여 일반의료기와 치과용 의료기기는 서로 유사하지 않다고 보았다(대법원 1994.12.2. 선고 93후1285 판결). 즉, 대법원의 경향은 '일반의료기 상호간'은 통상 서로 유사한 상품으로 보나, '치과용 의료기와 일반의료기 상호간'은 용도나 판매부문, 수요자의 범위가 다르다는 이유로 비유사한 상품으로 보는 것이 일반적이다. 따라서, 결국 옳지 않은 지문이다.
- ⑤ [○] 2016년 개정법은 제34조 제1항 7호의 판단시점을 구법상 '상표등록출원을 한 때(출원시)'에서 '상표등록여부결정을 할 때(등록여부결정시)'로 변경하였으므로, 제34조 제1항 제7호에 있어서 등록상표와 인용상표의 유사여부를 판단하는 경우 등록상표 또는 인용상표의 각 구성부분 중 일부가 자타상품의 식별력이 없는지 여부 또한 등록상표의 '상표등록여부결정을 할 때(등록여부결정시)'를 기준으로 판단하여야 한다.

정답 ④

32 상표의 동일·유사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 15 기출

- ① 상표법 제108조(침해로 보는 행위) 제1항 제1호에 따른 “등록상표와 유사한 상표”에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되지 아니하는 것으로 한다.
- ② 등록상표를 그 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 것을 의미하는 것은 아니고 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 포함된다.
- ③ 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에는 ‘식별력 있는 요부’에 해당한다고 볼 수 없다.
- ④ 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있으며, 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의해 명확하게 인정받을 필요까지는 없다.
- ⑤ 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다고 하더라도 거래 실정과 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 그 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다.

- ① [○] 제225조 제2항
- ② [○] 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다(대법원 1996.04.26. 선고 95후1555 판결).
- ③ [○] 로레알 사건, 대법원 2006.5.25. 선고 2004후912 판결.
- ④ [x] 상표의 유사 판단에 있어서 외국어 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다. 다만, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있거나 특정한 발음으로 널리 호칭하고 있다는 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 하나, 이러한 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다(짜이즈 사건, 대법원 2006.9.8. 선고 2006후954 판결 등).
- ⑤ [○] 그렇다면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '감자스낵' 제품이 속하는 '포테이토칩, 건과자' 부분이 선등록상표의 지정상품 중 '건과자' 부분과 동일·유사하여 양 상표가 일반적·추상적·정형적으로는 서로 유사해 보인다 하더라도, 위 지정상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 양 상표의 주지 정도 및 위 지정상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려할 때, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 위 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다(포카칩 사건, 대법원 2006.10.26. 선고 2005후2250 판결).
- ※ 선등록 "포타칩"과 후등록 "포카칩"은 표장 자체로는 서로 유사해보이지만, 후등록은 지정상품 건과자에 대하여 높은 인식도(현저한 인식도)를 취득하였고, 선등록은 건과자 분야에 사용된 사실이 없으므로 거래사회에서 수요자들은 적어도 지정상품 건과자에 관련하여 양 상표가 사용되더라도 출처의 오인·혼동이 발생되지 않을 것이라는 취지의 판시이다.

정답 ④

33 상표 유사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

21 기출

- ① 도형상표에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 한다.
- ② 상표의 유사 여부 판단에서 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 우리나라의 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다.
- ③ 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다.
- ④ 도형상표들에서 상표의 유사 여부 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다.
- ⑤ 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념, 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다.

해설

- ① [○] 닛 도형 사건, 대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결
- ② [○] 상표의 유사여부는 '해당 지정상품'의 일반 거래자나 수요자의 보통의 주의력을 기준으로 하여 판단하여야 한다.
- ③ [○] POPSAVENUE 사건, 2008. 9. 11. 선고 2008후1739 판결 등
- ④ [×] 지문⑤ 해설 참조
- ⑤ [○] 상표의 유사판단은 '별도의 기회와 장소'에서(즉, 때와 장소를 달리하여) 유사감을 불러일으킬 수 있는지 여부에 의하여 이격적으로 판단하여야 하며, 두 개의 상표를 같은 시간과 장소에서 나란히 놓고 대조하여 유사감을 일으키는지 여부(대비관찰)로 유사판단을 하여서는 안 된다. 같은 취지의 판결로는 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결 [거절결정(상)] 참조

정답 ④

34 상표법상 상표가 동일 또는 동일성이 있는 경우뿐만 아니라 유사한 경우에도 적용되는 것은?

'22 기출

- ① 출원 시의 특례(제47조)를 인정받기 위한 출원상표 판단 시
- ② 조약우선권 주장(제46조)의 객체적 요건 충족 판단 시
- ③ 불사용 취소심판(제119조 제1항 제3호)에서 등록상표의 사용으로 인정받기 위한 사용상표 판단 시
- ④ 타인의 등록상표가 표시된 상품을 양도·인도하기 위한 소지 행위가 '침해로 보는 행위' (제108조 제1항 제4호)에 해당하는 지 여부 판단 시
- ⑤ 법정손해배상청구(제111조)가 인정되기 위한 침해영역에 관한 요건 판단 시

해설

- ① [x] 제47조
- ② [x] 제46조
- ③ [x] 제119조 제1항 제3호
- ④ [○] 제108조 제1항 제4호(타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위)의 간접침해를 포함하여 간접침해 행위는 직접 침해와 마찬가지로 상표의 유사범위까지 적용된다. 나머지 지문은 모두 동일범위에 한하여 적용되는 규정이다.
- ⑤ [x] 제111조

정답 ④

35 상표의 유사판단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 24 기출

- ① 상표의 유사여부는 반드시 상품출처의 오인·혼동 가능성이 있는지 여부를 고려하여 판단하여야 한다.
- ② 상표의 유사여부의 관찰방법은 전체적, 객관적, 이격적 관찰을 원칙으로 하되 상표 구성 중 인상적인 부분(요부)이 있는 경우 이에 대하여 중점적으로 비교하는 것으로 하며, 이 경우 소리·냄새 등은 같은 유형의 상표 간에 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단한다.
- ③ 두 개의 상표를 직접 놓고 대비할 때에는 구성요소가 다른 점이 있다고 하더라도, 때와 장소를 달리하여 관찰했을 때 경험칙상 서로 출처의 오인·혼동이 일어나는 경우에는 유사한 상표로 보아야 한다.
- ④ 상표의 유사여부는 그 상표가 사용될 지정상품의 주된 수요계층과 기타 그 상품의 거래실정을 고려하여 일반수요자의 주의력을 기준으로 판단하여야 한다.
- ⑤ 등록상표의 구성 중 식별력 없는 일부분이 등록 전 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 그 부분은 사용상품과 유사한 상품에 관하여 상표유사판단의 요부가 될 수 있다.

해설

- ① [○] 상표심사기준 제5부 제7장
- ② [○] 상표심사기준 제5부 제7장
- ③ [○] 상표심사기준 제5부 제7장
- ④ [○] 상표심사기준 제5부 제7장
- ⑤ [×] 대법원은 “상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 「수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우(구법상 표현)」에는 그 부분은 ‘사용된 상품에 관하여’ 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.”고 판시하여(이른바, ‘알파’ 판결), 식별력 없는 표장이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 ‘실제로 사용한 상품(또는 이와 동일성 있는 상품)’에 한하여 상표 유사판단 시 요부가 될 수 있음을 분명히 하였다.

정답 ⑤

제3장 상품의 동일·유사

36 동일 구성의 표장에 대하여 甲은 상품에 대한 상표로 사용하고 있고, 乙은 서비스에 대한 상표로 사용하고 있다. 甲과 乙의 상표법상 관계에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (각각 널리 알려지지 않은 표장이며 견해 대립이 있으면 판례에 의한다)

04 기출

- ① 甲의 지정상품이 가구이고 乙의 지정서비스업이 통신업이라면 甲과 乙은 각각의 표장을 등록하고 사용하는데 하등 문제될 것이 없다.
- ② 甲의 지정상품이 햄버거이고 乙의 지정서비스업이 요식업인 경우에도 위 사안에서는 乙이 상표를 먼저 출원하면 선출원주의 원칙에 따라 乙이 상표를 등록받는데 甲의 상표는 장애 사유가 될 수 없다.
- ③ ②에서 乙이 상표등록을 받은 경우 甲이 뒤이어 상표출원을 하더라도 甲의 상표출원은 거절될 것이며, 이 상태에서 상표를 계속 사용하는 것은 乙의 상표권 침해가 성립될 수 있다.
- ④ ②에서 乙이 상표권을 확보한 경우라도 이를 햄버거 등의 상품에 사용하는 것은 등록상표의 전용권의 효력범위를 넘어서는 사용이다.
- ⑤ 만일 乙이 상표권을 등록하기 전부터 甲이 자기의 상호를 상표로 사용하고 있는 경우라면 어느 경우나 甲의 행위가 침해라고 볼 수 없다.

해설

- ① [○] 상품에 대한 상표와 서비스에 대한 상표 사이에는 지정상품과 지정서비스간에 동종성이 있을 때 사용금지효와 후등록 배제효가 미친다. '가구'와 '통신업'간에는 동종성이 인정되지 않는다. 따라서 각각 등록·사용이 가능하다.
- ② [○] '햄버거'와 '요식업'간에 동종성이 있다 하여도 乙이 먼저 출원하였다면 제34조 제1항 제9호 등이 문제되지 않는 한 乙의 출원이 등록가능하다.
- ③ [○] 乙이 상표등록을 하였다면 甲 출원은 동종성이 있으므로 제34조 제1항 제7호가 적용되어 거절될 것이고, 사용시에는 침해가 성립될 수 있다(삼성수원도매센터사건).
- ④ [○] 서비스를 지정하여 등록받은 상표권의 '적극적 효력(전용권)'은 지정된 서비스에만 미치는 것이므로 서비스에 대한 상표를 유형물인 상품에 부착하여 해당 상품 자체에 대한 식별표지로 사용하는 것은 그 상표권의 권리범위(전용권)를 넘는 것이다. 다만, 본 지문의 경우 논란의 소지가 있다. 즉, '요식업'에 등록받은 乙이 '해당 서비스업인 요식업의 제공을 위하여' 수요자에 햄버거를 제공한 것이라면 이는 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건(햄버거, 이때의 햄버거는 독립된 상품이 아님)에 상표를 표시하고 서비스를 제공한 것으로서, 해당 요식업(서비스업)에 대한 전용권 범위의 사용이 될 수 있다(이른바 '목촌옥' 판결이 이와 동일한 케이스임). 그러나 햄버거 또한 사안에 따라 별개의 상품이 될 수 있으므로, 만약 체인점 본부나 별개의 제조회사에서 대량생산을 목적으로 제조하여 유통과정에서 제공함으로써 '요식업(서비스업)'에 대한 출처표시가 아닌, '햄버거(상품)'라는 독립된 상품에 대한 상표의 사용으로 평가된다면 이는 '요식업'에 대한 등록상표의 전용권을 넘어서는 사용이다. 따라서 지문의 사실관계를 명확히 줄 필요가 있는데, 출제당시 본 지문은 서울고등법원 84나4257 판결(이른바, 휘미리 햄버거 판결)에 기초하여 요식업이라는 서비스에 대한 사용이 아닌 '햄버거(상품)'라는 상품에 대한 상표적 사용이라 상정하고 지문화 한 것이다(다만, 문제에서 정확한 사실관계를 밝히지 않았다는 점에서 사실상 지문 오류임).
- ⑤ [×] 乙이 상표권을 등록하기 전부터 甲이 자기의 상호를 상표로 사용하고 있는 경우라 하여도 제90조 제1항 제1호나 제99조 제1항의 경우 모두 '부정경쟁의 목적'이 없어야 하고, 나아가 '상거래 관행에 따라 상표로 사용'하여야 한다는 조건 등이 있으므로 어느 경우나 침해가 아니라는 본 지문은 옳은 지문으로 볼 수 없다.

정답 ⑤

37 상표등록요건 판단시, 상품의 유사 여부 판단에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? '09 기출

- ① 상표법상 상품류 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니라는 명문규정이 있다.
- ② 현행 심사실무상 상품 유사판단시 유사상품 심사기준에서 정하는 유사군코드에 반드시 구속되는 것은 아니다.
- ③ 상품의 유사 여부는 상품자체의 속성, 거래실정 등을 종합적으로 검토하여 사회통념에 따라 판단하여야 한다는 것이 판례의 주류적 입장이다.
- ④ 심사실무와 판례 모두 경쟁상품이면 유사상품이고, 비경쟁상품이면 비유사상품으로 보는 입장은 아니다.
- ⑤ 추상적으로 상정한 동일 또는 유사한 조어상표를 문제시되는 양 상품에 사용할 경우의 오인혼동 가능성을 기준으로 상품의 유사여부를 판단하는 견해도 ③과 동일한 입장이다.

해설

- ① [○] 제38조 제3항
- ② [○] 지식재산청은 유사상품 심사기준을 개정하여 과거의 “유사군코드가 동일한 상품 상호간은 서로 유사한 것으로 추정한다.”라는 규정을 “지정상품의 동일 유사여부는 ‘유사군 코드를 참고’ 하되 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단한다.”로 개정하였다. 따라서, 현행 심사실무상 상품 유사판단시 유사상품 심사기준에서 정하는 유사군코드에 반드시 구속되는 것은 아니다.
- ③ [○] 지정상품의 유사여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이라는 것이 주류 판례의 입장이다.
- ④ [○] 상품의 유사여부와 관련하여 경쟁상품인지 여부가 영향을 미칠 수는 있겠으나, 경쟁상품인지 여부에 따라 확립적으로 판단되는 것은 아니다.
- ⑤ [x] 추상적으로 상정한 동일 또는 유사한 조어상표를 문제시되는 양 상품에 사용할 경우의 오인·혼동 가능성을 기준으로 상품의 유사여부를 판단하는 견해는 통상 상대적 판정설 중 추상적 조어상표 기준설에 해당하는데, 이러한 견해에 따르면 상품의 유사여부는 일반적 출처의 혼동우려가 있느냐에 따라 판단하여야 하며, 따라서 추상적 조어 상표가 부착된 상품을 접한 수요자의 일반의 주관에 있어서 혼동의 위험성이 있느냐 없느냐를 추상적으로 고찰하여야 한다고 보므로, ③과 같이 상품 자체의 속성과 거래실정을 종합하여 사회통념에 따라 판단한다는 판례의 입장과는 차이가 있다.

정답 ⑤

제2편

등록요건

주 · 제 · 별

리담상표법 객관식 문제집

제1절 상표등록의 요건

33

본질적 식별력이 없는 상표(法 33①)

38 다음은 지정상품(또는 지정서비스업)과 상표를 나열한 것이다. 판례에 따른 경우 상표법 제33조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장으로 볼 수 없는 것은? 02 기출

- ① 스커트 — Twee
- ② 자동차수선업 — Speed
- ③ 컴퓨터통신업 — HOTMAIL
- ④ 서적 — 관족법(觀足法)
- ⑤ 컴퓨터하드웨어 수리업 — PC DIRECT

해설

- ① [×] 판례는 스커트, 원피스 등을 지정상품으로 하는 출원상표 Twee가 수요자인 여성들에게 “예쁜, 귀여운”의 의미로 직감되지 않는다 하여 기술적 상표에 해당하지 않는다고 하였다(대법원 1997.12.26 선고 97후1122 판결).
- ② [○] 대법원 1999.5.28 선고 99후444 판결(speed 판례)
- ③ [○] 대법원 1999.12.24 선고 99후2563 판결(HOTMAIL 판례)
- ④ [○] 대법원 2001.4.24 선고 2000후2149 판결(관족법 판례)
- ⑤ [○] 대법원 2001.3.23 선고 2000후1436 판결(PC DIRECT 판례)

정답 ①

39 다음 중 상표법 제33조 제1항 제3호에 관한 설명 중 옳은 것은?

'05 기출

- ① 특성의 상표가 일반 수요자들 사이에서 일반적으로 그 상품을 지칭하는 것으로 인식되고 사용되는 경우에는 상표법 제33조 제1항 제1호에 해당하지만, 그에 이르지 않는다고 관련 거래업계에서 당해 업자들 사이에서만 그 상품을 지칭하는 것으로 관용적으로 사용될 때는 그 특정상품의 성질을 표시하는 표장으로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는 것으로 된다.
- ② 기술적 표장인지 여부는 지정상품과의 관계에서 상대적으로 결정하여야 하는 것으로서 기술적 표장으로 인정되는 경우에는 그 지정상품의 품질을 오인할 우려가 있는 것으로 되어 언제나 상표법 제34조 제1항 제12호 전단의 품질오인 상표가 된다.
- ③ 대법원 판례에 의하면 기술적 표장인지 여부를 판단함에 있어서는 일반 수요자를 기준으로 하여야 하고 그 상품이 속하는 거래사회의 실정이나 거래자의 지식수준, 전문성 여부는 고려할 필요가 없다.
- ④ 상표의 구성이 지정상품의 품질·효능 등을 표시하는 식별력이 없는 부분과 그 외에 식별력이 있는 부분이 결합되어 있는 경우 그 상표는 지정상품의 성질을 표시하는 것으로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하는 것으로 된다.
- ⑤ 대법원 판례에 의하면 어느 상표가 지정상품의 성질을 표시하는지 여부를 판단함에 있어 그 상표가 지정상품의 성질을 표시하는 표장으로 실제 쓰이고 있거나 장래 필연적으로 사용될 개연성은 고려대상이 되지 아니한다.

해설

- ① [x] 관련 거래업계의 동종업자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 관용적으로 사용되는 경우는 제33조 제1항 제2호에 해당한다.
- ② [x] 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 하여 언제나 제34조 제1항 제12호 전단의 품질오인이 있는 것은 아니다.
- ③ [x] 당해상품에 관한 일반수요자를 기준으로 한다. 따라서, 지정상품이 특수한 계층의 전문가에 의해서만 거래된다는 특별한 사정이 있는 경우에는 그 전문가를 기준으로 판단한다.
- ④ [x] 상표의 식별력은 구성 전체로서 판단하는 것이고, 일부 식별력 없는 표장이 포함되어 있더라도 이에 식별력 있는 표장이 결합되어 전체적으로는 식별력이 인정되는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
- ⑤ [○] 대법원 판례의 지문으로서 맞는 지문이다. 다만, 하급심 판례 및 심사실무는 그 상표가 지정상품의 성질을 표시하는 표장으로 실제 쓰이는지 여부를 판단한 사례(특히 외국어 표장)가 여럿 있다. 본 판시는 원고, 피고의 주장에 근거하여 한정적으로 대법원이 판단한 법리로 보아야 한다.

정답 ⑤

40 甲은 다음과 같은 여러 상표를 출원하려고 한다(지리적 표시 단체표장은 제외). 이 중 상표법 제33조 제1항 각호에 해당하지 않는 것은 어느 것인가? (사용에 의한 식별력은 취득하지 않은 것으로 보고, 다통이 있는 경우에는 대법원 판례에 의함) '06 기출

- ① 외국에서 흔한 성(姓)인 'Johnson'을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표
- ② 지정상품의 수량을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
- ③ 처음에는 특정인의 상표이던 것이 주지·저명상표로 되었다가 상표권자가 상표관리를 허술히 함으로써 동종업자들 사이에 자유롭게 관용적으로 사용하게 된 상표
- ④ 지정상품의 가격을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
- ⑤ 현저한 지리적 명칭에 보조적인 기호가 결합된 상표

- 해설**
- ① [×] 판례는 “Johnson”이 우리나라에서 흔히 있는 성으로서 식별력이 없다고 할 수 없다고 판시하면서 제33조 제1항 제5호를 적용하지 않았다(대법원 1994.7.29 선고 94후333 판결).
 - ② [○] 제33조 제1항 제3호
 - ③ [○] 관용표장화된 경우로서 제33조 제1항 제2호가 적용된다.
 - ④ [○] 제33조 제1항 제3호
 - ⑤ [○] 현저한 지리적 명칭이 다른 문자나 도형과 결합된 것이라도 전체적으로 현저한 지리적 명칭을 직감하게 하거나 그것과 동등한 것으로 인식되는 정도면 제33조 제1항 제4호에 해당하므로 본 지문이 이 경우에 해당한다.

정답 ①

41 상표법상 서적의 제호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 10 기출

- ① 서적의 제호가 상표법에 의하여 보호받을 수 있는 상표가 되기 위해서는 상표법상 상표의 정의요건을 만족하여야 하며, 또한 자기의 업무에 관련된 상품과 타인의 상품을 구별하게 하는 식별력이 있어야 한다.
- ② 한자로 “生活情報”라고 횡서 표기한 문자상표의 경우, “생활정보”라는 용어는 우리의 생활 주변에서 일어나는 여러 가지 소식을 전달하는 뜻이 있으므로 지정상품인 잡지와와의 관계에 있어서 그 효능이나 용도 등 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 판단되므로 자타상품을 식별할 수 있는 기능을 결여한 것으로 그 등록은 무효라고 보아야 한다.
- ③ 영어참고서를 지정상품으로 하는 “영어실력기초”의 경우 “영어”, “실력”, “기초”등의 단어는 특별현저성이 결여된 기술적 표장에 불과한 것으로서, 위 상표는 그 지정상품과 관련지어 볼 때 ‘영어실력을 향상시키는 기초적인 영어교과서’로 인식되므로 기술적 표장에 해당한다.
- ④ 서적, 팸플릿, 녹화된 콤팩트 디스크(음악이 아닌 시디)를 지정상품으로 하는 “Linux”의 경우, 지정상품의 내용이 그 프로그램에 관련된 것임을 암시할 가능성이 있으며, 그 상품에 수록된 창작물의 내용이나 그 내용을 나타내는 제목에 중점을 두고 상품을 거래하는 점에 비추어 볼 때 기술적 표장에 해당한다.
- ⑤ 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용태양, 사용자의 의도, 사용경위 등 구체적 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로 기능하고 있다면 상표권을 침해하는 상표적 사용에 해당한다.

- ① [○] 서적의 제호 역시 상표등록이 가능하다. 다만, 저작물의 명칭에 해당한다는 점에서 주로 상표법상 상표의 정의를 만족하는지와 제33조 제1항 제3호의 식별력 유무가 문제된다.
- ② [○] 생활정보(生活情報) 사건, 대법원 1987.8.18. 선고 86후190 판결
- ③ [○] 영어 실력기초 사건, 대법원 1990.11.27. 선고 90후410 판결
- ④ [x] 리눅스 사건, 컴퓨터 운영체제 프로그램의 보통명칭 내지 관용표장으로 널리 알려진 등록상표 "Linux"가 그 지정상품 중 '서적, 팸플릿, 학습지, 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 콤팩트디스크 {음악이 아닌 시디}'에 사용될 경우 그 상품의 내용이 그 프로그램에 관련된 것임을 **암시할 가능성이 없는 것은 아니지만, 위 지정상품의 일반 수요자가 상표보다는 그 상품에 수록된 창작물의 내용이나 그 내용을 나타내는 제목에 중점을 두고 상품을 거래하는 점 등에 비추어 볼 때**, 위 컴퓨터 운영체제 프로그램에 관한 내용이 위 지정상품에 수록될 수 있다는 사정만으로 일반 수요자가 등록상표를 보고 위 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식한다고 보기 어려워, 등록상표가 제33조 제1항 제3호의 상표에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2002.12.10. 선고 2000후3418 판결).
- ⑤ [○] 영절하 사건, 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결. 즉, 특정 표장을 제호로서 사용하는 경우라도 제호의 성격, 사용태양, 시리즈물로 사용되었는지 여부, 광고판매실적 등을 종합하여 당해 표장이 거래계에서 서적의 출처를 표시하는 식별표지로 기능하고 있다면 제호임과 동시에 상표적 사용에 해당될 수 있다.

정답 ④

42 식별력 없는 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 10 기출

- ① 상품에 대하여 관용하는 상표는 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 의미한다.
- ② 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되지 않는다.
- ③ 외국의 여러 나라에 등록된 외국의 상표라 하더라도 국내에서 그 지정상품에 관용하는 표장이 될 수 있다.
- ④ 식물신품종 보호법에 의해 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대한 보통명칭으로 인정된다.
- ⑤ 상표권자가 상표권 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우에 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단된다.

해설

- ① [○] 옳은 지문이다. 다만, 관용표장은 반드시 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장만을 의미하는 것은 아니며, 그 상품 자체를 가리키는 것이 아니라 하여도 그 상품에 대하여 관용적으로 사용되는 것이라면 관용표장에 해당될 수 있다.
- ② [×] 대비대상이 되는 두 상표 중 하나가 자타 상품의 식별력이 없는 것이라면 설사 그 대비되는 상표와 외관·호칭·관념 중 일부에 동일·유사한 점이 있다 하더라도 상표 전체로서 수요자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 가능성이 크다 할 것이므로 오로지 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되어야 한다(대법원 2002.7.26. 선고 2002후765 판결).
- ③ [○] 상표의 식별력 유무는 '국내'를 기준으로 하므로, 외국에서 등록된 상표라 하여도 우리나라에서는 관용표장이 될 수도 있음은 물론이다.
- ④ [○] 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314 판결. 특히, 현행법상으로는 제34조 제1항 제17호에도 해당됨에 유의하여야 한다.
- ⑤ [○] 등록상표는 등록결정 당시에 이미 보통명칭화 된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에도 불구하고 보통명칭화 되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 '사실심 변론종결 당시'를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부를 가려야 할 것이다(대법원 2003.1.24. 선고 2002다6876 판결). 다만, 엄밀하게 말하면 손해배상청구에 있어서 등록상표가 보통명칭화 되었는지 여부는 '침해시(불법행위시)'를 기준으로 하여야 하나, 위 지문은 대법원 판례의 표현 그 자체로서 시험용 지문으로는 옳다고 보아야 한다(특히, 문제의 단서에 '다툼이 있으면 판례에 의함'이라는 명백한 단서가 있으므로).

정답 ②

43 상표등록요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 13 기출

- ① 서적과 같이 창작물이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표는 일반 수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하게 할 정도에 이르러야만 상표법 제33조 제1항 제3호(성질표시 상표)의 규정에 해당하게 된다.
- ② 상표법 제33조 제1항 제1호(상품의 보통명칭인 상표)의 경우에는 지정상품과의 관계를 고려하여 판단하지만, 상표법 제33조 제1항 제4호(현저한 지리적 명칭), 제5호(흔한 성 또는 명칭) 및 제6호(간단하고 흔한 표장)의 경우에는 성질상 반드시 지정상품과의 관계를 고려하여야 하는 것은 아니다.
- ③ 상표법 제34조 제1항 제16호(포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시)에서 규정하는 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시라 함은 산지를 그 지역의 문자로 표시한 것뿐만 아니라 한글 기타 그의 번역 및 음역을 포함한다.
- ④ 상표등록출원상표가 'A+B' 두 개의 부분으로 구성되고, 그 구성 중 'A'는 지정상품의 품질 표시이고, 'B'는 간단하고 흔한 표장이어서 각각 식별력이 없고 그 결합에 의해서도 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 그 상표는 상표법 제33조 제1항 제7호(기타 식별력이 없는 표장)에 해당한다는 이유로 식별력이 부정되는 경우가 있다.
- ⑤ 서비스의 제공에 특정한 자격을 필요로 하는 서비스업에 대하여 그러한 자격을 갖추지 못한 자가 상표등록출원하는 경우 상표법 제34조 제1항 제4호(공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 상표)에 해당한다는 것이 판례의 입장이다.

- 해설**
- ① [○] 리눅스 사건, 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 [등록무효(상)]. 즉, 일반적인 지정상품의 성질표시표장의 판단과 다르지 않다는 취지이다.
 - ② [○] 제33조 제1항 제1호 내지 제3호(조문구조) 및 제7호(판례)를 지정상품과의 관계를 고려하여 식별력 유무를 판단한다.
 - ③ [○] 상표심사기준 제5부 제16장 1.1.1
 - ④ [○] 본 지문의 법리를 명시적으로 판시한 대법원 판례가 있는 것은 아니나 실무, 판례상 제33조 제1항 제7호를 적용하는 일반적인 경우이다.
 - ⑤ [×] 서비스의 제공에 특정한 자격을 필요로 하는 서비스업에 대하여 그러한 자격을 갖추지 못한 자가 상표를 출원, 등록하더라도 제34조 제1항 제4호에 해당하지 않는다(대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후 271 판결).

정답 ⑤

44 상표법 제33조(상표등록의 요건)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) '16 기출

- ① 상표법 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ② 출원상표가 식별력을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단시점은 상표등록여부결정을 할 때(등록여부결정시)이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 여부가 결정되는 경우에는 심결시이다.
- ③ 상품의 관용표장은 처음에는 특정인의 상표이던 것이 상표권자가 상표관리를 허술히 함으로써 동종업자들 사이에서 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 상표를 의미한다.
- ④ 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표라 하더라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 그 지리적 표시를 사용한 상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.
- ⑤ 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우라 하더라도 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 등록이 가능하다.

해
설

- ① [○] 제33조 제2항
- ② [○] 출원 상표가 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 '결정시'이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 여부가 결정되는 경우에는 그 '심결시'라고 할 것이다(TOMATILO 사건, 대법원 2012.4.13. 선고 2011후1142 판결).
- ③ [○] 엄밀히 보면 제33조 제1항 제1호 보통명칭의 정의에 가까운 판시이지만, 대법원 판례 중에는 관용 표장을 정의하면서 보통명칭과 근사한 의미로서 실시한 판례가 더러 있다.
- ④ [×] 제33조 제1항 제4호의 규정에 해당하는 표장이라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 '그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품으로 하여' 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다(法 33③). 즉, 그 지리적 표시를 사용한 상품과 유사한 상품이 아니라 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 등록받을 수 있다.
- ⑤ [○] 제33조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 제33조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용될 수 있기는 하나, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 **새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는** 위 법조항의 적용이 배제된다(서울대학교 사건, 대법원 2015.1.29. 선고 2014후2283 판결).

정답 ④

45 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 각호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'17 기출

- ① 상표가 보통명칭화 되었는데의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우에 있어서는 상표등록여부결정 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는데의 여부를 판단한다.
- ② 관용표장이 포함된 상표로서 그 관용표장이 다른 식별력이 있는 표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하고 있어서 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 지정상품과의 관계에서 간접적, 암시적이라고 인식될 수 있는 표장이라도 실제 거래업계에서 직접적으로 상품의 성질을 표시하는 표장으로 사용되고 있는 경우에는 성질표시 표장에 해당한다.
- ④ 지리적 명칭은 원칙적으로 현존하는 것에 한하지만 특정 지역의 옛 이름, 애칭 등이 일반 수요자나 거래자들에게 통상적으로 사용된 결과 그 지역의 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우에는 현저한 지리적 명칭에 해당한다.
- ⑤ 알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로운 관념이 형성되는 경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없다.

해설

- ① [x] 어느 상표가 보통명칭화되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 한편 등록상표는 등록사정(등록결정) 당시에 이미 보통명칭화 된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에도 불구하고 보통명칭화 되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 '사실심 변론종결 당시'를 기준으로 등록상표가 보통명칭화되었는지의 여부를 가려야 할 것이다(Red Sandra 사건, 대법원 2003.1.24. 선고 2002다6876 판결).
- ② [○] 출원상표의 식별력 유무는 표장 전체로서 판단하는 것이므로 표장의 일부에 식별력 없는 부분이 있다고 하더라도 전체로서는 식별력이 존재하면 상표등록을 받을 수 있다. 즉, 제33조 제1항 제2호에는 '만'이라는 요건이 명시적으로는 없으나 식별력 판단의 원칙상 당연히 '만'이라는 요건이 있는 것으로 보고 식별력 유무를 판단해야 한다. 이는 제33조 제1항 제5호도 마찬가지이다.
- ③ [○] 지정상품과의 관계에서 간접적, 암시적이라고 인식될 수 있는 표장이라도 실제 거래업계에서 직접적으로 상품의 성질을 표시하는 표장으로 사용되고 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다(심사기준 제4부 제3장 2.1.2).
- ④ [○] 해당 지역의 옛 명칭은 원칙적으로는 현저한 지리적 명칭으로 보지 아니하나, 옛 이름이 여전히 지리적 감각을 직감시키는 경우에는 현저한 지리적 명칭으로 취급한다. ex) 빛고을(광주), 한밭(대전)
- ⑤ [○] CP 사건, 대법원 2003.5.27. 선고 2002후291 판결.

정답 ①

46 상표법상 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 19 기출

- ① 상표등록여부결정을 한 때에 식별력이 없어 등록을 받을 수 없었음에도 불구하고 잘못하여 상표등록이 이루어진 경우에는 비록 그 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였더라도 등록무효의 하자가 치유되지 아니한다.
- ② 현저한 지리적 명칭으로만 된 상표는 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었더라도 그 상표를 사용한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없다.
- ③ 사용에 의한 식별력을 특정 지역에서만 취득하여 등록이 된 경우에는 상표권의 효력은 식별력을 취득한 그 지역에만 미친다.
- ④ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표가 식별력 있는 표장과 결합하여 새로운 식별력이 있다고 인정되더라도 그 결합상표는 상표등록이 불가능하다.
- ⑤ 흔히 있는 성(姓)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 어떠한 경우에도 식별력을 취득할 수 없다.

해설

- ① [○] 뉴발란스 사건, 대법원 2014.3.20. 선고 2011후3698 판결(전합).
- ② [×] 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표도 사용에 의한 식별력을 취득한 이상 당연히 그 사용상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다(法 33②).
- ③ [×] 상표법에 별도의 제한 규정이 없는 이상 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 상표 또한 일반적인 상표권과 마찬가지로 전국적으로 그 효력이 미친다.
- ④ [×] 등록요건으로서의 식별력 유무는 출원상표 전체로서 판단하므로 식별력 없는 표장이 식별력 있는 표장과 결합하여 전체로서 새로운 식별력이 형성되었다면 상표등록이 가능하다.
- ⑤ [×] 제33조 제1항 제5호에 해당되는 표장이라도 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 등록을 받을 수 있다.

정답 ①

47 상표법 제33조(상표등록의 요건)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'20 기출

- ① 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 본질적인 식별력이 없다.
- ② 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하는 것은 아니고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수 있으며, 그와 유사한 상표의 장기간사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다.
- ③ 어떤 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 현실 거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 한다.
- ④ 현저한 지리적 명칭이란 일반수요자에게 널리 알려진 지명을 말하는 것으로, 그 판단에 있어서는 교과서, 언론보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다.
- ⑤ 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에서 '흔히 있는 성 또는 명칭'이라 함은 현실적으로 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭, 아호, 예명, 필명 또는 그 약칭 등을 말한다.

해설

- ① [○] 본질적 식별력은 표장 그 자체로 인정되는 식별력을 의미하며, 상표법은 제33조 제1항 각호에 본질적 식별력이 없는 표장을 규정하고 있다. 이와 비교하여 구체적 식별력은 사용이라는 구체적 행위에 의해 취득되는 식별력으로서 상표법은 제33조 제2항에서 규정하고 있다.
- ② [x] 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 **동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용**은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다(K2 사건, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결). 즉, 유사한 상표에 대하여는 식별력 취득을 인정할 수 없다.
- ③ [○] 글루텐 사건, 대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결 [등록무효(상)]
- ④ [○] 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결.
- ⑤ [○] “흔히 있는 성 또는 명칭이란 현실적으로 다수가 존재하는 경우는 물론 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성이나 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭을 말한다(심사기준 제4부 제5장 1.1.1). “본호에서 규정하는 ‘명칭’에는 법인명, 단체명, 법인격 없는 단체명, 상호, 아호, 예명, 필명 또는 그 약칭을 포함하며, 회장·총장·사장 등 일반적인 직위를 나타내는 명칭도 본호의 흔한 명칭에 해당한다(심사기준 제4부 제5장 1.1.2).” 본 지문은 위 두 가지 심사기준을 발췌·조합한 지문이다.

정답 ②

48 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

24 기출

- ① 일반적으로 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제1호·제2호·제3호는 「상품과 관련」하여 식별력 유무를 판단하여야 한다.
- ② 보통명칭에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력을 인정할 경우에도 당해 지정상품과 관련하여 상품에 대한 오인·혼동의 우려가 있을 때에는 지정상품의 범위를 그 보통명칭과 관련된 것에 한정하도록 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제12호를 적용한다.
- ③ 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제1호 내지 제3호를 이유로 거절결정을 하는 경우에는 지정상품 전부에 대하여 거절결정을 하여야 한다.
- ④ 출원 상표가 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 대한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표등록여부결정을 할 때이다.
- ⑤ 홀로그램상표의 경우 제출된 상표견본과 상표에 대한 설명을 통하여 특정되는 전체적인 외관이 지정상품의 품질, 원재료, 용도 등의 성질을 직접적으로 나타낸다고 인정되는 경우 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제3호를 적용한다.

해설

- ① [○] 일반적으로 보통명칭(法 1호)·관용표장(法 2호)·성질표시(法 3호)는 「상품과 관련」하여 식별력 유무를 판단하여야 하나, 현저한 지리적 명칭(法 4호)·흔한 성이나 명칭(法 5호)·간단하고 흔한 표장(法 6호)은 「상품과 관련 없이」 특정인에게 독점 배타적인 권리를 부여하는 것이 공익상 부당하다는 정책적인 고려에서 식별력이 없는 것으로 보고 있다.
- ② [○] 상표심사기준 제4부 제1장
- ③ [x] 보통명칭, 관용표장 및 기술적 표장인지 여부의 판단은 지정상품과의 관계를 고려하여 판단하여야 한다. 따라서, 일부 지정상품과의 관계에서 보통명칭 등일 수 있으나, 나머지 지정상품과의 관계에서는 보통명칭 등에 해당되지 않을 수 있으므로 지정상품 전체에 대하여 거절결정을 하여야 하는 것은 아니다.
- ④ [○] 심사실무 및 판례 모두 등록요건의 판단은 원칙적으로 등록여부 결정시를 기준으로 한다. 다만, 제34조 제2항 단서에서 규정하고 있는 등록요건의 판단은 상표등록출원을 한 때를 기준으로 한다.
- ⑤ [○] 상표심사기준 제8부 제3장

정답 ③

49 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제4호의 '현저한 지리적 명칭 등'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) '25 기출

- ① 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력 없는 표장과 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳는 경우에는 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제4호의 적용이 배제된다.
- ② 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있다.
- ③ 사찰 '불국사'는 문화재이므로 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않는다.
- ④ 현저한 지리적 명칭이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻한다.
- ⑤ 현저한 지리적 명칭인지 판단의 기준시점은 원칙적으로 출원상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이다.

해설

- ① [○] AMERICAN UNIVERSITY 사건, 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결【거절 결정(상)】
- ② [○] AMERICAN UNIVERSITY 사건, 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결【거절 결정(상)】
- ③ [×] 역사적 문화재의 경우 그 문화재가 저명한 결과 그 명칭이 단순히 문화재의 호칭으로써 뿐만 아니라 그 문화재가 소재하는 지역을 이르는 지리적인 명칭으로서도 현저하게 되었다면 그와 같은 명칭은 본 호에 해당하여 등록될 수 없다. 상표심사기준에 따르면 '남대문, 동대문, 불국사, 경복궁, 광화문' 등은 본 규정에 따른 현저한 지리적 명칭에 해당한다.
- ④ [○] 지문⑤ 해설 참조
- ⑤ [○] '현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고, 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다. 현저한 지리적 명칭은 지정상품의 일반 수요자에 한하지 않고 일반 수요자 전반에 널리 알려진 지리적 명칭을 의미한다(사리원 사건, 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 [등록무효(상)]). 제33조 제1항 제1호 내지 제3호 및 제7호는 지정상품의 일반 수요자를 기준으로 하고, 동조 동항 제4호 내지 제6호는 일반 수요자 전반을 기준으로 판단한다.

정답 ③

사용에 의한 식별력을 취득한 상표(法 33②)

50 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

02 기출

- ① 2014년 개정 전 구법상의 판례에 따를 때 상표법 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력 취득을 인정받기 위하여는 출원상표가 전국적으로 인식되어 있어야 하나, 현행법상으로는 다툼이 있을 수 있다.
- ② 상표법 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력 취득 여부는 그 상표를 사용한 상품이 세계적인 신문, 잡지에 광고된 실적이 있다는 것만으로도 추정할 수 있다.
- ③ 기술적 표장(記述的 標章)이 상표법 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력 취득 요건을 갖추어 등록된 경우에는 원칙적으로 그 상표권자는 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있다.
- ④ 상표법 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력 취득이 인정되어 상표등록을 받기 위하여는 출원인이 상표등록출원전 그 상표를 상당기간동안 실질적으로 독점사용하여 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어야 한다.
- ⑤ 상표법 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력 취득의 요건을 갖춘 상표로서 상표등록이 허용되기 위하여는 그 지정상품은 그 상표를 사용한 상품에 한한다.

해설

- ① [○] 2014년 개정 전 구법은 사용에 의한 식별력 취득을 위한 인식도의 정도를 '주지'로 규정하고 있었으나, 현행법은 '특정인의 출처로 식별 가능한 정도(주지보다는 낮은 정도)'로 개정하였다. 따라서, 구법상 식별력 취득의 지역적 범위에 관한 판례의 법리는 현행법에서도 적용될지 여부가 명확치 않다.
- ② [×] 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력은 그 상표를 사용한 상품이 어느 정도 광고된 실적이 있다는 것만으로는 추정할 수 없고, 구체적으로 그 상표 자체가 수요자 간에 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다(대법원 1989.12.22 선고 89후438 판결).
- ③ [○] 기술적 표장이 제33조 제2항에 의해 등록된 경우에도 원칙적으로 통상의 경우와 동일한 상표권의 효력이 발생하며, 나아가 제90조 제1항 제2호 소정의 상표에도 상표권의 효력이 미친다.
- ④ [○] 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력 취득이 인정되기 위하여는 출원인이 상표등록출원 전 그 상표를 상당기간동안 실질적·독점적으로 사용하여 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어야 한다.
- ⑤ [○] 사용에 의하여 식별력을 취득한 것은 실제로 사용한 상표 그 자체이므로 그에 유사한 상표에 대해서까지 등록이 허용되는 것은 아니며, 지정상품 역시 실제로 그 상표가 사용된 상품에 한한다.

정답 ②

51 상표법 제33조 제2항이 규정하는 소위 “사용에 의한 식별력”과 관련한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

'04 기출

- ① 사용에 의한 식별력이 인정되어 등록된 상표라도 후발적으로 식별력을 다시 상실하게 되었다면 무효사유에 해당한다.
- ② 보통명칭, 관용상표 및 현저한 지리적 명칭에 대해서는 사용에 의한 식별력 취득이 인정되지 아니한다.
- ③ 실제 사용한 상품과 상표에 대해서 식별력이 인정된다.
- ④ 사용상표가 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어야 한다.
- ⑤ 식별력 취득여부를 판단할 때에는 지정상품의 판매량, 상표사용의 방법·횟수, 광고기간 등을 종합적으로 고려한다.

해설

- ① [○] 제117조 제1항 제6호
- ② [×] 제33조 제2항의 대상은 제33조 제1항 제3호 내지 제7호이다. 따라서, 현저한 지리적 명칭(法 33① 4)는 사용에 의해 식별력을 취득하였다면 제33조 제2항에 따라 상표등록이 가능하다. 한편, 보통명칭·관용표장의 경우에도 ‘식별력 취득시 등록이 되는지 여부’에 대하여는 다툼이 있으나, 일단 ‘사용에 의한 식별력 취득이라는 것’ 자체가 부정된다고 할 수는 없다. 즉, 보통명칭이나 관용표장이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 법 제33조 제2항 규정과 무관하게 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ [○] 제33조 제2항
- ④ [○] 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어야 한다(특정인의 출처로서의 인식과 주지의 중간 정도의 인식도).
- ⑤ [○] 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결

정답 ②

52 사용에 의한 식별력 취득에 관한 상표법 제33조 제2항에 대한 다음 설명 중 옳은 것은? '05 기출

- ① 대법원 판례에 의하면 상표법 제33조 제2항은 상표법 제33조 제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라고 규정하고 있으므로 상표법 제33조 제1항 제7호(기타 식별력이 없는 상표)에 해당하는 상표는 가사 식별력 취득이 인정되어도 상표등록 될 수 없다고 판시한 바 있다.
- ② 상표법 제33조 제2항에 의하면 기술적 표장에 대한 식별력취득은 상표등록출원 전에 사용하여 수요자간에 현저하게 인식된 경우에 인정되므로 기술적 표장에 대한 식별력취득 여부의 판단은 출원시를 기준으로 하도록 규정되어 있다.
- ③ 상표법 제33조 제2항을 적용받아 등록된 상표인 경우 상표권의 효력이 제한된다는 것이 대법원 판례의 주류적 입장이다.
- ④ 2014년 개정전 구법상의 대법원 판례에 의하면 어떤 상표가 특정지역에서 수요자들 사이에 현저하게 인식된 경우에는 비록 그 상표가 전국적인 범위에서 알려지지 않았다고 하더라도 상표법 제33조 제2항에 의한 식별력을 인정받을 수 있다.
- ⑤ 상표가 출원전 여러 사람에 의하여 사용된 결과 현저하게 인식된 경우에도 사용에 의한 식별력이 인정되어 상표법 제33조 제2항에 의한 상표등록이 가능하다.

해설

- ① [x] 제33조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 제33조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 상표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003.7.11. 선고 2001후2863 판결). 이러한 판례의 태도를 반영하여 2023년 개정법에서 7호를 명문으로 법 제33조 제2항에 포함시켰다.
- ② [x] 2014년 개정법은 기존의 제33조 제2항의 법문을 ‘상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우’ 라고 개정하여, 법문의 표현상 상표등록출원 전부터 상표를 사용할 것을 요구하고 있을 뿐, 사용에 의한 식별력 취득까지를 함께 요구하지 않음으로써 사용에 의한 식별력 취득여부는 등록여부결정시를 기준으로 판단하고 있다. 또한, 법문상 ‘현저한 인식’을 요하지도 않는다. 따라서, 옳지 않은 지문이다.
- ③ [x] 대법원 판례는 일관하여 “제33조 제2항에 의하여 식별력을 취득한 상표는 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권의 효력 제한을 받지 아니한다.”라고 판시하고 있다.
- ④ [x] 2014년 개정 전 구법상의 대법원은 상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치는 것이므로 현저하게 인식되어 있는 범위는 전국적으로 걸쳐 있어야 할 것이라고 판시하였다.
- ⑤ [x] 상표가 출원 전 “여러 사람”에 의하여 사용된 경우에는 이론상 특정인(익명의 존재로서의 추상적 출처)의 출처로서 식별력을 취득하였다고 볼 수 없으므로, 제33조 제2항의 식별력을 구비하기 위하여는 특정인의 “계속적·독점적” 사용이 있어야 한다.

정답 없음

53 상표법 제33조 제2항(사용에 의한 식별력의 취득)의 규정에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

07 기출

- ① 사용에 의한 식별력 취득으로 상표등록을 받기 위해서는 특정인이 상당한 기간동안 독점적, 계속적으로 상표로 사용하여 특정상품의 표지로 인식되고, 사용한 결과 수요자들이 그 상표를 누구인가의 출처표시로 인식하고 있어야 하고, 또 현실로 특정한 자의 상품이라고 인식하고 있는 것이라야 한다.
- ② 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 것은 출원인이 입증해야 하며, 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다가거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처표시로 식별할 수 있게 되었음이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다.
- ④ 사용에 의하여 식별력을 취득한 것은 실제로 사용된 상표 그 자체이므로 이와 유사한 상표에 대해서까지 등록이 허용되는 것은 아니다.
- ⑤ 사용에 의해서 식별력을 취득한 상표에 대해 등록을 인정하는 것은 원래는 특정인의 독점 사용이 부적당한 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 인정기준은 엄격하게 해석, 적용되어야 한다.

해설

- ① [x] 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력은 당해 상품의 거래계에서 거래자 및 일반수요자의 대다수가 당해 표장을 특정인의 상품표지로 인식하고 있음을 의미하나, 이러한 특정인의 상품표지로서의 인식은 익명의 존재로서의 추상적 출처이면 족하지, 구체적으로 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야 하는 것은 아니다. 따라서, 현실로 특정한 자의 상품이라고 인식할 필요는 없다.
- ② [○] 제33조 제2항
- ③ [○] 지문⑤ 해설 참조
- ④ [○] 사용한 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(法 33②).
- ⑤ [○] 구 상표법(1990. 1. 3. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제2항에서 서비스표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에도 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 **엄격하게 해석·적용**하여야 할 것인바, 수요자간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 서비스표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다가거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고, 구체적으로 그 상표·서비스표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 **증거에 의하여 명확하여야 하며**, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(예술의 전당 사건, 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397 판결 등 [등록무효(상)]).

정답 ①

54 상표의 사용에 의한 식별력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 15 기출

- ① 사용에 의한 식별력 취득여부의 판단 시기는 원칙적으로 ‘상표등록여부 결정시’이지만, 권리범위 확인심판절차에서 상표의 요부 해당 여부 판단 시에는 ‘심결시’를 기준으로 판단할 수 있다.
- ② 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제7호의 기타 식별력이 없는 상표에 해당하는 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 등록받을 수 없다.
- ③ 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표는 실제로 상표가 사용된 상품뿐만 아니라 그와 동일성이 있거나 유사한 상품에 대해서도 그 등록이 허용된다.
- ④ 상표등록여부 결정시를 기준으로 본질적으로 식별력이 없는 상표가 과오로 등록 된 후 사용에 의하여 식별력을 취득하면 그 무효사유의 하자가 치유되어 무효심판을 청구할 수 없다.
- ⑤ 등록상표의 구성에서 식별력이 없는 부분은 등록 후 사용에 의해 비로소 식별력을 취득하더라도 중심적 식별력을 인정할 수 없어 요부가 될 수 없다.

해설

- ① [○] 제33조 제2항에 있어서 사용에 의한 식별력 취득여부의 판단은 ‘등록여부결정시’를 기준으로 하나(등록단계에서의 원칙적 모습), 상표의 요부에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 사용에 의한 식별력 취득여부를 판단하는 경우에는 상표 유사판단의 시점과 동일한 시점을 기준으로 하여야 하므로 권리범위 확인심판에서는 ‘심결시’를 기준으로 한다.
- ② [x] 객관적으로는 제33조 제1항 제7호에 해당하는 상표라 할지라도 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 제33조 제1항 제7호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않게 되고 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 제33조 제2항에 동조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003.7.11. 선고 2001후2863 판결). 이러한 판례의 태도를 반영하여 2023년 개정법(2024.05.01. 시행)은 법 제33조 제2항 규정에 동조 제7호를 명시적으로 포함하였다.
- ③ [x] 사용에 의한 식별력 취득은 실제로 사용된 상품과 동일성 있는 상품에 한한다.
- ④ [x] 식별력 없는 상표가 착오등록 후 사용에 의한 식별력을 사후적으로 취득하였다 하여도 무효사유의 하자는 치유되지 않는다.
- ⑤ [x] 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위 확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다(뉴발라스 사건, 2014.3.20. 선고 2011후3698 판결).

정답 ①

55 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'22 기출

- ① 소리상표를 오랫동안 지속적으로 사용하여 사용에 의한 식별력을 취득하였더라도 법률상 가능성이 인정되는 경우 상표등록을 받을 수 없다.
- ② 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제7호의 기타 식별력이 없는 상표에 해당하는 경우에도 사용에 의한 식별력을 취득하면 등록받을 수 있다.
- ③ 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호의 적용에 있어 선출원 등록상표의 등록여부결정시에는 식별력이 미약하였던 일부 구성부분이 타인의 후출원상표와 유사판단 시 요부로 되기 위해서는 타인의 후출원상표의 출원시를 기준으로 사용에 의한 식별력을 취득하여야 한다.
- ④ 사용에 의한 식별력을 취득한 기술적 상표는 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제2호에 의한 효력제한을 받지 아니한다.
- ⑤ 상표등록여부결정시를 기준으로 본질적으로 식별력이 없는 상표가 과오로 등록된 경우 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하더라도 무효로 될 수 있다.

해설

- ① [○] 소리·냄새상표가 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에도 '상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 소리 또는 냄새만으로 된 경우'로서 이른바 법률상의 가능성이 있다면 제34조 제1항 제15호의 규정에 따라 등록받을 수 있다.
- ② [○] 객관적으로는 제33조 제1항 제7호에 해당하는 상표라 할지라도 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별력을 취득하기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 제33조 제1항 제7호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않게 되고 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 제33조 제2항에 동조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결). 구법상 제33조 제2항에 제33조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않아 사용에 의한 식별력 취득의 대상인지 여부가 불분명하였으나, 2023년 개정법은 상기 판례의 취지를 반영하여 제33조 제2항에 제33조 제1항 제7호를 명문으로 포함시키고 있다.
- ③ [×] 제34조 제1항 제7호는 '후출원상표의 등록여부결정시'를 기준으로 하므로 선등록상표(인용상표)의 전부 또는 일부 구성이 선등록상표의 등록여부결정시에는 식별력이 없었다 하여도 그 후 '타인의 출원상표의 등록여부결정시'를 기준으로 사용에 의한 식별력을 취득하였다면 유사판단시 요부가 될 수 있다.
- ④ [○] 새우깡 사건, 대법원 1992. 5. 12. 선고 88후974,981,998(병합) 판결.
- ⑤ [○] 뉴발란스 사건, 등록결정 시에 식별력이 없어 등록을 받을 수 없었음에도 불구하고 잘못하여 상표등록이 이루어진 경우에는 비록 그 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였더라도 등록무효의 하자가 치유되지 아니한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결(전합)).

정답 ③

제34조 제1항 제1호 내지 제6호

56 다음은 상표법 제34조 제1항 제4호 소정의 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 상표에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은? (판례에 의한다.) 03 기출

- ① 본호에서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 상표의 구성자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다.
- ② 상표가 공서양속에 위반한 것인지 여부는 본호가 공익규정인 특성상 그 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.
- ③ 대법원의 주류적인 판례에 의하면, 창작성 있는 인용상표가 국내에서 주지·저명하다면 이를 모방한 상표를 출원한 것은 본호에 위반된다고 한다.
- ④ 출원상표가 본호에 해당되는지 여부는 사회의 거래실정 및 도덕관념의 변화 등에 따라 상대적으로 판단하여야 한다.
- ⑤ 본호에 위반된 상표가 잘못 등록되더라도 제척기간의 제한이 없는 등록무효 사유에 해당한다.

해설

- ① [○] 제34조 제1항 제4호
- ② [○] 제34조 제2항
- ③ [×] 단순히 주지저명상표를 모방한 사정만으로는 다른 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 제34조 제1항 제4호의 적용이 없다.
- ④ [○] 특허법원 1999. 11. 25. 선고 99허6121 판결 [등록무효(상)]
- ⑤ [○] 제122조

정답 ③

57 방송사 甲은 제작한 드라마가 인기리에 방영되자 그 드라마 제명을 상표로 출원한 후 이를 사용하고자 하는 乙에게 대가를 지불받고 사용허락까지 하였으나 이와 무관한 제3자인 丙이 동일제명을 자신이 출원한 동일 또는 유사한 지정 서비스에 선출원한 사실을 발견하였다. 각 표장의 등록적격성 및 甲과 丙과 乙의 관계에 관한 다음 설명 중 가장 옳은 것은? (식별력은 문제 삼지 않으며 견해의 대립이 있는 경우 판례에 의한다) 04 기출

- ① 상표법상 甲이 정보제공이나 이의신청을 통하여 丙의 출원의 등록을 저지할 수 있는 명백한 근거가 없다.
- ② 甲의 드라마가 저명해진 후에 丙이 출원한 경우에는 丙의 선출원이 거절되는 것에 다툼의 여지가 있을 수 없다.
- ③ 丙의 출원이 출원공고가 된다면 乙의 상표 사용에 대하여 丙은 서면경고 후에 손실보상청구권을 행사할 수 있다.
- ④ 丙이 상표등록을 받고 등록상표를 그대로 사용하는 경우라면, 그 사용에 있어 드라마 저작권자인 甲의 동의가 필요한 경우는 없다.
- ⑤ 丙은 상표등록을 받더라도 乙의 상표 사용에 대하여서는 권리 침해를 주장할 수 없다.

- ① [○] 甲의 출원은 丙출원보다 후출원이므로 丙은 선원주의에 위반되지 않고, 甲의 드라마 제명이 丙의 출원 당시 상품화 사업 등을 통하여 상표로서 인식되었다고 볼만한 사정도 없으므로 제34조 제1항 제9호 내지 제14호의 거절이유가 있다고 보기도 어려우며, 2014년 개정법 제34조 제1항 제20호에 해당할 만한 사정도 없기에 丙의 출원은 원칙적으로 등록에 별다른 문제가 없다. 다만, 심사기준은 모방상표의 근절을 위하여 '방송이나 인터넷을 포함한 정보통신매체 등을 통하여 출처표시로 인식되지 않을 정도로 널리 알려져 일반인들이 유행어처럼 사용하게 된 방송프로그램 명칭이나 영화 또는 노래의 제목에는 제33조 제1항 제7호를 적용한다. 널리 알려진 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭 등과 동일·유사한 상표를 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 제34조 제1항 제12호에 해당하는 것으로 본다.'라고 규정하고 있으므로, 사실관계에 따라 심사실무상으로는 丙의 출원에 제33조 제1항 제7호 또는 제34조 제1항 제12호가 적용될 여지는 있으나, 그렇다 하여도 본 문제에서 '상표법상 丙의 등록을 저지할 수 있는 명백한 근거'가 없다'는 것이 틀린 지문이라 보기는 어렵다.
- ② [×] 드라마 제명이 저명해져도 일반수요자가 상품표지로서 인식하지 못하면 제34조 제1항 제9호 등의 인용상표로서의 지위가 인정되지 않는다. 따라서, 제34조 제1항 제9호 내지 제14호의 적용은 없다. 다만, 위 지문 ①에서 소개한 심사기준의 규정에 따라 丙의 출원에 제33조 제1항 제7호 또는 제34조 제1항 제12호가 적용될 여지가 있으나 이에 대하여는 다툼이 있을 수 있으므로 '丙의 선출원이 거절되는 것에 다툼의 여지가 있을 수 없다.'는 지문은 옳지 못하다.
- ③ [×] 丙이 서면경고를 한다고 하여 서면경고 후 바로 손실보상청구권을 행사할 수 있는 것은 아니고 상표권설정등록 후에 가능하다.
- ④ [×] 2014년 개정 상표법은 제92조 제2항에서 '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제1호 파목에 따른 부정경쟁행위에 해당할 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.'고 규정하고 있다. 한편, 비록 문제의 사실관계가 불분명하나 甲의 드라마 제명이 상품화 라이선스 등을 통하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목 소정의 성과로 창출되어 있는 경우로서, 丙의 등록상표의 사용이 제92조 제2항에 해당한다면 (비록 丙이 선출원이라 하여도) 경우에 따라 그 사용에 있어 甲의 동의가 필요한 경우가 있으므로 옳은 지문이라 볼 수 없다. 다만, 드라마 제명은 저작권법상 보호받는 저작물은 아니므로 제92조 제1항은 문제되지 않는다.
- ⑤ [×] 丙이 상표등록을 받는다면, 甲은 등록될 수 없고 이러한 甲으로부터 허락을 받은 것에 불과한 乙은 丙의 권리를 침해한 것이 된다. 따라서, 丙은 상표등록 후 乙에게 권리 침해를 주장할 수 있다. (만약 丙의 등록상표가 제92조 제2항에 해당한다 하여도 그 금지권까지 제한되는 것은 아니므로 문제되지 않는다.)

정답 ①

58 상표법 제34조 제1항 제4호에 관한 설명 중 옳지 않은 것은(다툼이 있는 경우에는 대법원 판례에 의함)?

05 기출

- ① 출원상표가 출원인인 법인의 명칭과 달라 그 출원인이 다른 법인의 명칭으로 인식되어질 우려가 있는 경우에는 공서양속에 반하는 상표라고 하는 것이 대법원 판례의 확고한 입장이다.
- ② 대법원 판례에 의하면 타인의 상표가 해외에서만 주지·저명한 경우에는 그 상표와 유사한 상표를 출원하더라도 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하지 않는 것이 원칙이다.
- ③ 주지·저명한 타인의 상표를 모방하여 상표등록출원하는 경우에는 상표법 제34조 제1항 제9호 또는 제11호와 함께 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다(다만, 그 지정상품은 같은 것으로 한다).
- ④ 대법원 판례에 의하면 재앙을 막는다는 부적을 표시함이 분명한 상표를 아동복, 속내의 등을 지정상품으로 하여 출원하는 것은 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다고 한다.
- ⑤ 대법원 판례에 의하면 등록상표가 저명한 저작물을 모방하여 출원등록된 것이라도 당해 저작물이 국내에서는 보호대상 저작물이 아니라면 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 한다.

해설

- ① [×] 법인으로 된 출원인의 명칭과 다른 명칭이 상표로 출원되고 있는 경우 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는지의 여부는 일률적으로 판단할 수 없고 구체적인 경우에 개별적으로 살펴 보아야 할 것이다(대법원 1993.7.27. 선고 92후2311 판결).
- ② [○] ③번 해설 참조
- ③ [×] 구법상 판례는 고의로 타인의 저명한 상표 등의 신용에 편승하는 목적의 부정경쟁 목적의 모방상표에 대하여 본 규정을 적용할 수 있다고 보았으나, 2007년 개정 상표법의 취지에 비추어 보면 부정경쟁 목적의 모방상표라는 것만으로 본 규정이 적용된다고 볼 수 없다는 것이 일반적 견해이다. ※ 이러한 점에 미루어 보면 “해외에서만 주지·저명한 경우에는 ~”이라는 표현 역시 국어적으로는 문제가 있는 표현이다.
- ④ [○] 부적 사건, 대법원 1992. 4. 24. 선고 91후1878 판결.
- ⑤ [○] 타인의 저작권을 침해하는 상표라는 사정만으로 곧바로 제34조 제1항 제4호에 해당한다고 볼 수 없고(특허법원 2003. 5. 1. 선고 2002허6671 판결 등), 특히 2019. 1. 1. 시행 개정 상표심사기준은 타인의 저명한 저작권을 침해하는 경우 제34조 제1항 제4호에 해당하는 것으로 본다는 기존 규정을 삭제하여 저명한 저작권을 침해하는 경우라 하여도 본호의 적용이 없는 것으로 보고 있다. 한편, 이러한 논의와 무관하게 구법상 대법원 판례는 본 문제의 지문과 같이 “등록상표가 저명한 저작물을 모방하여 출원등록된 것이라도 당해 저작물이 국내에서는 보호대상 저작물이 아니라면 (결국 타인의 저명한 저작권을 침해한 것이 아니므로) 제34조 제1항 제4호에 해당하지 않는다.”라는 취지의 판시를 한 바 있고(대법원 2000.5.30. 선고 98후843 판결), 본 지문은 대법원 판례의 취지를 그대로 지문화 한 것으로 옳은 지문이다.

정답 ①, ③

- 59** 다음 중 상표등록 부등록 사유(상표법 제34조 제1항 제1호 내지 제6호에 한함)의 적용에 있어 출원주체에 따라 상표등록 가부가 달라질 수 있는 경우만으로 바르게 묶인 것은?
(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

'09 기출

- ㄱ. 한글 워드 소프트웨어에 사용하고자 하는 「세종대왕」
 ㄴ. 컴퓨터에 사용하고자 하는 「EDISON」
 ㄷ. 운동용 의류에 사용하고자 하는 「박지성」
 ㄹ. 완구류에 사용하고자 하는 「태권브이(V)」
 ㄹ. 신사복에 사용하고자 하는 「자유의 여신상」의 도형
 ㅂ. 스포츠용품에 사용하고자 하는 「OLYMPIC」
 ㅅ. 어학원 서비스에 사용하고자 하는 「연세학당」

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ, ㅂ ③ ㄷ, ㅂ, ㅅ
 ④ ㄹ, ㄹ, ㅅ ⑤ ㄴ, ㅂ, ㅅ

해설

▶ ㄱ 지문 ㄴ 해설 참조

▶ ㄴ (한글 워드 소프트웨어에 사용하고자 하는 「세종대왕」) 및 (컴퓨터에 사용하고자 하는 「EDISON」)의 경우 제34조 제1항 제2호의 적용여부가 문제되는데 제34조 제1항 제2호는 출원의 주체가 누구인지 여부와 상관이 없다(물론, 'ㄱ' 과 'ㄴ' 모두 제34조 제1항 제2호에 해당되지는 않는다).

▶ ㄷ (운동용 의류에 사용하고자 하는 「박지성」)의 경우 제34조 제1항 제6호가 문제되며, 제34조 제1항 제6호는 저명한 성명의 소유자 본인이 아닌 경우라면 그 저명한 타인의 승낙을 얻은 경우를 제외하고는 등록을 받을 수 없으므로 출원주체에 따라 상표등록 가부가 달라질 수 있다.

▶ ㄹ (완구류에 사용하고자 하는 「태권브이(V)」)의 경우 저명한 저작물(캐릭터)의 명칭에 해당하는 것으로 제34조 제1항 제4호가 문제될 수 있으나, 단순히 저명한 저작물의 '명칭'을 출원한 사정만으로는 제34조 제1항 제4호에 해당되지 않는다고 보아야 하므로, 출원주체에 따라 상표등록 가부가 달라지는 경우라 보기 어렵다. (참고 : 다만, '널리 알려진 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭 등과 동일·유사한 상표를 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 제34조 제1항 제12호에 해당하는 것으로 본다.'는 심사기준에 의할 때 제34조 제1항 제1호 내지 제6호에 한한다는 문제의 조건과 달리 제34조 제1항 제12호까지를 고려한다면, 'ㄹ'의 경우도 해당 저작물에 대한 정당한 권원이 없는 자가 출원한 경우에는 수요자 기만의 염려가 있다는 이유로 제34조 제1항 제12호가 적용될 수 있으므로 출원주체에 따라 상표등록 가부가 달라질 수 있다.)

▶ ㄴ (신사복에 사용하고자 하는 「자유의 여신상」의 도형)의 경우 상표법상 부등록 사유로 문제될 만한 거절 이유가 존재하지 않으며 따라서 출원의 주체가 누구인지 여부와 상관이 없음이 당연하다.

▶ ㄴ (스포츠용품에 사용하고자 하는 「OLYMPIC」)의 경우 제34조 제1항 제1호 다목이 문제되며, 제34조 제1항 제1호 다목은 그 단서에 따라 그 기관(국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관)이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 때에는 그 적용이 없으므로 출원주체에 따라 상표등록가부가 달라질 수 있다.

▶ ㄴ (어학원 서비스에 사용하고자 하는 「연세학당」)의 경우 제34조 제1항 제3호가 문제되며, 제34조 제1항 제3호는 그 단서에서 그 국가 등(국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인)이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있으므로 출원주체에 따라 상표등록 가부가 달라질 수 있다. 따라서 정답은 ③이다.

정답 ③

60 상표법 제34조 제1항 제2호(국가 등과의 관계를 거짓으로 표시하거나 모욕하는 상표)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 10 기출

- ① 출원상표 “JAMES DEAN”은 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니하며 고인과의 관련성에 대한 아무런 표시가 없어 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당하지 않는다.
- ② 검은 색 바탕에 흰 오선을 긋고 그 위에 단순히 “MOZART”라는 고인의 성명 자체를 기재하여 출원·등록된 상표는 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당하지 않는다.
- ③ 흑인의 도형과 “DARKIE”라는 문자가 결합된 상표는 흑인종족을 비방, 모욕, 악평을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.
- ④ 등록상표 “인디안”은 지정상품인 건과자, 아이스크림과의 관계에서 특정국가, 민족을 비방, 모욕 또는 악평을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.
- ⑤ 신사복 등 의류에 관한 “CARDINAL”이 카톨릭의 추기경을 의미하는 뜻이 있더라도 영어권이 아닌 우리나라에서 일반인에게 추기경으로 인식된다고 할 수 없고, 출원상표의 외관, 칭호, 관념과 지정상품 및 거래실정 등에 비추어 종합적으로 볼 때 카톨릭 종교를 비방 또는 모욕하거나 악평을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다.

해설

- ① [○] 본원상표 ‘JAMES DEAN’은 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 제34조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 1997.7.11. 선고 96후2173 판결).
- ② [○] MOZART 오선지 사건, 대법원 1998. 2. 13. 선고 97후938 판결
- ③ [○] 본원상표는 흑인의 도형과 그 밑에 영문자로 “DARKIE”를 횡서하고 다시 한문자로 “黑人”을 병기하여 도형과 문자가 결합된 상표로서 본원상표의 영문자 “DARKIE”는 흑인을 경멸하는 구어로서의 영문자 “Darky” 또는 “Darkey”와 동일한 발음 및 동일한 의미로 사용되는 것으로 본원상표 전체를 객관적, 이격적으로 보면 흑인종족, 흑인민족을 비방, 모욕, 악평을 받게 할 염려를 배제할 수 없다 할 것이라고 하여 제34조 제1항 제2호의 규정에 해당한다(대법원 86후163 판결).
- ④ [×] 본원상표 인디안은 인도사람 또는 아메리칸 인디안 종족의 악칭을 통상적인 방법으로 호칭하는 것으로 보여지고, 위와 같은 기준에서 관찰할 때 그것이 위 종족과의 관계를 허위표시하거나 이를 비방, 모욕 또는 악평을 받게 할 염려가 있는 상표라고 보이지 아니한다(대법원 1989.7.11. 선고 89후346 판결).
- ⑤ [○] CARDINAL 사건, 대법원 1990.9.28. 선고 89후711 판결

정답 ④

61 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 11 기출

- ① 상표법 제34조 제1항 제1호 다목에 규정된 “저명한 국제기관”이라 함은 국제연합(UN) 및 산하기구와 EU·NATO·OPEC와 같은 지역 국제기구 등 국제사회에서 일반적으로 인식되고 있는 국가 간의 단체를 말한다.
- ② 상표법 제34조 제1항 제1호 나목에 규정된 “「공업소유권의 보호를 위한 파리협약」 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법조약」 체결국의 국기와 동일·유사한 상표”는 등록을 받을 수 없으며, 본 호에서 나열하는 국가는 우리나라가 승인한 국가만을 의미한다.
- ③ 상표법 제34조 제1항 제1호 다목에 규정된 “국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭·약칭·표장”이라도 등록을 받을 수 있다.
- ④ 상표법 제34조 제1항 제1호 마목에 규정된 “공공기관”은 중앙행정기관·지방행정기관 그 밖의 지방자치단체·공공조합·공법상의 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관을 포함한다.
- ⑤ 상표법 제34조 제1항 제1호 마목에 규정된 “감독용 또는 증명용 인장·기호”라 함은 상품 등의 규격·품질 등을 통제·증명하기 위하여 동맹국의 국가 자체가 채택한 표장을 말한다.

해설

- ① [○] 제34조 제1항 제1호 다목 소정의 저명한 국제기관이라 함은 국제연합(UN) 및 산하기구와 EU, NATO, OPEC와 같은 지역 국제기구 등 국제사회에서 일반적으로 인식되고 있는 국가(정부)간의 국제기관뿐만 아니라 정부 간의 합의에 의하지 않고 창설된 이른바 비정부단체나 국제적 민간단체도 이에 포함된다(대법원 1987.04.28. 선고 85후11 판결). 따라서, 옳은 지문이다.
- ② [×] 제34조 제1항 제1호 나목 소정의 ‘국기’는 모든 외국의 국기가 보호되는 것은 아니며, ‘동맹국 등’의 국기에 한한다. 다만, 동맹국이면 족하고 우리나라의 국가승인 여부는 불문한다.
- ③ [○] 그 기관(국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관)이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다(法 34조 제1항 제1호 다목 단서). ※ 지문의 표현이 객관식용으로 적절치 않다. “등록을 받을 수 있는 경우가 있다.” 정도가 타당하다.
- ④ [○] 제34조 제1항 제1호 마목 소정의 ‘공공기관’은 동맹국 등의 중앙 또는 지방행정기관과 제34조 제1항 제2호 소정의 공공단체(지방자치단체, 공공조합, 공법상의 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관)를 포함한다.
- ⑤ [○] 상표심사기준 제5부 제1장 1.3

정답 ②

62 정당한 상표권자 또는 상표 사용자를 위한 규정에 관한 설명으로 옳은 것은? '14 기출

- ① 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표라도 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 상표등록시 동종업자간에 식별할 수 있게 된 경우라면, 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ② 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 지명한 국제기관의 명칭, 약칭, 포장과 동일하거나 이와 유사한 상표는 정당한 권리자라 하더라도 상표등록을 받을 수 없다.
- ③ 정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일·유사한 표장이 있는 상표는 해당 박람회에서 상패·상장 또는 포장을 받은 자가 그 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용하는 경우에도 상표등록을 받을 수 없다.
- ④ 동맹국 등이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장과 동일·유사한 상표는 그 동맹국 등이 허락을 받은 제3자라도 상표등록을 받을 수 없다.
- ⑤ 등록상표에 대해 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제2호의 취소심판이 청구되어 심결이 확정된 경우, 상표권자는 취소심판 청구일부터 3년이 경과한 후 그와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록출원을 하면 상표등록을 받을 수 있다.

해설

- ① [x] '상표등록시 동종업자'가 아니라 '상표등록여부결정을 할 때 (거래자 및) 일반수요자'에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어야 하며, 나아가 제33조 제1항 제1호 및 제2호는 사용에 의한 식별력 취득시 등록이 가능한지 여부에 대하여 다툼이 있다.
- ② [x] 정당한 권리자(해당 기관)는 제34조 제1항 제1호 다목 단서에 따라 등록이 가능하다.
- ③ [x] 제34조 제1항 제5호 단서에 따라 옳지 않다.
- ④ [○] 제34조 제1항 다목 단서, 라목 단서 및 제34조 제1항 제3호 단서는 예외적 본인등록표장으로서 해당 규정의 주체들만이 예외적으로 상표등록을 받을 수 있는 것이고, 해당 주체들에게 허락을 받았더라도 제3자는 상표등록을 받을 수 없다.
- ⑤ [x] '취소심판 청구일' 아닌 '취소심결확정일'이다.

정답 ④

63 상표법 제34조 제1항 제6호의 저명한 타인의 성명·명칭 등 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) '17 기출

- ① 저명한 타인의 성명, 명칭 등을 상표로 사용한 때에는 타인 자신의 불쾌감의 유무 또는 사회통념상 타인의 인격권의 침해여부를 불문하고 본호를 적용한다.
- ② 사회통념상 국내 일반수요자 또는 관련 거래업계에서 타인의 성명·명칭 등이 저명하면 되고, 타인 그 자체는 저명할 필요가 없다.
- ③ 타인이라 함은 현존하는 국내의 자연인 또는 법인은 물론이고 국내 일반수요자 또는 관련 거래업계에서 일반적으로 널리 인식되고 있는 현존하는 외국의 자연인 또는 법인도 포함된다.
- ④ 저명한 연예인그룹 명칭이나 약칭을 포함하는 상표를 제3자가 임의로 출원한 경우 본호에 해당하는 것으로 본다.
- ⑤ 저명한 타인의 성명, 명칭 등 또는 이들의 약칭이 상표의 부기적인 부분으로 포함되어 있는 경우에는 본호에 해당하지 않는 것으로 본다.

해설

- ① [○] 상표심사기준 제5부 제6장 2.3
- ② [○] 상표심사기준 제5부 제6장 1.1.2
- ③ [○] 상표심사기준 제5부 제6장 1.2.1
- ④ [○] 상표심사기준 제5부 제6장 1.2.3
- ⑤ [×] 저명한 타인의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명, 인장, 아호, 예명, 필명 또는 이들의 약칭이 상표의 부기적인 부분으로 포함되어 있는 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다(상표심사기준 제5부 제6장 2.1).

정답 ⑤

64 상표등록을 받을 수 있는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) '21 기출

- ㄱ. 해군사관학교 사관생도의 “견장”
- ㄴ. 의류를 지정상품으로 하는 상표 “JAMES DEAN”
- ㄷ. 지정상품이 기계류인 출원상표 “KSB”
- ㄹ. 지정상품을 ‘눈썹용 연필, 립스틱, 매니큐어, 아이섀도, 마스크라’ 등으로 하는 외국 회사의 출원상표 “2NE1”
- ㅁ. 공인노무사업, 법무사업, 변호사업, 변리사업 등을 지정서비스업으로 하면서 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 상표 “나홀로”
- ㅂ. 지정상품을 서적으로 하는 출원상표 “관족법(觀足法)”

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

해설

- ㉠. [x] 제34조 제1항 제1호에 규정된 ‘기장’이란 공적을 기념하거나 신분, 직위 등을 표상하는 휘장 또는 표장을 의미하는 것으로서, 해군사관학교 사관생도의 견장 “”은 해군사관학교 사관생도로서의 신분과 그 학년을 표상하므로 그 전체가 대한민국의 기장에 해당한다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후 4721 판결). 따라서, 제34조 제1항 제1호 가목(대한민국의 국기, 국장(國章), 군기(軍旗), 훈장, 포장(褒章), 기장, 대한민국이나 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장(印章)·기호와 동일·유사한 상표)에 해당하는 표장으로 등록될 수 없다.
- ㉡. [○] 대법원은 ‘JAMES DEAN’이라는 상표의 등록여부와 관련하여 본원상표는 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 제34조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 거짓으로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 본원상표 자체의 의미에서 선량한 도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수는 없으며, 본원상표와 같은 표장을 사용한 상품이 국내에서 유통됨으로써 국내의 일반 수요자들에게 어느 정도라도 인식되었음을 인정할 자료가 없는 이상 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자들이 본원상표를 타인의 상품 표장으로서 인식할 가능성은 없으므로, 본원상표는 제34조 제1항 제4호 또는 제34조 제1항 제12호 소정의 상표라고 볼 수 없다고 판시하였다(대법원 1997. 7. 11. 선고 96후2173 판결). 따라서, 등록이 가능하다.
- ㉢. [○] 출원상표 “KSB”와 한국방송공사의 저명한 업무표장인 인용표장 “KBS”의 외관이 유사하다고 하더라도 관념과 칭호가 다르고, 한국방송공사는 방송업무 및 그 부대사업만을 시행하고 있음에 비추어 출원상표의 지정상품인 기계류의 수요자들이 그 상품을 한국방송공사에서 제조 또는 수입, 판매하는 것이거나 그 상품의 출처와 한국방송공사 사이에 어떠한 관련관계가 있다고 오인, 혼동할 가능성은 없다고 할 것이므로 전체적으로 보아 출원상표의 인용표장은 유사하다고 할 수 없다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후2011 판결). 즉, 제34조 제1항 제3호가 적용되기 위하여는 국가·공공단체 등의 저명한 업무표장과 동일·유사한 상표라야 하는데, “KSB”의 경우 한국방송공사의 저명한 업무표장인 “KBS”와 유사하지 않아 등록이 가능하다.
- ㉣. [x] 제34조 제1항 제6호에 해당하여 등록될 수 없다(대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결).
- ㉤. [x] 제33조 제1항 제3호에 해당하여 등록될 수 없다(대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결).
- ㉥. [x] 제33조 제1항 제3호에 해당하여 등록될 수 없다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2000후2149 판결). 따라서, 정답은 ‘㉡, ㉢’으로 구성된 ㉠이다.

정답 ㉠

65 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 24 기출

- ① 저명한 연예인 이름, 연예인 그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내외 유명 인사 등의 이름이나 이들의 약칭을 포함하는 상표를 출원한 경우에는 지정 상품과 관계없이 제34조 제1항 제6호를 적용한다.
- ② 제34조 제1항 제2호는 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하거나 비방 또는 모욕하거나 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 경우에 적용한다.
- ③ 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하는 것이 아니라도 지정상품과의 관계를 고려할 때 저명한 고인과 관련 있는 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 경우에는 제34조 제1항 제12호를 적용한다.
- ④ 현존하는 저명한 공익법인의 명칭 또는 약칭이나 이를 포함하는 상표에 대해서는 제34조 제1항 제6호를 적용한다.
- ⑤ 저명한 고인의 성명을 정당한 권리자의 동의 없이 출원하여 그 명성에 편승하려는 경우 제34조 제1항 제2호가 적용된다.

해설

- ① [○] 상표심사기준 제4부 제7장 3.
- ② [○] 상표심사기준 제5부제2장 3.
- ③ [○] 상표심사기준 제5부제2장 3.
- ④ [○] 상표심사기준 제5부제2장 3.
- ⑤ [×] 본호가 적용되기 위해서는 거짓표시나 평판을 나쁘게 할 우려가 있어야 하므로 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없다면, 본호에 해당되지 않는다. 대법원은 '의류' 등을 지정상품으로 한 'JAMES DEAN'이라는 상표의 등록여부와 관련하여 i) 본원상표는 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 제34조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 거짓으로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 ii) 본원상표 자체의 의미에서 선량한 도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수는 없으며, iii) 본원상표와 같은 표장을 사용한 상품이 국내에서 유통됨으로써 국내의 일반 수요자들에게 어느 정도라도 인식되었음을 인정할 자료가 없는 이상 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자들이 본원상표를 타인의 상품 표장으로서 인식할 가능성은 없으므로, 본원상표는 제34조 제1항 제4호 또는 제34조 제1항 제12호 소정의 상표라고 볼 수 없다고 판시하였다(대법원 1997. 7. 11. 선고 96후2173 판결).

정답 ⑤

66 상표법 제34조 제1항(상표등록을 받을 수 없는 상표)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'25 기출

- ① 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시한 상표라도 유족의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
- ② 공공단체의 비영리 업무를 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일한 상표라도 그 공공단체의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 저명한 타인의 성명·명칭을 포함하는 상표라도 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
- ④ 저명한 국제기관의 명칭·약칭과 동일한 상표라도 그 국제기관의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
- ⑤ 대한민국의 국기, 국장(國章)과 동일한 상표라도 대한민국 정부의 승낙을 받은 경우에 비영리법인인 상표등록을 받을 수 있다.

해설

- ① [×] 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하는 상표의 등록에 관하여 유족의 승낙을 받았더라도, 제34조 제1항 제4호에 해당되지 않는 것은 별론으로 하더라도 제34조 제1항 제2호 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없다. 이와 비교하여, 제34조 제1항 제6호는 저명한 타인(현존하는 타인)의 승낙에 의해 그 적용이 배제된다.
- ② [×] 지문⑤ 해설 참조
- ③ [○] 제34조 제1항 제6호
- ④ [×] 지문⑥ 해설 참조
- ⑤ [×] 예외적 등록 표장(法 34조 제1항 제1호 다목, 라목, 동조 동항 제3호)은 본인(저명한 국제기관 등, 동맹국 등이 가입한 국제기구, 국가 등)이 예외적으로 등록받을 수 있는 것이고, 본인의 허락에 의해 제3자가 등록을 받을 수는 없다. 제3자의 사용을 배제하고자 하는 취지에 따라 예외적 본인 등록 표장은 질권의 설정이 허용되지 않는다(사용권 설정에 관한 제한 규정 역시 필요하나 현 상표법 상 제한이 없음).

정답 ③

제34조 제1항 제7호

67 상표법 제34조 제1항 제7호에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

05 기출

- ① 후출원상표가 파리협약 동맹국의 1국에 등록된 상표권으로서 선출원 등록상표의 출원일보다 먼저 동맹국에서 등록된 것이라도, 타인의 선출원 등록상표와 상표 및 지정상품이 유사하다면 본 호가 적용된다.
- ② 후출원상표의 출원당시에 이미 등록되어 있던 선등록인용상표가 후출원상표의 출원일 전부터 계속해서 3년간 불사용되었다면 후출원상표의 출원인이 선등록인용상표권에 대하여 별도로 제119조 제1항 제3호에 의한 취소심판을 청구하지 않아도 후출원상표는 본 호의 적용을 받지 않는다.
- ③ 선출원에 의한 등록상표와 동일 또는 유사한 상표라도 그 지정상품이 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 경우가 아니면 본 호에 해당되지 않는다.
- ④ 선출원등록상표의 상표권자가 그와 유사한 후출원상표의 출원에 동의하였다고 하더라도 선출원등록상표와 유사한 후출원상표의 출원은 본 호가 적용된다.
- ⑤ 후출원상표가 널리 사용되어 현저하게 알려진 상표라 하더라도 선출원등록상표와 상표 및 그 지정상품이 동일 또는 유사하다면 본 호가 적용된다.

해설

- ① [○] 조약에 따른 우선권을 주장하지 않은 이상 제1국에서의 등록여부는 제34조 제1항 제7호 적용 여부 판단에 영향이 없다.
- ② [×] 인용상표에 불사용으로 인한 취소사유가 있음이 명백한 경우라도 심판 또는 판결에 의하여 그 등록이 취소되지 않는 한 제34조 제1항 제7호의 인용상표가 될 수 있다(대법원 1990.09.28 선고 90후366 판결). 따라서, 선등록인용상표에 불사용 취소사유가 있다 하여도 심판을 청구하여 이를 실제 소멸시켜야 한다.
- ③ [○] 본 규정은 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표에 적용되는 규정이다.
- ④ [×] 상표공존동의제도의 도입에 따라 선출원등록상표의 상표권자의 동의가 있다면 선출원등록상표와 유사 범위에 있는 후출원 상표는 상표등록을 받을 수 있게 되었다.
- ⑤ [○] 후출원 상표의 인식도는 제34조 제1항 제7호 적용 여부의 판단에 있어 고려사항이 아니다.

정답 ②, ④

68 선출원에 의한 甲의 등록상표와 유사한 상표에 대해 甲의 등록상표의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원한 乙이 자기의 출원상표를 등록받을 수 있는지 여부의 판단에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? '09 기출

- ① 乙이 甲의 등록상표에 대하여 제119조 제1항 제1호에 의한 취소심판을 청구하여 취소확정된 경우 乙의 출원상표에는 제34조 제1항 제7호의 거절이유가 존재한다.
- ② 乙이 출원 과정에서 甲이 乙 출원의 등록을 동의한다는 취지의 공존동의서를 제출한 경우에는 乙의 출원상표는 등록을 받을 수 있다.
- ③ 甲은 乙 출원의 지정상품 중 일부에 대한 등록만을 동의한다는 공존동의를 하는 것도 가능하다.
- ④ 乙이 상표등록출원 후 등록여부결정 전에 甲의 상표권을 양도 받으면 출원상표는 등록받을 수 있다.
- ⑤ 乙의 상표등록출원시 존재하였던 甲의 등록상표가 乙의 출원상표의 등록여부결정 전에 무효심판에 의하여 무효로 확정된 경우에는 乙의 출원상표는 등록 받을 수 있다.

- 해설**
- ① [×] 제34조 제1항 제7호는 '상표등록여부결정을 할 때'를 기준으로 하므로(法 34②), 甲의 선등록상표가 취소심판에 의하여 소멸한 경우, 乙의 출원상표에는 제34조 제1항 제7호가 적용되지 않는다.
 - ② [○], ③ [○] 2023년 개정법에 따라 상표공존동의 제도가 도입되었다. 이에 따라 법 제34조 제1항 제7호 또는 제35조 규정에 따른 거절이유를 갖는 유사범위의 후출원의 경우에도 선출원인의 동의를 얻어 상표등록을 받을 수 있다. 이 경우 출원 단계에서 상표공존 동의서를 제출하여야 하며, 일부 지정상품에 대한 공존동의도 허용된다.
 - ④ [○] 제34조 제1항 제7호 규정의 타인인지 여부의 판단은 등록여부결정시를 기준으로 하므로 후출원인이 후출원의 등록여부결정 전에 선출원 등록을 양도 받는 경우 후출원은 상표등록을 받을 수 있다.
 - ⑤ [○] 乙의 상표등록출원시 존재하였던 甲의 등록상표가 乙의 출원상표의 등록여부결정 전에 무효심판에 의하여 무효로 확정된 경우라면, 甲의 등록상표는 처음부터 존재하지 않는 것이 되므로 결국 乙의 출원에는 제34조 제1항 제7호의 거절이유가 없고, 乙의 출원상표는 등록 받을 수 있다.

정답 ①

- 69 출원상표에 대한 1차 심사결과 지정상품 중 일부 지정상품에 대하여 타인의 선등록상표와 유사범위에서 저촉되므로 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다는 의견제출통지서를 송달받았다. 의견제출통지서의 내용을 검토한 결과 심사관의 거절이유통지는 타당한 것으로 판단되었다. 이 경우 출원상표의 상표등록방법으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

12 기출

- ㄱ. 선등록상표의 권리자로부터 선등록상표를 양수받은 후 그 사실을 증명하는 서류와 함께 의견서를 제출하는 방법
 ㄴ. 출원상표가 등록되는 것을 허락한다는 승낙서를 선등록상표의 권리자에게 받은 후 이를 첨부하여 의견서를 제출하는 방법
 ㄷ. 일부 지정상품에 대한 거절결정이 확정되도록 방지하는 방법
 ㄹ. 선등록상표에 대하여 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에 기한 취소심판을 청구한 후 의견서에 심사보류를 요청하는 방법
 ㅁ. 선등록상표가 출원상표의 출원일부터 소급하여 1년 이상 전혀 사용된 사실이 없다는 확인서를 선등록상표의 권리자로부터 받아서 그 서류와 함께 의견서를 제출하는 방법

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ

해설

- ㄱ. [○] 제34조 제1항 제7호에 있어서 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때(등록여부결정시)를 기준으로 하므로(法 34②), 선등록상표의 권리자로부터 선등록상표를 양수받은 후 그 사실을 증명하는 서류와 함께 의견서를 제출하는 것은 등록을 위한 타당한 조치이다.
 ㄴ. [○] 상표공존동의 제도의 도입에 따라 선등록권리자의 동의에 의해 유사범위의 후출원도 등록이 가능하게 되었다.
 ㄷ. [○] 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우(일부 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대한 거절결정이 확정된 경우를 말한다)에는 상표등록결정을 하여야 한다. 따라서, 거절이유가 존재하는 지정상품에 대한 거절결정이 확정되도록 방지하더라도 나머지 지정상품에 대한 상표등록이 가능하다.
 ㄹ. [○] 제34조 제1항 제7호의 판단시점은 상표등록여부결정을 할 때이므로 비록 출원시 선등록상표가 존재하였다 하여도 심사계속 중 선등록상표가 제119조 제1항 제3호로 취소확정이 되면 이를 극복하고 등록될 수 있다. 따라서 타당한 조치라 할 수 있다.
 ㅁ. [x] 제34조 제1항 제7호는 선등록상표가 소멸되기 전 불사용 된 경우일지라도 여전히 적용된다. 따라서 옳은 타당한 조치가 될 수 없다.

정답 ①

70 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

14 기출

- ① 본 호는 심사의 간이 및 신속을 기하기 위해 일관되게 상표등록출원시를 기준으로 적용한다.
- ② 본 호의 규정에 위반한 경우 상표등록 전에는 상표등록거절이유, 정보제공이유 및 이의신청이유에 해당한다.
- ③ 인용표장의 권리자가 甲 및 乙이고 출원상표의 권리자는 甲인 경우, 인용표장의 권리자는 본 호에서의 타인에 해당한다.
- ④ 본 호에 해당함에도 착오로 등록된 경우에는 5년의 제척기간이 적용되는 무효사유에 해당된다.
- ⑤ 상품과 서비스업간에 동종성이 인정되어 수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는 경우에는 상품에 대한 상표와 서비스에 대한 상표 간에도 본 호가 적용된다는 것이 대법원 판례의 태도이다.

해설

- ① [x] 2016년 개정으로 인하여 본호는 '상표등록여부결정을 할 때(등록여부결정시)'를 기준으로 한다.
- ② [○] 지문④ 해설 참조
- ③ [○] 인용표장의 권리자가 2인 이상일 경우에는 그 구성원의 전부가 일치하지 않는 한 타인에 해당한다.
- ④ [○] 제34조 제1항 제7호 위반은 상표등록의 거절이유, 지정상품 추가등록의 거절이유, 정보제공사유, 이의신청사유 및 등록 후 무효사유(제척기간 有)에 해당한다. 따라서, 맞는 지문이다.
- ⑤ [○] 유형적 상품과 서비스업(현행법에서는 모두 상품으로 일원화됨) 간에도 유사 판단이 가능하며 양자의 유사판은 동종성(동종유사성) 유무를 기준으로 판단한다.

정답 ①

71 甲은 X상표에 대하여 a상품을 지정상품으로 하여 2016년 8월 8일에 상표등록출원을 하였고, 현재 심사 진행 중에 있다. 다음 설명 중 옳은 것은? (명시적으로 인용된 경우를 제외하고 각 지문은 서로 독립된 것으로 취급함) 17 기출

- ① 甲의 출원상표 X 및 지정상품 a가 미국인 乙이 미국에서 출원하여 등록받은 X'상표 및 a'상품과 유사하고, 甲은 상표등록출원 당시 乙이 미국에서 생산하는 상품을 수입하여 판매하는 대리점에 해당한다고 할 경우, 乙이 甲의 상표등록출원에 대하여 이의신청이나 정보제공을 하지 않더라도 甲의 상표등록출원은 거절될 수 있다.
- ② 상기 ①의 경우 乙이 甲의 상표출원에 대하여 명시적으로 동의한 경우에만 甲의 출원은 유효하게 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 2017년 2월 24일에 甲의 출원에 대한 상표등록여부를 결정할 때, 甲의 출원상표 X와 표장과 지정상품 면에서 각각 유사한 乙의 등록상표 X'가 2016년 4월 8일에 포기 등록되어 소멸된 사실이 확인된 경우, 甲의 출원은 乙의 소멸된 등록상표 X'로 인하여 거절된다.
- ④ 甲의 출원상표 X와 유사한 상표를 유사한 지정상품에 선출원하여 선등록한 乙의 등록상표 X'가 甲의 상표출원시 존재할 경우에도 乙의 등록상표 X'가 2017년 2월 24일에 존속기간 만료로 소멸되면 甲의 출원은 상표등록을 받을 수 있다.
- ⑤ 甲의 출원이 2017년 2월 24일에 상표등록된 경우 지식재산처장은 상표권자의 성명·주소 및 상표등록번호 등을 상표공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.

해설

- ① [x] 제34조 제1항 제21호는 2016년 개정 전의 구법상 별도의 거절이유(舊法 23①3)가 2016년 개정법에서 새롭게 부등록사유로 편입된 규정으로서, 2016년 개정법 시행(2016. 9. 1.) 후 출원된 경우에 한하여 적용되며, 2016년 개정법 시행 전에 출원된 상표에 대하여는 종전의 규정인 구법 제23조 제1항 제3호에 따른다. 한편, 사안에서 甲의 X상표 출원일은 2016. 8. 8. 로 개정법 시행일(2016. 9. 1.) 전의 출원인데, 위와 같이 제34조 제1항 제21호는 소급적용을 하지 않으므로 甲이 乙의 미국 등록상표인 X'의 대리인에 해당한다 하여도 구법 제23조 제1항 제3호가 적용되어 乙로부터 이의신청, 정보제공 등이 있어야 거절될 수 있다.
- ② 조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '정당한 이유'가 있는 경우만 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다(대법원 2016. 7. 27. 선고 2016후717, 724, 731, 748, 755, 762, 779, 786 판결 [등록취소(상)]).
- ③ [x] 2016년 개정 전의 구법은 제7조(현행 제34) 제1항 제8호에서 "상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표"는 출처혼동 방지차원에서 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있었는데, 2016년 개정법은 이를 삭제하였다. 나아가 2016년 개정법 부칙 제4조는 "제34조 제1항의 개정규정(같은 항 제21호의 개정규정은 제외한다)은 이 법 시행 전에 출원된 상표등록출원으로서 이 법 시행 이후 상표등록결정을 하는 경우에도 적용한다."라고 규정하여 '제34조 제1항의 개정규정'을 소급하여 적용하고 있으므로, 개정법 시행(2016. 9. 1.) 전에 타인의 상표권이 소멸한 날부터 1년 이내에 출원된 상표등록출원으로서 구법 제7조 제1항 제8호의 거절이유가 있다 하여도, 개정법 시행(2016. 9. 1.) 이후 상표등록여부결정을 하는 경우에는 구법 제7조 제1항 제8호가 삭제된 개정법을 소급적용하여 그 거절이유가 해소될 수 있다. 따라서, ③ [x] 지문에서 비록 乙의 포기등록에 의한 소멸일인 2016. 4. 8.로부터 1년 이내인 2016. 8. 8. 甲이 출원한 경우로 구법 제7조 제1항 제8호의 거절이유가 있다고 하여도 甲 출원의 결정 시가 2017. 2. 24.로서 2016년 개정법 시행일 이후라면 구법 제7조 제1항 제8호의 거절이유가 해소되어 甲의 출원은 등록이 될 수 있다.
- ④ [x] 甲의 X상표 출원일은 2016. 8. 8. 로 개정법 시행일(2016. 9. 1.) 전의 출원이므로 구법 제7조 제1항 제7호가 적용되는데, 구법 제7조 제1항 제7호는 '상표등록출원시'를 기준으로 하므로, 甲의 출원시 乙의 등록상표 X'가 존재하였다면 그 후 존속기간 만료로 소멸되었다 하여도 甲의 출원은 등록을 받을 수 없다.
- ⑤ [○] 2016년 개정법은 제82조 제3항을 신설하여 출원공고와는 별도로 '등록공고' 제도를 신설하였으며, 등록공고는 2016년 개정법 시행(2016. 9. 1.) 이후 '상표권의 설정등록을 하는 경우'부터 적용한다(2016년 개정법 부칙 제7). 따라서, 甲의 출원이 2017. 2. 24.자로 상표등록이 되었다면 등록공고의 대상이 된다.

정답 ⑤

72 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 각 호의 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

23 기출

- ㄱ. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장을 포함한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표
- ㄴ. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표
- ㄷ. 수요자들에게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시키는 상표
- ㄹ. 국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

해설

- ㉠ [x] 제34조 제1항 제7호에서는 지리적 표시 단체표장은 제외되므로 옳지 않은 지문이다. cf) 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 단체표장인 경우를 규정하고 있는 제34조 제1항 제8호에서는 상품의 범위에 "동일하다고 인식되어 있는 상품"만이 포함되어 있다.
- ㉡ [○] 제34조 제1항 제20호
- ㉢ [x] 제34조 제1항 제11호의 적용을 위해서는 수요자들에게 "현저하게" 인식되어 있어야 한다.
- ㉣ [○] 제34조 제1항 제2호

정답 ④

제34조 제1항 제9호 내지 제13호

73 상표법 제34조 제1항 제12호에서 규정한 수요자 기만 상표에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

02 기출

- ① 상표법 제34조 제1항 제12호의 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있는 것으로 해석되나 법적안정성 측면에서 동 규정을 이유로 한 상표등록의 무효심판은 제척기간이 적용된다.
- ② 수요자 기만의 염려가 있는 원인이 있는 부분은 반드시 해당 상표의 요부일 필요는 없고 그것이 기술적(記述的)·부기적인 경우에도 적용될 수 있으며, 상표의 출원인에게 부정경쟁의 의사나 고의·과실의 유무를 묻지 아니한다.
- ③ 판례는 인용상표가 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우에도, 만일 어떤 상표가 인용상표와 동일 또는 유사하고 또한 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용된 경우 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보여지는 경우라면, 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 본다.
- ④ 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지 여부는 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단한다.
- ⑤ 수요자 기만의 염려가 있는 상표와 관련하여, 판례는 동일 또는 유사한 상표가 핸드백과 여자구두(단화)에 각각 사용되는 경우에는 동일 또는 유사 상품에 사용된 경우에 못지 않게 상품 출처의 오인·혼동의 우려가 있다고 보았다.

해설

- ① [x] 제34조 제1항 제12호 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있으므로(대법원 1991.1.11 선고 90후311 판결), 등록무효심판의 경우 제척기간의 적용이 없다(法 122). 지문 ①의 전반부는 판례의 견해로서 옳지만 후반부는 제척기간이 적용된다 하여 옳지 않으므로 틀린 지문이다.
- ② [○] 제34조 제1항 제12호는 거래질서의 보호를 위한 공익규정이므로 출원인의 부정경쟁의사나 고의·과실의 유무를 묻지 않고 수요자 기만의 염려가 있는 원인이 되는 부분도 반드시 해당상표의 요부일 필요가 없으며, 수요자 기만의 염려가 있는 상표인지 여부도 등록여부결정시를 기준으로 판단한다(대법원 1992.7.28 선고 92후278 판결 등).
- ③ [○] 판례는 제34조 제1항 제12호 후단의 출처 혼동에 따른 수요자 기만에 해당하기 위해서는 상표는 동일하거나 유사할 것을 요구하고 있고, 상표의 경우도 원칙적으로는 동일하거나 유사할 것을 요하고 있다. 다만, 동일 또는 유사한 상품에 사용된 경우 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보여지는 경우라면 적용될 수 있다고 보았고(ASK, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결), 선사용상표가 저명상표인 경우에는 물품이 비유사한 경우라도 출처의 혼동(광의의 혼동)의 발생을 이유로 본 규정의 적용을 인정하고 있다(소녀시대, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결).
- ④ [○] 제34조 제2항
- ⑤ [○] ‘핸드백’과 ‘여성용 구두 또는 의류’(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결), ‘의류’와 ‘선글라스’(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결), ‘의류’와 ‘팔목시계’(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3275 판결) 이른바 토털패션화 경향 등을 고려할 때 동일·유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있는 경우에 해당한다.

정답 ①

74 상표의 희석에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

'03 기출

- ① 희석은 상표의 판매력을 약화시키거나 상표가 가지는 굿윌(good will)을 손상시키는 것과 관련된다.
- ② 희석은 단일의 출처에 의한 단일의 것이라는 인식에서 여러 출처에 의한 여러 개의 것이라는 인식으로 변할 때 발생한다.
- ③ 희석은 동종 경쟁업자가 상표권자의 상표를 사용하는 것에 대하여 적용되는 것이 일반적이다.
- ④ 자동차에 관한 유명한 상표인 롤스로이스(Rolls Royce)를 롤스로이스 캔디에 사용하는 것과 보석가게와 관련하여 유명한 상표를 음란한 상품을 광고하는 것에 사용하는 것 모두 상표의 희석에 해당할 수 있다.
- ⑤ 우리나라의 상표법상 희석화의 염려가 있는 상표의 등록을 저지할 수 있다고 주장될 수 있다.

해설

- ① [○] 저명상표의 희석화란 타인의 저명상표를 비경쟁적 또는 부정적 이미지의 상품에 사용함으로써 상표의 고객흡인력 내지 판매력(good will)을 훼손하는 행위를 말한다.
- ② [○] 희석화는 일반적으로 특정 상품에 대한 저명한 상표를 다른 종류의 상품에 사용하는 경우에 발생하므로, 수요자의 인식이 단일의 출처에 의한 단일의 것이라는 인식에서 여러 출처에 의한 여러 개의 것이라는 인식으로 변하게 된다.
- ③ [×] 희석화는 위와 같이 타인의 저명상표를 비경쟁적(비유사) 또는 부정적 이미지의 상품에 사용하는 경우에 발생하므로, 일반적으로 동종 경쟁업자가 상표를 사용하는 경우가 아닌 비경쟁 관계에 있는 자의 사용에 의하여 발생하는 경우가 많다.
- ④ [○] 전자의 희석화 행위를 상표의 약화행위라고 하고, 후자는 상표의 손상행위라고 한다.
- ⑤ [○] 2014년 개정법은 제34조 제1항 제11호 후단을 신설하여 저명상표의 희석화 염려가 있는 상표를 부등록사유로 규정하고 있는바, 본 규정에 의하여 희석화 염려가 있는 상표의 '등록'을 저지할 수 있다. 또한 제34조 제1항 제13호는 지정상품의 동일·유사를 필요로 하지 않기에 본 규정도 일정부분 등록단계에서의 희석화 방지조항으로 볼 수 있다. 단, 상표법상의 침해는 저명상표의 경우도 동일 또는 유사한 상품에 한하여 인정되므로 상표법상 희석화를 야기하는 상표에 대한 '사용'을 저지시키기는 어렵다.

정답 ③

75 乙은 甲의 미등록 국내 주지상표를 모방하여 甲의 사용상표의 상품과 동일한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받았다. 양자 간의 관계에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? '05 기출

- ① 甲은 상표법 제34조 제1항 제9호 또는 제12호에 해당됨을 이유로 乙의 등록상표에 대한 무효심판을 청구할 수 있다.
- ② 乙의 상표권이 유효한 권리라 하더라도 甲의 상표사용에 대한 乙의 상표권 행사는 권리남용으로서 甲의 주지상표의 사용은 乙의 상표권에 대한 침해로 되지 않는다.
- ③ 乙이 등록상표를 그 지정상품에 사용함으로써 인하여 甲의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 甲은 乙의 상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제1호에 의거 상표등록을 취소시킬 수 있다.
- ④ 甲이 乙의 등록상표에 상표법 제34조 제1항 제9호를 이유로 무효심판을 청구한 경우 乙의 등록상표의 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 그 해당여부를 따져야 한다.
- ⑤ 상표법 제34조 제1항 제9호(주지상표)를 이유로 乙의 등록상표가 무효확정된 후 그와 동일 또는 유사한 상표가 甲, 乙에 의하여 동일자에 출원된 경우 상표법 제35조의 협의규정이 적용되지 아니할 수 있다.

해설

- ① [○] 제9호에 해당되는 경우 판례가 실시한 제12호 후단 출처혼동에 따른 수요자 기만 요건을 만족하게 된다. 따라서, 제12호 후단의 적용 범위가 너무 넓어짐에 따라 제9호가 사문화된다는 문제 제기가 있다.
 - ② [○] 대법원 1993.01.19. 선고 92도2054 사안으로서 판례는 “상표의 등록이나 상표권의 양수가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표나 상호, 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻음 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다”고 하였다. 참고로 사안에서는 甲이 2007년 개정법상의 선사용권을 주장 할 수도 있다.
 - ③ [x] 제119조 제1항 제1호는 법문의 규정에 따라 등록상표의 유사범위내 사용인 경우에 한하여 적용되고, 등록상표의 전용권 범위내 사용이나 전혀 비유사한 영역에서 사용하는 경우에는 적용되지 않는다는 것이 주류 판례이자 통설적 견해이다. 따라서, 본 지문은 틀린 지문이다.
 - ④ [○] 제34조 제2항
 - ⑤ [○] 乙의 상표는 제34조 제1항 제9호의 거절이유가 있어 제35조 제3항에 따라 선원의 지위가 부정되므로 제35조 제2항의 협의규정이 적용되지 않을 수 있다.
- ※ 본 문제에서는 乙의 등록상표와 甲의 주지상표와의 관계가 명확하게 특정되지 않은 문제가 있다. 출제자는 유사 관계로 전제하고 문제를 낸 것으로 보인다.

정답 ③

76 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호 및 제12호에 대한 설명 중 옳지 않은 것은(다툼이 있는 경우에는 대법원 판례에 의함)?

'05 기출

- ① 상표법 제34조 제1항 제9호는 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 배제하는 것으로서 그 지정상품 또한 타인의 주지상표의 사용상품과 동일·유사한 경우에 적용되는 것이 원칙이다.
- ② 상표법 제34조 제1항 제11호는 타인의 저명상표와 동일·유사한 상표의 등록을 배제하는 것으로서 그 지정상품이 타인의 저명상표의 사용상품과 반드시 동일·유사한 것이어야 하는 것은 아니다.
- ③ 상표법 제34조 제1항 제12호 후단은 특정인의 상표나 상품이라고 인식된 정도에 이르게 된 타인의 상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품이 동일 또는 유사한 경우 그 등록을 배제하는 효력이 있다.
- ④ 지정상품과의 관계에서 기술적인 표장이 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록된 경우에는 그 상표는 상품의 품질오인의 우려를 이유로 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 의하여 무효가 되지 않는다.
- ⑤ 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호 및 제12호 후단은 각각 그 주지·저명성의 정도가 상이하기는 하나 이와 동일한 타인의 상표에 대하여 중복하여 적용될 수도 있다.

해설

- ① [○] 제34조 제1항 제9호
- ② [○] 대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결 [거절결정(상)]
- ③ [○] 이에 더하여 판례는 상품이 비유사하더라도 오인될 만한 특별한 사정이 있다면 적용이 가능하고, 선사용상표가 저명상표인 경우에는 사용상품과 전혀 경제적 건련관계가 없는 상품에 대해서도 수요자 기만의 염려가 있다고 보았다.
- ④ [×] 제33조 제2항에 따라 극복되는 거절이유는 제33조 제1항 각호의 요건이고, 제34조 규정에 따른 등록요건은 별도의 요건으로 판단된다. 이에 따라 판례는 “제33조 제2항의 현저한 인식이 있을 경우에는 같은 법 제34조 제1항 제12호의 품질오인 등의 문제가 생기지 아니한다는 주장은 독자적인 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.”라고 판시하였다.
- ⑤ [○] 타인의 선사용상표의 인식도가 저명까지 이르는 경우에는 제34조 제1항 제9호 내지 제13호가 모두 적용될 수 있다.

정답 ④

77 다음은 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
(법조문에 없는 경우에는 대법원 판례에 의함) '06 기출

- ① 상표법 제34조 제1항 제9호 및 제10호에 규정된 ‘수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표’의 해당 여부에 관한 판단은 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 한다.
- ② 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제21호(조약당사국에 등록된 상표권자와 신의관계가 있는 자가 무단으로 출원한 경우)의 규정에 위반하여 등록된 경우 취소사유가 아닌 무효사유에 해당한다.
- ③ 외국의 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용에 손상을 입히는 경우 상표법 제34조 제1항 제13호 소정의 ‘부정한 목적’에 해당한다고 볼 수 있다.
- ④ 상표법 제34조 제1항 제1호 다목 소정의 ‘저명한 국제기관’에는 이미 소멸된 기관도 포함된다.
- ⑤ 상표법 제34조 제1항 제7호의 규정을 적용하기 위해 지정상품의 유사 여부를 판단하는 경우 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다.

해설

- ① [○] 제34조 제2항
- ② [○] 조약당사국에 등록된 상표권자와 신의관계가 있는 자가 무단으로 출원하여 등록된 경우 2016년 개정 전의 구법에서는 취소사유(舊法 73①7)에 해당하였으나, 현행법에서는 제117조 제1항 소정의 무효 사유에 해당한다.
- ③ [○] 상표심사기준은 i) 외국상표권자의 국내시장 진입저지나 대리점 체결강제 목적, ii) 저명상표의 출처표시기능을 희석화하기 위한 목적, iii) 창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방한 경우[다만, '창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방한 경우'라 하여도 이는 단지 부정한 목적이 있다고 볼 수 있는 사정(또는 부정한 목적이 있는지 여부를 판단할 때의 고려 요소 중 하나)에 불과한 것이지 그 자체로 곧바로 제34조 제1항 제13호에 해당하는 것은 아니므로, 다른 요건을 만족하지 못한 이상 단순히 창작성이 인정되는 타인의 상표를 모방하였다는 이유만으로 본 호가 적용되는 것은 아님에 유의할 필요가 있다.] iv) 타인의 선사용상표의 영업상의 신용이나 고객흡인력 등에 편승하여 부당한 이득을 얻을 목적이 있는 경우 본 호 소정의 부정한 목적이 있는 것으로 보고 있다.
- 이외에 대법원 판례가 부정한 목적을 인정한 사례로는 이하가 있다.
- (스타크래프트 사건) 인용상표 “STARCRAFT(지정상품: 컴퓨터게임소프트웨어)”는 등록상표 “ORION STARCRAFT(지정상품: 건과자, 캔디 등)”의 출원 당시 이미 국내의 일반 수요자들 사이에 저명한 상표로 인식되어 있었으며, 인용상표가 저명한 이상 등록상표의 출원·등록이 인용상표의 식별력을 약화시키는 결과를 가져오고, 그에 따라 등록상표에 제34조 제1항 제13호에 정한 등록무효 사유가 있다(대법원 2005. 6. 9. 선고 2003후649 판결).
- (동서가구 사건) “선사용상표의 공동보유자 중 1인이 선사용상표와 동일·유사한 상표를 출원하여 등록을 받는 것은 나머지 공동보유자가 이를 용인하는 등의 특별한 사정이 없는 한 선사용상표의 공동보유자 중 1인이 등록상표권을 독점하는 불합리한 결과를 초래한다.”고 판시하여, 선사용상표의 공동 보유자 중 1인의 출원을 본 호 소정의 부정한 목적이 있는 것으로 보았다(대법원 2024. 7. 11. 선고 2023후 10446 판결 [거절결정(상)]).
- ④ [×] 등록여부결정시 현존하는 것에 한하여 적용한다(대법원 1998.6.26. 선고 97후1443 판결).
- ⑤ [○] 지정상품의 유사여부를 판단함에 있어 대법원은 일관되게 상품류 구분에 따른 상품의 유사 판단에 대해 법적 구속력을 인정하지 않고 있으며, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다고 판시하고 있다.

정답 ④

78 다음 중 상표법 제34조 제1항 제12호(품질오인 또는 수요자 기만 염려가 있는 상표)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) '07 기출

- ① 대법원 판례에 의하면 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위해서는 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 관련관계가 인정되어야 하므로, 과즙음료 등을 뜻하는 Nectar를 화장품류에 상표로 사용하는 경우에는 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없다.
- ② 출원상표와 동일, 유사한 타인의 상표가 주지·저명하지 아니한 경우에도 출원상표가 본 호의 수요자 기만 염려가 있는 상표에 해당할 수 있다.
- ③ 대법원은 ‘진(Jeans)’이라는 출원상표를 진(Jeans)이 아닌 다른 섬유로 만든 의류에 사용하는 경우에는, 그 의류의 판매시 제공되는 카탈로그에 의류가 어떤 소재의 섬유로 만들어졌는지가 반드시 표기되어 있다고 하더라도 거래 통념상 일반 수요자들은 진(Jeans)으로 만든 의류로 품질을 오인할 가능성이 있는 것으로 판시하고 있다.
- ④ 인용상표의 사용상품 또는 지정상품이 출원상표의 지정상품과 동일 유사한 경우에만 출원상표가 본 호의 수요자 기만 염려가 있는 상표에 해당한다.
- ⑤ 출원상표가 수요자 기만 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단하는 기준시점은 등록여부결정시(상표등록여부결정을 할 때)이고, 본 호에 해당함에도 착오로 등록된 경우에는 무효심판을 청구할 수 있으며 그 청구에는 제척기간의 적용이 없다.

해설

- ① [○] 제34조 제1항 제12호에서 정하고 있는 “상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표”라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계, 예컨대 양자가 동일 계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 한다(NECTAR 사건, 대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결 [거절사정]).
- ② [○] 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조).
- ③ [○] 제34조 제1항 제12호에서 정하고 있는 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 할 것이며, 또한 어떤 상표가 품질오인의 우려가 있는지를 판단함에 있어 그 지정상품과 관련지어 생각하여야 한다는 것은 그 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 관련이 있어야 함을 의미하는 것이지 그 오인우려의 여부를 판단함에 있어 상품의 구성 그 자체뿐 아니라 **상품에 부착되거나 포장용기에 부착된 상품의 설명서 등까지 고려하여 오인여부를 판단하라는 것은 아니다**(JEAN 사건, 대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 [거절사정(상)]).
- ④ [x] 판례는 인용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도, 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보여지는 경우라면 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판시하고 있다(대법원 1997.03.14. 선고 96후412 판결 등 다수).
- ⑤ [○] 제34조 제2항, 제122조

정답 ④

79 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

'08 기출

- ① 파리협약 동맹국의 국기, 문장, 기, 훈장, 포장 및 기장은 파리협약 제6조의3에 따라 세계 지적소유권기구로부터 통지받아 지식재산처장이 지정한 것만을 보호한다.
- ② 상품과 서비스업 간에 동종성이 인정되어 수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는 경우에는 상품에 관한 상표와 서비스에 관한 상표 간에도 상표법 제34조 제1항 제7호가 적용될 수 있다.
- ③ 외국의 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용에 손상을 입히는 경우 상표법 제34조 제1항 제13호 소정의 '부정한 목적'에 해당한다고 볼 수 있다.
- ④ 상표법 제34조 제1항 제9호에 규정된 '수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표'의 해당 여부에 관한 판단은 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 한다.
- ⑤ 상표법 제34조 제1항 제7호의 규정을 적용하기 위해 지정상품의 유사 여부를 판단하는 경우 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다.

해설

- ① [x] 파리협약 동맹국의 문장, 기, 훈장, 포장 및 기장은 파리협약 제6조의3에 따라 세계지적소유권기구로부터 통지받아 지식재산처장이 지정한 것만을 보호하나(法 34①1라목), “국기”는 통지 등이 필요치 않다(法 34①1나목).
- ② [○] 현행법에서는 서비스 역시 상품의 개념으로 일원화되었으나, 구법상 판시된 판례에서 종종 유형적 상품과 서비스를 구분하여 판시한 내용들을 확인할 수 있다. 유형적 상품과 서비스는 동종(유사)성 유무에 따라 유사 여부를 판단한다. 이 경우 동종성이라는 것은 해당 상품이 없으면 해당 서비스가 제공될 수 없을 정도의 밀접한 관련성을 의미한다. 상표는 상품 그 자체를, 서비스에 대한 상표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로 상품과 서비스 사이의 동종·유사성을 지나치게 광범위하게 인정하여서는 아니 되고, 따라서 상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 인정하여야 한다.
- ③ [○] 상표심사기준은 i) 외국상표권자의 국내시장 진입저지나 대리점 체결강제 목적, ii) 저명상표의 출처표시기능을 희석화 하기 위한 목적(스타크래프트 사건), iii) 창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방한 경우, [다만, ‘창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방한 경우’라 하여도 이는 단지 부정한 목적이 있다고 볼 수 있는 사정(또는 부정한 목적이 있는지 여부를 판단할 때의 고려요소 중 하나)에 불과한 것이지 그 자체로 곧바로 제34조 제1항 제13호에 해당하는 것은 아니므로, 다른 요건을 만족하지 못한 이상 단순히 창작성이 인정되는 타인의 상표를 모방하였다는 이유만으로 본호가 적용되는 것은 아님에 유의할 필요가 있다.] iv) 타인의 선사용상표의 영업상의 신용이나 고객흡인력 등에 편승하여 부당한 이득을 얻을 목적이 있는 경우 본호 소정의 부정한 목적이 있는 것으로 보고 있다.
- ④ [○] 제34조 제2항
- ⑤ [○] 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일·유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2008. 4. 24. 선고 2008도1689 판결 [상표법위반]).

정답 ①

80 상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적에 의한 상표등록출원)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

10 기출

- ① 본호는 상표가 외국의 수요자에게 널리 알려졌다면 국내의 수요자에게는 전혀 알려지지 않았더라도 적용 가능하다.
- ② 본호는 상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 주지·저명한 정도로 인식되지 않았더라도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 정도라면 적용 가능하다.
- ③ 본호에서는 상표의 동일·유사성은 명문으로 규정하고 있지만 상품에 대해서는 아무런 제한규정이 없으므로 상표법 제34조 제1항 제9호의 규정을 적용하기 어려운 경우에도 적용될 여지가 있다.
- ④ 본호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당하는지 여부에 대한 판단은 출원시(상표등록출원을 한 때)를 기준으로 한다.
- ⑤ 본호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년을 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다.

해설

- ① [○] 제13호는 모방대상상표(선사용상표)가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다면 적용될 수 있다.
- ② [○] 제13호는 선사용상표가 특정인의 상품 표지로 인식(LEVEL 3) 이상으로만 인식도를 취득하면 적용될 수 있다.
- ③ [○] 제13호는 선사용상표와 동일·유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 대하여 적용하는 규정이므로, 상품의 측면에서는 제한 규정이 없다. 이에 따라, 상표와 상품 모두 동일 또는 유사를 요구하는 제9호가 적용되기 어려운 경우에도 적용될 여지가 있다.
- ④ [○] 제34조 제1항 제11호·제13호·제14호·제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정하되, 상표등록출원인(이하 “출원인”이라 한다)이 제1항의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다(法 34②).
- ⑤ [×] 상표등록의 무효심판 중 제척기간이 있는 것은 제34조 제1항 제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조에 한한다(法 122①).

정답 ⑤

81 甲은 A라는 표장을 가방 및 스포츠용 의류를 지정상품으로 하여 출원하였다. 乙은 甲의 상표등록출원 사실을 모른 채 甲의 출원상표 A와 극히 유사한 표장 A'를 스포츠용 의류에 상표로 사용하던 중 甲의 A 상표가 출원공고 되었다. 이때 甲과 乙에 관한 내용 중 상표법상 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

13 기출

- ① 甲의 상표등록출원이 乙의 상표사용일보다 늦게 출원되었다면, 그 사실만으로 乙은 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) 제1항의 규정에 따라 해당상표를 그 사용상품에 계속하여 사용할 권리를 갖는다.
- ② 乙의 상표사용이 甲의 상표등록출원일 이후에 비로소 시작된 경우라도 乙은 자기의 상표사용을 근거로 상표법 제34조 제1항 제12호(품질의 오인 또는 수요자 기만)의 규정에 의해 甲의 상표등록출원의 등록을 저지할 수 있는 경우가 있다.
- ③ 乙이 A' 상표를 계속 사용한 결과 甲의 상표등록출원의 공고결정 이후에 이르러 수요자들 사이에서 A' 상표가 乙의 상품을 표시하는 식별표지로서 널리 알려졌다면 乙은 甲의 상표등록출원이 상표법 제34조 제1항 제13호(부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려는 등의 부정한 목적)에 해당한다는 이유의 이익신청을 통해 甲의 상표등록을 저지할 수 있다.
- ④ 乙의 A' 상표가 乙의 약칭에 해당하고, 甲이 출원한 A 상표의 등록여부결정시에 乙의 약칭이 저명하게 되면, 乙은 상표법 제34조 제1항 제6호(저명한 타인의 명칭 등)을 이유로 甲의 상표등록을 저지할 수 있다.
- ⑤ 甲은 乙을 상대로 상표등록출원의 공고 후 상표권의 설정등록시까지의 기간에 발생한 당해상표의 사용에 관한 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있다.

- 해설
- ① [x] 특정인의 출처로 인식되어야 하고, 나아가 부정경쟁의 목적도 없어야 하므로 옳지 않은 지문이다.
 - ② [○] 제34조 제1항 제12호는 상표등록여부결정을 할 때(등록여부결정시)를 기준으로 하고 설령 약의 사용인 경우라도 문제 없으므로 옳은 지문이다.
 - ③ [x] 제34조 제1항 제13호는 상표등록출원을 한 때(상표등록출원시)를 기준으로 판단하므로 옳지 않은 지문이다.
 - ④ [△] 2016년 개정법은 제34조 제1항 제6호를 구법과 달리 상표등록여부결정을 할 때(등록여부결정시)를 기준으로 하므로 옳은 지문이다. [다만, 제34조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명 등과 '동일유사한 상표'에 대하여 적용되는 것이 아니라 조문 그대로 저명한 타인의 성명을 '포함하는 상표'에 대하여 적용되는데, 설문의 경우 甲의 A상표는 乙의 저명한 약칭인 A'와 동일하거나 A'를 포함하는 상표가 아닌 단지 '극히 유사'하다고 주어진다는 점에서 (즉, A'를 포함하는 상표라 단정할 수 없으므로) 다툼의 소지가 있다. 그러나, 문제의 조건이 통상의 유사가 아닌 '극히 유사'라고 주어진다는 점, 제34조 제1항 제6호의 판단시점을 묻고자 함이 출제의도라는 점 등에서 甲의 A상표를 乙의 저명한 약칭인 A'와 실질적으로 동일한 상표(즉, 포함하는 상표)로 보아 ④지문도 맞는 지문으로 처리함. 실제 시험이라면 일단 ②를 명백한 정답으로 골라내고, ④는 출제취지에 따라 논란이 있을 수 있음]
 - ⑤ [x] '출원공고 후'가 아니라 '경고 후'이다(法 58②).

정답 ②, ④

82 상표등록요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 15 기출

- ① 보통명칭의 경우 일반소비자들이 지정상품의 보통명칭으로 인식할 우려가 있다는 것만으로는 부족하고, 실제 거래계에서 그 명칭이 특정 상품의 일반명칭으로서 현실적으로 사용되고 있어야 한다.
- ② 자기의 성명·명칭 등을 상표로 출원하는 경우에도 저명한 동일명칭 소유주가 따로 있으면 그 타인의 승낙을 필요로 한다.
- ③ 기존의 상표사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3자의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하여 특정인의 출처표시로 인식된 경우에는 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제12호 적용 시의 인용상표가 될 수 없다.
- ④ 상품과 서비스간에 동종성이 인정되어 수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는 경우에는 상품에 대한 상표와 서비스에 대한 상표 간에도 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호가 적용될 수 있다.
- ⑤ 상품의 형상이 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우라 하더라도 '품질오인의 우려'가 있거나 그 '상품의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만'으로 된 경우에는 상표등록을 받을 수 없다.

해설

- ① [○] 제33조 제1항 제1호 소정의 상표 및 서비스표 등록조각요건에 해당하기 위하여서는 상표나 서비스표의 명칭이 가지는 관념으로부터 유추하여 일반 소비자들이 지정상품의 보통명칭으로 **인식할 우려가 있는 것만으로는 부족**하고 실제거래에 있어서 일반 소비자들이 지정상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통으로 사용하고 있는 사실이 인정되어야 한다(대법원 1987.02.24 선고 86후42 판결). 이와 비교되어야 하는 판례로는, "식물신품종 보호법에 따라 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 제33조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다(화랑 사건, 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314 판결 [거절결정(상)])."가 있다.
- ② [○] 자기의 성명 등이 저명한 타인의 성명과 동일한 경우일지라도 등록을 받기 위하여는 저명한 타인의 승낙을 요한다(法 34①6).
- ③ [×] 제34조 제1항 제12호의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 '객관적인 상태'를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없다(스카발 사건, 대법원 2004.03.11. 선고 2001후3187 판결).
- ④ [○] 상품과 서비스 간에는 상호간에 출처의 오인·혼동을 초래할 정도로 밀접한 관계가 있는지 여부를 따지는 **'동종·유사성(동종성)' 유무로 이를 판단**한다. 이 경우 동종성의 판단에 있어서는 상표는 상품 그 자체를, 서비스에 대한 상표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로 상품과 서비스 사이의 동종·유사성을 지나치게 광범위하게 인정하여서는 아니 되고, 따라서 상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 인정하여야 한다.
- ⑤ [○] 사용에 의한 식별력의 취득에 따라 극복되는 거절이유는 식별력에 관한 제33조 제1항 각호의 거절이유이고, 제34조 제1항 제12호 규정에 따른 품질오인의 염려나 제34조 제1항 제15호 규정에 따른 기능성의 존재 여부와는 무관하다. 따라서, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 제34조 제1항 각호의 규정에 따른 거절이유가 존재한다면 상표등록을 받을 수 없다.

정답 ③

83 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제13호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'22 기출

- ① 본 호에 해당하려면 출원 당시에 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다.
- ② 본 호의 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다.
- ③ 본 호의 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되기 위해서는 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.
- ④ 선사용상표가 양도된 경우 본 호의 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표로 인정되기 위해서는 선사용상표에 관한 주지성이 양수인에게 승계되었거나 양수인이 독자적으로 주지성을 획득해야 하며, 양도 전의 사용실적을 고려할 수는 없다.
- ⑤ 본 호의 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되는지를 결정하기 위해 외국에서의 상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가를 참작할 수 있다.

① [○] 지문④ 해설 참조

② [○] 지문④ 해설 참조

③ [○] 지문④ 해설 참조

④ [x] 최신 판례인 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결(이른바, ‘노단자’ 판결)을 문제화 하였다. 다음 판례 참조: 등록상표가 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. **따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용 실적이 고려될 수 없는 것은 아니다.** 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용 만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용 실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다. 그럼에도 원심은, 상표권이 양도되면서 영업 일체가 함께 이전되지 않으면 제34조 제1항 제13호의 선사용상표가 알려진 정도를 판단할 때 상표권 양도 전의 사용실적이 고려될 수 없다는 전제에서, 노단자회사가 취득한 주지성이 헤이룽지앙 치다에 승계되지 않았고, 헤이룽지앙 치다가 상표권 양수 이후 선사용상표에 관하여 별도로 주지성을 취득하였다고 보기도 어렵다는 이유로, 선사용상표가 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되지 않았다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 제34조 제1항 제13호에서 정한 ‘국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고 이유 주장은 이유 있다.

⑤ [○] 지문④ 해설 참조

정답 ④

제34조 제1항 제15호

84 상표법상 상표의 기능성 원리의 판단기준과 적용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 116 기출

- ① 입체상표로 출원한 상품의 사용에 있어서 그 형상 등으로 인해 상당한 사용상의 효용이 있다고 광고 선전을 하였을 경우 기능성이 있는 것으로 본다.
- ② 소화기에 쓰이는 빨간 색은 소화기의 이용과 목적을 달성하기 위하여 반드시 필요한 것으로서 기능성이 있는 것으로 본다.
- ③ 기능성 원리는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상 등에 적용되므로 상품 자체가 기능적인지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.
- ④ 입체상표에서 해당 기능을 확보할 수 있는 대체 형상이 다수 존재하는 경우에도 입체적 형상 등이 해당 상품의 목적과 이용에 본질적인 것이라면 기능성이 있는 것으로 본다.
- ⑤ 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표는 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 상표 등록을 받을 수 없다.

해설

- ① [○] 입체적 형상 등의 실용적인 이점에 대한 광고·홍보·설명 존재 여부는 기능성 인정에 있어 고려하는 사항에 해당한다(상표심사기준 제5부 제15장 2.2.2).
- ② [○] 색채 및 색채의 조합이 기능성을 가지는 일반적인 예: 소화기에 사용되는 빨간색, 안전표시판에 쓰이는 노란색, 소프트 아이스크림콘의 갈색, 맥주 용기에 사용되는 갈색(상표심사기준 제8부 제2장 예시란).
- ③ [×] 기능성 원리는 상품의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상, 색채 등의 출원상표에 적용이 되는 것으로 '상품 자체'가 기능적인지는 당연히 아무런 상관이 없고, 상표로 출원된 '입체적 형상, 색채, 소리 또는 냄새' 그 자체가 기능적 인지 여부를 따져야 한다.
- ④ [○] 입체상표는 해당 기능을 발휘할 수 있는 대체적 요소가 없거나 그 수가 극히 제한되어 있는 경우에 통상 기능성이 있는 것으로 보나, 대체적 형상이 다수 존재한다 하여도 입체적 형상이 해당 상품의 이용과 목적에 불가결하다면 기능성이 있는 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ [○] 입체상표가 제34조 제1항 제15호에 해당하는 경우라면 실령 제33조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에도 등록될 수 없다. 즉, 자유경쟁의 필요성에 의하여 기능성이론이 식별력에 대하여 우월적으로 작용한다.

정답 ③

제34조 제1항 제20호 및 제21호

85 다음의 상표등록출원에 대한 거절이유 가운데 상표등록출원시를 기준으로 그 적용여부를 판단하는 것은 모두 몇 개인가?

05 기출

- ㄱ. 보통명칭 또는 관용표장에 해당하는 상표
- ㄴ. 현저한 지리적 명칭에 해당하는 상표
- ㄷ. 타인의 선출원에 의한 등록상표와 동일한 상표
- ㄹ. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
- ㅁ. 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표
- ㅂ. 저명한 타인의 성명이나 명칭을 포함하는 상표
- ㅅ. 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로 구성된 상표
- ㅇ. 공익법인의 비영리 업무를 표시하는 저명한 표장과 동일 또는 유사한 상표
- ㅈ. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표
- ㅊ. 계약관계 등을 통하여 타인이 사용 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표

- ① 5개 ② 4개 ③ 3개 ④ 2개 ⑤ 1개

해설 제34조 제1항 각 호는 제34조 제2항에 따라 원칙적으로 '상표등록여부결정을 할 때'를 기준으로 하여 결정하되, 다만, 제34조 제1항 제11호·제13호·제14호·제20호 및 제21호의 경우는 '상표등록출원을 한 때'를 기준으로 하여 결정한다. 따라서, ㄱ.(法 34①11) 및 ㄷ.(法 34①20)가 '상표등록출원을 한 때(상표등록출원시)'를 기준으로 판단하는 등록요건이다. 따라서, 정답은 2개 ④번이다.

정답 ④

86 상표등록출원인의 출원상표가 상표등록을 받을 수 없는 사유에 해당하는지 여부를 지식 재산처 심사관이 판단하는 기준시점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? '19 기출

- ① 저명한 고인(故人)을 비방하는 상표에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.
- ② 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.
- ③ 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.
- ④ 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 상표에 해당하는지 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 판단한다. 다만, 이와 관련하여 타인에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.
- ⑤ 동업관계를 통하여 타인이 사용하는 상표임을 알면서 그 상표와 유사한 상표를 유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

해설

- ① [○] 제34조 제1항 제2호
- ② [○] 제34조 제1항 제4호
- ③ [○] 제34조 제1항 제6호
- ④ [○] 제34조 제1항 제11호
- ⑤ [×] 제34조 제1항 및 상표등록출원인 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 다만, 제34조 제1항 제11호·제13호·제14호·제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정한다(法 34②). 다만, 이 경우에도 주체의 동일성 여부는 등록여부 결정시를 기준으로 한다(法 34②단서).

정답 ⑤

제3절 선출원

35

87 甲은 A 표장에 대해 상표등록출원하였고, 그 이후 A 표장과 유사한 A' 표장을 상표등록출원하였다. 선출원 상표의 지정상품과 후출원 상표의 지정상품은 서로 유사하다. 다음은 선출원 상표와 후출원 상표 간의 관계에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? '05 기출

- ① 후출원 상표등록출원은 선출원 상표등록출원으로 인하여 선출원주의 위반을 이유로 거절되지 않는다.
- ② 선출원 상표가 등록된 상태에서 후출원 상표를 출원하였다면, 후출원 상표등록출원은 선출원 등록상표로 인하여 거절되지 않는다.
- ③ 후출원 상표등록출원을 타인인 乙에게 이전(출원인변경신고)하면, 후출원 상표등록출원은 상표법 제48조 제2항 단서규정(유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다)의 위반을 이유로 거절되지 않는다.
- ④ 상표법 제35조의 적용시점은 출원일이므로 甲이 후출원 상표등록출원 A'를 타인인 乙에게 이전(출원인변경신고)하는 경우에도 乙의 상표등록출원은 甲의 상표등록출원으로 인하여 선출원주의 위반으로 거절되지 않는다.
- ⑤ 후출원 상표등록출원이 등록된 후 타인인 乙에게 이전하는 경우 乙의 상표등록은 甲의 상표등록을 이유로 무효로 되지 않는다.

해설

- ① [○] 동일인간에는 제35조의 적용이 없다.
- ② [○] 동일인간에는 제34조 제1항 제7호의 적용이 없다.
- ③ [○] 제48조 제2항 단서는 유사한 지정상품을 함께 이전하여야 한다는 것으로서, 후출원 상표등록출원을 타인인 乙에게 이전(출원인변경신고)하여도 후출원 상표등록출원이 제48조 제2항 단서규정의 위반을 이유로 거절되지는 않는다.
- ④ [×] 제35조 제1항 및 제2항에의 해당여부는 등록여부결정시를 기준으로 하므로, 甲이 후출원 상표등록출원 A'를 타인인 乙에게 이전(출원인변경신고)하는 경우에는 乙의 상표등록출원은 甲의 상표등록출원으로 인하여 선출원주의 위반으로 거절된다. 따라서, 본 지문은 틀린 지문이다.
- ⑤ [○] 제35조 제1항의 선원주의 위반여부는 당해 상표출원의 상표등록여부결정을 할 때(상표등록여부결정시)를 기준으로 하므로, 후출원 상표등록출원이 등록된 후 타인인 乙에게 이전하는 경우 乙의 상표등록은 甲의 상표등록을 이유로 무효로 되지 않는다.

정답 ④

88 상표법의 '공존동의에 의한 상표등록'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

25 기출

- ① 동일한 지정상품에 사용할 동일한 상표에 대하여 먼저 출원한 자로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우에는 나중에 출원한 자도 상표를 등록받을 수 있다.
- ② 공존동의서는 출원서 또는 의견서에 첨부하여 제출이 가능하다.
- ③ 적법한 공존동의서 제출시 지정상품 일부에 대한 공존동의도 가능하다.
- ④ 지리적 표시 단체표장과 유사한 표장에는 공존동의를 적용하지 않는다.
- ⑤ 업무표장의 출원에는 원칙적으로 공존동의를 적용하지 않는다.

해설

- ① [x] 공존동의의 대상이 되는 후출원은 선출원과 유사범위에 있는 것으로 한한다. 즉, 동일범위의 후출원에 대해서는 선출원인의 동의가 있더라도 중복 등록을 허용하지 않는다(法 35⑥).
- ② [○] 상표심사기준 제5부 제7장 보충기준 1.
- ③ [○] 상표심사기준 제5부 제7장 보충기준 1.
- ④ [○] 상표심사기준 제5부 제7장 보충기준 1.
- ⑤ [○] 상표심사기준 제5부 제7장 보충기준 1.

정답 ①

제4절 상표등록을 받을 수 있는 자 및 없는 자

3

89 상표법상 상표등록을 받을 수 있는 자 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

'26 기출

- ① 증명표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 증명표장과 동일·유사한 표장을 단체표장으로 등록 받을 수 없지만, 업무표장으로 등록받을 수는 있다.
- ② 상품의 품질 등 특성을 증명하고 관리하는 것을 업으로 할 수 있는 자라도 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다.
- ③ 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 판매하는 자만으로 구성된 법인은 직접 사용하기 위한 표장에 대해 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.
- ④ “동음이의어 지리적 표시”란 같은 상품에 대한 지리적 표시가 타인의 지리적 표시와 발음은 같지만, 의미는 다른 지리적 표시를 말한다.
- ⑤ 국내에서 영리를 목적으로 업무를 하는 자는 자기의 업무인 경우에 한하여 업무표장을 등록받을 수 있다.

해설

- ① [x] 증명표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 증명표장과 동일·유사한 표장을 상표·단체표장 또는 업무표장으로 등록을 받을 수 없다(法 3⑤).
- ② [○] 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업으로 할 수 있는 자는 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족하는 것을 증명하는 데 사용하기 위해서만 증명표장을 등록받을 수 있다. 다만, **자기의 영업에 관한 상품**에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다(法 3③단서). 제3조 제3항 단서는 거절이유 및 무효사유에 해당한다. 더하여, 증명표장권자가 제3조 제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우에는 상표등록 취소사유에 해당한다(法 119①9나목).
- ③ [x] "지리적 표시 단체표장"이란 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 **생산·제조 또는 가공하는 자가** 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다(法 2①6). 판매하는 자만으로 구성된 법인은 지리적 표시 단체표장을 등록받을 수 없다. 다만, 생산·제조 또는 가공하는 자가 포함되어 있다면 유통이나 판매자도 해당 법인의 구성원이 되어 지리적 표시 단체표장을 등록받을 수 있다.

	관련 법조문	내용
단체표장	法 2①3, 2①4, 2①6, 3②	(일반 단체표장) 생산·제조·가공·판매, 서비스의 제공 (지리적 표시 단체표장) 생산·제조·가공
지리적 표시	法 2①4	품질·명성 또는 그 밖의 특성
증명표장	法 2①7, 3③	품질·원산지·생산방법 또는 그 밖의 특성

- ④ [x] "동음이의어 지리적 표시"란 같은 상품에 대한 지리적 표시가 타인의 지리적 표시와 발음은 같지만 해당 **지역**이 다른 지리적 표시를 말한다(法 2①5).
- ⑤ [x] 국내에서 영리를 목적으로 **하지 아니하는** 업무를 하는 자는 자기의 업무표장을 등록받을 수 있다(法 3⑥).

(comment) 제2조 및 제3조의 조문을 변형·재구성하여 출제한 유형입니다. 이는 산업재산권 3법에서 반복적으로 출제되는 전형적 패턴이므로, 평소 학습 단계에서 조문 문언을 정확히 암기하고 의미까지 함께 정리해 둘 필요가 있습니다. 예컨대 제2조 제1항 제6호의 '생·제·가'와 같은 두문자를 숙지하지 않으면, 3번 지문의 정오 판단이 곤란합니다.

정답 ②

제3편 출원

주 · 제 · 별

리답상표법 객관식 문제집

제1절 상표등록출원

36

- 90** 상표법 제36조(상표등록출원)에서 상표등록출원서를 제출하면서 제1항 각 호의 사항 외에 첨부하여야 하는 것을 기술한 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

23 기출

- ㄱ. 단체표장등록: 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관
 ㄴ. 증명표장등록: 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 표장에 관한 설명과 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법 그리고 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류
 ㄷ. 지리적 표시 단체표장등록: 대통령령으로 정하는 바에 따라 지리적 표시상품의 생산지를 증명하는 서류
 ㄹ. 업무표장등록: 그 업무의 경영 사실을 증명하는 서류

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

해설 ㉠ [○] 제36조 제3항

㉡ [×] 증명표장등록의 경우 “표장에 관한 설명”을 특별히 요구하지 않는다.

㉢ [×] 지리적 표시 단체표장의 경우 상품의 생산지를 증명하는 서류가 아닌 지리적 표시의 정의에 일치함을 증명하는 서류를 제출해야 한다.

	제36조	시행규칙 상 서식
단체표장	대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관	정관의 요약서 1통
증명표장	1. 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항을 정한 서류(정관 또는 규약) 2. 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류	정관 또는 규약의 요약서 1통
지표단	단체표장 서류 + 지리적 표시 관련 서류(지리적 표시의 정의에 일치함을 증명할 수 있는 서류)	1. 정관의 요약서 1통 2. 지방자치단체장의 확인서류(지리적 표시 합치여부 및 이해관계자간의 이해 조정 사항) 3. 대표성에 관한 서류 (임의)
지표증	증명표장 서류 + 지리적 표시 관련 서류	1. 정관 또는 규약의 요약서 1통 2. 지방자치단체장의 확인서류(지리적 표시 합치여부 및 이해관계자간의 이해 조정 사항) 3. 대표성에 관한 서류(임의)
업무표장	그 업무의 경영사실을 증명하는 서류	업무의 경영사실을 입증하는 서류 1통

㉤ [○] 제36조 제6항

정답 ③

제4편

이익제도

주 · 제 · 별

리담상표법 객관식 문제집

제1절 실체의 보정

40, 41, 42, 43

91 출원공고결정 후의 보정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

'08 기출

- ① 거절이유나 이의신청이유 또는 거절결정의 이유에 나타난 사항에 한하여 최초 출원의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.
- ② 심사관이나 심판관의 거절이유를 통지받은 경우에 위 보정가능기간은 의견서 제출기간 내이다.
- ③ 상표등록이의신청이 있는 경우에 위 보정가능기간은 답변서 제출기간 내이다.
- ④ 거절결정에 대한 불복심판을 청구한 때에는 위 보정가능기간은 심판의 청구일로부터 30일 내이다.
- ⑤ 요지변경임이 간과되어 등록되었음이 상표권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원한 것으로 본다.

해설

- ① [○] 제41조 제1항
- ② [○] 제41조 제1항
- ③ [○] 제41조 제1항
- ④ [○] 제41조 제1항
- ⑤ [×] 상표권 설정등록이 있는 후에 제41조 제1항에 따른 보정(출원공고결정 후의 보정)이 제40조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것(요지변경)으로 인정된 경우에는 그 상표등록출원은 그 보정을 하지 아니하였던 상표등록출원에 관하여 상표권이 설정등록된 것으로 본다(法 41③).

정답 ⑤

제2절 출원의 분할

45

92 '상표등록출원의 분할'과 관련하여 다음 중 그 내용이 옳지 않은 것은?

'06 기출

- ① 상표권의 존속기간갱신등록신청이 2이상의 상품을 지정상품으로 하여 신청된 경우에는 상표법 제40조(출원공고결정 전의 보정)의 규정에 의한 보정기간 이내에 2 이상의 상표권의 존속기간갱신등록신청으로 분할할 수 있다.
- ② 조약에 의한 우선권주장 및 그 증명서류 제출의 경우와 출원시의 특례적용취지의 제출 및 그 증명서류의 제출은 출원일의 소급효를 인정하지 않고 분할출원일을 기준으로 한다.
- ③ 마드리드의정서에 기한 국제상표등록출원에 대해서는 지정상품의 이전이 수반되지 아니한 단순한 출원분할은 허용되지 않는다.
- ④ 원출원의 지정상품이 포괄명칭으로 된 경우 그 명칭을 구체적인 상품으로 분할하는 것은 허용되지 않는다.
- ⑤ 출원분할은 상표법 제40조 및 상표법 제41조(출원공고결정 후의 보정)의 보정이 가능한 기간 내에 할 수 있다.

해설

- ① [x] 구법과 달리 2010년 개정법상으로는 지정상품이 2 이상인 경우에 분할하여 존속기간 갱신등록신청을 할 수 없고, 이미 신청된 존속기간갱신신청을 2 이상의 존속기간갱신신청으로 분할 할 수도 없다(舊法 44 삭제).
- ② [○] 이는 분할출원인이 우선권 주장의 절차를 밟을 수 있도록 하기 위함이다(法 45②).
- ③ [x] 2023년 개정법(2024.05.01. 시행)에 따르면 이전이 수반되지 아니한 국제상표등록출원의 분할도 가능하게 되었다(舊法 200 삭제).
- ④ [x] 포괄명칭으로 기재된 지정상품인 경우에 그 포괄명칭을 세분하여 각각의 상품으로 분할하는 것은 원출원 범위 내로서 허용된다.
- ⑤ [○] 제45조 제1항

정답 ①, ③, ④

제3절 조약에 따른 우선권 주장

46

93 상표법상 조약에 의한 우선권주장에 대한 설명 중 옳은 것은?

07 기출

- ① 2002년 7월 19일 미국지식재산처에 상표등록출원을 하고 2003년 1월 8일 한국지식재산처에 우선권주장을 하여 상표등록출원을 하였다면 우선권증명서류는 늦어도 2003년 2월 8일까지 제출하여야 한다.
- ② 상표등록출원시 상표등록출원서에 우선권주장의 취지와 최초로 출원한 국명 및 출원연월일을 기재하지 못한 경우에도 우선권증명서류 제출기간 내에 우선권증명서류 제출과 동시에 이를 보정할 수 있다.
- ③ 우선권주장의 기초가 된 동맹국 출원이 무효·취하·포기 또는 거절결정이 확정되었다는 이유로 우선권주장의 기초로서의 효력이 상실되는 것은 아니다.
- ④ 조약에 의한 우선권을 주장하여 출원하였으나 우선권증명서류의 제출기간을 초과하여 증명서류를 제출한 경우에는 그 출원은 부적법한 것으로서 그 출원자체가 거절된다.
- ⑤ 상표권의 존속기간갱신등록신청과 지정상품의 추가등록출원에 대하여는 성질상 조약에 의한 우선권을 주장할 수 없다.

해설

- ① [×] 우선권증명서류는 출원일로부터 3월 이내에 제출하면 족하므로 2003년 4월 8일까지 제출하면 된다.
- ② [×] 우선권 주장은 반드시 출원과 동시에 하여야 하고 보정을 통해 주장할 수 없으므로 틀린 지문이다.
- ③ [○] 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원은 출원일이 인정된 정규의 출원이기만 하면 되고, 출원의 무효·취하·포기 또는 거절결정의 확정은 기초출원의 지위에 영향을 미치지 않는다.
- ④ [×] 우선권증명서류의 제출기간을 초과하여 우선권증명서류를 제출하지 못한 경우에는 우선권 주장의 효과만 인정되지 않으며, 2국에서의 실제 출원일을 기준으로 심사한다.
- ⑤ [×] 존속기간갱신신청에 대하여는 우선권 주장이 불가능하나(法 88①), 지정상품추가출원에 대하여는 우선권 주장이 가능하다(法 88②)

정답 ③

94 상표법상 조약에 따른 우선권 주장 등에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? 26 기출

- ㄱ. 상표등록출원 시 우선권 주장을 하지 않았더라도 우선권 주장 기간 내에 출원한 경우에는 추후 출원서를 보정하여 우선권 주장을 할 수 있다.
- ㄴ. 동맹국에서 정식으로 수리되어 출원일이 부여된 정규 출원은 출원이 취하된 경우에도 우선권 주장의 기초 출원이 될 수 있다.
- ㄷ. 국제상표등록출원의 출원인이 우선권 주장을 하는 경우에는 지식재산처장에게 우선권 증명서류를 제출하지 아니하더라도 우선권 주장은 효력을 상실하지 아니한다.
- ㄹ. 우선권 주장을 수반한 상표등록출원을 기초로 하여 분할출원하는 경우 우선권이 인정되기 위해서는 분할출원시 별도로 우선권 주장을 해야 한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

해설

- ㉠ [×] 제46조 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 상표등록출원 시 상표등록출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원 연월일을 적어야 한다(法 46③). 출원 이후에 별도의 보정서를 통해 우선권을 주장할 수 없다.
- ㉡ [○] 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원은 동맹국에서의 정규의 출원으로 인정된 것에 한하며, 정규의 출원이란 출원의 결과여부에 불구하고 당해국에서 정식으로 수리되어 출원일이 부여된 출원을 의미한다(파리협약 제4조(A)(3): 정규의 국내출원이라 함은 출원의 결과여부에 불구하고 당해국에 출원을 한 일부(日附)를 확정하기에 적합한 모든 출원을 의미한다.) 따라서 출원 후 그 출원이 무효·취하·포기 또는 거절결정이 된 경우에도 우선권 주장 기간 내라면 이를 기초로 우선권주장을 할 수 있다.
- ㉢ [○] 국제상표등록출원을 하려는 자가 파리협약에 따른 우선권 주장을 하는 경우에는 제46조 제4항(증명서류의 제출) 및 제5항(증명서류 부제출의 효과)을 적용하지 아니한다(法 188).
- ㉤ [×] 분할의 기초가 된 상표등록출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 상표등록출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 상표등록출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(法 45③).

정답 ③

제4절 출원 시의 특례

47

95 상표법상 기간에 관한 설명으로 옳은 것은?

22 기출

- ① 상표등록을 받을 수 있는 자가 정부가 개최하는 박람회에 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품일부터 12개월 이내에 그 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 그 상표등록출원은 그 출품을 한 때에 출원한 것으로 본다.
- ② 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일부터 3개월 내에 거절이유 등에 해당한다는 것을 이유로 지식재산처장에게 이의신청을 할 수 있다.
- ③ 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음날에 상표권이 소멸된다.
- ④ 상표법 제35조(선출원)에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일로부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다.
- ⑤ 심판에서 심판관의 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 30일 이내에 소명하여야 한다.

해설

- ① [x] 제47조의 출원시 특례의 기간은 박람회 출품일부터 '6개월'이다.
- ② [x] 이의신청 기간은 출원공고일부터 '30일'이다(法 60①).
- ③ [○] 제106조 제1항
- ④ [x] '5년'의 제척기간이 적용된다(法 122).
- ⑤ [x] 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명(疎明)하여야 한다(法 137②).

정답 ③

96 상표법에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

24 기출

- ① 상표법 제92조(타인의 디자인권 등과의 관계)에서 등록상표가 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 저작권자의 동의 없이 그 등록상표를 사용할 수 없기 때문에 저작권자와 관계없는 제3자가 등록된 상표를 무단으로 사용하는 경우에 상표권자는 그 사용금지를 청구할 수 없다.
- ② 상표법 제47조(출원 시의 특례)에 따라 상표등록을 받을 수 있는 자가 조약당사국이 가입된 국제기구가 개최하는 국제박람회에 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품을 한 때에 그 상표등록 출원한 것으로 하기 위해서는 그 취지를 적은 상표등록출원서와 이를 증명할 수 있는 서류를 상표등록출원일로부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ③ 확정된 심결에 대하여 재심을 청구하는 경우에 당사자는 심결 확정 후 재심 사유를 안 날부터 90일 이내에 재심을 청구하여야 한다.
- ④ 상표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자의 상표의 사용권이 제한받게 되지만, 제3자가 그 상표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자는 그 상표권에 기하여 제3자의 상표의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있다.
- ⑤ 상표법상 손실보상청구권은 출원인의 서면경고가 필수이고, 상대방인 제3자에게 이익이 발생한 경우에만 손실에 상당하는 보상금의 지급을 받을 수 있다.

해설

- ① [×] 저촉관계에 있는 상표권이라도 소극적 효력의 행사는 가능하다.
- ② [×] 출원시의 특례의 적용을 받으려는 자는 그 취지를 적은 상표등록출원서를 지식재산처장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 상표등록출원일로부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ③ [×] 재심사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다(法 159①).
- ④ [○] 전용사용권이 설정된 경우 이와 저촉되는 범위 안에서는 상표권자의 사용이 제한된다(적극적 효력의 제한). 다만, 제3자의 무단 사용에 대한 소극적 효력까지 제한되는 것은 아니다.
- ⑤ [×] 제3자의 이익발생 여부와 무관하게 출원인에게 “업무상 손실”이 발생하여야 한다(法 58②).

정답 ④

제5편 심사

주 · 제 · 별

리답상표법 객관식 문제집

제1절 심사 또는 소송 절차의 중지

70

97 상표법상 국내상표등록출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

11 기출

- ① 출원공고 후라도 상표법 소정의 거절이유를 발견한 경우, 심사관은 상표등록거절결정을 할 수 있다.
- ② 심사장은 이의신청이 있는 경우에는 이의신청서 부분(副本)을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 주어야 한다.
- ③ 출원상표에 대한 심사에 있어서 그와 유사하다는 인용상표에 대한 등록무효심결이 대법원에 계속 중인 경우, 심사관은 그 심사절차를 중지하여야 한다.
- ④ 지식재산처장은 상표등록여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다.
- ⑤ 상표등록출원의 상표등록거절결정에 대하여 취소의 심결이 있는 경우로서 해당 상표등록출원에 대하여 이미 출원공고된 사실이 있고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우 심사관은 출원공고결정을 생략할 수 있다.

해설

- ① [○] 제67조 제1항
- ② [○] 제66조 제1항
- ③ [×] 상표등록출원의 심사에서 필요한 경우에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 상표등록출원의 심사절차를 중지할 수 있다(法 70①). 따라서, 출원상표에 대한 심사에 있어서 그와 유사하다는 인용상표에 대한 등록무효심결이 대법원에 계속 중인 경우라도 심사절차를 반드시 중지하여야 하는 것은 아니며, 심사관의 재량사항이다.
- ④ [○] 제69조 제2항
- ⑤ [○] 제57조 제1항 제2호

정답 ③

98 다음 중 상표법상 지정상품별로 할 수 있는 것으로 규정하고 있지 아니한 것은? '02 기출

- ① 상표권자의 부정사용으로 인한 상표등록취소심판
- ② 상표등록출원에 대한 거절결정
- ③ 상표권의 포기
- ④ 상표권의 이전
- ⑤ 상표등록출원의 분할

- 해설**
- ① [x] 제119조 제1항 제1호 규정에 따른 취소심판은 지정상품 전체에 대하여 청구하여야 한다.
 - ② [○] 종래 구법상 상표등록출원에 대한 거절결정은 출원일체의 원칙상 지정상품별로 할 수 없고 출원 전체에 대해 하여야 한다고 규정하고 있었으나, 2023. 02. 04. 시행 개정법은 일부 지정상품에만 거절이 유가 있는 경우에는 해당 상품만 거절결정하도록 하는 부분거절제도를 도입하였다.
 - ③ [○] 상표권자는 상표권에 관하여 지정상품마다 포기할 수 있다(法 101).
 - ④ [○] 상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다(法 93).
 - ⑤ [○] 출원인은 둘 이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 제40조 제1항 각 호 및 제41조 제1항 각 호에서 정한 기간 내에 둘 이상의 상표등록출원으로 분할할 수 있다(法 45①).

정답 ①

99 상표와 관련된 심사 및 심판절차에 관한 다음의 설명 중 옳은 것은?

'06 기출

- ① 상표를 공동으로 출원한 경우 거절결정에 대한 불복심판은 공동출원인 중 1인이 단독으로 청구할 수 있다.
- ② 지정상품이 복수인 상표등록출원에 있어서 일부 지정상품에만 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대하여만 거절결정을 하게 된다.
- ③ 상표등록의 무효심판청구는 누구든지 할 수 있다.
- ④ 상표법 제185조(보정의 특례)에 따른 국제상표등록출원에 대한 출원공고결정 전의 보정은 거절이유의 통지를 받은 때에 한하며 그 보정대상은 지정상품에 한정한다.
- ⑤ 출원인은 상표등록출원을 단체표장등록출원으로 변경할 수 없다.

해설

- ① [x] 공유자 전원이 심판청구인이 되어야 한다(法 124③).
- ② [○] 2023. 02. 04. 시행 개정법은 일부 지정상품에만 거절이유가 있는 경우에는 해당 상품만 거절하는 부분거절제도를 도입하였다.
- ③ [x] 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있다(法 117①).
- ④ [○] 법 제185조 제1항
- ⑤ [x] 변경이 가능하다(法 44).

정답 ②, ④

100 부분거절제도에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

24 기출

- ㄱ. 부분거절제도란 상표등록출원의 지정상품 중 일부에 거절이유가 있는 경우 해당 거절이유가 있는 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 하여 나머지 지정상품에 대하여는 상표등록을 받을 수 있도록 하는 것으로, 이 제도의 도입으로 인하여 해당 상품을 분할출원 하지 않더라도 거절이유 없는 지정상품에 대한 조기등록이 가능하다.
- ㄴ. 상표등록출원의 일부 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 받은 경우에는 그 일부 지정상품에 대하여 재심사청구가 가능하다.
- ㄷ. 일부 지정상품에 거절이유가 있는 경우 거절이유가 없는 지정상품에 대하여 먼저 출원공고결정을 거쳐 상표등록결정을 할 수 있다.
- ㄹ. 부분거절제도는 국제상표등록출원에도 그 적용이 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

해설 ㉠ [×] 지문㉠ 해설 참조

㉠ [○] 제55조의2 제1항 규정에 따르면 “제54조에 따른 상표등록거절결정을 받은 자는 그 결정 등본을 송달받은 날부터 3개월(제17조 제1항에 따라 제116조에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 **해당 상표등록출원에 관한 재심사**를 청구할 수 있다.”고 규정되어 있어, 항상 출원 단위로만 재심사가 수행되는 것이 아닌지에 대한 의문이 있다. 다만, 문제에서 제시된 바와 같이 일부 지정상품에 대해서만 거절결정이 내려진 경우에는 거절결정된 지정상품에 한하여 재심사가 수행될 수 밖에 없다는 점, 제54조에 따른 상표등록거절결정에는 지정상품 전부에 대한 거절결정 뿐만 아니라 일부 지정상품에 대한 거절결정도 포함되어 있다는 점을 고려하면, 부분거절제도의 도입에 따라 일부 지정상품에 대하여 재심사청구가 가능하다고 해석된다.

㉡ [×] 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 출원공고결정을 하여야 하는데, 일부 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대한 거절결정이 확정된 경우에 출원공고결정을 하여야 한다(法 57①). 또한 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 상표등록결정을 하여야 하는데, 일부 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대한 거절결정이 확정된 경우에 상표등록결정을 하여야 한다(法 68). 즉, 일부 지정상품에 거절이유가 있는 경우 거절이유가 없는 지정상품에 대하여 먼저 출원공고결정을 거쳐 상표등록결정을 할 수는 없고, 거절이유가 있는 지정상품에 대하여 거절결정이 확정된 후 비로소 출원공고결정을 거쳐 상표등록결정을 하여야 한다. 따라서 부분거절제도의 도입으로 인하여 거절이유 없는 지정상품에 대한 조기등록이 가능한 것은 아니며, 거절이유가 없는 지정상품의 조기등록을 위하여는 해당 상품을 분할출원하여야 한다.

㉢ [○] 부분거절제도는 국제상표등록출원에도 적용한다.

정답 ⑤

제3절 재심사의 청구

55의 2

101 상표법상 재심사의 청구 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

26 기출

- ① 출원인이 재심사 청구를 하면서 지정상품을 보정한 경우 그 보정이 최초의 상표등록 출원의 요지를 변경하여 부적법한 때에는 심사관은 보정각하 결정을 하여야 한다.
- ② 재심사 청구시 출원인이 의견서를 반드시 제출해야 하는 것은 아니다.
- ③ 지정상품추가등록출원, 존속기간갱신등록신청 및 상품분류전환등록신청에 대한 거절결정에 대해서도 재심사 청구를 할 수 있다.
- ④ 상표등록거절결정에 대한 거절결정불복심판의 청구기간이 상표법 제17조(기간의 연장 등) 제1항에 따라 연장된 경우 그 연장된 기간만큼 재심사 청구의 기간도 연장된다.
- ⑤ 재심사가 유효하게 청구된 경우 그 상표등록출원에 대하여 종전에 이루어진 상표등록거절결정은 취소된 것으로 본다.

해설

- ① [○] 제42조 제1항
- ② [○] 제55조의2 제1항, 재심사청구에 있어 보정은 필수적이지만 의견서의 제출은 필수가 아니다.
- ③ [×] 존속기간갱신등록 신청은 실체심사가 이루어지지 않으므로 재심사 청구 제도가 준용되지 않는다(法 88①). 지정상품추가등록출원과 상품분류전환등록신청은 실체심사가 이루어지므로 재심사 청구가 준용된다(法 88②, 212)
- ④ [○] 제55조의2 제1항 괄호
- ⑤ [○] 제55조의2 제3항

정답 ③

제4절 손실보상청구

58

102 상표등록출원 및 특허출원의 공고 또는 공개의 효과에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

03 기출

- ① 누구든지 상표출원공고일로부터 30일 이내에 상표등록이의신청을 청구할 수 있으며, 특허출원 공개 이후에는 당해 출원에 거절이유가 있다는 취지의 정보제공을 할 수 있다.
- ② 출원공고에 의한 상표법상 손실보상청구권과 출원공개에 의한 특허법상 보상금 청구권은 모두 설정등록 이후라야 행사할 수 있다.
- ③ 손실보상청구권과 보상금청구권을 행사하기 위하여서는 반드시 경고를 하여야 한다.
- ④ 손실보상청구권의 경우에는 출원공고 이전에도 경고할 수 있다.
- ⑤ 손실보상청구권과 보상금청구권은 각각 상표권과 특허권의 행사와는 독립적인 것이다.

해설

- ① [x] 특허 관련 지문은 40회 시험 출제 당시에는 맞는 지문이었으나, 2006년 10월 1일 시행된 개정 특허법은 출원공개 전이라도 출원 계속 중이면 언제든지 정보제공을 할 수 있도록 개정하였으므로 현재는 틀린 지문이 된다.
- ② [○] 제58조 제3항, 특허법 제65조 제3항
- ③ [x] 상표법상의 손실보상청구권은 반드시 서면경고를 하여야 발생한다. 그러나, 특허법상의 보상금청구권은 서면경고가 원칙이나 악의의 사용자에게는 서면경고 없이도 보상금청구권이 발생한다(法 58②, 특허법 65②).

요건	특허디자인	상표
출원공개 / 출원공고	출원공개 필수	출원공고 전이라도 출원의 사본을 제시하여 경고 可
악의	출원공개에 따른 경고를 받거나 or 출원공개된 발명(디자인)임을 안 경우	제58조 제1항에 따른 서면경고 필수
보호범위 이내의 실시 / 사용	특허출원된 발명의 실시 행위 / 디자인등록출원된 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시 행위	동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 행위
인정 기간	경고를 받거나 안 때부터 설정등록할 때까지	경고 후 설정등록할 때까지
손실발생	요건 x	손실 발생이 전제 → 출원인의 사용 要
인정 금액	합리적으로 받을 수 있는 금액	업무상 손실에 상당하는 보상금

- ④ [○] 제58조 제1항 단서. 단, 상표출원서 사본을 제시하여 경고 할 수 있다.
- ⑤ [○] 제58조 제4항, 특허법 제65조 제4항

정답 ①, ③

103 상표법상의 손실보상청구권(상표법 제58조)과 손해배상청구권에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

107 기출

- ① 손실보상청구권은 마드리드의정서의 가입을 대비하여 국제상표등록출원과 국내상표등록출원과의 형평을 유지하기 위하여 상표등록 전에 일정한 보호를 인정한 것이다.
- ② 손실보상청구권은 상표를 사용한 자에게 수익이 발생하였는지 여부를 묻지 않고, 출원인에게 당해 상표의 사용으로 인한 업무상의 손실이 발생하였으면 인정되는 것이다.
- ③ 손실보상청구권과 등록된 상표의 상표권 침해로 인한 금지청구권 및 손해배상청구권 등 상표권에 기한 권리는 각각 별개로 행사가 가능하다.
- ④ 손해액의 추정에 관한 상표법 제110조, 고의의 추정에 관한 상표법 제112조의 규정은 손실보상청구권에는 적용되지 아니한다.
- ⑤ 손실보상청구권은 출원공고 후 상표등록결정시까지 침해된 권리에 대한 보상제도이므로 출원공고 후 서면에 의한 경고를 한 경우에만 상표등록결정이 있는 후에 이를 실제로 행사할 수 있다.

해설

- ① [○] 손실보상청구권은 "국제등록일부터 그 상표가 해당 지정국 관청에 등록된 것과 동일하게 보호를 해야 한다."는 마드리드 의정서의 규정을 준수하기 위해 도입된 제도이다.
- ② [○] 손실보상청구권은 '해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금'을 청구하는 권리이므로 제3자의 사용에 의하여 출원인에게 업무상의 손실이 발생하여야 하고, 이 경우 제3자에게 이익이 발생하였는지 여부는 묻지 않는다.
- ③ [○] 양 권리가 보호하는 시기가 서로 상이하기 때문이다(法 58④)
- ④ [○] 손실보상청구권이 발생되기 위해서는 경고가 필수적이므로 제112조(고의의 추정) 규정이 적용될 여지가 없다.
- ⑤ [×] 손실보상청구권은 '경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간'에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있는 권리를 말하며, 출원공고 전에도 출원서 사본을 함께 제시하여 경고 할 수 있다.

요건	특허·디자인(보상금청구권)	상표(손실보상청구권)
출원공개 / 출원공고	출원공개 필수	출원공고 전이라도 출원의 사본을 제시하여 경고 可
악의	출원공개에 따른 경고를 받거나 or 출원공개된 발명(디자인)임을 안 경우	제58조 제1항에 따른 서면경고 필수
보호범위 이내의 실시 / 사용	특허출원된 발명의 실시 행위 / 디자인등록출원된 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시 행위	동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 행위
인정 기간	경고를 받거나 안 때부터 설정등록할 때까지	경고 후 설정등록할 때까지
손실발생	요건 x	손실 발생이 전제 → 출원인의 사용 要
인정 금액	합리적으로 받을 수 있는 금액	업무상 손실에 상당하는 보상금

정답 ⑤

104 상표법 제58조(손실보상청구권)에 관한 설명으로 옳은 것은?

15 기출

- ① 손실보상청구권은 제3자에게 공시의 의미를 갖는 출원공고가 있는 후에 반드시 서면에 의한 경고를 하여야 발생하며, 출원공고가 있기 전에는 발생할 수 없다.
- ② 출원인은 서면에 의한 경고 후 상표등록 결정등본을 송달받은 날까지의 기간에 대해서만 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있다.
- ③ 지리적 표시 단체표장등록이 된 후에 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단된 것을 이유로 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에 손실보상청구권은 처음부터 발생하지 않는 것으로 본다.
- ④ 손실보상청구권은 상표권의 설정등록일로부터 3년간 행사하지 아니하거나 제3자가 출원 상표를 사용한 날로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다.
- ⑤ 손실보상청구권은 손해배상청구권 및 부당이득반환청구권의 성격을 가진 정지조건부의 준물권적 권리로서 상표권 설정등록이 있는 후가 아니면 행사할 수 없다.

해설

- ① [x] 손실보상청구권은 출원공고 전에도 경고할 수 있으나, 다만 당해 상표등록출원의 사본을 함께 제시하여 서면으로 경고하여야 한다(法 58①).
- ② [x] 손실보상청구권은 '경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간'에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.
- ③ [x] 후발적 무효사유를 이유로 후발적으로 무효확정된 경우에는 손실보상청구권에는 영향이 없다.
- ④ [○] 제58조 제5항
- ⑤ [x] 손실보상청구권은 준물권적 권리가 아니라 상표법이 출원인에게 인정하여 주는 특수한 권리로서의 채권적 권리인 금전적 청구권이다.

정답 ④

105 상표법상 손실보상청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

21 기출

- ① 출원인은 출원공고 후 해당 상표등록출원에 관한 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 해당 상표등록출원에 관한 상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고할 수 있고, 출원인이 해당 상표등록출원의 사본을 제시하는 경우에는 출원공고 전이라도 서면으로 경고할 수 있다.
- ② 상표법 제58조(손실보상청구권) 제 1항에 따라 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정 등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.
- ③ 상표등록출원이 포기·취하·무효가 되거나 상표등록거절결정이 확정된 경우, 손실보상청구권은 처음부터 발생하지 않는 것으로 추정한다.
- ④ 손실보상청구권은 해당 상표등록출원에 대한 상표권의 설정등록 전까지는 행사할 수 없다.
- ⑤ 손실보상청구권을 행사할 때 상표법 제110조(손해액의 추정 등)가 준용되지 않기 때문에 업무상 손실에 관한 사항은 청구권자가 입증하여야 한다.

해설

- ① [○] 제58조
- ② [○] 제58조
- ③ [×] 손실보상청구권은 i) 상표등록출원이 포기·취하 또는 무효가 된 경우, ii) 상표등록출원에 대한 상표등록거절결정이 확정된 경우, iii) 제117조에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다(法 58⑥). 즉, 추정규정이 아닌 간주규정이다.
- ④ [○] 제58조
- ⑤ [○] 제58조

정답 ③

제5절 이의신청

60-66, 71

106 상표법상 상표등록 이의신청 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

26 기출

- ① 상표등록의 이의신청인은 이의신청기간이 지난 후 30일 이내에 그 이의신청서에 적은 이유와 증거를 보정할 수 있다.
- ② 심사관합의체는 이의신청인이 이의신청기간 내에 그 이유나 증거를 제출하지 아니한 때에는 출원인에게 답변서 제출기회를 주지 아니한 경우라도 상표법 제61조(이의신청 이유 등의 보정)에 따른 이의신청 이유 등의 보정기간이 지난 후 결정으로 이의신청을 각하할 수 있다.
- ③ 심사관합의체는 둘 이상의 이의신청이 있는 경우에 그 중 어느 하나의 이의신청이 이유가 있다고 인정할 때에는 다른 이의신청에 대해서는 결정하지 아니할 수 있다.
- ④ 심사관합의체는 이의신청에 관하여 출원인이나 이의신청인이 주장하지 아니한 이유에 관하여도 심사할 수 있으나 이 경우 출원인이나 이의신청인에게 기간을 정하여 그 이유에 관하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ⑤ 지정상품추가등록 이의신청의 이유는 통상의 상표등록 이의신청의 이유와 동일하다.

해설

- ① [○] 제61조
- ② [○] 심사관합의체는 이의신청인이 제60조 제1항에 따른 이의신청기간 내에 그 이유나 증거를 제출하지 아니한 경우에는 제1항에도 불구하고 제61조에 따른 기간이 지난 후 결정으로 이의신청을 각하할 수 있다. 이 경우 그 결정의 등본을 이의신청인에게 송달하여야 한다(法 66④).
- ③ [○] 제65조 제1항
- ④ [○] 제63조
- ⑤ [×] 지정상품추가등록의 이의신청 사유는 통상의 상표등록의 이의신청사유에 더하여 제87조 제1항 제2호 및 제3호의 사유가 추가된다.

정답 ⑤

제6편

상표권

주 · 제 · 별

리담상표법 객관식 문제집

- 효력

- 변동

- 소멸

- 관련제도

제1장 효력

제1절 상표권의 효력

89, 91, 96, 108

107 상표권과 관련된 다음의 설명 중 옳은 것은?

‘06 기출

- ① 상표권자가 지정상품에 관하여 그 등록상표를 독점적으로 사용할 권리 범위와 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 행사하는 금지청구권의 범위는 일치한다.
- ② 상표권의 침해행위로 인하여 생긴 상품이 그 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표가 분리되는 경우에는 그 상품을 몰수하지 아니할 수 있다.
- ③ 상표권자는 상표권에 관하여 지정상품마다 이를 포기할 수 없다.
- ④ 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 등록단체표장과 동일 또는 유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권을 독점적으로 사용할 수 있는 상표권자·전용사용권자만이 그 등록상표를 지정상품에 사용하는 경우에 한하여 그 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록 후 상표등록출원일부터 10년이다.

해설

- ① [x] 상표권의 효력은 독점적 사용권의 경우 동일성 범위, 금지권의 경우 동일·유사범위까지 효력이 미친다. 따라서 독점적 사용권과 금지권의 범위가 일치하지 않는다.
- ② [○] 제236조 제2항
- ③ [x] 지정상품마다 포기할 수 있다(法 101).
- ④ [x] 통상사용권자도 포함된다(法 90②4).
- ⑤ [x] 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년이다(法 83①).

정답 ②

108 다음은 상표권의 효력에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

107 기출

- ① 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 다만, 적법하게 등록된 후에 당해 등록상표가 그 지정상품에 대하여 보통명칭화된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 입체상표로서 등록되었다고 하더라도 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ③ 지리적 표시 단체표장으로 등록된 경우에는 지정상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표에 대해서는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.
- ④ 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도, 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.
- ⑤ 서적류의 제호는 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용표장과 같은 성격을 가지므로 원칙적으로 상표권의 효력이 미치지 아니하나 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있으므로, 그러한 경우에도 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다.

해설

- ① [x] 적법하게 등록 후 보통명칭화 된 경우에도 당연히 제90조에 의하여 효력이 제한되며, 나아가 후발적 무효심판의 대상이 된다. 보통명칭화 되었다면 식별력을 상실한 것이기 때문이다.
- ② [○] 제90조 제1항 제5호
- ③ [○] 제90조 제2항 제2호
- ④ [○] 후지필름 사건, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 [상표법위반·부경법위반]
- ⑤ [○] 영절하 사건, 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결 [가처분이의]

정답 ①

109 상표권 침해에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 108 기출

- ① 지리적 표시 단체표장의 경우에 그 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 유사상품에 사용하는 경우에는 침해가 성립하지 않는다.
- ② 심결확정에 의하여 무효로 된 타인의 상표권이 재심에 의하여 회복된 경우, 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 해당 등록상표를 사용한 때에도 상표권의 침해행위가 성립되는 경우가 있다.
- ③ 수출업자가 작성·서명하여 외국환은행을 통하여 환어음 및 다른 선적서류와 함께 수입업자에게 보내지는 수출송장에 대하여 타인의 등록상표의 지정상품에 해당하는 제품에 그 등록상표를 사용한 경우라도 이것이 국내의 유통과정에 놓여지는 상품에 사용한 것이 아니기 때문에 침해가 성립되지 않는다.
- ④ 상표가 상품의 출처를 표시하는 등 상표의 본질적 기능을 발휘하는 태양으로 사용되지 아니하고 단지 장식적으로 사용된 경우에는 상표권 침해가 성립하지 않는다.
- ⑤ 서적의 제호로서 사용하는 경우에는 그것이 저작권법에 저촉되지 않는 한 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭, 관용표장과 같은 성격을 가지는 것이므로 여기에는 상표권의 효력이 미치지 않는다.

해설

- ① [○] 지리적 표시 단체표장권의 효력을 동일·유사한 상표를 **동일하다고 인정되는 상품**에 사용하는 범위에 한하여 미친다(法 108②1).
- ② [○] 선의(善意)가 아닌 사용에는 상표권의 효력이 미친다(法 160).
- ③ [×] 제2조 제1항 제11호 나목은 “상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위”를, 제2조 제1항 제11호 라목은 “상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위”를 상표의 사용으로 규정하고 있으므로, 수출업자가 수입업자에게 보내는 수출송장에 대하여 타인 등록상표의 지정상품에 해당하는 제품에 그 등록상표를 사용한 경우라면 국내 유통과정에 놓여지는 상품에 사용한 것이 아니라도 침해가 성립된다.
- ④ [○] 상표권의 침해가 성립하기 위해서는 상표법상 상표의 사용이 있어야 하는데, 상표의 사용이란 제2조 제1항 제11호 각목에 해당하는 사용행위에 더하여 상표의 본질적 기능(출처표시기능, 자타상품식별기능)이 발휘되는 사용이어야 한다. 따라서 설명문구로서의 사용, 순전한 디자인적 사용 등은 출처표시로서 사용된 것이 아니므로 상표법상 침해가 성립하지 않는다.
- ⑤ [○] 녹정기 사건, 대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결 [가처분이의]

정답 ③

- 110** 상A는 의류브랜드로 유명한 타인의 등록상표 “BRIN”에 대한 위조 상품을 제조하기로 마음먹고 다음과 같이 이를 실행하였다. 우선, A는 의류 라벨 전문제조업자인 B에게 “BRIN” 라벨을 제조하여 공급해달라는 요청을 하였고, B는 A가 위조상품에 사용하려는 사실을 알고도 A의 요청대로 “BRIN”라벨 500개를 제조하여 A에게 교부하였다. A는 B가 만든 “BRIN”라벨을 C 및 D에게 전달하였고, 이 때 C는 A로부터 전달받은 “BRIN”라벨을 의류에 사용하게 할 목적으로 판매하였으며, D는 A로부터 받은 “BRIN”라벨을 이용하여 위조상품을 제조하였다. A는 완성된 위조 상품을 D로부터 인도받아 의류 판매업자인 E에게 전량 판매하였고, E는 이 제품을 자신의 매장에서 일반소비자를 상대로 판매하였다. E는 위조상품을 판매하고 남은 재고 일체를 해외 바이어(buyer)인 F에게 팔았으며, F는 이를 자신의 본국에 수출하였다. 위 침해 행위 중에서 같은 유형의 상표권 침해를 한 자들은?

'12 기출

- ① B, C ② B, D ③ C, D ④ C, E ⑤ C, F

해설

본문제는 간접침해와 직접침해를 구별하는 문제로 B 및 C의 행위는 제108조 제1항 제2호 소정의 ‘간접침해’에 해당하고 D, E, F의 행위는 ‘직접침해’에 해당한다. 한편, A는 직접침해뿐 아니라 간접침해행위도 하고 있으므로, A의 행위는 직접침해 및 간접침해 모두에 해당한다.

정답 ①

111 상표권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 13 기출

- ① 상표등록출원일 전에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권이 만료되는 때에 원특허권의 범위 안에서 상표를 사용할 권리를 가지는 원특허권자는 상표권자 또는 전용사용권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
- ② 상표권이 저작권과 저촉되는 경우에 상표권자가 저작권자로부터 동의를 받지 아니하고 등록상표와 동일성 범주 내의 상표를 사용한 것은 상표법 제119조 제1항 제3호(불사용으로 인한 취소심판)에 있어서 상표의 '정당한 사용'에 해당한다.
- ③ 상표법 제33조 제2항(사용에 의한 식별력)에 의하여 식별력을 취득한 상표는 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다.
- ④ 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ 상표권자 또는 전용사용권자는 특허권의 존속기간 만료 후에 상표를 사용할 권리를 갖게 된 자에게 그 자의 업무에 관한 상품과 자기 업무에 관한 상품 간에 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 청구할 수 있다.

해설

- ① [×] 제98조 제3항, 원특허권자는 대가를 지급할 필요가 없다.
- ② [○] CROCO KIDS 사건, 대법원 2001.11.27. 선고 98후2962 판결. 즉, 저작권 위반의 사용행위도 불사용취소심판에서의 정당한 사용으로 보겠다는 취지이다. 이는 불사용취소심판은 불사용 그 자체에 대한 제재 성격을 가지고 있음을 고려한 것이다.
- ③ [○] 새우깡 사건, 대법원 1992. 5. 12. 선고 88후974,88후981,88후998 판결 [권리범위확인(상)]
- ④ [○] 제90조 제1항 제5호
- ⑤ [○] 제98조 제4항

정답 ①

112 영화제작자 甲은 제작·흥행에 성공한 만화영화 주인공 캐릭터를 상표로 사용하기 전에 그 캐릭터 도형을 문방구류의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 후, 제3자인 乙이 거의 동일한 캐릭터를 甲의 출원과 동일 또는 유사한 지정상품에 선출원한 사실을 확인하였다. 사안에 대한 설명으로 옳은 것은? (식별력은 문제 삼지 않으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

16 기출

- ① 乙의 상표등록출원이 거절결정이 확정되더라도 선출원의 지위가 유지되므로 甲의 출원은 乙의 선출원으로 인하여 등록받을 수 없다.
- ② 상표법에는 영화제작자로서 甲이 정보제공이나 이의신청을 통하여 乙의 등록을 저지할 수 있는 법적 근거가 있다.
- ③ 甲은 캐릭터에 대한 주지·저명상표의 권리자로서 乙의 출원에 대한 상표등록을 저지할 수 있다.
- ④ 乙이 상표등록을 받는다면 乙은 甲의 저작권과 저촉되는지 여부와 관계없이 甲의 동의를 얻지 아니하고 정당하게 그 등록상표를 사용할 수 있다.
- ⑤ 乙이 상표등록을 받는다면 乙이 甲의 동의를 받지 않고 등록상표를 사용하여도 상표의 정당한 사용이 아니라고 할 수 없으므로 불사용취소심판에 의해 등록이 취소될 수 없다.

해설

- ① [x] 乙의 상표등록출원이 거절결정이 확정되면 제35조 제3항의 규정에 따라 선출원의 지위를 상실하고, 따라서, 다른 거절이유가 없는 한 甲은 등록이 가능하다.
- ② [x] 상표법에는 타인의 저명한 캐릭터를 무단으로 상표로 출원한 경우에 대한 명시적 거절이유 등이 존재하지 않는다. 이와 비교하여 상표심사기준은 “널리 알려진 방송프로그램이나 명칭, 영화나 노래 제목, 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭 등과 동일·유사한 상표를 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우”를 제34조 제1항 제12호 후단의 순수한 수요자 기만의 일 유형으로 보고 있다. 다만, 이는 판례로 정립된 법리는 아니며 특허법원의 판시 중에는 저명한 저작물의 저작권 위반 사례의 경우에 상표등록을 허용한 경우가 있다(특허법원 2003. 5. 1. 선고 2002허6664, 6671 판결(확정)).
- ③ [x] 설문의 경우 甲의 캐릭터는 상품출처로 알려진 것이 아니므로, 주자저명한 상표라 볼 수 없고, 따라서 甲이 캐릭터에 대한 주자저명상표의 권리자로서 乙의 출원의 등록을 저지할 수 있는 것은 아니다.
- ④ [x] 甲의 저작권과 저촉되는 경우에 한하여 甲의 동의를 요한다(法 92①).
- ⑤ [○] 판례는 일관하여 등록상표의 사용이 타인의 저작권을 침해하는 경우일지라도 불사용으로 인한 상표등록취소의 요건과 관련하여서는 상표의 정당한 사용으로 해석하고 있다(CROCO KIDS 사건, 대법원 2001.11.27. 선고 98후2962 판결).

정답 ⑤

- 113** 다음 행위 중 상표법상 상표권 침해에 해당하지 않는 경우를 모두 고른 것은? (단, 국내에 유효한 타인의 등록상표가 존속하고 있고 국내 상표권자인 타인은 외국 상표권자와 동일인으로 볼 수 없으며, 다통이 있으면 판례에 따름)

16 기출

- ㄱ. 자동차부품 제조업자가 허락 없이 부품 포장상자에 부품이 사용되는 차종을 밝히기 위하여 완성차 제조회사의 등록상표를 표시한 경우
- ㄴ. 타인의 저명상표와 유사한 상표를 허락 없이 비유사 상품에 사용한 경우
- ㄷ. 타인의 등록상표가 인쇄된 트럼프 카드를 구입한 후 특수요리로 처리하여 육안으로 식별하기 불가능하게 한 후 유통시킨 경우
- ㄹ. 진정상품을 일본국 내에서만 판매하기로 한 약정을 위반하여 일본의 수입업자가 대한민국으로 수출하여 유통시킨 경우
- ㅁ. 타인의 등록상표가 각인된 일회용 카메라 용기를 재활용하여 새로운 필름을 장착한 후 그 등록상표를 가리지 않은 상태에서 자신의 상표를 붙인 포장지로 감싼 후 판매하는 경우

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

- ㉠. [침해 x] 설명적 문구에 불과하여 상표적 사용이 아니므로 침해가 아니다(대법원 2001.7.13. 선고 2001도1355 판결 : ‘자동차, 자동차용 에어클리너’ 등을 지정상품으로 한 타인의 등록상표인 ‘소나타’라는 표장을 자신이 제조한 ‘에어클리너’의 포장에 자신의 상표인 ‘신일 E. N. G.’라는 표장과 함께 [적용차종 : 소나타]와 같이 표시한 경우에 있어서, “에어클리너의 출처표시가 명백하고 부품 등의 용도 설명 등을 위하여 사용한 것”이라는 이유로 상표권 침해를 부정함)
- ㉡. [침해 x] 저명상표의 경우도 상표권 침해는 상표와 상품의 동일·유사범위에 한하므로 비유사한 상품에 사용한 이상 침해가 아니다.
- ㉢. [침해 x] 대법원 2009.10.15. 선고 2009도3929 판결 : 타인의 등록상표가 인쇄된 트럼프 카드를 구입한 후 그 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하여 색약보정용 콘택트렌즈 또는 적외선 필터를 사용하면 식별할 수 있지만 육안으로는 식별이 불가능한 카드를 제조·판매한 경우 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하였다 하더라도 육안으로는 그 무늬와 숫자를 식별하기 불가능하여 이를 특수한 목적을 가진 사람이 특수한 방법으로 사용하지 않는 이상 여전히 그 본래의 용도대로 사용될 수 있고, 이 사건 카드를 다시 사용·양도 또는 판매하는 경우에도 이를 알고서 취득하는 수요자로서는 그 원래 상품의 출처를 혼동할 염려가 없으며 이를 모르고 취득하는 수요자들로서도 상표권자가 제조한 그대로의 상품을 취득한 것으로 인식하여 그 본래의 기능에 따라 사용하게 될 것이므로, 피고인들의 위와 같은 이 사건 카드 제조·판매행위를 가리켜 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공·수선이라고 하거나 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 침해하였다고 하기 어렵다(상표권 침해 부정).
- ㉣. [침해 ○] ‘진정상품병행수입의 요건을 만족하였다면’ 판매지 제한 약정에 위반하여 수입·유통된 경우에도 상표권 침해에 해당하지 않는다(대법원 2005.6.9. 선고 2002다61965 판결). 다만, 이는 진정상품병행수입의 요건을 만족한 경우라야 하는데, 본 문제의 경우 문제의 단서에 ‘국내 상표권자인 타인은 외국상표권자와 동일인으로 볼 수 없다.’는 조건이 주어졌다는 점에서 특별한 사정이 없는 한 병행수입이 허용되는 경우가 아니고 따라서 침해에 해당한다.
- ㉤. [침해 ○] 이른바 ‘후지필름 사건’으로 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 본 지문과 같이 일회용 카메라에 새로운 필름을 장착하여 유통시킨 경우에는 권리소진이론이 적용되지 않는 경우로 상표권 침해에 해당한다. 따라서, 침해에 해당하지 않는 경우는 ‘㉠, ㉡, ㉢’이다.

정답 ①

114 甲은 X상표를 a상품에 대하여 2010년경부터 사용하기 시작하여 현재까지도 사용하고 있다. 한편, 乙은 甲의 X상표와 유사한 X'상표를 a상품과 유사한 a'상품에 대하여 2016년 6월 15일에 출원하여 2016년 12월 1일에 출원공고 되고 2017년 2월 20일에 등록되었다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

17 기출

- ① 甲이 乙의 X'상표등록출원에 대하여 이의신청을 제기하였을 경우 지식재산처장은 직권으로 이의신청이유 등의 보정기간을 30일 이내에서 한 차례 연장할 수 있으며, 甲이 교통이 불편한 지역에 있는 자에 해당하는 경우 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.
- ② 甲이 사용 중이던 X상표를 a상품에 대하여 상표등록출원한 시점이 乙의 X'상표등록 후 그 무효심결확정 전이라 하더라도 甲의 X상표등록출원이 등록될 수도 있다.
- ③ 乙이 제기한 적극적 권리범위 확인심판에서 甲에게 상표법 제99조 제1항의 선사용권이 인정되는 경우라도 그 선사용권의 존재가 적법한 항변사유가 될 수 없다.
- ④ 甲에게 상표법 제99조 제1항의 선사용권이 인정되면 그 선사용권은 甲의 지위를 승계한 자에게도 그대로 인정된다.
- ⑤ 甲의 X상표가 사용에 의하여 수요자들에게 특정인의 상표로 알려지기 시작한 시기가 乙의 X'상표등록출원의 등록여부결정시 이후라면 乙의 상표등록 이후 甲의 X상표 사용은 乙의 상표권행사에 의해 저지될 수 있다.

해설

- ① [×] 본 문제에서 乙의 X'상표의 출원일은 2016. 6. 15. 로 2016년 개정법 시행일(2016. 9. 1.) 전의 출원이므로 2016년 개정법 부칙 제2조에 따라 '2016년 개정 전의 구법'이 적용되어야 한다. 한편, ① 지문은 2016년 개정법이 적용되는 경우라면 옳은 지문이다. 그러나 위와 같이 乙의 출원에는 2016년 개정 전의 구법이 적용되어야 하는데, 2016년 개정 전의 구법은 제5조의14(기간의 연장 등) 제1항에서 단순히 "지식재산처장 또는 특허심판원장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 청구에 따라 또는 직권으로 상표등록이의신청이유 등의 보정기간, 거절결정불복심판 또는 보정각하불복심판의 청구기간을 연장할 수 있다."라고만 규정하고 있었으므로 본 지문은 옳지 않은 지문이다.
- ② [○] 甲이 비록 乙의 X'상표등록 후 그 무효심결 확정전에 X상표를 출원하였다 하여도 甲의 X상표 출원에 대한 등록여부결정시 전에 乙의 상표등록이 무효확정된다면 乙의 상표등록은 처음부터 없는 것이 되어 甲의 X상표 출원은 등록이 될 수도 있다. 참고로, 지문의 해결과는 무관하나 乙의 X'상표등록(2017. 2. 20.) 이후 甲이 X상표를 출원하였다면, 시기상 甲의 출원에는 2016년 개정법이 적용된다.
- ③ [○] 권리범위 확인심판에서는 선사용권을 판단하지 않는다.
- ④ [○] 제99조 제1항의 선사용권은 그 지위를 승계한 자를 포함한다.
- ⑤ [○] 지문과 같은 경우라면 甲은 선사용권자에 해당하지 않고 나아가 甲에 대한 乙의 권리행사가 권리남용에 해당되지 않을 수 있으므로(단, 이는 구체적 사안별로 달리볼 여지는 있음) 결국 甲의 X상표 사용은 乙의 상표권 행사에 의해 저지될 수 있다. 따라서, 옳은 지문이다.

정답 ①

115 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

17 기출

- ㄱ. 甲의 상표(X)가 정당하게 출원·등록된 후 제3자인 乙이 甲의 등록상표(X)와 동일·유사한 상표(Y)를 정당한 이유 없이 사용한 결과 사용상표(Y)가 주지성을 획득하더라도 상표권자(甲)가 상표사용자(乙)를 상대로 등록상표(X)의 상표권에 기초한 침해금지를 청구하는 것은 권리남용에 해당하지 아니한다.
- ㄴ. 진정상품병행수입업자가 타인의 등록상표가 표시된 진정상품인 화장품을 보다 작은 용량의 용기에 재병입하면서 그 용기에 임의로 제작한 그 등록상표를 표시하여 판매하는 경우에는 상표권의 침해를 구성하지 아니한다.
- ㄷ. 상표권의 침해가 계속적으로 행하여지는 경우 상표권의 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 최종 손해를 안 때부터 일괄적으로 진행된다.
- ㄹ. 丙의 X 상표가 정당하게 출원·등록된 후 丙이 X 상표와 동일·유사한 포장 및 지정상품에 대해 출원·등록(Y 상표)한 경우, X 상표와 동일·유사한 상표로서 X 상표의 등록 이후부터 사용되어 온 결과 Y 상표의 등록결정 당시 丁의 상표로 인식된 Z 상표와의 관계에서, Z 상표와 유사한 Y 상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하여 등록이 무효로 될 수 있다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. [○] 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해 금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다(KATANA GOLF 사건, 대법원 2014.8.20. 선고 2012다6035 판결). 따라서, 옳은 지문이다.
- ㄴ. [×] 상표권자 내지 정당한 사용권자(이하 '상표권자 등'이라고 한다)에 의해 등록상표가 표시된 상품이 양수 또는 수입한 자가 임의로 그 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 그 등록상표를 표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 양도하였다면 비록 그 내용물이 상표권자 등의 제품이라 하더라도 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해칠 염려가 있으므로, 이러한 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 내지 전용사용권을 침해하는 행위에 해당한다(SUPER TEMPRA 사건, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011도17524 판결). 따라서, 틀린 지문이다.
- ㄷ. [×] 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해이므로, 민법 제766조 제1항에서 정한 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 그 각 손해를 안 때부터 각별로 진행된다고 보아야 한다(KATANA GOLF 사건, 대법원 2014.8.20. 선고 2012다6035 판결). 따라서, 틀린 지문이다.
- ㄹ. [○] 선행 등록상표의 등록 이후에 등록결정이 된 후행 등록상표가 선행 등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하고, 또한 후행 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표라고 인식된 타인의 상표가 선행 등록상표의 등록 이후부터 사용되어 온 것이라고 하더라도, 이러한 타인의 사용상표와의 관계에서 후행 등록상표가 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하여 그 등록이 무효로 될 수 있다(KATANA GOLF 사건, 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6035 판결). 따라서, 옳은 지문이다.

정답 ②

116 상표법에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

18 기출

- ① 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다.
- ② 업무표장이란 국내 및 국외에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장이다.
- ③ 상품의 품질오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없는데 상품의 품질오인이란 상품의 품질에 관한 오인을 말하는 것이지, 상품자체를 오인하게 하는 경우는 포함되지 않는다.
- ④ 등록상표임을 표시한 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
- ⑤ 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다.

해설

- ① [x] 두 개의 상표를 나란히 놓고 대비하는 ‘대비관찰’은 허용되지 않는다.
- ② [x] 제3조 제6항의 해석상 업무표장이란 ‘국내에서’ 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장을 말한다.
- ③ [x] 상품 자체의 오인도 포함한다.
- ④ [x] 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정하므로(法 112), ‘고의’를 추정한다(法 112). 또한, 대법원은 상표권 침해시 상표권자가 ‘등록상표임을 표시하였는지 여부와 무관’하게 침해자에게 그 침해행위에 대한 ‘과실’이 있는 것으로 추정한다(남선알루미늄 사건, 대법원 2013.7.25. 선고 2013다21666 판결) 따라서, 어느 관점으로 보나 옳지 않은 지문이다.
- ⑤ [○] 페라가모 사건, 대법원 2008.10.9. 선고 2007후2834 판결 등

정답 ⑤

117 다음 중 상표법 제89조(상표권의 효력)에 규정된 상표권자의 독점할 권리의 범위를 침해하는 것은 모두 몇 개인가? (단, 다음의 행위들은 정당한 권원이 없는 것으로 간주함) 20 기출

- 타인의 등록상표와 동일한 상표가 표시된 지정상품과 동일한 상품을 양도하기 위하여 소지하는 행위
- 타인의 등록상표와 동일한 상표가 표시된 지정상품과 유사한 상품을 인도하기 위하여 소지하는 행위
- 타인의 등록상표와 동일한 상표가 표시된 지정상품과 동일한 상품을 양도 목적으로 전시하는 행위
- 타인의 등록상표와 동일한 상표가 표시된 지정상품과 동일한 상품을 인도 목적으로 수입하는 행위
- 타인의 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품의 포장에 표시한 것을 양도한 경우

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

해설 본 문제는 상표권의 독점적 범위와 배타적 범위, 직접침해와 간접침해(침해로 보는 행위)를 구분할 수 있는지를 묻는 문제로 일단 앞의 2개는 제108조 제1항 제4호 소정의 간접침해이고, 그 뒤 나머지 3개는 제2조 제1항 제11호 나목 소정의 상표의 사용행위로 직접침해에 해당한다. 한편, 문제에서는 제89조(상표권의 효력)에 규정된 상표권자의 독점권을 침해하는 행위가 무엇인지를 묻고 있는데, 상표권자의 독점권은 동일범위에 한한다는 점에서 **동일범위의 직접 침해**행위에 해당하는 뒤의 3개가 답이 될 수 있다. 따라서 정답은 3개이다.

정답 ③

118 상표권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

21 기출

- ① 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록절차의 이행을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있으면 상표권에 관한 이전등록절차 이행청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다.
- ② 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고, 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.
- ③ 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 상표권은 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 합리적으로 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.
- ⑤ 상표권의 행사가 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 그 상표권의 행사는 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

해설

- ① [×] 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다(KT 사건, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다71964 판결).
- ② [○] 남선알루미늄 사건, 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결.
- ③ [○] 제110조 제4항, 2020. 10. 20. 시행 개정법은 상표권 사용료 산정기준을 “통상적으로” 받을 수 있는 금액에서 “합리적으로” 받을 수 있는 금액으로 변경하였다.
- ④ [○] 크라운진 사건, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712·59729(병합) 판결.
- ⑤ [○] 진한커피 사건, 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결.

정답 ①

119 상표법상 표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

'22 기출

- ① 상표권자는 상표법 제98조(특허권 등의 존속기간 만료 후 상표를 사용하는 권리)에 따라 상표를 사용할 권리를 가진 자에게 그 자의 업무에 관한 상품과 자기의 업무에 관한 상품 간에 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 청구할 수 있다.
- ② 상표권자는 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 수 있는 권리) 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.
- ③ 상표법 제223조(동음이의어 지리적 표시 등록단체표장의 표시)에 따라 둘 이상의 지리적 표시 등록단체표장이 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 경우 각 단체표장권자와 그 소속 단체원은 지리적 출처에 대하여 수요자가 혼동하지 아니하도록 하는 표시를 등록 단체표장과 함께 사용하여야 한다.
- ④ 상표법 제223조(동음이의어 지리적 표시 등록단체표장의 표시)를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ⑤ 누구든지 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 상품에 표시하는 행위를 해서는 아니 되며, 이를 위반시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

해설

- ① [○] 제98조 제4항
- ② [○] 제99조 제3항, 단, 제99조 제2항의 이른바 '영세상인을 위한 성명·상호 등의 선사용권'에 대하여는 혼동방지청구권이 인정되지 않음에 주의한다.
- ③ [○] 제223조, 즉, 각 단체표장권자와 그 소속 단체원 모두 혼동방지표시를 하여야 한다.
- ④ [×] 상표법은 제223조에서 “둘 이상의 지리적 표시 등록단체표장이 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 경우 각 단체표장권자와 그 소속 단체원은 지리적 출처에 대하여 수요자가 혼동하지 아니하도록 하는 표시를 등록단체표장과 함께 사용하여야 한다.”라고 규정하여 각각 등록 후 사용 시 일반 수요자의 혼동을 초래하지 않도록 하고 있으며, 이를 위반하여 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 지리적 출처에 대한 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 지리적 표시 단체표장권의 취소사유로 규정하고 있다(法 119조 제1항 제8호 나목). 즉, 지리적 표시 단체표장권의 취소사유인 것이지 형사처벌의 대상이 아니다.
- ⑤ [○] 제233조의 거짓 표시의 죄에 해당하며, 거짓 표시의 죄는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

정답 ④

120 상표권 침해 쟁송절차 및 침해여부 판단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'22 기출

- ① 후행 등록상표인 침해상표가 일반수요자에게 인식되어 있어 역혼동이 발생하는 경우에 침해상표에 대한 인식만을 근거로 하여서도 그 상표 사용자를 상대로 한 선행 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 권리남용에 해당한다고 볼 수 있다.
- ② 상표권 침해소송에서 등록상표에 명백한 무효사유가 있어 그 상표권의 행사가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 법원은 그 당부를 살피기 위한 전제로 무효여부에 대해 판단할 수 있으며 무효사유는 특별히 한정하지 않고 있다.
- ③ 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제3호의 상표권의 효력이 제한되는 경우에 해당하는지 여부는 권리범위 확인심판의 판단대상이 된다.
- ④ 타인의 등록상표가 표시된 일회용 필름용기의 재활용에 있어 그 용기에 새겨진 타인의 상표를 그대로 둔 채 필름만 대체해서 재판매한 경우 상표권은 소진되지 않으므로 상표권 침해가 성립된다.
- ⑤ 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)의 선사용권을 근거로 침해에 해당하지 않는다는 주장은 침해소송에서는 인정될 수 있으나 권리범위 확인심판에서는 인정될 수 없다.

- ① [×] 이른바 'KATANA' 판결을 지문화 하였다. “어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표(후행 등록상표)가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도(지문에서 말하는 역혼동이 발생하는 케이스임), 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결).
- ② [○] 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다(하이우드 사건, 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 판결(전합)).
- ③ [○] 제90조의 효력제한 사유는 권리범위 확인심판의 심리범위에 포함된다.
- ④ [○] 이른바 ‘후지필름 판결’로 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것이다.
- ⑤ [○] 송석 사건, 판례는 허락에 의한 통상사용권의 존부, 제99조 소정의 선사용권 또는 상표권자의 상표등록출원행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된다는 등의 대인적(對人的) 상표권 행사의 제한사유는 상표권 침해소송이 아닌 권리범위 확인심판에서 이를 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다고 본다.

정답 ①

121 상표법에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

25 기출

- ㄱ. 상표권 존속기간의 갱신등록은 원등록(原登錄) 효력이 끝나는 날부터 효력이 발생한다.
 ㄴ. 상표권자는 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.
 ㄷ. 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다.
 ㄹ. 지식재산처장은 상표등록의 무효심판이 청구된 경우 그 취지를 해당 상표권의 전용 사용권자 및 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설

㉠ ×, 원등록의 효력이 끝나는 다음 날부터 효력이 발생한다(法 85②). ㉡ ○, 제99조 제3항㉢ ○, 제106조 제1항㉣ ×, 심판장이 통지한다(法 117⑤).

정답 ②

122 상표권 침해에 대한 손해배상청구에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

25 기출

- ① 상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의로 침해한 자에 대하여 1억원 이하의 범위에서 상표법 제111조(법정손해배상의 청구)의 법정손해배상을 청구할 수 있다.
- ② 상표권자는 자기가 사용하고 있는 국내에 현저하게 알려진 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 자기 등록상표의 식별력을 손상한 자에 대하여는 1억원 이하의 범위에서 상표법 제111조(법정손해배상의 청구)의 법정손해배상을 청구할 수 있다.
- ③ 상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같은 상표를 그 지정상품과 같은 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의적으로 침해한 경우에는 법정손해배상과 함께 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 따라 손해배상을 청구한 상표권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 법정손해배상의 청구로 변경할 수 있다.
- ⑤ 상표법 제222조(등록상표의 표시)에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 본다.

해설

- ① [x] 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다(法 111①). 제111조 규정에 따른 법정손해배상의 청구는 동일 범위의 침해행위에 대해서만 청구가 가능하다.
- ② [x] 저명상표의 희석화(식별력 손상, 식별력 약화)는 상표권의 침해로 취급하지 아니하므로 손해배상 청구의 대상이 아니다.
- ③ [x] 법정손해배상의 청구는 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 청구할 수 있다. 즉, 제109조와 제111조는 선택적으로 청구할 수 있다.
- ④ [○] 제111조 제2항여기서 변론의 종결은 사실심변론종결시로 해석하는 것이 일반적이다.
- ⑤ [x] 제222조에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다(法 112). 즉, 본다(간주)가 아니라 추정하는 것이다.

정답 ④

123 상표법 제108조(침해로 보는 행위)의 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)의 침해로 보는 행위가 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) '25 기출

- ① 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위
- ② 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 행위
- ③ 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용할 목적으로 소지하는 행위
- ④ 타인의 등록상표를 위조할 목적으로 그 용구를 소지하는 행위
- ⑤ 타인의 등록상표가 표시된 지정상품과 동일한 상품을 양도하기 위하여 소지하는 행위

해설

① [x] 상표법은 제89조와 제108조에서 상표권의 적극적·소극적 효력의 범위를 규정하고 있다. 제89조는 소위 동일 범위(등록상표&지정상품)의 침해 인정의 근거가 되는 규정이며, 제108조 제1항 제1호는 유사 범위(등록상표&유사 지정상품 + 등록상표와 유사한 상표&(동일 or 유사 지정상품)) 침해의 근거 조문이다. 이러한 동일·유사 범위의 침해 이외에도 제108조 제1항 제2호 내지 제4호에서는 침해로 보는 행위(간접침해)를 추가적으로 규정하고 있다. 따라서, ①번 지문의 행위는 제89조 규정에 근거한 침해행위에 해당하므로 제108조 규정의 침해 행위에는 해당되지 않는다.

- ② [○] 제108조 제1항 제1호
- ③ [○] 제108조 제1항 제2호
- ④ [○] 제108조 제1항 제3호
- ⑤ [○] 제108조 제1항 제4호

정답 ①

제2절 상표권의 효력 제한

124 상표법상 상표등록의 요건 등에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 26 기출

- ① 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제2항에 따라 등록한 상표는 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 아니한다.
- ② 상표법 제33조 제1항에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품과 동일·유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 그 상품에 대하여 관용하는 상표를 상표등록출원 전부터 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 제33조 제2항에 따라 등록할 수 있다.
- ④ 특정지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 유사하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 상표는 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제10호에 따라 상표등록을 받을 수 없다.
- ⑤ 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정한 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 경우, 상표법 제34조 제1항 제4호의 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표에 해당한다.

- ① [○] 제90조 제1항 제2호가 기술적 표장에는 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있지만 만일 어느 기술적 표장이 같은 제33조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 자타상품식 별력을 갖추게 된 것이어서 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 위 제90조 제1항 제2호 소정의 (사용)상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 할 것이고 따라서 그 상표권자는 위 제90조 제1항 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있다고 할 것이다(새우깡 사건, 대법원 1992. 5. 12. 선고 88후974,88후981,88후998 판결 [권리범위확인(상)]).
- ② [×] 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(法 33②).
- ③ [×] 제33조 제2항은 제33조 제1항 제2호 내지 제7호에 해당하는 상표의 예외적 등록에 대해 규정하고 있다. 다만, 제33조 제1항 제1호(보통명칭), 제2호(관용표장)에 해당하는 상표라도 등록여부결정시를 기준으로 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 **제33조 제2항과 무관하게** 식별력 있는 상표로 취급되어 상표 등록이 가능하다.
- ④ [×] 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 상표는 제34조 제1항 제10호 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없다. 즉, 선출원 등록이 지리적 표시 단체표장(또는 증명표장)인 경우 후출원의 배제의 범위는 "동일·유사 상표 & 동일 상품"이다.
- ⑤ [×] 라이선스계약을 체결한 주식회사의 대표이사가 계약 상대방의 상호를 자신의 상표의 구성의 일부로 출원·등록하였다고 하더라도 그 등록상표가 제34조 제1항 제4호에 해당하지 않는다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2003후137 판결).

(34조 1항 4호 적용 여부)	관련사례		관련사례
상표자체가 공서양속 위반	양키고훈(적용 ○), NUDE TEXT(적용 ×)	계약이나 신의성실의 원칙에 위반	송석(적용 ×)
상표가 상품에 사용되는 경우의 공서양속 위반	MADONNA - 주류(적용 ○), 부적이미지 - 의류(적용 ○), 경년군 - 종중업무(적용 ○)	개인이 법인명의 상표를 출원	적용 ×
다른 법률에 위반	조약(적용 ○), 약사법(적용 ○) 저작권(적용 ×), 상법 제20조(적용 ×)	사용의사가 없는 상표를 출원	적용 ×
고인 명예 훼손, 유족 추모경에 마음 손상	백남준(적용 ○, 출원경과), 피카소(적용 ○, 서명의 특성), 하준본가(적용 ○, 관계표시)	사회 공공의 이익을 침해	우리은행(적용 ○, 필수적 단어)
모방상표	적용 × → 제9호 내지 제13호 적용	서비스 제공의 자격이 필요	나홀로(적용 ×)
문화재 명칭	척주동해비(적용 ×)	증명표장 제도의 악용	적용 ○ (심사기준)

정답 ①

법에 따른 제한(法 77③, 90, 161)

125 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(상표법 제90조)에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

02 기출

- ① 판례는 자기의 성명이나 상호 등을 비상표적으로 사용하는 경우는 물론, 그것을 상거래 관행에 따라 사용하는 것이라면 상표로서 사용되는 경우도 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당한다고 한다.
- ② 판례는 상표법 제90조 제3항에서 말하는 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기 어렵다고 한다.
- ③ 상표권자가 등록상표의 일부만을 사용한 경우에 있어서도 상표 사용자의 부정경쟁의 목적이 인정되는 경우가 있다.
- ④ 판례는 상표권의 설정등록이 있기 전부터 부정경쟁의 목적으로 등록상표와 유사한 상호를 상표로서 사용한 경우에는 상표권의 설정등록 후에 이를 계속하여 사용하더라도 상표법 제90조 제3항의 적용이 없다고 한다.
- ⑤ 상표법에는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표의 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다는 규정이 없다.

해설

- ① [○] 대법원 1995. 5. 12. 선고 94후1930 판결 등의 내용으로 판례의 주류적 태도이나 이에 반대하는 듯한 판례가 몇몇 존재한다. 다만, 통설적 태도에 따를 때 옳은 지문으로 보는데 문제가 없다.
- ② [○] 한일 사건, 대법원 1995. 11. 21. 선고 95후804 판결
- ③ [○] 상표법 제90조 제3항에서 규정한 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는 것이며 여기서의 '등록된 상표권자의 신용'은 반드시 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 불사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전히 보장되어야 하므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용이 등록상표의 부정사용에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일부의 사용으로써도 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체의 주지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 보아야 한다(거북표 사건, 대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결).
- ④ [×] 판례는 상표권의 설정 등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 등록상표와 유사한 상호를 상표로서 사용한 경우는 물론, 상표권의 설정등록이 있기 전부터 부정경쟁의 목적으로 사용하여 상표권의 설정등록 후에 이를 계속하여 사용하는 경우에도 제90조 제3항의 적용이 있다고 한다(학원 사건, 대법원 2000.4.11 선고 98후2221 판결).
- ⑤ [○] 제90조는 제33조에 해당되는 표장 중 보통명칭(法 33①1)과 기술적 표장(法 33①3), 관용표장(法 33①2)과 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표(法 33①4)를 효력제한 사유로 규정하고 있으나, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표의 경우는 효력제한 사유로 규정하고 있지 않다.

정답 ④

126 甲은 “새한”이라는 상표를 가방류, 화장품류, 신발류 및 의류에 상표등록을 하고 10년 이상 국내 유명 백화점에서 자기의 상표를 부착한 상품을 인기리에 판매하여 오던 중 乙이 “주식회사 새한”이라는 자기 상호를 사용하여 “의류세탁업”을 시작하는 경우 甲과 乙의 지위에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함) 09 기출

- ① 甲은 乙의 의류세탁업이 의류를 서비스업의 원재료로 사용하므로 자기 등록 상표의 지정 상품인 의류와 밀접한 관계가 있어 서로 혼동의 우려가 있다는 주장을 하여 상표권의 침해금지를 청구할 수 있다.
- ② 乙은 자기의 표장을 서비스업의 출처를 표시하기 위한 상표로 사용하지 아니하고 단지 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 것에 불과하므로 甲의 상표권의 효력이 미치지 아니한다는 주장을 할 수 있다.
- ③ ②에서 乙의 주장이 인정되더라도 乙이 부정경쟁의 목적이 없음을 입증하지 못하는 한 乙은 상표권 침해의 책임을 면할 수 없다.
- ④ 乙에게 부정경쟁의 목적이 있는지 여부는 표장선정의 동기 등 주관적 사정과 표장 및 영업목적의 유사성 등 객관적 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다.
- ⑤ 사안의 정황으로 보아 乙에게는 부정경쟁의 목적이 있음이 강하게 추정되므로 甲은 자기의 상표권 침해소송에서 승소 가능성이 크다고 할 수 있다.

해설

- ① [○] 표장이 동일 또는 유사하고 상품과 서비스업간에 동종성이 인정되면 상표권 침해가 될 수 있으므로 옳은 지문이다.
- ② [○] 제90조 제1항 제1호
- ③ [×] 입증책임 분배원칙에 따라 권리장에 규정으로서 제90조 제1항 제1호는 침해의 대항을 받는 乙이 주장입증을 하여야 함은 물론이다. 다만, 원칙규정인 제90조 제1항 제1호의 예외규정에 해당하는 제90조 제3항의 요건사실(‘그러하지 아니하다.’고 규정됨)은 제90조 제1항 제1호의 법률효과를 다투는 상대방인 상표권자인 甲이 입증책임을 부담한다. 즉, 乙이 부정경쟁의 목적이 없음을 입증하여야 하는 것이 아니라 甲이 乙에게 부정경쟁의 목적이 있음을 주장입증하여야 한다.
- ④ [○] 대법원 1999.12.07. 선고 99도3997 판결
- ⑤ [○] 제90조 제1항 제1호 단서에서 말하는 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 아닌지 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실 사용상태 등 객관적 사정을 고려하여 판단해야 한다(유화정철학원 사건, 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 [권리범위확인(상)]). 甲의 “새한”은 10년 이상 국내 유명 백화점에서 상표가 부착된 상품이 인기리에 판매되었던 점, 乙의 사용상품인 “의류세탁업”은 甲의 등록상표의 지정상품과 동종업의 관계에 있는 점을 고려하면 乙에게는 부정경쟁의 목적이 있음이 강하게 추정된다.

정답 ③

127 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)의 적용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

11 기출

- ① 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 대하여 관용하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ② 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제2항의 '사용에 의한 식별력'을 인정받아 등록된 상표라 하더라도 그 상표의 지정상품과 동일한 상품의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 보는 것이 판례의 일관된 입장이다.
- ③ 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 구성된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ④ 자신의 저명한 필명을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니하나, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.

해설

- ① [○] 제90조 제1항 제4호
- ② [x] 판례는 일관하여 “제33조 제2항에 의하여 식별력을 취득한 상표는 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권의 효력 제한을 받지 아니한다.”라고 판시하고 있다(새우깡 사건, 대법원 1992.5.12. 88후 974,981,998(병합)). 따라서, 옳지 않은 지문이다.
- ③ [○] 제90조 제1항 제5호
- ④ [○] 제90조 제3항
- ⑤ [○] 제90조 제1항 제3호

정답 ②

128 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

18 기출

- ① 상표법 제90조 제3항의 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 볼 수는 없다.
- ② 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.
- ③ 상표법 제90조 제3항의 '부정경쟁의 목적'에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다.
- ④ 등록된 상표가 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 상표법 제90조 제3항에 규정된 '부정경쟁의 목적'이 인정되는 것은 아니다.
- ⑤ 상표법 제90조 제1항 제2호의 '상품의 산지'라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니다.

해설

- ① [○] 메디팜 사건, 대법원 2011.7.28. 선고 2011후538 판결.
- ② [×] 지리적 표시 등록단체표장에 대한 효력제한규정이므로 제90조 제2항 제1호에 따라 '산지'가 제외되어야 하며, '상거래 관행에 따라 사용하는 상표'가 아닌 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'이어야 한다.
- ③ [○] 입증책임 분배원칙에 따라 제90조 제3항의 부정경쟁의 목적에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다.
- ④ [○] 메디팜 사건, 대법원 2011.7.28. 선고 2011후538 판결.
- ⑤ [○] 시목 사건, 대법원 2006.7.28. 선고 2004도4420 판결.

정답 ②

129 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

20 기출

- ① 상표법 제90조 제1항 제1호의 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니하며, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우에도 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ② 상표법 제90조 제1항 제1호의 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에서 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 등은 저명할 것을 요건으로 한다.
- ③ 상표법 제90조 제1항 제2호의 보통명칭 또는 기술적 표장에 해당하는지 여부는 권리범위 확인심판에서는 심결시, 침해금지청구소송에서는 판결시를 기준으로 판단하여야 한다.
- ④ 전체적으로 볼 때 일반수요자를 기준으로 사용상품의 품질·효능·용도 등을 표시하는 것으로 직감할 수 있을 정도로 도안화된 상표는 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당하여 이에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합상표의 경우 분리인식 될 수 있는 일부 부분이 상표법 제90조의 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위의 상표에 해당하는 경우, 그 일부분에만 효력이 제한되는 것은 아니므로 그 부분을 제외한 나머지 부분을 기초로 상표유사여부를 판단할 수 없다.

해설

- ① [x] 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(法 90①1). 다만, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 위 제90조 제1항 제1호를 적용하지 아니한다(法 90③).
- ② [x] 아호·예명·필명 및 약칭(아·예·필·약)에 한하여 저명성을 요한다.
- ③ [x] 침해금지청구소송에서는 ‘사실심 변론종결시’를 기준으로 한다.
- ④ [○] 사용상표가 도안화가 되어 있으나 그 정도에 있어 품질, 성질 등을 표시하는 것으로 직감할 수 있을 정도라면, 결국 도안화에도 불구하고 품질, 성질을 직감할 수 있는 성질표시에 해당한다는 것이므로 제90조 제1항 제2호에 따라 효력이 미치지 않는다.
- ⑤ [x] 제90조 소정의 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면, 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다(매직블럭 사건, 대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결).

정답 ④

권리소진

130 상표권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'23 기출

- ① 甲이 등록한 상표와 동일한 상표를 그 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 乙이 임의로 사용하여 丙에게 판매한 경우, 상표권자 甲은 乙에게 손해배상을 청구할 수 있으나 그 상품이 위조상표를 부착한 상품이라는 사정을 자신의 책임 있는 사유 없이 전혀 알 수 없었던 丙에게는 권리소진의 항변이 인정되므로 손해배상을 청구할 수 없다.
- ② 상표권자 甲으로부터 상표권의 지분을 1% 이전받은 乙은 상표권을 침해하는 丙을 상대로 단독으로 상표권 침해금지청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 상표권을 甲과 乙이 각각 50%의 지분비율로 등록을 하고 있는 경우에 乙은 甲의 동의 없이 자신의 지분에 기하여 丙에게 특정지역에 한정하여 통상사용권을 설정하는 것은 허용되지 않는다.
- ④ 증명표장권자는 지식재산처장의 허가를 받더라도 같은 증명업무를 영위하는 자에게 증명표장만을 양도할 수는 없다.
- ⑤ 국제올림픽위원회는 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제1호 다목 단서에 따라 자기표장인 오륜기를 상표등록을 받더라도 그 상표권에 대하여 질권을 설정할 수 없다.

해설

- ① [×] 권리소진이론은 정당한 권리자에게 등록상표가 표시된 상품을 양도받은 경우에 적용되는 것이다. 따라서, 丙의 인식 여하를 불문하고 침해자인 乙에게 양도받은 상품에 대해서는 권리소진이론의 적용이 없다.
- ② [○] 상표권의 공유는 민법상 준공유에 해당하고, 이에 따라 침해금지청구는 보존행위로서 각자가 단독으로 할 수 있다. 따라서 지분율에 상관없이 지분을 가진 권리자는 자기의 지분에 기한 보존행위로서 침해금지청구를 할 수 있다.
- ③ [○] 상표권의 공유인 경우 어느 공유자는 타 공유자의 동의 없이 (자신의 지분율에 상관없이) 통상사용권을 설정할 수 없다.
- ④ [○] 증명표장권은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 법 제3조 제3항에 따라 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전할 경우에는 지식재산처장의 허가를 받아 이전할 수 있다(法 93⑦). 따라서 i)증명표장을 등록받을 수 있는 자, ii)업무와 함께, iii)지식재산처장의 허가의 세가지 요건을 만족하는 경우에만 이전이 가능하다.

	이전제한	질권설정제한	사용권 설정제한
공유상표권	전원의 동의하에 가능(法 93②)	전원의 동의하에 가능(法 93②)	전원의 동의하에 가능(法 93③)
업무표장	i)업무와 함께 양도하는 경우만 가능(法 93④)	설정 불가(法 93⑧)	설정 불가(法 95②, 97⑤)
예외적 본인등록표장	i)업무와 함께 양도하는 경우만 가능(法 93⑤)	설정 불가(法 93⑧)	규정 無
단체표장	i)법인의 합병, ii)지식재산처장의 허가를 받아 가능(法 93⑥)	설정 불가(法 93⑧)	설정 불가(法 95②, 97⑤)
증명표장	i)증명표장을 등록받을 수 있는 자, ii)업무와 함께, iii)지식재산처장의 허가를 받아 가능(法 93⑦)	설정 불가(法 93⑧)	설정 불가(法 95②, 97⑤)
취소사유 해당(法 119①4) 여부	취소사유 ○	공유상표권만 취소사유 ○, 나머지는 취소사유 ×	취소사유 ×

- ⑤ [○] 업무표장권, 제34조 제1항 제1호 다목 단서, 같은 호 라목 단서 또는 같은 항 제3호 단서에 따른 상표권(예외적 본인 등록 표장), 단체표장권 또는 증명표장권을 목적으로 하는 질권은 설정할 수 없다(法 93⑧).

정답 ①

131 상표법상 권리소진에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 26 기출

- ① 상표권자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우 특별한 사정이 없는 한 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 아니한다.
- ② 상표권자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우라도, 그 양도된 상품을 원래 상품과의 동일성을 해할 정도로 가공 또는 수선한 경우에는 상표권자의 권리를 침해한다.
- ③ 한국 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 상표를 외국 상표권자가 그 수입된 상품에 부착하였고, 수입상품과 한국 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이의 품질에 실질적 차이가 없으면, 위 상품의 수입은 상표권 침해가 아니다.
- ④ 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우에도 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위이므로 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다.
- ⑤ 등록상표가 표시된 상품을 수입한 자가 임의로 그 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담은 방식으로 포장한 후 그 등록상표를 표시하거나 그 표시한 것을 양도하였다면 특별한 사정이 없는 한 상표권을 침해하는 행위에 해당한다.

① [○] 지문② 해설 참조

② [○] 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이다. 그리고 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다(후지필름 사건, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 [상표법위반]).

③ [○] 국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, ① 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, ② 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 한다. ③ 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 하고, 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니다(스타크래프트 사건, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결 [판매등]).

④ [x] 지정상품, 존속기간, 지역 등과 관련된 통상사용권의 사용 범위는 통상사용권 계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 **일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고**, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다(메트로씨티 사건, 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결 [상표법위반]).

⑤ [○] 상표권자 내지 정당한 사용권자(이하 '상표권자 등'이라고 한다)에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수 또는 수입한 자가 임의로 그 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담은 방식으로 포장한 후 그 등록상표를 표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 양도하였다면 비록 그 내용물이, 상표권자 등의 제품이라 하더라도 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해칠 염려가 있으므로, 이러한 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 내지 전용사용권을 침해하는 행위에 해당한다(SUPER TEMPRA 사건, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011도17524 판결 [상표법위반]).

정답 ④

진정상품병행수입

132 진정상품의 병행수입에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 108 기출

- ① 복수국가에서 동일한 상표권을 가지고 있는 상표권자에 의해 제1국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통된 상품을 정당한 권원 없는 제3자가 제2국으로 그 상표권자 또는 전용사용권자의 허락 없이 수입하여 판매하는 행위를 말한다.
- ② 진정상품 병행수입업자가 선전광고물, 명함, 포장지 등에 상표권자의 상표를 사용하여 적극적 광고행위를 하는 경우에는 상표권 침해가 성립한다.
- ③ 진정상품 병행수입행위 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해를 구성하지 않기 때문에 진정상품 병행수입업자는 상표권자의 상표가 부착된 상품을 판매할 수 있다.
- ④ 병행 수입된 진정상품과 국내 전용사용권자가 제조·판매하는 상품 사이에 품질상의 차이가 존재한다면 병행수입은 허용되지 않는다.
- ⑤ 국내외 상표권자가 동일인으로 볼 수 있는 관계에 있는 경우에 진정상품 병행수입이 허용된다.

해설

① [○] 지문⑤ 해설 참조

② [x] 병행수입업자가 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로, 상표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다고 봄이 상당하다고 할 것이다(버버리 사건, 대법원 2002.9.24. 선고 99다42322 판결).

③ [○] 병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인바, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고, 상표는 기본적으로 당해 상표가 부착된 상품의 출처가 특정한 영업주체임을 나타내는 상품출처표시기능과 이에 수반되는 품질보증기능이 주된 기능이라는 점 등에 비추어 볼 때, 병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로, 상표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다(버버리 사건, 대법원 2002.9.24. 선고 99다42322 판결 등 참조).

④ [○] 지문⑤ 해설 참조

⑤ [○] 국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 한다. 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 하고, 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니다(STARCRAFT 사건, 대법원 2006.10.13. 선고 2006다40423 판결 등 참조).

정답 ②

133 상표권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 12 기출

- ① 상표법상 2개의 유사한 상표가 유사한 상품을 지정상품으로 하여 시기를 달리하여 각기 출원되어 등록되었다 하더라도 무효심판 등에 의하여 어느 일방의 권리가 소멸되지 않는 한 다같이 상표권으로서 보호를 받고 어느 일방의 사용이 다른 일방의 상표권에 대한 침해가 되지 않는다.
- ② 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)에서 규정하는 선사용자는 선사용에 따른 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.
- ③ 등록상표가 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에도 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용에 대해서 저작권자의 동의를 받으면 상표권자는 그 등록상표를 사용할 수 있다.
- ④ 외국의 상표권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출된 경우에 이러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니지만, 그러한 약정 위반만으로도 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표는 위법하게 된다.
- ⑤ 병행수입업자가 상표부착상품을 판매하는 행위는 물론 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전하는 행위를 하더라도 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성이 없다면, 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 없다고 보는 것이 판례의 입장이다.

해설

- ① [×] 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 '후출원 등록상표'라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다(데이터팩토리 사건, 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결). 따라서 틀린 지문이다.
- ② [○] 선사용자가 갖는 사용권의 범위는 '당해 사용 상표와 동일한 상표(해당 상표)를 그 사용하는 상품과 동일한 상품'에 사용하는 경우로 한정된다.
- ③ [○] 제92조 제1항
- ④ [×] 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니다(CAMERINO 사건, 대법원 2005.6.9. 선고 2002다61965 판결).
- ⑤ [○] 병행수입업자가 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로, 상표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다고 봄이 상당하다고 할 것이다(버버리 사건, 대법원 2002.9.24. 선고 99다42322 판결).

정답 ①, ④

권리남용

134 상표권의 행사와 권리남용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

10 기출

- ① 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건은 권리남용 성립의 필수요건이 아니다.
- ② 비록 상표권의 행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.
- ③ 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일, 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것은 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정될 수 없다.
- ④ 주지성을 획득하지 못한 상표의 경우에는 특수한 개별적인 관계에서 부정한 의도가 존재하거나 경업금지의무 등의 위반이 있는 경우와 같이 상표권의 행사가 신의칙 내지 사회질서에 반하는 경우라도 권리행사의 외형을 갖추었다면 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로 볼 수 없다.
- ⑤ 외국법인이 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 국내 총판대리점 관계에 있던 회사가 그 상표들을 출원·등록해 놓았다가, 그 외국법인과의 총판대리점 관계가 종료된 후, 등록상표들을 실제 상품에 사용하지도 아니하면서 그 외국법인의 국내 출자 법인을 상대로 등록상표권을 행사하여 그동안 정당하게 사용해오던 상표나 이를 포함한 표장을 인터넷 도메인 이름 또는 전자우편주소로 사용하거나 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 금지해 달라고 청구하는 것은 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

해설

- ① [○] 지문② 해설 참조
- ② [○] 상표권의 행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호 받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없으며, 이때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건은 필요치 않다는 것이 판례이다(진한커피 사건, 대법원 2007.1.25. 선고 2005다67223 판결).
- ③ [○] 비제바노사건, 사임당 사건 등, 대법원 2000.05.12. 선고 98다49142 판결
- ④ [x] 국내 널리 인식된 주지상표를 부정경쟁의 목적으로 모방하여 형식상 상표권을 취득하는 경우뿐만 아니라, 주지성을 획득하지 못한 경우라도 특수한 개별적인 관계에서 부정한 의도가 존재하거나 영업금지 의무 등의 위반이 있는 경우와 같이 상표권의 행사가 신의칙 내지 사회질서에 반하는 경우라면 당연히 권리남용에 해당될 수 있다(KGB 사건, 대법원 2006.2.24. 선고 2004마101 결정 등). 예컨대, 지문 ⑤의 경우도 그 하나의 예라 할 수 있다.
- ⑤ [○] ACM IT WATER 사건, 대법원 2007.2.22. 선고 2005다39099 판결

정답 ④

135 甲의 등록상표의 사용이 그 사용상태에 따라 甲의 상표등록출원일 전에 출원되어 등록된 乙의 디자인권과 저촉되거나 선 발생한 丙의 저작권 등 타인의 선행 권리 또는 법적 지위와 저촉되는 경우, 다음 설명 중 옳은 것은? 15 기출

- ① 甲은 선행권리자의 동의를 얻지 못하면 자기의 등록상표라도 사용할 수 없으며, 동의 없이 사용하면 乙의 디자인권과 丙의 저작권 등 선행권리의 침해가 성립하며, 동의 없는 사용은 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제3항의 정당한 사용에 해당하지 아니하므로 결국 불사용을 이유로 취소된다.
- ② 甲으로부터 상표사용허락을 받은 통상사용권자 丁도 乙과 丙등 타 선행권리자의 동의 없이 상표사용을 할 수 없으며, 이들이 동의를 해 주지 않는 경우 통상사용권허여심판을 청구하여 동의를 강제할 수 있다.
- ③ 丙의 저작권 존속기간이 만료된 경우 丙은 존속기간 만료 후에도 부정경쟁의 목적이 없는 한, 원 저작권의 범위 내에서 등록상표와 동일, 유사한 상표를 계속하여 사용할 수 있다.
- ④ 丙등 선행권리자에게 인정되는 존속기간 만료 후에 상표를 사용하는 권리는 법정사용권에 해당하므로 상표권자인 甲의 동의를 받지 않고도 타인에게 그 상표를 사용할 권리를 이전할 수 있다.
- ⑤ 乙등의 선행권리와 甲의 등록상표와의 저촉은 상표등록 무효사유에는 해당하지 않으나, 甲의 등록상표의 사용이 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률' 제2조(정의)의 일반조항을 위반하는 경우 상표등록취소사유가 될 수 있다.

해설

- ① [x] 제92조 제1항에 따라 선행권리자의 동의를 얻지 않은 한 선행권리의 침해가 성립되나, 판례는 일관하여 등록상표의 사용이 타인의 저작권을 침해하는 경우일지라도 불사용으로 인한 상표등록취소의 요건과 관련하여서는 상표의 정당한 사용으로 해석하고 있다.
- ② [x] 통상사용권자 또한 선행권리자의 동의를 받아야 등록상표를 사용할 수 있으나, 통상사용권허여심판은 존재하지 않는다.
- ③ [x] 저작권은 산업발전과는 무관한 것이므로 제98조의 법정사용권에서는 제외된다.
- ④ [x] 제98조 소정의 법정사용권은 상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우를 제외하고 상표권자 또는 전용사용권자의 동의를 받아야 한다(法 98⑤).
- ⑤ [○] 디자인권 등 선행권리와 저촉은 상표법상 무효사유에 해당하지는 않는다. 한편, 지문에서 말하는 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조의 일반조항'이란 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목 소정의 보충적 일반조항을 의미한다고 할 것인데, 등록상표의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목에 해당하여 제92조 제2항의 적용이 있는 경우, 이는 제119조 제1항 제6호 소정의 취소사유에 해당한다.

정답 ⑤

136 상표법상 저촉에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 22 기출

- ㄱ. 상표권자는 저촉관계에 있는 타인의 등록상표를 확인대상표장으로 하여 권리대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.
- ㄴ. 상표등록출원일 전에 발생한 저작권과 상표권이 저촉되는 경우 부정경쟁의 목적이 없는 한 저작권자는 존속기간이 만료한 후에도 원 저작권의 범위 내에서 등록상표와 동일·유사한 표장을 계속하여 사용할 수 있다.
- ㄷ. 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본 원리로 하고 있고, 이러한 원리는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다.
- ㄹ. 상표법에 따르면 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정되며, 이에 위반하여 등록된 상표는 제척기간의 적용을 받는 등록무효심판의 대상이 된다.
- ㅁ. 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

해설 ㉠ [x] 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판은 인정되지 않는다.

㉡ [x] 저작권은 산업발전과는 무관하므로 제98조에서 제외된다.

㉢ [○] 지문② 해설 참조

㉣ [○] 지문② 해설 참조

㉤ [x] 최근 전원합의체 판결로 중요한 이른바 'DATA FACTORY'판결의 판결요지이다. “상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다(대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결).” 따라서 ‘ㄷ’은 옳은 지문이고, ‘ㄹ’은 제34조 제1항 제7호의 무효사유가 적용되므로 제척기간의 적용이 있어 옳은 지문이다. ‘ㅁ’은 틀린 지문이다.

정답 ②

제4절 상표권자의 보호

107-114

137 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

12 기출

- ① 상표권 침해자가 침해행위에 의하여 이익을 받으면 그 이익액이 손해액으로 추정되므로 상표권자는 침해자가 취득한 이익을 입증하면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생간의 인과관계에 대하여는 입증할 필요가 없다.
- ② 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제3항은 권리자에게 입증책임을 완화시켜 주는 추정규정이지만 침해자는 상표권 침해행위에도 불구하고 상표권자에게 손해의 발생이 없음을 주장·입증하면 손해배상책임을 면할 수 있다.
- ③ 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것이 증명된 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다.
- ④ 상표등록출원인에게 인정된 손실보상청구권의 경우에 배상액의 추정 등에 관한 상표법 제110조(손해액의 추정 등)의 규정은 적용되지 않는다.
- ⑤ 상표법의 규정에 의하여 선서한 당사자·증인·감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정 또는 통역을 하였을 경우에는 상표법상 위증죄에 해당한다.

- ① [○] 제110조 제3항에 의한 손해배상청구를 하는 경우 상표권자는 상표권 침해자가 취득한 이익을 입증하면 되고 그 밖에 침해행위와 손해발생 간의 인과관계에 대하여는 이를 입증할 필요가 없다(대법원 1992.2.25. 선고 91다23776 판결).
- ② [○] 제110조 제3항은 손해액의 추정규정에 불과하고 손해의 발생까지를 추정 또는 간주하는 것이 아니므로, 침해자는 상표권 침해행위에도 불구하고 상표권자에게 손해의 발생이 없음을 주장·입증하면 손해배상책임을 면할 수 있다(한편, 제110조 제4항의 경우도 통설에 따르면 손해발생을 간주하는 규정이 아니므로 여전히 침해자가 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 것을 주장·입증하여 손해배상책임을 면할 수 있다).
- ③ [○] 제110조 제3항은 손해액의 추정규정에 불과하고 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있다. 다만, 위 규정의 취지에 비추어 보면 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 (업으로 등록상표를 사용하여) 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다(대법원 1997.9.12. 선고 96다43119 판결).
- ④ [○] 손실보상청구권에는 배상액 추정에 관한 제110조의 규정은 준용되지 않는다. 따라서, 손실보상액은 원칙적으로 출원인이 이를 입증하여야 한다.
- ⑤ [x] 상표법의 규정에 의하여 선서한 '증인·감정인 또는 통역인'이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정 또는 통역을 하였을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(法 232조: 위증죄). 신분범이란 형사상의 범죄에 있어 구성요건인 행위의 주체에 일정한 신분을 요하는 범죄로, 진정신분범과 부진정신분범으로 나뉘는데 이중 진정신분범이란 일정한 신분에 있는 자에 의하여만 범죄가 성립되는 경우를 말하며, 위증죄가 가장 대표적이다. 따라서, 제232조 소정의 위증죄는 어느 경우라도 명문에 규정된 '증인·감정인 또는 통역인'에 대하여만 성립될 수 있으며, 지문상 '당사자'는 제외되어야 한다.

정답 ⑤

138 상표권 또는 전용사용권의 침해에 대한 구제에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

15 기출

- ㄱ. 상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구 하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다.
- ㄴ. 상표권 침해를 이유로 소가 제기된 경우 법원은 공소 제기가 없더라도 고소인의 신청에 따라 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있으며, 이 경우 법원은 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다.
- ㄷ. 전용사용권자는 자기의 전용사용권을 고의는 물론 과실로 침해한 자에 대하여도 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있으며, 이 때 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.
- ㄹ. 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제3항과 제6항의 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며, 이 때 등록상표를 사용하고 있는 경우란 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

해설

- ㄱ. [x] 법정손해배상청구는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 '같거나 동일성이 있는 상표'를 그 지정상품과 '같거나 동일성이 있는 상품'에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에게 청구할 수 있다(法 111①).
- ㄴ. [x] 제107조 제1항에 따른 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 소가 제기된 경우 법원은 원고 또는 고소인(이 법에 따른 공소가 제기된 경우만 해당한다)의 신청에 의하여 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 원고 또는 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다(法 107③).
- ㄷ. [○] 제110조 제3항
- ㄹ. [○] 제110조 제3항에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며, 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우란 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다(대법원 2009.10.29. 선고 2007다22514,22521 판결). 한편, 제110조 제6항 또한 손해에 관한 피해자(상표권자)의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정으로 위와 마찬가지이다.

정답 ⑤

139 상표법상 법정손해배상제도에 관한 설명으로 옳은 것은?

'16 기출

- ① 법정손해배상의 청구는 한·미 자유무역협정이 발효된 2012년 3월 15일 이후에 등록된 상표권 또는 전용사용권에 기초하여 청구할 수 있다.
- ② 상표권자 또는 전용사용권자는 등록상표의 사용과 무관하게 법정손해배상을 청구할 수 있다.
- ③ 상표권자 또는 전용사용권자는 손해의 발생과 무관하게 소정의 법정손해배상액을 청구할 수 있으나 손해액 입증이 극히 곤란하다는 점을 증명하여야 한다.
- ④ 법정손해배상은 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 의한 손해배상청구와 달리 유사범위의 상표권 침해에는 적용되지 아니하고 등록상표와 같거나 동일성 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대해서만 청구할 수 있다.
- ⑤ 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 의한 손해배상청구를 한 상표권자 또는 전용사용권자는 그 청구를 법원의 판결이 확정되기 전까지 법정손해배상청구로 변경할 수 있다.

해설

- ① [x] 법정손해배상제도는 2012년 개정법 시행(2012.3.15.) 후 최초로 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소가 제기된 것부터 적용한다(2012년법 부칙 제4호).
- ② [x] 법정손해배상 청구를 하려면 상표권자 또는 전용사용권자가 반드시 등록상표를 사용하고 있어야 한다.
- ③ [x] 법정손해배상은 제111조에 규정된 법정손해배상 청구의 요건을 입증하면 되는 것이지 손해액 입증이 곤란하다는 점 등을 입증할 필요는 없다.
- ④ [○] 제111조 제1항
- ⑤ [x] 제111조 제1항 전단에 해당하는 침해행위(동일영역에서의 침해행위)에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 '변론을 종결할 때'까지 그 청구를 법정손해배상청구로 변경할 수 있다(法 111②).

정답 ④

140 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제4항의 합리적으로 받을 수 있는 금액의 청구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

16 기출

- ① 상표법 제110조 제4항은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 손해에 관한 상표권자 등의 주장·증명책임을 경감해 주기 위한 규정이다.
- ② 상표권자가 상표법 제110조 제4항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 충분하다.
- ③ 상표권자가 상표법 제110조 제4항에 따라 손해배상을 청구하는 경우에 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있다 하여도 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정되지는 아니한다.
- ④ 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다.
- ⑤ 상표법 제110조 제4항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우 피해자의 과실을 참작하여야 한다.

해설

① [○], ② [○], ③ [×] 제110조 제4항은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 손해에 관한 상표권자 등의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라고 할 것이나, 그 규정 취지에 비추어 보면, 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 것이다(대법원 2013.7.25. 선고 2013다21666 판결). 따라서, ①②는 옳은 지문이고, ③은 옳지 않은 지문이다.

④ [○] 상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 또한 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도(특허법 제130조, 실용신안법 제30조, 디자인보호법 제65조 제1항 본문) 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 할 것이고, 그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(남선알루미늄 사건, 대법원 2013.7.25. 선고 2013다21666 판결).

⑤ [○] 불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작하여야 하고, 양자의 과실비율을 교량함에 있어서는 손해의 공평부담이라는 제도의 취지에 비추어 불법행위에 관련된 제반 상황을 충분히 고려하여야 하며, 과실상계사유에 관한 사실인정이나 그 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항이라고 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하여서는 아니 되고(대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다76733 판결 등 참), 이러한 법리는 제110조 제4항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 원심이 제110조 제4항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정함에 있어서는 과실상계를 할 수 없다고 본 것은 잘못이라 할 것이다(남선알루미늄 사건, 대법원 2013.7.25. 선고 2013다21666 판결).

정답 ③

141 상표법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

18 기출

- ① 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다 하더라도 상표권이전등록청구권의 소멸시효는 진행된다.
- ② 아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 편익의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 하더라도 이는 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다는 것이 판례의 입장이다.
- ③ 상표권자가 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제4항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 상표권자는 권리침해 사실과 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다.
- ④ 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제4항에 의하여 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 합리적으로 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되므로, 상표권자가 상표를 등록만 해두고 실제 사용하지는 않았더라도 침해자에게 손해배상책임이 인정된다.
- ⑤ 상표법 제121조(권리범위 확인심판)에 의한 적극적 권리범위 확인심판사건에서 확인대상 표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 차이가 있더라도 그 차이 나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성이 인정되는 경우에는 확인의 이익이 있다.

해설

- ① [○] 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다(대법원 2013.5.9. 선고 2011다71964 판결).
- ② [○] WCO 사건, 대법원 2013.7.12. 선고 2012후3077 판결.
- ③ [○] 대법원 2002.10.11. 선고 2002다33175 판결.
- ④ [x] 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 합리적으로 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없다(크라उन진 사건, 대법원 2014.7.24. 선고 2014다59712 판결).
- ⑤ [○] 기록에 의하면, 원고가 실제로 사용하고 있는 상표는 피고가 이 사건 등록상표의 권리범위의 확인을 구한 확인대상표장에 비하여 SINCE 1758, PREMIUM, REFRESHING TASTE OF BEER, MALT BEVERAGE, BROUWERI MARTENS N.V.의 문자가 있고 없는 차이가 있는바, SINCE 1758, PREMIUM, REFRESHING TASTE OF BEER, MALT BEVERAGE의 문자는 모두 작은 글씨로 되고 성질을 표시하는 부기적 부분에 불과하고, BROUWERI MARTENS N.V.는 회사의 이름으로서 그 자체로는 성질을 표시하는 부분이 아니지만, 방패 모양의 테두리선 내부에 아주 작은 글씨로 기재되어 있어 그것으로 인하여 상표 유사 판단에 영향을 미칠 수는 없는 부기적 부분에 불과하다고 보아야 할 것이므로, 결국 이러한 부기적 부분을 생략한 채 간략하게 표시한 이 사건 확인대상표장은 원고의 실사용 상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표라고 봄이 상당하므로, 이 사건 심판 청구가 실제로 사용하지 않는 확인대상표장에 대한 것으로 확인의 이익이 없다고 하는 상고이유 제1점은 이유 없다(HITE 사건, 대법원 2001.12.27. 선고 2001후577 판결). 즉, 대법원은 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상표장과 실사용 상표의 차이가 있다 하여도 그 차이가 부기적인 것에 불과하여 양 표장의 동일성이 인정되는 경우에는 확인의 이익을 인정한다.

정답 ④

142 상표권침해와 손해배상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 따름) 23 기출

- ① 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.
- ② 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.
- ③ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝난 경우에도 또한 같다.
- ④ 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 상표권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 상표법 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억 원(고의적으로 침해한 경우에는 3억 원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다.

- 해설
- ① [○] 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대장금·주몽 사건, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참).
 - ② [○] 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다(하이우드 사건, 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결).
 - ③ [○] 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝난 경우에도 또한 같다(法 151③).
 - ④ [×] 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 **합리적으로 받을 수 있는 금액**에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다(法 110④).
 - ⑤ [○] 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다(法 111①).

정답 ④

143 상표권의 침해 및 그 구제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 24 기출

- ① 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있도록 법원에 권한을 부여하고 있다.
- ② 상표권의 침해가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에 그 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 정책적인 이유에 의하여 최초로 손해가 발생한 때부터 일괄적으로 진행되는 것으로 본다.
- ③ 상표권자가 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구하는 대신에 상표법 제111조(법정손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구하는 경우에 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.
- ④ 상표법은 제222조(등록상표의 표시)에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다.
- ⑤ 상표권자가 상표권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우에는 그 상표권이 경매에 의하여 이전되더라도 지정상품 중 사용하고 있는 상품에 한정하여 사용하는 경우에는 상표권 침해가 되지 않는다.

해설 ① [○] 제110조 제7항

② [×] 상표권의 침해는 대부분 특정한 기간 동안 계속적으로 이루어지는 경우가 많은데, 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해이므로 민법 제766조 제1항에서 정한 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 그 각 손해를 안 때부터 각별로 진행된다고 보아야 한다. 따라서 상표권 침해가 계속적으로 행하여지는 경우 그 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 최초로 손해를 안 때로부터 일괄적으로 진행되는 것이 아니라 각 손해를 안 때로부터 개별적으로 진행된다.

③ [○] 제111조 제1항

④ [○] 소위 '고의의 추정' 규정이다. 이와는 별개로 판례는 "상표권을 침해한 자에 대하여만 특허법과 디자인보호법과 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고, 그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 i) 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 ii) 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다."고 판시하였다(남선알루미늄 사건, 2013다21666(손배)).

⑤ [○] 제104조의2.

정답 ②

144 상표법상 손해배상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 26 기출

- ① 상표법 제111조(법정손해배상의 청구)에 의한 손해배상을 청구하려면 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 한다.
- ② 상표법 제111조는 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.
- ③ 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다.
- ④ 법원이 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정한 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제6항은 법관에게 손해액 산정에 관한 자유 재량을 부여한 것이다.
- ⑤ 상표법 제110조 제3항에 따라 침해자의 이익액이 상표권자의 손해액으로 추정되었어도, 침해자가 자신의 상품의 품질과 기술의 우수성 등 상표권 침해와 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있음을 증명하면, 위 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있다.

- ① [○] 제111조 법정손해배상의 청구는 동일성 범위 내에서의 상표권 침해에 대해서 손해배상을 청구할 수 있다(法 111①)

	고의, 과실	상표·상품의 인정범위	실손해액 이상 인정
손해액의 인정(法 110⑥)	고의 or 과실	동일 or 유사	인정 不可
징벌적 손해배상(法 110⑦)	only 고의	동일 or 유사	실손해액 이상 인정 可
법정손해배상(法 111)	고의 or 과실	only 동일	실손해액 이상 인정 可

- ② [○] 제111조 제1항은 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명에 관한 하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다. 따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없다(크라운진 사건, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2014다59712판결 [침해금지 등]).

- ③ [○] 상표법 '제110조 제3항'의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있으나, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 [손해배상(지)]).

※ 상기 법리는 손해배상청구에 관한 모든 청구에 대해 적용될 수 있다.

- ④ [x] 본 규정은 자유심증주의 하에서 손해의 발생 사실은 증명되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 증명이 곤란한 경우 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니다. 따라서 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수급할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결 [기술료 등]).

- ⑤ [○] 제110조 제3항은 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익의 액으로 권리자가 받은 손해액을 추정하는 것으로서, 침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 의장 상표 또는 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 이외의 다른 상표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 입증책임은 침해자에게 있다고 할 것이다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 [손해배상(기)]).

정답 ④

제5절 벌칙

230-237

145 상표법상 벌칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

18 기출

- ① 상표법에 따라 선서한 증인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술, 감정 또는 통역을 하였을 경우에는 위증죄에 해당한다.
- ② 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없더라도 비밀유지명령 위반죄로 공소를 제기할 수 있다.
- ③ 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 등에 표시하는 행위를 한 경우에는 거짓표시의 죄에 해당한다.
- ④ 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 상표권침해죄의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 벌금형을 과(科)하고 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여 상표등록, 지정상품의 추가등록, 존속기간갱신등록, 상품분류전환등록 또는 심결을 받은 경우에는 거짓행위의 죄에 해당된다.

해설

- ① [○] 제232조(위증죄).
- ② [x] 비밀유지명령 위반죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. 즉, 침해죄 등과 달리 '친고죄'이다(法 231②).
- ③ [○] 제233조(거짓 표시의 죄).
- ④ [○] 제235조(양벌규정).
- ⑤ [○] 제234조(거짓 행위의 죄).

정답 ②

146 상표법상 벌칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

'19 기출

- ① 상표법에 따라 선서한 증인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술을 하였을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 이 위증죄를 범한 증인이 그 사건의 상표등록여부결정 또는 심결의 확정 전에 자수하였을 경우에는 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다.
- ② 상표등록을 하지 아니한 상표를 등록상표인 것같이 영업용 광고에 표시한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여 상표등록을 받은 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ④ 상표권의 침해행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ⑤ 상표권의 침해물 제작에 사용하기 위하여 제공된 제작 용구에 대해서는 몰수가 가능하나, 상표권의 침해물 제작에 사용하기 위하여 제공된 재료에 대해서는 몰수가 불가능하다.

해설

- ① [○] 상표법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정 또는 통역을 하였을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(法 232①). 다만, 제1항에 따른 죄를 범한 자가 그 사건의 상표등록여부결정 또는 심결의 확정 전에 자수하였을 경우에는 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다(法 232②).
- ② [×] 제233조 소정의 '거짓 표시의 죄'이므로 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ [×] 제234조 소정의 '거짓 행위의 죄'이므로 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ④ [×] 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(法 230).
- ⑤ [×] 형사집행을 위한 몰수 대상에는 침해물 제작에 제공된 '제작 용구' 이외에 '재료'까지 포함된다(法 236).

정답 ①

147 상표법상 벌칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

21 기출

- ① 상표권 침해행위는 권리자에게 피해를 주는 것 이외에 상품 출처의 오인·혼동을 발생시킴으로써 거래질서를 혼란하게 할 우려도 있으므로, 상표권 침해죄는 특허권 침해죄와는 달리 비친고죄이다.
- ② 상표법에 따라 선서한 증인으로서 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정을 하여 위증죄를 범한 자가 그 사건의 상표등록여부결정 또는 심결의 확정 전에 자수하였을 경우에는 필요적으로 그 형을 감경하거나 면제하여야 한다.
- ③ 상표법상 비밀유지명령위반죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄이다.
- ④ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여 상표등록, 지정상품의 추가등록, 존속기간갱신 등록, 상품분류전환등록 또는 심결을 받은 자는 거짓행위의 죄에 해당되는데 이 죄는 비친고죄이다.
- ⑤ 상표권 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 침해물과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 필요적 몰수의 대상이지만, 상품이 그 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표 또는 포장과 쉽게 분리될 수 있는 경우에는 그 상품을 몰수하지 아니할 수 있다.

해설

- ① [○] 하단 박스 참고
- ② [x] 상표법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정 또는 통역을 하였을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 위증죄를 범한 자가 그 사건의 상표등록여부결정 또는 심결의 확정 전에 자수하였을 경우에는 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다(法 232). 즉, 필요적으로 그 형을 감경하거나 면제하여야 하는 것이 아닌 재량규정에 불과하다.
- ③ [○] 제231조 제2항에 따라 비밀유지명령 위반죄는 '친고죄'에 해당한다.
- ④ [○] 제234조 소정의 거짓 행위의 죄는 '비친고죄'이다.
- ⑤ [○] 상표권 또는 전용사용권 침해죄에 해당하는 행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표·포장 또는 상품(이하, '침해물'이라 한다)과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 몰수한다. 다만, 상품이 그 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표 또는 포장과 쉽게 분리될 수 있는 경우에는 그 상품은 몰수하지 아니할 수 있다(法 236). 따라서, 맞는 지문이다.

참고

지문 ①의 경우 2020. 10. 20. 시행 특허법이 특허권 침해죄를 피해자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없는 친고죄에서 피해자가 기소를 원하지 않는다는 의사를 확실히 표명할 경우에만 기소를 하지 않는 '반의사불벌죄'로 변경(특허법 제225②)하였다는 점에서 일부 논란이 있을 수 있다. 다만, 반의사불벌죄는 피해자의 의사와 관계없이 공소제기를 할 수는 있지만, 피해자가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 표시하거나 처벌의 의사표시를 철회한 경우에는 공소를 제기할 수 없고, 공소를 제기한 후라면 공소기각의 판결을 선고해야 한다는 점(형사소송법 제327조 제6호)에서 기본적으로는 비친고죄보다는 친고죄에 가깝고(서울형사지방법원 1993.5.20. 선고 92노5251 판결의 경우 일부 대법원에서 법리오해가 있다고 지적받기는 하였으나, 반의사불벌죄는 친고죄의 일종 또는 이에 준하는 범죄유형이라고 봄이 상당하다고 판시함), 국가가 형벌권의 발동을 피해자의 의사에 종속시켜도 관철을 만큼 법익 침해가 경미한 경우에 반의사불벌죄라는 규정형식을 택한다는 형사법 학계의 일반적인 설명에 비추어 보아도(배종대 외 3인, 신형사소송법 제3판, 홍문사, 2011년) 반의사불벌죄는 크게 보면 비친고죄보다는 친고죄에 가깝다고 볼 수 있다. 결국 위와 같은 관점에서 보면 지문 ①을 틀린 지문이라 평가하기는 어렵겠고, 나아가 특허권 침해죄는 어찌되었던 명시적인 비친고죄가 아니라는 관점에서 쉽게 접근해 보아도 '상표권 침해죄는 특허권 침해죄와는 달리 비친고죄이다'라는 지문 자체는 맞는 말이 될 수밖에 없다는 점에서 틀린 지문으로 보기는 어렵다.

정답 ②

148 상표법상 벌칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

25 기출

- ① 상표권 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 침해물과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 몰수의 대상이다. 다만, 상품이 그 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표 또는 포장과 쉽게 분리될 수 있는 경우에는 그 상품은 몰수하지 아니할 수 있다.
- ② 국내외에서 정당한 사유 없이 비밀유지명령을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 이에 대해서는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.
- ③ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여 상표등록, 지정상품의 추가등록, 존속기간갱신등록, 상품분류전환등록 또는 심결을 받은 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ④ 상표법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정 또는 통역을 하였을 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ⑤ 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 상품에 표시하는 행위를 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

해설

- ① [○] 제236조
- ② [x] 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(法 231). 친고죄인 것은 맞다.
- ③ [x] 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(法 234).
- ④ [x] 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(法 232).
- ⑤ [x] 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(法 233).

정답 ①

제2장 변동

제6절 상표권의 이전 및 공유

93

149 다음 중 상표권의 이전과 관련하여 옳지 않은 것은?

06 기출

- ① 공익사업을 목적으로 하는 국가·공공단체의 자기의 저명한 표장(상표법 제34조 제1항 제3호 단서)에 대한 상표권을 양도할 경우에는 반드시 업무와 함께 양도하여야 한다.
- ② 전용사용권이 설정등록되어 있는 경우에는 상표권 이전시 전용사용권자의 이익 보호를 위해 전용사용권자의 동의를 얻어야 한다.
- ③ 업무표장권은 반드시 업무와 함께 양도하여야 한다.
- ④ 단체표장권은 법인의 합병의 경우에는 지식재산처장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
- ⑤ 상표권의 이전으로 인하여 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그 중 1인이 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 그 지정상품에 사용함으로써 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 한 경우 누구든지 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

해설

- ① [○] 제93조 제5항
- ② [×] 상표권의 이전시에는 부수적인 권리에 영향이 없으므로 전용사용권자의 동의를 얻을 필요가 없고, 포기시에 동의를 얻어야 한다.
- ③ [○] 제93조 제4항
- ④ [○] 제93조 제6항
- ⑤ [○] 제119조 제1항 제5호

정답 ②

150 상표권의 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 10 기출

- ① 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 않는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다.
- ② 상표권이 공유인 경우에 그 상표권에 관한 권리범위 확인심판을 청구하는 때에는 공유자 전원에게 대하여 공동으로 청구하여야 한다.
- ③ 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다.
- ④ 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다.
- ⑤ 상표등록원부에 공유상표권자로 등재되어 있는 상표권자 중 일부가 그 지분권을 포기하였다 하여도 그 포기가 등록되지 않은 상태에서 나머지 공유자들만이 존속기간갱신등록신청을 하는 경우에는 거절결정이 된다.

해설

- ① [○] 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 **합유와 유사한 성질**을 가지지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 **민법상의 공유의 규정이 적용**될 수 있다고 할 것이다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 [권리범위확인(상)]).
- ② [○] 제124조 제2항
- ③ [×] 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이더라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다(대법원 2004.12.9 선고 2002후567 판결).
- ④ [○] 제93조 제3항
- ⑤ [×] 2010년 개정법은 구법상 존속기간갱신등록출원을 존속기간갱신등록신청제도로 개정하였다. 이에 2010년 개정법은 구법 제45조(상표권의 존속기간갱신등록거절결정 및 거절이유통지)를 삭제하였으며, 이에 따라 현행법상 갱신등록신청이 '거절결정' 되는 경우는 있을 수 없다. 따라서, 일단 무조건 틀린 지문이 된다. 한편, 2019년 개정법은 구법과 달리 상표권이 공유인 경우 공유자 중 1인의 존속기간갱신신청을 허용하므로, 지문과 같이 상표등록원부에 공유상표권자로 등재되어 있는 상표권자 중 일부가 그 지분권을 포기하였다 하여도 그 포기가 등록되지 않은 상태(즉, 여전히 공유인 상태)에서 나머지 공유자들만이 존속기간갱신등록신청을 하는 경우에는 '갱신등록'을 받을 수 있다.

정답 ③, ⑤

151 상표권의 이전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

21 기출

- ① 단체표장권은 이전할 수 없다. 다만, 법인의 합병의 경우에는 지식재산처장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
- ② 단체표장권, 업무표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다.
- ③ 업무표장권은 이전할 수 없다. 다만, 그 업무와 함께 이전할 경우에는 지식재산처장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
- ④ 상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다.
- ⑤ 상표권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸, 존속기간의 갱신, 상품분류전환, 지정상품의 추가 또는 처분의 제한에 해당하는 사항은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.

해설

- ① [○] 제93조 제6항
- ② [○] 제95조 제2항
- ③ [×] 업무표장권은 양도할 수 없다. 다만, 그 업무와 함께 양도하는 경우에는 그러하지 아니하다(法 93④). 따라서 지식재산처장의 허가 여부는 이전의 요건이 아니다.
- ④ [○] 제93조 제1항
- ⑤ [○] 제96조 제1항 제1호.

정답 ③

152 상표법상 이전에 관한 설명으로 옳은 것은?

23 기출

- ① 국제등록 명의의 변경에 따라 국제등록 지정상품의 전부 또는 일부가 분할되어 이전된 경우에는 국제상표등록출원은 변경된 국제등록명의인에 의하여 각각 출원된 것으로 본다.
- ② 지식재산처장은 상표에 관한 절차가 지식재산처에 계속(繫屬) 중일 때 상표권 또는 상표에 관한 권리가 이전된 경우에는 그 상표권 또는 상표에 관한 권리의 승계인에게 그 절차를 속행(續行)하도록 하여야 한다.
- ③ 통상사용권은 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 받지 아니하고 설정행위로 정한 범위에서 이전할 수 있다.
- ④ 상표권자는 상표권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 상표권의 분할청구 전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우라도 그 상표권이 경매에 의하여 이전되는 경우 그 상표권에 대하여 통상사용권을 가지지 않는다.
- ⑤ 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날에 상표권이 소멸된다.

해설

- ① [○] 제184조 제2항
- ② [x] “~ 속행하게 할 수 있다”(法 21)이고, “속행하도록 하여야 한다”가 아니다.
- ③ [x] 통상사용권은 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권의 경우에는 상표권자 및 전용사용권자를 말한다)의 동의를 받지 아니하면 이전할 수 없다(法 97③).
- ④ [x] 상표권자(공유인 상표권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 상표권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 상표권의 분할청구 전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우에는 그 상표권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 상표권에 대하여 지정상품 중 사용하고 있는 상품에 한정하여 통상사용권을 가진다. 이 경우 상표권자는 경매 등에 의하여 상표권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 104의2).
- ⑤ [x] 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 **다음 날에** 상표권이 소멸된다(法 106①).

정답 ①

153 상표권 등의 분할 및 이전에 관하여 다음 중 옳은 것은?

'03 기출

- ① 전용사용권은 상표권자의 동의가 없어도 상속 기타 일반승계의 경우 또는 실시사업과 함께 이전할 수 있다.
- ② 상표권의 지정상품이 2이상인 경우 상표권을 지정상품별로 분할하는 것은 상표권이 소멸하기 전까지에 한하여 가능하다.
- ③ 유사한 2개의 등록상표 중 어느 하나만을 타인에게 이전하게 되면, 수요자로 하여금 상품 출처나 품질의 오인을 야기시키므로 유사한 상표는 함께 이전하여야 한다.
- ④ 전용사용권이 설정등록되어 있는 상표권에 대해 상표권자는 전용사용권자의 승낙을 얻지 아니하고도 상표권을 양도할 수 있다.
- ⑤ 유사상품인 a,b,c를 지정상품으로 하는 등록상표권자인 甲은 b에 관한 상표권만을 乙에게 양도할 수 있으나, 후일 乙의 승낙을 얻지 아니하면 c에 관한 상표권을 丙에게 양도할 수 없다.

해설

- ① [x] 전용사용권자는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 받지 아니하면 그 전용사용권을 이전할 수 없으며, 따라서 실시사업과 함께 이전하는 경우라도 상표권자의 동의를 받아야 한다(法 95⑤).
- ② [x] 원칙적으로 상표권이 소멸하기 전에 분할이 가능하나 무효심판이 청구된 경우에는 심결이 확정되기까지는 상표권이 소멸된 후에도 상표권을 분할 할 수 있다(法 94②).
- ③ [x] 상품에 대해서 유사한 경우 함께 이전하도록 하고 있으며(法 93①후단), 상표에 대해서는 이러한 제한이 없다. 다만, 이전 후 제119조 제1항 제5호가 문제될 수는 있다.
- ④ [○] 상표권 이전시에는 부수적 권리에 영향이 없으므로 전용사용권자의 승낙을 요하지 않는다.
- ⑤ [x] 상표권을 이전하는 경우는 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다(法 93①). 따라서, 유사상품인 a,b,c를 지정상품으로 하는 등록상표권자인 甲은 b에 관한 상표권만을 乙에게 양도할 수는 없고, 이를 위반한 경우 제119조 제1항 제4호 소정의 취소사유에 해당한다.

정답 ④

제8절 사용권 일반

95, 97, 100

154 상표권에 관한 전용사용권과 통상사용권에 대한 다음의 설명으로 옳은 것은 ? (다툼이 있는 경우에는 대법원 판례에 의함)

'06 기출

- ① 상표권에 관한 전용사용권은 그 설정계약이 해지되면 상표원부에 이를 등록하여야 소멸한다.
- ② 상표권에 관한 전용사용권이나 통상사용권의 설정은 이를 등록하여야만 효력이 발생한다.
- ③ 상표권에 관한 전용사용권과 통상사용권은 상속 기타 일반승계의 경우에도 상표권자의 동의를 얻어야만 이전할 수 있다.
- ④ 상표권에 관한 통상사용권은 이를 등록하더라도 그 등록 후에 상표권을 취득한 자에 대하여 효력이 없다.
- ⑤ 국제등록기초상표권의 경우에는 통상사용권자의 동의가 없어도 국제사무국에 국제등록을 포기함으로써 국제등록기초상표권을 포기할 수 있다.

해설

- ① [x] 2012년 개정으로 인하여 전용사용권의 소멸은 등록이 그 효력발생요건이 아니다. 따라서, 전용사용권은 그 설정계약이 해지되면 소멸하며, 등록을 요하지 않는다. (다만, 제100조 제1항에 따라 전용사용권의 '포기에 의한 소멸'은 등록이 제3자 대항요건이다.)
- ② [x] 전용사용권 또는 통상사용권의 설정은 등록이 제3자 대항요건이다(法 100①).
- ③ [x] 상속 기타 일반승계의 경우에는 상표권자의 동의는 필요 없다.
- ④ [x] 전용사용권 또는 통상사용권을 등록한 때에는 그 등록 후에 상표권 또는 전용사용권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다(法 100②).
- ⑤ [○] 국제사무국은 지정관청에 의한 확인절차를 거치지 아니하고 일방적으로 국제등록의 포기를 등록할 수 있으므로 국제등록기초상표권의 포기시에는 사용권자 또는 질권자의 동의를 요하지 않는다(法 203①).

정답 ⑤

155 다음은 상표법에서 규정하는 사용권에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

107 기출

- ① 상표권에 관한 통상사용권의 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다.
- ② 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우 그 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판을 누구든지 청구할 수 있다.
- ③ 전용사용권은 그 설정계약이 해지되면 등록여부에 관계없이 그 효력을 상실한다.
- ④ 전용사용권자는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 받지 아니하면 그 전용사용권을 이전할 수 없다.
- ⑤ 업무표장권과 단체표장권에 대하여는 전용사용권을 설정할 수 없다.

해설

- ① [○] 제97조 제1항
- ② [○] 제119조 제5항
- ③ [○] 2012년 개정으로 인하여 '전용사용권의 설정·이전(상속, 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한'은 등록이 제3자 대항요건에 불과하다. 따라서, 전용사용권의 설정이나 소멸은 등록과 무관하게 효력이 발생하므로 ③지문과 관련하여 전용사용권의 설정계약이 해지되면 등록여부에 관계 없이 그 효력을 상실한다(또한 이 경우는 포기에 의한 소멸이 아니므로 등록이 제3자 대항요건도 아니다). 나머지 지문은 이론의 여지없이 옳은 지문이므로 본 문제의 정답은 없다.
- ④ [○] 제95조 제5항
- ⑤ [○] 제95조 제2항

정답 없음

156 상표의 전용사용권과 통상사용권에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

'08 기출

- ① 전용사용권은 설정계약에 의해 이루어지고 등록에 의해 그 효력이 발생한다.
- ② 업무표장권이나 단체표장권에 대해서는 전용사용권과 통상사용권을 설정할 수 없다.
- ③ 상표권자에 의한 통상사용권 설정행위는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정의하고 있는 상표의 사용에 해당하지 않는다.
- ④ 상표법 제119조 제1항 제2호(전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용)의 규정에 해당함을 이유로 하는 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 누구든지 이를 청구할 수 있다.
- ⑤ 상표권자와 전용사용권 설정계약을 체결하고 동시에 상표권자로부터 통상사용권 설정에 대한 동의를 얻은 자는 전용사용권 설정등록 이전이라도 제3자에게 통상사용권 설정을 할 수 있다.

해설

- ① [×] 2012년 개정으로 인하여 전용사용권의 설정은 설정계약만으로 그 효력이 발생하고, 등록은 제3자 대항요건에 불과하다(法 100①).
- ② [○] 제95조 제2항, 제97조 제5항
- ③ [○] 상표권자에 의한 사용권의 설정행위 그 자체는 제2조 제1항 제11호 규정 상의 상표사용행위에 해당하지 않는다.
- ④ [○] 제119조 제5항
- ⑤ [○] 상표법상의 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있는데, 2012년 개정법은 전용사용권의 등록을 제3자 대항요건에 불과한 것으로 개정하였으므로, 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결하고 나아가 상표권자로부터 통상사용권 설정에 관한 사전 동의를 얻었다면 2012년 개정법상으로는 전용사용권 설정등록 이전이라도 등록상표의 전용사용권자로서 제3자에게 통상사용권을 설정하여 줄 수 있다. 따라서, 2012년 개정법상으로는 ⑤는 옳은 지문에 해당한다.

정답 ①

157 상표법의 사용권 제도에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 14 기출

- ① 상표권자는 그 상표권에 대하여 등록상표를 지정상품에 대하여 설정행위로 정한 범위 내에서 독점적으로 사용할 수 있는 전용사용권을 설정할 수 있으며, 전용사용권은 준물권적 권리이므로 등록하여야 효력이 발생한다.
- ② 전용사용권이 침해된 경우 전용사용권자는 침해금지청구, 손해배상청구 및 신용회복의 청구 등이 가능하나, 전용사용권자에게 그 사용권을 설정해 준 상표권자에게는 이를 행사할 수 없다.
- ③ 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자가 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있다면, 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있지 않더라도 선사용에 의한 통상사용권이 인정된다.
- ④ 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자는 상표사용의 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된다면 그 상표를 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 수 있다.
- ⑤ 상표법 제97조에 의한 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정해 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 이를 다시 설정하여 줄 수는 없다.

해설

- ① [×] 2012년 개정에 따라 전용사용권은 등록이 효력발생요건이 아니고 제3자 대상요건에 해당한다(法 100).
- ② [×] 전용사용권은 물권적 권리이므로 전용사용권이 침해된 경우 상표권자에게도 민형사상의 조치가 가능하다.
- ③ [×] 제99조 제1항의 선사용권은 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 한다.
- ④ [×] 제99조 제2항의 선사용권은 인식도와 무관하게 인정될 수 있다.
- ⑤ [○] 상표법상 통상사용권은 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하기는 하나(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 참조), 제95조 제6항 및 제97조 제1항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다(SHISEIDO 사건, 대법원 2012.4.12. 선고 2012후177 판결).

정답 ⑤

158 상표권자의 허락에 의한 사용권에 관한 설명으로 옳은 것은?

15 기출

- ① 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 상속하는 경우에는 지체없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고해야 한다.
- ② 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정한 경우 질권자는 당해 등록상표를 사용할 수 있다.
- ③ 전용사용권자는 반드시 그 상품에 자기의 성명이나 명칭을 표시하여야 하지만 통상사용권자는 그 상품에 자기의 성명이나 명칭을 표시할 의무가 없다.
- ④ 전용사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로서 등록을 하지 않더라도 효력이 발생하므로 등록을 하지 않은 전용사용권자는 그 후 상표권을 새롭게 양수 받은 양수인에 대하여도 그 효력을 주장할 수 있다.
- ⑤ 전용사용권자로부터 통상사용권 허락을 받은 통상사용권자는 전용사용권자의 동의를 얻으면 상표권자의 동의를 얻지 않더라도 그 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

해설

- ① [○] 제100조 제3항.
- ② [x] 상표권·전용사용권 또는 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 경우에는 질권자는 해당 등록상표를 사용할 수 없다(法 104).
- ③ [x] 전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다(法 95④ 및 97⑥).
- ④ [x] 전용사용권(또는 통상사용권)의 설정은 등록이 제3자 대항요건에 불과하나, 전용사용권의 설정 후 등록을 하지 않은 경우라면 그 후 상표권의 이전이 있는 경우 등록상표의 양수인에게 대항할 수 없어 등록상표의 양수인으로부터 허락을 얻지 않는 한 원칙적으로 당해 상표의 사용을 중지하여야 한다.
- ⑤ [x] 전용사용권에 관한 통상사용권에 있어서는 상표권자 및 전용사용권자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다(法 97④).

정답 ①

159 상표권의 전용사용권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 17 기출

- ① 상표권자는 특약이 없는 한 전용사용권이 설정된 범위 내에서 등록상표를 사용할 수 없지만 제3자의 무단사용행위에 대해서는 전용사용권 설정 후에도 침해금지를 청구할 수 있다.
- ② 업무표장권, 단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다.
- ③ 전용사용권의 설정등록은 효력발생요건이지만 그 이전등록은 제3자 대항요건에 불과하다.
- ④ 전용사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 반드시 표시하여야 하며, 법정사용권자인 선사용권자에게 자기의 상품과 출처의 오인이나 혼동을 방지하는데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.
- ⑤ 전용사용권자는 상표권자의 의사와 상관없이 이해관계인의 입장에서 상표권의 존속기간갱신등록 신청에 대한 상표등록료를 대납할 수 있다.

해설

- ① [○] 전용사용권이 설정된 상표의 상표권자도 제3자의 무단사용에 대한 금지를 청구할 수 있고 나아가 이 경우 전용사용권 침해로 인한 상표법 위반죄 외에 상표권 침해로 인한 상표법 위반죄가 함께 성립한다(대법원 2006.9.8. 선고 2006도1580 판결).
- ② [○] 제95조 제2항
- ③ [×] 전용사용권에 관한 사항은 등록이 효력발생요건이 아닌 제3자 대항요건에 불과하다(法 100①).
- ④ [○] 전용사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 하며(法 95④), 상표권자나 전용사용권자는 선사용권자(단, 제99조 제1항의 선사용권자에 한함)에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다(法 99③).
- ⑤ [○] 전용사용권자는 상표권자의 의사와 관계없이 이해관계인의 입장에서 상표권의 존속기간갱신등록신청에 대한 상표등록료를 대납할 수 있다(法 72②).

정답 ③

160 상표법상 사용권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

20 기출

- ① 상표권자가 '상표에 관한 어떠한 경우라도 독점적인 권리를 부여하지 않고, 다만 사용권자가 상표권자의 상표를 사용할 권리를 부여하며 사용권자의 상표사용에 대하여 상표침해의 책임을 묻지 않는다'는 내용으로 사용권을 설정한 경우에 제3자가 무단으로 상표를 사용하더라도 그 사용권자에 대한 상표법 제230조(침해죄)는 성립하지 않는다.
- ② 상표권 권리범위 전부에 대하여 전용사용권이 설정된 경우에 제3자가 그 상표를 정당한 법적 권한 없이 사용하면 전용사용권자가 금지청구권을 행사하므로 상표권자는 금지청구권을 상실한다.
- ③ 상표권자가 자신의 상표권에 설정된 질권을 상속받은 경우 상속에 관한 사항을 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다.
- ④ 상표권자 甲은 자신의 상표권에 대하여 조그만 개인 식당을 운영하던 아버지에게 전용사용권을 설정하여 주었는데, 아버지가 사망하여 전용사용권을 甲이 단독 상속하는 경우라면 상속에 관한 사항을 등록하여야 제3자에게 대항할 수 있다.
- ⑤ 상표권 권리범위 전부에 대하여 전용사용권을 설정한 경우라도 상표권자가 상표를 사용하는 것이라면 전용사용권의 침해가 성립되지 않는다.

해설

- ① [○] 지문의 조건을 보면, 상표권자가 '독점적 권리를 부여하지 않고 단지 사용권자가 상표권자의 등록상표를 사용할 권리만을 부여하여 사용권자의 사용에 침해 책임을 묻지 않겠다.'는 것으로 그 핵심은 준물권적 권리인 전용사용권이 아니라 채권적 권리에 불과한 통상사용권을 설정하였다는 것이다. 따라서, 제3자가 무단으로 상표를 사용해도 그 사용권자에 대한 침해죄 등은 성립될 수 없다.
- ② [x] 전용사용권이 설정된 경우에도 상표권의 소극적 효력은 제한되지 않는다고 할 것이므로 전용사용권을 설정한 상표권자도 침해금지청구 등을 행사할 수 있다.
- ③ [x] 상표권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(권리의 혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(法 96조 제1항 제2호). 한편, 지문의 경우 상표권자가 자신의 상표권에 설정된 질권을 상속받은 것이므로 해당 질권은 '권리의 혼동(서로 대립되는 두개의 법률상 지위가 동일인에게 귀속하는 것)에 의하여 소멸'되는 것이고, 따라서, 위 조문규정에 따라 등록하지 않아도 그 효력이 발생한다. 따라서, 틀린 지문이다.
- ④ [x] 전용사용권 또는 통상사용권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(法 100①(1)). 한편, 본 지문의 경우 상표권자가 해당 상표권에 대한 전용사용권을 상속한 것이므로 본 지문의 전용사용권 또한 위 3번 지문과 마찬가지로 '권리의 혼동에 의하여 소멸'되는 것이다. 그런데, 위 조문규정에 따라 전용사용권은 '포기에 의한 소멸'만이 등록이 제3자 대항요건이고 나머지 소멸사유는 등록이 제3자 대항요건이 아니므로 상속에 관한 사항을 등록하여야 제3자에게 대항할 수 있다는 본 지문은 틀린 지문이다.
- ⑤ [x] 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다(法 89). 따라서, 지문의 경우 전용사용권 침해가 성립된다.

정답 ①

161 상표법에 관한 설명으로 옳은 것은?

'23 기출

- ① 전용사용권 설정행위에 의하여 그 등록상표의 지정상품과 유사한 상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 권리가 취득될 수 있다.
- ② 전용사용권자는 상표권의 사용에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 그 지급 또는 인도 전에 그 대가나 물건을 압류하여 물상대위권을 행사할 수 있다.
- ③ 통상사용권자는 그 사용권을 지식재산처에 등록할 필요는 없으나 그 상품에 자신의 이름이나 명칭과 상표에 관한 표시를 하여야 한다.
- ④ 동일자로 출원된 특허권과 상표권이 상호 저촉되는 경우, 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 상표권의 통상사용권자는 상표를 사용할 권리를 가진 자에게 그의 업무에 관한 상품과 자기의 업무에 관한 상품 간에 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 청구할 수 있다.
- ⑤ 질권자가 질권의 목적인 상표권을 이전받은 경우, 권리의 혼동으로 인한 그 질권의 소멸은 등록하지 아니하더라도 그 효력이 발생한다.

해설

- ① [x] 사용권은 상표권의 전용권의 범위 내에서 설정되는 것이므로, 전용사용권의 설정행위에 의하여 지정상품과 동일한 상품에 대하여 등록상표를 독점적으로 사용할 권리가 취득되는 것이다(法 89). 따라서 유사한 상품에 대하여 사용할 권리가 취득되는 것은 아니다.
- ② [x] 물상대위권은 전용사용권이 아닌 질권에 인정되는 권리이다.
- ③ [x] 통상사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다(法 97⑥준용 95④). 따라서 지문상 상표에 관한 표시를 하여야 한다는 부분은 옳지 않다.
- ④ [x] 혼동방지표시의 청구를 할 수 있는 자는 "상표권자 또는 전용사용권자"이다(法 98④).
- ⑤ [○] 상표권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(권리의 혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(法 96①(2)). 따라서, 권리의 혼동으로 인한 질권의 소멸은 등록하지 아니하더라도 그 효력이 발생한다.

정답 ⑤

제9절 법정사용권

98, 99, 104의2

162 상표법상 제99조 제1항의 선사용권에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

08 기출

- ① 선사용자는 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있어야 한다.
- ② 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저히 인식되어 있어야 한다.
- ③ 상표권자나 전용사용권자는 선사용자에게 자기의 상품과 선사용자의 상품간의 출처의 오인이나 혼동을 방지할 수 있는 적당한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.
- ④ 선사용권은 일정요건만 갖추면 당연히 발생하는 법정사용권이므로 상표법상 통상사용권 허여의 심판제도는 적용되지 아니한다.
- ⑤ 선사용권은 2007년 7월 1일 이후 최초로 타인이 상표등록출원을 하여 등록되는 상표에 대하여만 인정되며 그 이전에 타인이 상표등록출원을 하여 등록된 상표에 대하여는 인정되지 않는다.

해설

- ① [○] 제99조 제1항, 제3항
- ② [x] 현저하게 인식될 필요는 없고 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있으면 족하다(法 99①2).
- ③ [○] 제99조 제1항, 제3항
- ④ [○] 법정사용권은 법정된 요건을 만족하면 효력이 바로 발생한다. 또한, 상표법에는 강제사용권 제도가 없다.
- ⑤ [○] 제99조 제1항은 2007년 개정법에서 도입된 제도인데, 2007년 개정법은 부칙 제1조 단서에 따라 2007년 7월 1일부터 시행되며 이에 따라 2007년 7월 1일 이후 출원되어 등록된 상표권에 대하여 선사용자가 본 규정에 따른 요건을 갖춘 때 적용된다. 제2항은 2013년 10월 6일부터 시행되었는데, 별도의 부칙이 없어 문제되나 특허법원은 2013년 10월 6일 이전에 출원되어 등록된 상표권에 대해서는 제99조 제2항을 적용할 수 없다고 보아야한다고 판시한바 있다(특허법원 2019. 9. 20. 선고 2018나1503 판결).

정답 ②

163 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

24 기출

- ① 제1항에 따른 선사용권은 엄격한 선출원주의 운영에 따른 문제점을 보완하여 사용주의와 선출원주의를 조화시킴으로써 상표의 정당한 선사용자를 보호하기 위한 것이다.
- ② 상표권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있지만, 제2항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게는 이러한 표시를 할 것을 청구할 수 없다.
- ③ 제1항에 따른 선사용권은 법정통상사용권이므로 상속과 같은 일반승계 또는 영업양도에 의하여 타인에게 이전되지 않는다.
- ④ 제2항에 따른 선사용권은 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있어야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 선사용권은 상표를 사용한 결과 타인의 상표설정등록 시가 아니라, 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라는 인식이 필요하다.

해설

- ① [○] 제99조 제1항 규정에 따른 선사용권은 등록상표의 출원 시에 이미 일정 수준의 인식도를 취득한 선사용자를 보호하기 위한 규정이다.
- ② [○] 제99조 제3항
- ③ [×] 제99조 제1항 규정에 따른 선사용권에 관한 이전의 허용여부와 그 조건에 대하여 명문의 규정은 없으나 제99조 제1항의 선사용권은 i) 명문의 규정상 ‘그 지위를 승계한 자’도 사용권을 가질 수 있으며, ii) 영업일체가 이전된 경우 그에 따른 신용도 함께 승계된 것으로 볼 수 있다는 점에서 해당 영업과 함께 이전되는 경우에는 이전이 가능하다고 봄이 타당하다.
- ④ [○] 제99조 제1항 제1호에 규정된 제1항 선사용권의 요건으로서, 이는 제1항 및 제2항 규정에 따른 선사용권의 공통 요건이다.
- ⑤ [○] 제99조 제1항 제2호

정답 ③

제10절 질권

104, 105

164 상표법상 질권의 설정 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

26 기출

- ① 상표법 제100조(전용사용권·통상사용권 등의 등록의 효력) 제1항에 따른 상속에 의한 통상사용권 이전의 경우 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.
- ② 상표권을 목적으로 하는 질권이 상속에 의하여 이전된 경우, 등록하지 아니하여도 그 효력이 발생한다.
- ③ 상표권 또는 전용사용권뿐만 아니라 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정한 경우에도 질권자는 해당 등록상표를 사용할 수 없다.
- ④ 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
- ⑤ 업무표장권을 목적으로 하는 질권은 설정할 수 있다.

해설

- ① [○] 전용사용권·통상사용권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다(法 100③).
- ② [○] 상표권의 이전은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. 다만, 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 등록하지 않더라도 효력이 발생한다(法 96①1괄호). 이 경우 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다(法 96②).
- ③ [○] 상표권·전용사용권 또는 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 경우에는 질권자는 해당 등록상표를 사용할 수 없다(法 104).
- ④ [○] 제93조 제2항, 상표권이 공유인 경우 "1)지분의 양도, 2)질권의 설정, 3)전용·통상 사용권의 설정"에 있어서는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 한다.
- ⑤ [×] 업무표장, 증명표장, 단체표장, 예외적 본인 등록표장(法 34①1다목 단서, 라목 단서, 3호 단서)에 대해서는 질권을 설정할 수 없다(法 93⑧). 상기 표장들에 대해서는 예외적 본인등록 표장을 제외하고는 사용권 역시 설정할 수 없다(法 95②, 97⑤).

정답 ⑤

제3장 소멸

제11절 상표권의 소멸

106

165 다음 중 상표권의 소멸사유가 아닌 것만으로 바르게 묶여진 것은?

03 기출

- ㉠ 지식재산처장의 직권에 의한 상표등록의 취소
- ㉡ 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 이전등록을 하지 아니한 경우
- ㉢ 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품의 일부 또는 전부에 대하여 전환등록신청을 하지 아니한 경우
- ㉣ 상표권의 존속기간만료일의 다음 날에 존속기간 갱신등록신청을 한 경우
- ㉤ 후발적 무효사유를 이유로 하는 상표등록의 무효심결이 확정된 경우
- ㉥ 상표권의 설정등록일부터 4년차 이후의 등록료를 납부하지 않은 경우
- ㉦ 갱신신청에 대한 상표등록료를 불납하였다가 그 후 적법하게 상표등록료를 추납한 경우

- ① ㉠, ㉡, ㉣ ② ㉠, ㉢, ㉥, ㉦ ③ ㉢, ㉤, ㉥
- ④ ㉠, ㉢, ㉥, ㉦ ⑤ ㉠, ㉤, ㉦

해설 상표권의 소멸 사유에는 i) 존속기간의 만료 또는 등록료의 분할납부시 2회차 등록료 미납으로 인한 소멸, ii) 상표권의 포기, iii) 상속인의 부존재, iv) 상속인의 이전등록불이행 및 법인의 소멸에 따른 상표권의 소멸, v) 상표등록취소심결의 확정, vi) 상품분류전환등록이 없는 경우, vii) 무효심결이 확정된 경우 등이 있다. ㉠ 취소사유에 해당되더라도 취소심판을 통해서 심결이 확정된 때에 소멸되며 지식재산처장 직권에 의해 취소시킬 수는 없다. ㉡ 존속기간갱신등록신청은 존속기간이 끝난 후 6개월까지는 가능하다(法 84②). ㉢ 상표법은 특허법과는 달리 등록료를 일시에 납부하거나 2회로 분할납부하는 경우만이 존재하므로 4년차 이후 등록료(연차료) 불납에 의하여 상표권이 소멸되는 경우는 없다. 다만, 만약 지문이 “상표권의 설정등록일로부터 5년차 이후의 등록료를 납부하지 않은 경우”라고 표현되어 있다면 그 표현이 명백한 것은 아니나 이는 분할납부시 2회차 등록료를 납부하지 않은 경우를 의미하는 것으로 볼 여지가 충분하고 이와 같이 해석하는 범위에서는 소멸사유로서 맞는 지문으로 볼 수 있다. ㉤의 경우 갱신신청에 대한 상표등록료를 불납하였다 하여도 제77조의 규정에 따라 ‘적법하게’ 추납을 하였다면 소멸사유에 해당되지 않는다. 따라서 답은 ㉠㉡㉤㉦ ㉣로 조합된 ④이다.

정답 ④

166 상표법상 상표권 소멸에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

11 기출

- ㄱ. 상표권은 그 설정등록일로부터 10년이 되는 날의 다음 날이 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의한 ‘근로자의 날’인 경우에는 그 ‘근로자의 날’의 다음 날(공휴일이 아님) 소멸한다.
- ㄴ. 통상사용권을 설정한 상표권자는 통상사용권자의 동의를 얻어야만 상표권을 포기할 수 있다.
- ㄷ. 상표권의 포기에 의한 소멸은 이를 등록하지 아니하여도 그 효력이 발생한다.
- ㄹ. 상품분류전환등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우, 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 관한 상표권은 제209조(상품분류전환등록의 신청) 제3항에 따른 상품분류전환등록신청기간의 만료일이 속하는 존속기간의 만료일 다음 날에 소멸한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

해설

- ㄱ. [x] 제16조 제4호는 “상표에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(토요일 및 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날을 포함한다)이면 기간은 그 다음 날로 만료한다.”라고 규정하고 있다. 한편, 위 규정은 명문의 규정 그대로 “상표에 관한 절차”에 대하여만 그 적용이 있으므로 상표권의 존속기간 등과 같은 상표의 권리에 관련된 기간은 기간의 말일이 공휴일이라도 다음날에 만료되는 것이 아니라 원래의 해당일로 종료된다.
- ㄴ. [○] 상표권자는 전용사용권자·통상사용권자 또는 질권자의 동의를 받지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다(法 102①).
- ㄷ. [x] 상표권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·「포기에 의한 소멸」, 존속기간의 갱신, 상품분류전환, 지정상품의 추가 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(法 96①).
- ㄹ. [○] 제213조 제1항

정답 ④

167 상표권의 소멸에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

18 기출

- ① 상표권자가 사망한 경우 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 상표권의 이전등록을 하지 아니하면 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날에 상표권이 소멸한다.
- ② 상표원부에 상표권자인 법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 상표권의 말소등록이 이루어진 경우, 이러한 상표권의 말소등록행위는 항고소송의 대상이 될 수 있다.
- ③ 상품분류전환등록신청이 취하된 경우 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 관한 상표권은 상품분류전환등록신청기간의 만료일이 속하는 존속기간의 만료일 다음 날에 소멸한다.
- ④ 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품으로서 상품분류전환등록신청서에 기재되지 아니한 지정상품에 관한 상표권은 상품분류전환등록신청서에 기재된 지정상품이 전환등록 되는 날의 다음 날에 소멸한다.
- ⑤ 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결등기일까지 상표권의 이전등록을 하지 아니하면 청산종결등기일에 소멸한다.

해설

- ① [x] 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 '다음 날'에 상표권이 소멸된다(法 106①).
- ② [x] 상표권자인 법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 한 상표권의 말소등록행위는 항고소송의 대상이 될 수 없다(대법원 2015.10.29. 선고 2014두2362 판결).
- ③ [○] 제213조 제1항
- ④ [x] 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품으로서 상품분류전환등록신청서에 적지 아니한 지정상품에 관한 상표권은 상품분류전환등록신청서에 적은 지정상품이 '전환등록 되는 날'에 소멸한다(法 213조 제2항 본문).
- ⑤ [x] 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결등기일까지 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 '다음 날'에 소멸된다(法 106③).

정답 ③

168 상표법상 상표권의 소멸에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 19 기출

- ㄱ. 상표권자는 전용사용권자·통상사용권자 또는 질권자의 동의를 받지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다. 다만, 국제등록기초상표권에 대해서는 이러한 내용이 적용되지 않는다.
- ㄴ. 상표권의 포기를 하였을 경우에는 상표권은 그때부터 소멸되므로 상표권의 포기에 대한 등록이 없어도 그 효력이 발생한다.
- ㄷ. 상표권자가 사망한 날부터 1년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다.
- ㄹ. 선출원상표가 등록 후 무효심결이 확정된 경우에는 선출원의 지위를 소급적으로 상실한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄹ

- 해설 ㄱ. [○] 상표권자는 전용사용권자·통상사용권자 또는 질권자의 동의를 받지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다(法 102①). 다만, 국제등록기초상표권에 대해서는 제102조 제1항을 적용하지 아니한다(法 203①).
- ㄴ. [x] 상표권의 포기는 등록이 효력발생 요건이다(法 96①(1)).
- ㄷ. [x] 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다(法 106①).
- ㄹ. [○] 선출원의 상표가 등록된 후 그 상표에 대한 등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록과 그로부터 발생한 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로 선출원이 처음부터 등록에 이르지 못하고 소멸된 경우와 마찬가지로 선출원 상표로서의 선원의 지위는 소급적으로 상실된다(대법원 2002.01.08. 선고 99후925 판결).

정답 ③

제4장 관련제도

제12절 존속기간 갱신등록

84, 85, 88①

169 甲은 신사복과 블라우스를 지정상품으로 하여 PARADISE라는 상표를 2001년 6월 22일 출원하여 2002년 6월 15일 등록 받았다. 이와 관련하여 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

02 기출

- ① 위 상표권의 존속기간만료일은 2012년 6월 15일이다.
- ② 위 상표권의 존속기간갱신등록을 위하여 甲은 늦어도 2012년 12월 15일까지는 상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.
- ③ 甲은 위 지정상품을 각각 신사복과 블라우스로 분할하여 상표권의 존속기간 갱신등록신청을 할 수 있다.
- ④ 위 상표권의 존속기간갱신등록신청을 甲이 2012년 5월 4일 신청하여 2012년 9월 10일 갱신등록을 받았다면 현행 상표법에 의할 경우 甲은 다음 존속기간갱신 등록신청을 2023년 3월 10일까지 할 수 있다.
- ⑤ 만일 위 상표권의 존속기간중 甲이 그 지분을 乙에게 이전하여 상표권의 소유자가 甲과 乙 공유로 되었다면 위 상표권의 존속기간갱신등록신청은 甲과 乙이 공동으로 하여야 한다.

- 해설**
- ① [○] 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년이다(法 83①). 따라서, 甲의 상표권의 존속기간만료일은 2012년 6월 15일이다.
 - ② [○] 상표권의 존속기간갱신등록신청은 존속기간 만료 전 1년 이내가 원칙이나 존속기간이 끝난 후 6개월 까지도 할 수 있다(法 84②단서). 따라서, 甲은 늦어도 2012년 12월 15일까지는 상표권의 존속기간 갱신등록신청을 할 수 있다.
 - ③ [×] 2010년 개정 전의 구법과 달리 2010년 개정법상으로는 지정상품이 2 이상인 경우에 분할하여 존속기간 갱신등록 신청을 할 수는 없다.
 - ④ [×] 상표권의 존속기간 갱신등록이 적법하게 이루어진 경우에는 상표권의 존속기간 만료일의 다음날부터 다시 10년간 상표권이 존속하므로, 차회 존속기간의 만료일은 2022년 6월 15일이고, 제84조 제2항 단서에 의해 다음 존속기간 갱신등록신청은 2022년 12월 15일까지 할 수 있다.
 - ⑤ [×] 2019년 개정법은 “상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다(舊法 84④).”는 규정을 삭제하였고, 2023년 개정법은 상표권이 공유인 경우 공유자 중 1인의 존속기간갱신등록신청을 명문으로 허용하고 있다(法 84①).

정답 ③, ④, ⑤

170 상표권의 존속기간갱신에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

'08 기출

- ① 지정상품이 2 이상인 상표권에 대하여는 이를 분할하여 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.
- ② 존속기간갱신등록신청에 대하여는 상표법 제39조(절차의 보정)를 준용하지 아니한다.
- ③ 존속기간갱신등록신청에 있어서 거절이유가 없는 것은 출원공고된다.
- ④ 상표권자가 아닌 사람이 한 갱신등록신청에 의하여 등록되었다는 것을 이유로 갱신등록 무효심판을 청구하는 때에는 5년의 제척기간 내에 청구하여야 한다.
- ⑤ 존속기간갱신등록신청에 대하여는 실체심사를 하지 아니한다.

해설

- ① [x] 2010년 개정법은 구법 제44조를 삭제하였으므로, 등록상표의 지정상품이 2 이상의 상품으로 되어 있는 경우라도 이를 분할하여 존속기간갱신등록신청을 할 수 없다. 다만, 2 이상의 지정상품 중 일부의 지정상품에 한하여 존속기간갱신등록신청을 할 수는 있다.
- ② [x] 존속기간갱신신청에 대하여도 제39조(절차의 보정)는 준용된다(法 88①).
- ③ [x] 존속기간갱신등록신청에 대하여는 출원공고가 준용되지 않는다.
- ④ [x] 존속기간갱신등록무효사유에는 해당되나(法 118①2), 이 경우는 5년의 제척기간이 없다.
- ⑤ [○] 2010년 개정 상표법은 구법상의 존속기간갱신등록출원제도를 **신청제도**로 간소화하여 완전한 의미의 실체심사를 수행하지 않는 제도로 변경하였다.

정답 ⑤

171 상표권의 존속기간갱신등록 및 신청에 관한 설명으로 옳은 것은?

13 기출

- ① 등록상표의 지정상품이 2 이상인 경우 이를 분할하여 상표권의 존속기간갱신등록 신청을 할 수 있다.
- ② 상표권의 존속기간갱신등록신청은 상표권자뿐만 아니라 전용사용권자도 할 수 있다.
- ③ 상표권의 존속기간갱신등록을 무효로 하는 심결이 확정된 경우, 설정등록에 의하여 발생한 상표권은 갱신되기 전 상표권의 존속기간이 종료하였을 때 소멸한다.
- ④ 상표등록원부에 공유상표권자로 등재되어 있는 상표권자 중 일부가 존속기간갱신등록신청의 포기의사를 표시하더라도 그 포기가 등록되지 않은 상태에서 나머지 공유자들만으로 존속기간갱신등록신청을 한 경우에 그 등록상표는 갱신된다.
- ⑤ 국제등록기초상표권의 존속기간은 국내에서의 상표권의 설정등록이 있는 날부터 국제등록일 후 10년이 되는 날까지이며, 국제등록기초상표권에 대해서도 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판에 관한 규정이 적용된다.

해설

- ① [x] 상표권을 분할하여 존속기간갱신등록신청을 하거나, 존속기간갱신등록신청을 분할하는 것은 허용되지 않는다(法 88①).
- ② [x] 존속기간갱신등록신청은 상표권자만(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)이 할 수 있다(法 84①).
- ③ [○] 존속기간갱신등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 존속기간갱신등록은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 118③). 따라서, 옳은 지문이다.
- ④ [○] 2019년 개정법은 상표권이 공유인 경우 공유자 중 1인에 의한 존속기간갱신등록신청을 허용한다. 따라서, 지문과 같이 “상표등록원부에 공유상표권자로 등재되어 있는 상표권자 중 일부가 존속기간갱신등록신청의 포기의사를 표시하더라도 [(그 포기가 등록되지 않은 상태에서) → 존속기간갱신등록신청의 포기의사는 등록사항이 아니므로 이 부분은 아무런 의미가 없는 부분으로 무시하고 읽으면 됨] 나머지 공유자들만으로 존속기간갱신등록신청을 한 경우에 그 등록상표는 갱신된다.”는 지문은 옳은 지문이 된다.
- ⑤ [x] 제204조에 따라 국제등록기초상표권에 대해서는 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판에 관한 규정이 적용되지 않는다.

정답 ③, ④

172 상표권의 존속기간과 존속기간갱신등록신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 14 기출

- ① 甲과 乙이 상표권을 공유하는 경우, 甲 또는 乙 단독에 의한 존속기간갱신등록신청도 허용된다.
- ② 상표권의 존속기간갱신등록은 원등록의 효력이 끝나는 다음 날부터 효력이 발생한다.
- ③ 존속기간갱신등록은 존속기간갱신등록신청서의 제출과 갱신등록료의 납부만으로 별도의 실체심사 없이 가능하다.
- ④ 등록상표의 지정상품이 2 이상인 경우 존속기간은 각 지정상품에 대하여 동일하여야 하므로, 일부의 지정상품만에 대하여는 존속기간갱신등록신청을 할 수 없다.
- ⑤ 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 하며, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.

해설

- ① [○] 2019년 개정법은 상표권이 공유인 경우 공유자 중 1인의 존속기간갱신등록신청을 허용하고 있다(法 84①괄호).
- ② [○] 존속기간갱신등록은 원등록(原登錄)의 효력이 끝나는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다.(法 85②)
- ③ [○] 존속기간갱신등록에 있어 별도의 실체심사를 수행하지 않는다. 따라서, 후발적으로 식별력이 상실되었다고 하더라도 존속기간의 갱신은 가능하다. 다만, 후발적 무효사유를 이유로 무효심결에 의해 상표권이 소멸될 수 있을 뿐이다.
- ④ [×] 등록상표의 지정상품이 2 이상의 상품으로 되어 있는 경우라도 이를 분할하여 존속기간갱신등록신청을 할 수 없으며, 나아가 존속기간갱신등록신청 후 이를 2 이상의 존속기간갱신등록신청으로 분할할 수 없다. 다만, 이와 무관하게 2 이상의 지정상품 중 일부의 지정상품에 한하여 존속기간갱신등록신청을 할 수 있음은 물론이다. 따라서 옳지 않은 지문이다.
- ⑤ [○] 제84조 제2항.

정답 ④

173 상표권의 존속기간과 존속기간갱신등록에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

22 기출

- ① 상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 10년이지만 10년씩 갱신하여 영구적 독점이 가능하다.
- ② 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 할 수 있다.
- ③ 상표권이 공유인 경우 공유자는 단독으로 상표권 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.
- ④ 상표법 제84조(존속기간갱신등록신청) 제2항에 따른 기간에 존속기간갱신등록신청을 하면 상표권의 존속기간이 갱신된 것으로 보며, 존속기간갱신등록은 원등록(原登錄)의 효력이 끝나는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다.
- ⑤ 존속기간갱신등록신청에 대해서는 실체심사를 하지 아니하므로 1상표 1출원(제38조), 절차의 보정(제39조) 등 상표등록출원의 심사에 따른 규정이 준용되지 아니한다.

해설

- ① [○] 제83조 제1항 및 제2항
- ② [○] 제84조 제2항
- ③ [○] 상표권이 공유인 경우 2019년 개정 전의 구법은 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다고 규정하였으나(舊法 84③), 2019년 개정법은 이러한 규정을 삭제함과 아울러 2023년 개정법은 상표권자 중 1인의 명시적 청구권을 인정하여 공유자 중 1인이 단독으로 존속기간갱신등록을 신청할 수 있도록 하였다.
- ④ [○] 제85조
- ⑤ [x] 존속기간갱신등록신청은 실체심사가 존재하지 아니하므로 지문의 제38조를 포함하여 실체보정에 관한 제40조 및 제41조 등은 당연히 준용되지 아니하나, 절차의 보정에 관한 제39조는 준용한다(法 88①).

정답 ⑤

174 상표권의 존속기간갱신에 관한 설명으로 옳은 것은?

24 기출

- ① 상표법 제84조(존속기간갱신등록신청) 제2항에 따른 기간에 존속기간갱신등록신청을 하면 갱신등록이 되기 전이라고 하더라도 상표권의 존속기간이 갱신된 것으로 본다.
- ② 상표권의 공유자 중 일부가 그 지분권을 포기하였으나 그 포기가 등록되지 않은 경우에, 나머지 상표권의 공유자들이 존속기간갱신등록신청을 하여 상표권이 갱신된 경우에는 존속기간갱신등록무효심판의 대상이 된다.
- ③ 상표권의 전용사용권자는 상표권의 이해관계자로 상표권자가 존속기간갱신등록신청을 하지 않는 경우에 상표권자 대신에 상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.
- ④ 상표권 존속기간갱신등록이 상표법 제84조(존속기간갱신등록신청) 제2항에 따른 존속기간 갱신등록 신청서를 제출해야 하는 기간에 제출하지 않은 경우에 상표권 존속기간 갱신등록이 되면 당연무효에 해당하므로 이해관계인은 제척기간에 관계없이 존속기간 갱신등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 존속기간갱신등록은 원등록(原登錄)의 효력이 끝나는 날부터 효력이 발생한다.

해설

- ① [○] 존속기간갱신등록**신청**의 효과 → 존속기간이 갱신된 것으로 본다(法 85①). / 존속기간갱신등록의 효과 → 원등록의 효력이 끝나는 다음 날부터 효력이 발생한다(法 85②).
- ② [×] 존속기간갱신등록신청인은 해당 등록상표의 상표권자이어야 한다. 한편, 상표권이 공유인 경우 2019년 개정 전의 구법은 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다고 규정하였으나(舊法 84③), 2019년 개정법은 이러한 규정을 삭제하여 **공유자 중 1인이 단독으로 신청할 수 있도록 하였다**. 이는 공유자 중 일부의 소재가 불분명하거나 일방 당사자가 악의적으로 갱신등록신청을 거부하면 상표권의 갱신이 불가능한 불합리를 해소하고자 함이다. 이에 따라 “상표권 또는 그 지분의 포기는 등록을 하여야만 효력이 발생하므로(法 96①1), 상표권의 공유자 중 일부가 그 지분권을 포기하였다 하더라도 그 포기가 등록되지 않은 상태(즉, 여전히 공유인 상태)에서 나머지 공유자들만이 존속기간갱신등록신청을 하여 등록된 경우에는 존속기간갱신등록무효심판의 대상이 된다.”는 구법상의 대법원 판례(대법원 2004. 5. 28. 선고 2003후564 판결 등)는 이제 개정법상으로는 잘못된 판례가 되었다.
- ③ [×] 존속기간갱신등록신청인은 해당 등록상표의 상표권자이어야 한다.
- ④ [×] 갱신등록신청의 시기적 요건에 위반하였음을 이유로 존속기간갱신등록무효심판을 청구하는 경우에는 5년의 제척기간이 적용된다(法 122①).
- ⑤ [×] 존속기간갱신등록은 원등록(原登錄)의 효력이 끝나는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다(法 85②).

정답 ①

제13절 지정상품 추가등록

86, 87, 88②

175 다음 중 상표권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

04 기출

- ① 상표권의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 그 상표권을 지정상품별로 분할할 수 있다.
- ② 상표등록의 무효심판은 상표권이 소멸한 경우에도 청구할 수 있다.
- ③ 업무표장권 또는 단체표장권을 목적으로 하는 질권의 설정은 허용되지 아니한다.
- ④ 상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있으며, 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다.
- ⑤ 상표권자의 동의가 있다면 전용사용권자에 의한 지정상품의 추가등록출원도 적법하다.

해설

- ① [○] 제94조 제1항
- ② [○] 제117조 제2항
- ③ [○] 제93조 제8항
- ④ [○] 제93조 제1항
- ⑤ [×] 지정상품추가등록출원은 상표권자 또는 상표출원인만이 할 수 있다(法 87①2).

정답 ⑤

제7편 심판

주 · 제 · 별

리답상표법 객관식 문제집

제1절 일사부재리

150

176 상표법상 일사부재리 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 21 기출

- ① 상표법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 경우에 그 사건에 대해서 이해관계인은 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 다시 심판을 청구할 수 있다.
- ② 확정심결에 일사부재리의 효력을 인정하는 이유는 서로 모순·저촉되는 심결방지와 확정심결의 신뢰성확보·권위 유지, 심판청구의 남발 방지, 확정심결에 대한 법적 안정성에 있다.
- ③ 확정심결의 일사부재리는 심결당사자, 그 승계인뿐만 아니라 제3자에 대하여도 대세적 효력이 있다.
- ④ 대법원은 동일 증거에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로, 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 반하지 않는다고 판시하였다.
- ⑤ 대법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지의 판단 시점을 '심결시'에서 '심판청구시'로 변경하였다.

해설

- ① [x] 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 경우에는 그 사건에 대해서는 '누구든지' 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다(法 150). 따라서 틀린 지문이다.
- ② [○] 일사부재리의 취지에 관한 설명으로서 옳은 지문이다.
- ③ [○] 제150조의 규정에 따라 일사부재리에는 대세효가 있음은 당연하다.
- ④ [○] 대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결
- ⑤ [x] 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결. 다만, 최근 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결은 위 2009후2234 전원합의체 판결이 '선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 (과거 대법원의 입장인) 심결시에서 심판청구시로 변경한 것'이며, 따라서 일사부재리의 요건 중 후 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것인지는 여전히 과거 대법원 판결에 따라 '심결시'를 기준으로 판단하여야 한다고 하였다. 즉, 완벽한 지문이 되기 위해서는 "대법원은 일사부재리의 원칙 중 「선행심결의 확정여부에 관한 판단 시점」을 '심결시'에서 '심판청구시'로 변경하였다."라고 주어져야 하는데, 해당 지문은 '선행심결의 확정여부에 관한 판단시점'이라는 판단조건을 명확히 주지 않았다는 점에서 문제되고, 결국 이의신청에 의하여 복수정답 처리되었다.

정답 ①, ⑤

177 상표법상 심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

'25 기출

- ① 상표등록의 무효심판, 존속기간갱신등록무효심판, 상표등록취소심판, 권리범위 확인심판, 상품분류전환등록무효심판에서 심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 각자 또는 그 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.
- ② 공동심판 청구인이나 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있을 경우 그 효력은 모두에 대하여 발생한다.
- ③ 심판관은 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리를 할 수 있다.
- ④ 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있으며, 이 경우 피청구인이 답변서를 제출하였더라도 상대방의 동의를 받지 않아도 된다.
- ⑤ 상표등록의 무효심판을 청구하고자 하는 자는 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

해설

- ① [○] 제124조 제1항
- ② [○] 제124조 제4항
- ③ [○] 제146조 제1항
- ④ [×] 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 제133조 제1항에 따른 답변서가 제출된 경우에는 상대방의 동의를 받아야 한다(法 148①).
- ⑤ [○] 제125조 제1항.

정답 ④

제3절 거절결정에 대한 심판

116, 123, 154, 156

178 상표의 심판에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

'09 기출

- ① 거절결정에 대한 심판청구와 동시에 보정을 하였으나 요지변경이라는 이유로 보정각하 된 경우에는 별도의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 적극적 권리범위 확인심판의 심결이 확정된 경우 동일 권리에 대한 소극적 권리범위 확인 심판에 대하여는 일사부재리의 효력이 미치지 않는다.
- ③ 거절결정에 대한 심판이 청구된 경우 그 거절결정이 등록이의신청에 의한 것일 때에는 특허심판원장 또는 심판장이 이의신청인에게 통지하여야 하며 이의신청인은 당해 심판에 참가할 수 있다.
- ④ 권리범위 확인심판에서 진정상품병행수입의 항변 또는 권리남용의 항변도 심리대상에 포함된다.
- ⑤ 거절결정에 대한 심판이 청구되고 그 청구일로부터 30일이 경과한 후에 그 지정상품 중 일부를 삭제하는 보정을 하고자 할 경우에는 심판장으로부터 기간연장 승인을 받아야 한다.

- 해설
- ① [x] 심사단계에서의 보정에 대한 '심사관'의 보정각하결정에 대하여는 '심판'으로 불복함이 원칙이나(法 115), 상표법은 제162조 제1항에서 "심결에 대한 소와 제123조 제1항(法 161조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 준용되는 제42조 제1항에 따른 보정각하결정 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다."라고 규정하고 있기에, 거절결정불복심판단계에서의 보정에 대한 '심판관'의 보정각하결정(法 123조 제1항에 따라 준용되는 제42조 제1항에 따른 보정각하결정)에 대하여는 심판이 아닌 '특허법원의 소송'으로 불복하여야 한다.
 - ② [x] 판례는 등록상표와 확인대상표장이 동일한 이상 적극적 권리범위 확인심판의 심결이 확정된 때에는 그 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위 확인심판 청구에 대해서도 그대로 미치는 것이라 보고 있다.
 - ③ [x] '특허심판원장'은 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판이 청구된 경우 그 거절결정이 이의신청에 의한 것일 경우에는 그 취지를 이의신청인에게 알려야 하며(法 126③), 거절결정불복심판에서는 어떠한 경우라도 참가가 불가능하다.
 - ④ [x] 권리범위 확인심판은 단순히 그 상표자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이나, 침해여부에 대한 직접적인 판단은 아니다. 따라서, 침해에 대한 직접적인 판단의 문제인 진정상품병행수입의 항변 또는 권리남용의 항변은 권리범위 확인심판의 심리대상이 아니다.
 - ⑤ [x] 심판단계에서의 보정은 거절결정불복심판청구일로부터 30일 또는 당해 심판에서 주어진 의견서제출 기간 내에 할 수 있을 뿐이므로 ⑤는 옳지 않은 지문이다.

정답없음

179 甲는 ‘마르샤’라는 상표를 ‘비누’를 지정상품으로 하여 2008년 6월 2일 상표등록출원을 하여 2009년 3월 16일에 등록받았다. 그러나 甲의 등록상표 ‘마르샤’는 2009년 6월 5일 무효심판이 청구되어 2010년 9월 15일 무효심결이 확정되었다. 한편, 乙은 ‘마르셀’이라는 상표를 ‘비누’를 지정상품으로 하여 2008년 8월 1일 상표등록출원을 하였으나, 심사관은 乙의 표장과 지정상품이 甲의 표장과 지정상품과 유사하다고 판단하여 상표법 제35조(선출원) 위반을 이유로 2009년 5월 11일 거절결정을 하였다. 이에 乙은 거절결정불복심판을 청구하였다. 심사관은 2011년 1월 7일 乙의 거절결정불복심판에 대한 심결을 하려고 한다. 주어진 상황만을 고려할 때 예측되는 결과로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

‘14 기출

- ① 인용심결 ② 각하심결 ③ 기각심결 ④ 일부인용심결 ⑤ 거절결정

해설

대법원은 일관하여 “선출원의 상표가 등록된 후 그 상표에 대한 등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록과 그로부터 발생한 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로 선출원이 처음부터 등록에 이르지 못하고 소멸된 경우와 마찬가지로 선출원 상표로서의 선원의 지위는 소급적으로 상실된다.”라고 판시하고 있는바, 선출원상표가 등록 후 무효심결이 확정되어 소급 소멸된 경우에는 제35조 선출원의 지위를 상실한다. 따라서, 乙은 심결시(결정시)를 기준으로 하여 제35조의 거절이유가 없으므로 심판부는 인용심결을 내려야 한다.

정답 ①

180 상표법상 심결취소소송에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 25 기출

- ① 해당 심판(재심)에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자는 제162조(심결 등에 대한 소)에 따른 심결취소소송에서 원고적격을 갖지 못한다.
- ② 거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에는 민사소송법상 보조참가에 관한 규정이 준용되지 않는다.
- ③ 심결취소판결의 확정 이후 특허심판원의 재심리과정에서 취소판결에서의 취소의 기본이 된 이유에 따라 한 심결에 대하여 새로운 사실의 주장이나 입증이 없더라도 그 적법 여부를 다룰 수 있다.
- ④ 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 주요사실에 대한 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립할 수 있고, 사실에 대한 법적 판단 내지 평가도 자백의 대상이 된다.
- ⑤ 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송에서 지식재산처장은 거절결정의 이유 외에 심사나 심판 단계에서의 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유는 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있다.

해설

- ① [X] 심결 등에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자만 제기할 수 있다(法 162②).
- ② [X] 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 행정소송에 해당한다(대법원 2005. 7. 28. 선고 2003후922 판결 참). 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제71조는 보조참가에 관하여 소송결과에 이해관계가 있는 자는 한쪽 당사자를 돕기 위하여 법원에 계속중인 소송에 참가할 수 있다고 규정하고 있으므로, 거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에도 민사소송법상의 위 보조참가에 관한 규정이 준용된다. 원심이 참가인의 보조참가를 허용한 것은 이러한 법리에 기초한 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 보조참가에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다(대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결).
- ③ [X] 취소판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(法 165③).
- ④ [X] 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되고, 따라서 자백 또는 의제자백도 인정되나, 자백의 대상은 사실이고 이러한 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다.
- ⑤ [O] 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차(심결취소소송)에서 지식재산처장은 i) 거절결정의 이유 외에도 ii) 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 iii) 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다. 그리고 상표등록이의신청서에 기재되어 출원인에게 송달됨으로써 답변서 제출의 기회가 주어진 사유는 의견서 제출의 기회가 부여된 사유로 볼 수 있다(W-CONCEPT 사건, 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결).

정답 ⑤

제4절 상표등록의 무효심판

117, 122①

181 상표법 제34조에서 정하고 있는 부등록사유 중 무효심판청구에 있어 제척기간의 적용(상표법 제122조 제1항)을 받는 사유가 아닌 것은?

*05 기출

- ① 저명한 타인의 성명, 명칭 등을 포함하는 상표
- ② 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표
- ③ 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표
- ④ 수요자간에 현저하게 인식되어있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표
- ⑤ 포도주 또는 증류주의 지리적 표시를 포함하고 있는 상표

해설

- ① [○] 제122조 제1항
- ② [○] 제122조 제1항
- ③ [○] 제122조 제1항
- ④ [×] 제34조 제1항 제11호에 해당하는 무효사유인데, 이는 제122조 제1항에서 제척기간의 적용이 없는 것으로 규정하고 있다.
- ⑤ [○] 제122조 제1항

정답 ④

182 甲은 국내에서 주지된 乙의 미등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 출원하였는데 심사착오로 상표등록이 되었다. 이 경우 甲과 乙 양자의 관계에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

09 기출

- ① 甲의 등록상표가 무효로 되기 전이라면 법원이 그 등록의 효력을 부인할 수 없는 것이 원칙이다.
- ② ①에도 불구하고 乙은 자기가 사용해 온 상표를 계속 사용할 수 있는 여지가 있다.
- ③ 乙은 甲의 등록상표가 존재하는 경우라 하여도 일단 자신의 주지상표를 상표등록출원하여 놓고 추후 甲의 등록상표를 무효시켜 자신의 상표등록출원을 등록 받을 수도 있다.
- ④ 甲의 등록상표가 등록 후 5년이 경과하면 乙은 자기의 주지상표와 유사하다는 이유(상표법 제34조 제1항 제9호)로는 상표등록의 무효심판을 청구할 수 없다.
- ⑤ 甲의 등록상표가 무효로 되기 전이라면 그 존속기간 동안 甲의 등록상표의 사용에 제약을 받는 경우는 없다.

해설

- ① [○] 무효심결확정에 의하여 소멸되지 않는 한 단순히 무효사유가 존재한다는 사정만으로 법원이 그 등록의 효력을 부인할 수 없음이 원칙이다. 다만, 무효사유가 명백한 권리에 의한 권리행사는 '권리남용'에 해당한다.
- ② [○] 乙은 제99조 규정에 따른 선사용권에 의하여 자기가 사용해 온 상표를 계속 사용할 수 있는 여지가 있다.
- ③ [○] 甲의 등록상표가 무효심판에 의하여 무효확정된 경우 甲의 등록상표는 처음부터 없었던 것으로 보므로(法 117③), 乙은 甲의 등록상표가 존재하는 경우라 하여도 일단 자신의 주지상표를 상표등록출원하여 놓고 추후 甲의 등록상표를 무효시켜 제34조 제1항 제7호의 거절이유를 극복하고 자신의 상표등록출원을 등록 받을 수도 있다.
- ④ [○] 제122조 제1항
- ⑤ [×] 甲의 등록상표가 무효되기 전이라도 甲이 乙의 상표에 화체된 신용에 편승하기 위하여 형식상 상표권을 취득한 경우라면 그 '적극적 사용'도 권리남용으로 볼 수 있고, 이 경우는 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제되어 甲이 비록 자신의 등록상표를 사용하는 경우일지라도 그 사용은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목에 의한 부정경쟁행위가 될 수 있어 사용에 제약을 받을 수 있다. 따라서, ⑤가 정답이다.

정답 ⑤

183 파리협약 당사국인 일본에 등록된 상표 X(국내외 수요자간에 인식되어 있지 않음)에 대한 상표권자인 甲의 국내 수입대리인인 乙이 甲의 동의를 받지 아니하고 이와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 국내에 상표등록출원하여 등록받은 경우, 甲이 취할 수 있는 조치에 관한 설명 중 옳은 것은? '09 기출

- ① 甲이 심사단계에서 상표등록이의신청이나 정보제공을 한 사실이 있는 경우에 한하여 甲은 乙의 상표등록에 대하여 상표등록의 취소심판 또는 무효심판을 청구할 수 있다.
- ② ①의 조건과 무관하게 甲은 乙의 상표등록에 대하여 등록 후 5년 이내에 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
- ③ ①의 조건과 무관하게 甲은 乙의 상표등록에 대하여 언제든지 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
- ④ 乙의 출원·등록 여부와 상관없이 甲은 乙이 국내에서 상표 X를 무단사용 하는 것에 대하여 상표법상 권리행사를 할 수 있다.
- ⑤ 乙은 조약 당사국인 일본에 등록된 상표의 지정상품과 동일한 상품이 아니라 유사한 지정상품에 대하여 등록받은 경우이므로 아무런 조치도 취할 수 없다.

해설

- ① [x] 지문⑤ 해설 참조
- ② [x] 지문⑤ 해설 참조
- ③ [○] 지문⑤ 해설 참조
- ④ [x] 甲은 국내 상표권자 또는 국내에서 출원한 자가 아니기에 당연히 상표법상 乙의 사용에 대하여 어떠한 권리행사를 할 수 있는 것은 아니다.
- ⑤ [x] “조약당사국에 등록된 상표와 **동일·유사한 상표**로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 **지정상품과 동일·유사한** 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표”는 제34조 제1항 제21호 소정의 부등록사유에 해당하여 제54조 및 제117조에 따른 거절·무효 사유에 해당한다. 즉, 2016년 개정 전의 구법은 위의 사유에 해당하는 경우 조약당사국에 등록된 권리자가 상표등록이의신청이나 정보제공을 한 경우에 한하여 거절할 수 있었고, 등록된 경우에도 무효심판이 아닌 취소심판(제척기간 5년 적용)의 대상이 되도록 하였으나, 2016년 개정법은 이를 부등록사유로 편입하여 상표등록이의신청이나 정보제공 유무와 상관없이 거절하고, 착오 등록시 무효심판(제척기간 적용 없음)의 대상이 되도록 하였다. 따라서, 정답은 ③이다.

정답 ③

184 상표법상 상표등록의 무효심판 청구사유에 해당하지 않는 것은?

11 기출

- ① 상표권을 분할하여 이전하면서 유사한 지정상품 중 일부를 이전하지 않은 경우
- ② 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 식별력 없는 상표가 된 경우(상표법 제33조 제2항에 의한 '사용에 의한 식별력'을 취득한 경우를 제외한다)
- ③ 지정상품의 추가등록이 그 상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자에 의한 경우
- ④ 상표등록출원을 분할하여 이전하면서 유사한 지정상품 중 일부를 이전하지 않은 경우
- ⑤ 업무표장등록출원을 양도하면서 해당 업무는 함께 양도하지 않은 경우

해설

- ① [x] 제119조 제1항 제4호 소정의 취소사유이다.
- ② [○] 제117조 제1항 제6호 소정의 후발적 무효사유이다.
- ③ [○] 제117조 제1항 제2호
- ④ [○] 제117조 제1항 제1호에 규정된 제48조 제1항 후단.
- ⑤ [○] 제117조 제1항 제1호에 규정된 제48조 제6항 제1호

정답 ①

185 상표등록의 무효심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

19 기출

- ① 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 해당 등록상표에 대한 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
- ② 선출원에 의한 타인의 등록상표와 유사한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표에 해당하는 것을 이유로 한 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년의 제척기간 내에 청구하여야 한다.
- ③ 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표에 해당하는 것을 이유로 한 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년의 제척기간 내에 청구하여야 한다.
- ④ 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 유사한 상품에 사용하는 상표에 해당하는 것을 이유로 한 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년의 제척기간 내에 청구하여야 한다.
- ⑤ 심판장은 상표등록의 무효심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.

해설

- ① [○] 상표등록의 무효심판은 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다(法 117①후단).
- ② [○] 제34조 제1항 제7호는 제척기간 5년이 적용된다(法 122①).
- ③ [×] 제34조 제1항 제4호는 제척기간의 적용이 없다.
- ④ [○] 제34조 제1항 제9호는 제척기간 5년이 적용된다(法 122①).
- ⑤ [○] 제117조 제5항.

정답 ③

186 상표법상 심판에 관한 설명으로 옳은 것은?

26 기출

- ① 둘 이상의 지정상품에 관하여 상표법 제117조(상표등록의 무효심판) 제1항에 따른 상표등록의 무효심판이 청구되었을 경우 지정상품마다 심판청구를 취할 수 있다.
- ② 상표권자는 상표등록을 무효로 한다는 심결에 불복하기 위해 심결 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 특허법원에 심결취소의 소를 제기하여야 한다.
- ③ 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 각호 전체의 사유에 의한 상표등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다.
- ④ 상표법 제116조(거절결정에 대한 심판)에 따른 거절결정불복심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 심판장에게 참가신청서를 제출하여 그 심판에 보조참가를 할 수 있다.
- ⑤ 상표법 제119조 제1항 제3호를 사유로 하는 불사용 취소심판에서 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 경우 그 상표권은 그때부터 소멸된다.

해설

- ① [○] 둘 이상의 지정상품에 관하여 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판(일반출원, 지정상품추가등록출원, 상품분류전환등록의 거절결정에 대한 심판)이나 제117조 제1항(상표등록, 지정상품추가등록의 무효심판), 제118조 제1항(존속기간갱신등록의 무효심판) 또는 제214조 제1항(상품분류전환등록의 무효심판)에 따른 무효심판이 청구되었을 경우에는 지정상품마다 심판청구를 취할 수 있다(法 148②).

	지정상품별 청구	지정상품별 취하	지정상품별 인용·기각
보정각하결정에 대한 심판	×	×	×
거절결정에 대한 심판	○ (法 116)	○ (法 148②)	○ (규정 無, 심판구조상)
취소심판(法 119③3 제외)	×	×	×
불사용 취소심판	○ (法 119②)	×	×
무효심판	○ (法 117①, 118①, 214①)	○ (法 148②)	○ (규정 無, 심판구조상)
권리범위확인의 심판	○ (法 121)	규정 無 (실무는 불인정)	규정 無 (실무는 인정)

- ② [×] 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다(法 162③).
- ③ [×] 제119조 1항 제3호(불사용), 제4호(이전제한), 제6호(성과모용)는 제112조 제척기간의 적용을 받지 않는다. 다만, 제3호에 따른 취소심판은 심판청구 전 그 취소사유가 소멸되면 불사용 상태가 해제되었다는 의미이므로 취소심판을 제기하더라도 기각될 것이다. 제4호, 제6호에 따른 취소심판은 심판 청구 후라도 그 심판청구에 해당하는 사실이 없어지면 역시 심결로서 기각될 것이다.
- ④ [×] 제124조 제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다(法 142①). 즉, 당사자계(무효, 취소, 권범) 심판에만 참가가 가능하고, 결정계(불복심판) 심판에는 참가 제도가 없다.
- ⑤ [×] 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만, 제119조 제1항 제3호(불사용)에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다(法 119⑥).

(comment) 상표법의 심판·소송·재심 파트 문제 지문에서는 특허법 이론이 절반 이상을 차지하는 경향이 있습니다. 이는 해당 파트의 규정이 특허법·상표법·디자인보호법 간 공통 규정으로 구성되어 조문 체계와 절차가 사실상 동일하게 작동하는 경우가 많기 때문입니다. 따라서 특허법 조문을 축으로 공통 규정을 구조화해 암기할 필요가 있습니다.

정답 ①

제5절 상표등록의 취소심판

119, 122②

제119조 제1항 제1호 및 제2호

187 甲은 컴퓨터를 지정상품으로 하여 상표 'A' 를 1995년 2월 1일 상표등록출원하여 1996년 1월 6일 상표등록 받은 후 계속하여 사용함으로써 'A' 상표는 주지상표가 되었다. 그런데, 그 후 乙이 컴퓨터를 지정상품으로 하여 甲의 'A' 상표와 유사한 'A+' 상표를 2001년 3월 5일 상표등록출원하여 2002년 2월 8일 상표등록을 받았고 그 후 丙에게 2005년 10월 8일 통상사용권을 설정하였다. 한편, 丙은 乙로부터 통상사용권을 설정받은 'A+' 상표를 사용하지 아니하고 乙의 묵인 하에 甲의 'A' 상표와 극히 유사한 'A^o' 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 甲의 'A' 상표 상품과 출처의 혼동을 야기하고 있다. 이 경우 甲이 乙의 'A+' 상표에 대해 취할 수 있는 상표법상의 조치로서 옳은 것은? '08 기출

- ① 상표법 제34조 제1항 제7호(선출원 등록상표와 유사상표)에 기한 상표등록 무효심판청구
- ② 상표법 제34조 제1항 제9호(주지상표)에 기한 상표등록 무효심판청구
- ③ 상표법 제119조 제1항 제1호(상표권자의 고의적인 부정사용)에 기한 상표등록 취소심판청구
- ④ 상표법 제119조 제1항 제2호(사용권자의 부정사용)에 기한 상표등록 취소심판청구
- ⑤ 乙의 등록상표 'A+'가 甲의 등록상표 'A'의 권리범위에 속한다는 취지의 권리범위 확인심판청구

해설

① [x] 지문② 해석 참조.

② [x] 제34조 제1항 제7호 및 제9호 규정에 따른 무효심판의 청구는 "설정등록일부 5년 이내"에 무효심판을 청구하여야 한다(法 122①). 한편, 乙의 설정등록일은 2002년 2월 8일이고, 시험일(2008년 3월)을 기준으로 할 때 설정등록일로부터 5년이 경과하였음이 명백하므로 甲의 조치가 될 수 없다.

③ [x] 사용권자의 부정사용에는 제119조 제1항 제1호의 적용이 없다.

④ [○] 사용권자인 丙이 등록상표와 유사한 상표를 사용하여 제3자의 대상상표와의 관계에서 상품 출처의 혼동을 야기하고 있으므로 제119조 제1항 제2호 규정에 따른 취소심판 청구의 요건이 만족된다.

⑤ [x] 권리 대 권리간 적극적 권리범위 확인심판은 인정되지 않는다.

정답 ④

188 甲은 “天緣”이라는 한자로 구성된 상표를 “사이다”를 지정상품으로 하여 상표등록을 받았으나 실제로는 그 한글 음역인 “천연”으로 구성된 상표의 우측상단에 “®”표시를 한 상표를 사용하여 “사이다”를 제조·판매하고 있다. 이 경우에 발생할 수 있는 상표법상 제 문제에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

09 기출

- ① 甲은 등록상표와 동일성이 없는 유사한 상표를 사용한 것이므로 甲의 등록상표는 불사용 취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호)의 대상이 될 수 있다.
- ② “천연”사이다에서 “천연”은 “자연 그대로의 상태”를 의미하여 수요자들에게 상품의 품질의 오인을 초래할 우려가 있으므로 甲의 등록상표는 부정사용취소심판(상표법 제119조 제1항 제1호) 청구의 대상이 될 수 있다.
- ③ “®”표시는 통상 등록상표임을 표시하는 표장이므로 거짓 표시의 문제가 발생 할 수 있다.
- ④ 제3자인 乙이 “천연 사이다”라는 표장을 사이다 상품에 사용할 경우 “天緣”과 “천연”은 칭호가 동일하므로 甲의 상표권 침해에 해당한다.
- ⑤ 甲의 상표 사용이 상품의 품질의 오인을 생기게 하였다는 이유로 하는 상표등록의 취소심판(상표법 제119조 제1항 제1호)은 누구든지 청구할 수 있다.

해설

- ① [○] 한자로 된 “天緣”을 등록받은 후 실제로는 그 한글 음역인 “천연”으로 구성된 상표를 사용하였다면 유사한 상표의 사용에 불과하여 제119조 제1항 제3호의 대상이 될 수 있다.
- ② [○] 유사범위의 사용으로 품질오인을 초래할 우려가 있으므로 제119조 제1항 제1호의 대상이 될 수 있다.
- ③ [○] 제224조
- ④ [×] 칭호가 동일하여 유사한 상표라 볼 수 있으나 乙의 사용 표장은 이른바 기술적 표장에 해당하여 제90조 제1항 제2호에 따라 甲의 상표권의 효력이 미치지 아니하므로 乙은 甲 상표권의 침해가 아니다.
- ⑤ [○] 제119조 제5항

정답 ④

189 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제1호 또는 제2호에 규정된 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 16 기출

- ① 전용사용권자 또는 통상사용권자가 고의로 지정상품에 등록상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 한 경우에만 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
- ② 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판 사건에서 등록상표의 지정상품 중 어느 하나에만 취소사유가 있는 경우 그 지정상품에 관한 상표등록만이 취소된다.
- ③ 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 후 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우 특허심판원은 기각하는 심결을 하여야 한다.
- ④ 이해관계가 없는 자가 한 취소심판청구는 부적법한 심판청구로서 각하된다.
- ⑤ 상표권자가 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하여 수요자로 하여금 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 그 타인의 상표가 주지·저명하지 아니하더라도 상표등록은 부정사용을 이유로 한 취소심판에 의하여 취소될 수 있다.

해설

- ① [x] '지정상품에 등록상표를 사용'한 경우 뿐만 아니라, 동일유사범위의 사용(즉 '지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용'한 경우)에 대하여 제119조 제1항 제2호 소정의 사용권자의 부정사용에 의한 취소심판을 청구할 수 있다. 또한, '고의' 유무는 제119조 제1항 제2호 취소심판청구의 요건이 아니다.
- ② [x] 등록상표의 지정상품 중 어느 하나에만 취소사유가 있다 하여도 등록상표 전체가 취소된다.
- ③ [x] 제119조 제1항 제1호 및 제2호는 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다(法 119④).
- ④ [x] 제119조 제1항 제1호 및 제2호는 누구든지 청구할 수 있다(法 119⑤).
- ⑤ [○] 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 제34조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 **반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만** 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 **특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도**로는 알려져 있어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다(BCBG 사건, 대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조).

정답 ⑤

190 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제1호의 심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'22 기출

- ① 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표')가 저명한 경우 대상상표의 상품과 실사용 상표의 상품이 유사하지 않아도 경제적 건련관계가 있으면 본 호를 적용할 수 있다.
- ② 상표권이 이전되는 경우 양도인의 부정사용의 책임은 이전 후 양수인에게 승계되지 아니하므로 양수인이 스스로 부정사용을 하지 않는 한 본 호를 적용할 수 없다.
- ③ 대상상표가 식별력이 없는 표장인 경우 실사용 상표와 대상상표가 유사한 경우라면 출처 혼동의 우려가 있으므로 본 호를 적용할 수 없다.
- ④ 본 호 규정은 타인의 선등록 상표의 신용에 부당편승을 방지하는 취지이므로 대상상표가 미등록 또는 후등록 상표인 경우에는 적용할 수 없다.
- ⑤ 본 호의 고의 요건 판단에 있어 대상상표가 주지·저명한 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못한 경우에도 고의의 존재가 추정된다.

해설

- ① [○] 제119조 제1항 제1호에서 말하는 혼동은 '광의의 혼동'까지를 포함한다고 봄이 학설의 일반적 견해이고, 대법원 판례 또한 본호의 혼동에 광의의 혼동까지를 포함한다고 본다. 다만, 건련관계에 대한 오인·혼동을 말하는 이른바 '광의의 혼동'은 통상 저명상표에 있어서 나타내는 현상이므로, 광의의 혼동을 이유로 본호가 적용된다고 하기 위하여는 대상상표가 저명한 경우라야 할 것이다.
- ② [×] 상표권의 이전이 있는 경우 이전 전(前) 양도인의 부정사용의 책임은 이전 후 양수인에게 그대로 승계되므로 비록 양수인 스스로 부정사용을 하지 않았다 하여도 해당 상표권이 취소될 수 있다(ROOT 사건, 특허법원 2002. 6. 12. 선고 2001허1556 판결).
- ③ [×] 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다고 하려면, 그 대상상표가 적어도 상표로서의 자타상품식별력이 있어야 한다. 따라서 대상상표가 기술적 표장에 불과할 뿐 상표로서의 자타상품식별력을 갖춘 것이라고는 보기 어려운 경우에는 실사용상표와 대상상표가 유사하다고 하더라도 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다고 할 수 없다(노이에루 사건, 대법원 1990. 1. 25. 선고 88후1328 판결).
- ④ [×] 제119조 제1항 제1호는 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이므로 대상상표는 오인·혼동의 염려가 있는 한 등록여부 또는 등록상표보다 선등록되었는지를 묻지 않고 나아가 반드시 주지·저명할 것을 요하지 않는다.
- ⑤ [×] 제119조 제1항 제1호의 고의는 대상상표의 존재에 대한 인식만으로 충분하다고 봄이 통설·판례이고 대상상표가 주지·저명상표인 경우에는 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다. 다만, 고의의 존재가 '추정'되는 것이므로 상표권자가 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하였음을 입증한다면 추정사실이 복멸될 수 있다.

정답 ①

191 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

24 기출

- ① 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 한 경우에 상표등록취소심판을 청구하려면 통상사용권자의 고의가 필요하다.
- ② 전용사용권자가 등록상표를 변형하여 실제로 사용한 경우에만 제119조 제1항 제2호에 따른 상표등록취소심판이 가능하다.
- ③ 지리적 표시 단체표장 등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하였지만, 상표등록취소심판의 청구 이후에 정관을 변경하여 그 소속 단체원의 가입을 허용하였다면 취소사유에 영향을 미친다.
- ④ 증명표장권자가 사용을 허락받은 자에 대한 감독에 상당한 주의를 하지 않아 증명표장의 사용허락을 받은 자가 정관을 위반하여 타인에게 사용하게 한 경우에는 누구든지 증명표장의 상표등록취소심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 지식재산처장은 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.

해설

- ① [x] 제119조 제1항 제2호 규정에 따른 상표권의 취소는 사용권자의 고의를 요건으로 하지 않는다.
- ② [x] 제119조 제1항 제2호 규정에 따른 상표권의 취소는 동일범위(동일 상표, 동일 상품) 내의 사용에 대하여도 적용될 수 있다. 즉, 변형하여 사용한 경우에만 적용되는 것은 아니다.
- ③ [x] 제119조 제1항(같은 항 제4호 및 제6호는 제외한다)에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다(法 119④).
- ④ [○] 제119조 제1항 제9호 다목
- ⑤ [x] 심판장은 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다(法 119⑦).

정답 ④

제119조 제1항 제3호

192 불사용에 의한 상표등록취소심판에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

02 기출

- ① 등록상표의 지정상품이 다른 법률의 규정에 의하여 그 제조 및 판매에 있어서 허가를 필요로 하는 경우 허가 없이 해당 품목에 등록상표를 사용한 사실이 있다 하더라도 이는 등록상표의 정당사용이라 볼 수 없다.
- ② 외국에서 발행된 간행물에 상표가 선전·광고된 경우 그 간행물이 국내에 입수되어 반포되었다면 상표사용행위로 볼 수 있다.
- ③ 등록상표와 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우는 정당한 상표사용행위로 볼 수 있다.
- ④ 수개의 지정상품을 대상으로 하여 불사용취소심판청구가 있는 경우 그 가운데 어느 하나의 상품에만 등록상표를 적법하게 사용하였다는 사실이 입증되면 그 입증된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구는 인용할 수 있다.
- ⑤ 상표법 제119조 제1항 제3호에서 말하는 통상사용권자는 반드시 등록된 통상 사용권자일 필요는 없다.

해설

- ① [×] 최근 판례는 관련 행정법규가 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격에 미달하는 제품 등의 제조·판매 등을 금지하고 있는 경우, 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, “상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였다고 하여 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되지 않았다고 일률적으로 결정할 수는 없고”, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 “여러 사정을 참작하여 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다.”
- ② [○] 상표의 사용은 국내에서의 사용에 한정되지만, 상표의 광고가 게재된 외국간행물의 국내반포가 입증되면 불사용 취소를 면할 수 있다(대법원 1991.12.13 선고 91후536 판결).
- ③ [○] 등록상표의 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다(대법원 1992.11.20 선고 92후650 판결).
- ④ [×] 수개의 지정상품을 대상으로 하여 불사용취소심판청구가 있는 때에 그 중 어느 하나의 지정상품에 대하여 사용이 입증된 경우에는 그 심판청구를 전제로서 기각하여야 하고 일부 기각 일부 인용의 심결을 하여서는 아니된다(대법원 1993. 12. 28 선고 93후718 판결; 法 119④).
- ⑤ [○] 통상사용권은 상표권자와의 합의만에 의하여 발생하며, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐이므로 불사용취소를 면하게 할 수 있는 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없다(대법원 1995.9.5 선고 94후1602 판결).

정답 ①, ④

193 불사용으로 인한 상표등록의 취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호)에 관한 해석으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의한다.) '04 기출

- ① 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다.
- ② 타인의 저작권을 침해하는 등록상표의 사용도 불사용으로 인한 상표등록 취소의 요건과 관련하여서는 상표의 정당한 사용이다.
- ③ 소송 등을 통하여 상표권을 행사하였다면 이를 상표의 사용이라고 할 수 있으며, 특히 방위적(防衛的) 목적의 상표에 있어서는 상표권 침해자에 대하여 상표권을 행사하여 온 것만으로도 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 있다.
- ④ 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 누구나 청구할 수 있는 것이고, 청구인이 비록 등록상표권의 침해자인 경우에도 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 그로 인하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 심판청구권의 남용이라고 할 수 없다.
- ⑤ 주문자 상표부착방식(소위 OEM방식)에 의하여 수출 목적으로 등록상표가 부착된 상품을 제조하는 것은 국내에서의 상표사용 행위라고 볼 수 있다.

- ① [○] 상표권자는 동일범위 내에서 상표 사용 권한을 갖는다(法 89). 따라서, 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 것은 정당한 사용이라고 할 수 없다.
- ② [○] 저작권 침해가 되어 민사상 손해배상책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 그 등록상표와 동일성 범주 내에 있는 실사용상표를 상표적으로 사용한 이상은 그 사용 자체는 제119조 제1항 제3호 소정의 등록상표의 '정당한 사용'으로 볼 수 있다(CROCI KIDS 사건, 대법원 2001. 11. 27. 선고 98후2962 판결).
- ③ [x] 소송 등을 통하여 상표권을 행사한 것을 두고 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 수는 없을 뿐만 아니라, 방위적 목적의 상표라고 하여 상표권 침해자에 대하여 상표권을 행사하여 온 것만으로는 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 없다(PAOLOGUCCI 사건, 대법원 2001. 4. 24. 2001후188 판결). 따라서 상표의 사용이 아니므로 상표권이 취소된다.
- ④ [○] 2016년 개정으로 인하여 불사용취소심판은 누구든지 청구할 수 있고, 이해관계를 요하지 않는다. 대법원 2001.4.24. 선고 2001후188 판결; 실무적으로 보면 오히려 상표권 침해의 대항을 받는 자가 장래 적법한 사용을 확보할 의도로 등록상표에 대하여 불사용취소심판 등을 청구하는 경우가 많고, 따라서 침해자가 불사용취소심판을 청구하였다 하여 심판청구권의 남용이라 볼 수 없음은 당연하다.
- ⑤ [○] 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것 인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(송가네 냉면, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결).

정답 ③

194 상표 심판에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 대법원 판례에 의함)

'06 기출

- ① 불사용으로 인한 상표등록의 취소심판에서 피심판청구인은 상표등록의 취소심판이 청구된 복수의 지정상품 중 하나에 대하여만 사용을 입증하면 되므로, 복수의 지정상품 중 하나에 대하여 사용이 입증되면 그 심판청구가 전체로서 인용될 수 없다.
- ② 상표권자의 부정사용으로 인한 상표등록의 취소심판에서 등록상표와의 혼동 여부가 문제로 되는 상표가 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 경우에도 대상상표로 삼을 수 있다.
- ③ 공유인 상표권에 대한 상표등록의 무효심판에서 상표권자들이 패소하였다면 공유자 중 1인이 단독으로 심결취소의 소를 제기할 수 없다.
- ④ 불사용으로 인한 상표등록의 취소심판에서 상표권이 이전된 경우 전(前) 권리자의 불사용기간도 통산된다.
- ⑤ 상표권자의 부정사용으로 인한 상표등록의 취소심판에서 등록상표와의 혼동 여부가 문제로 되는 상표가 기술적 표장에 불과한 경우에는 상표권자의 실사용상표와 그 대상상표가 유사하더라도 상표법 제119조 제1항 제1호의 부정사용에 해당하지 않는다.

해설

- ① [○] 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용한 사실을 입증하면 지정상품 전부에 대한 취소를 면할 수 있다(法 119③).
- ② [○] 대상상표는 오인·혼동의 염려가 있는 한 등록여부 또는 등록상표보다 선등록되었는지를 묻지 않고 나아가 반드시 주지·저명할 것을 요하지는 않는다.
- ③ [×] 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이더라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다(대법원 2004.12.9 선고 2002후 567 판결).
- ④ [○] 대법원 1982.2.23. 선고 80후118 판결은 “전권리자의 불사용기간은 통산되므로 이전등록시부터 불사용기간을 계산하여야 하는 것은 아니다.”라고 판시하였다.
- ⑤ [○] 노이에루 사건, 대법원 1990.1.25. 선고 88후1328 판결.

정답 ③

195 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

10 기출

- ① 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다.
- ② 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 불법적 등록상표의 존속으로 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다.
- ③ 이해관계인만이 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내·외에서 사용하고 있지 아니한 것을 이유로 취소심판을 청구할 수 있다.
- ④ 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다.
- ⑤ 상표권의 침해자가 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것은 등록취소심판 청구권의 남용이라고 볼 수 없다.

해설

① [○] 지문② 해설 참조.

② [○] 제119조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항 소정의 '이해관계인'이라 함은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고 (대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 참조), 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 참조).

③ [x] 2016년 개정으로 인하여 제119조 제1항 제3호의 취소심판은 누구든지 청구할 수 있으며(法 119 ⑤), 나아가 제119조 제1항 제3호는 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 "국내에서" 사용하고 있지 아니한 경우를 이유로 하는 것이므로, "국내·외에서 사용하고 있지 아니한 것"을 이유로 청구할 수 있다는 표현 또한 옳지 않다. 즉, 오로지 "국내" 사용여부만이 기준이 될 뿐이며, "외국"에서 사용하였는지 여부는 전혀 상관이 없다.

④ [○] 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았을 때에는 심판에 의하여 그 상표 등록을 취소하도록 규정하고 있다. 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다. 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 참조).

⑤ [○] 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 누구나 청구할 수 있는 것이고, 등록상표권의 침해자라고 하나 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 것이라고 할 수는 없으므로, 등록취소심판청구가 심판청구권의 남용이라고 볼 수 없다(대법원 2001.4.24. 선고 2001후188 판결). 실무적으로 보면 오히려 상표권 침해의 대항을 받는 자가 장래 적법한 사용을 확보할 의도로 등록상표에 대하여 불사용취소심판 등을 청구하는 경우가 많고, 침해자가 불사용취소심판을 청구하였다 하여 심판청구권의 남용이라 볼 수 없음은 당연하다.

정답 ③

196 2001년 한글과 영문을 2단으로 병기하여 등록한 상표를 오랫동안 사용해 왔던 甲은 영문 또는 국문만으로 된 상표만을 사용하고 있다. 등록상표에 대한 존속기간갱신등록신청을 할 시점에 즈음하여 실사용 상표의 형태에 맞추고 지정상품도 종전보다 확대하여 상표권을 확보하고자 한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)^{12 기출}

- ① 갱신등록신청에 의해서는 소기의 목적을 달성할 수 없으며 지정상품 추가등록출원에 의해서도 소기의 목적을 달성할 수 없다.
- ② 상표권 존속기간이 만료되기 전에 甲과 제3자인 乙이 선등록상표와 유사한 상표등록출원을 하면 乙의 유사상표등록출원은 거절되지만 甲의 출원은 1상표1등록주의나 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호에 위배되지 않는다.
- ③ 甲의 등록상표에 대해 불사용 취소심판이 청구되면 등록상표의 사용으로 인정받을 수 없어 취소될 수 있다.
- ④ 甲의 등록상표권이 불사용 취소심판으로 소멸된다면 그 소멸일은 불사용 취소심판청구일이 된다.
- ⑤ 甲의 등록상표권이 포기로 인하여 소멸된 경우에도 소멸일로부터 1년 동안은 타인의 상표등록출원이 배제되므로 원상표권자인 甲이 우선적 지위를 유지할 수 있다.

해설

- ① [○] 갱신등록은 오로지 상표권의 존속기간만을 갱신하는 것이고, 추가등록은 상표는 동일한 채 오로지 지정상품만이 추가되는 것이므로 옳은 지문이다.
- ② [○] 甲의 후출원 상표의 상표가 본인의 선등록상표와 동일하지 않는 이상 甲의 후출원은 1상표 1출원주의(法 38)에 위반되지 않고 동일인간에는 제34조 제1항 제7호가 적용되지 않으므로 甲의 후출원은 제34조 제1항 제7호에도 위배되지 않는다.
- ③ [△] 과거 판례는 영문과 이를 음역한 한글이 2단으로 병기되어 각각의 요부를 구성하고 있는 상표에 있어서 영문자 또는 국문자만을 사용한 경우에는 등록상표의 동일성의 범위로 보지 않았으나, 최근 판례(전합)는 '영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한' 이를 동일성 범주로 보고 있다. 한편, 설문의 경우 단지 '한글과 영문을 2단으로 병기하였다'고만 주어져 있으므로 만약 한글 부분이 영문의 단순한 음역이 아닌 영문과 다르게 호칭되는 별도의 독립된 요부였다면 동일성 범주로 보기 어렵다. 따라서, 본 지문은 세부적인 조건에 따라 달라질 수 있으므로 엄밀히 말하면 △이고, 명확한 정답 ⑤가 있으므로 일단 정답은 ⑤로 보아야 한다. 다음 판례 참고 : 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다. 이와 달리 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용이 아니라는 취지로 판시한 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다(콘티넨탈 사건, 대법원 2013.9.26. 선고 2012후2463(전합)).
- ④ [○] 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만, 제119조 제1항 제3호(불사용 취소심판)에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다(法 119조 ⑥).
- ⑤ [x] 2016년 개정법은 타인의 상표권이 소멸된 날로부터 1년 이내에 유사한 상표를 출원하면 거절한다는 취지의 구법 제7조 제1항 제8호를 삭제하였으므로, 甲의 등록상표권이 소멸된 경우 그 소멸일로부터 1년 동안 타인의 상표등록출원이 배제되는 것은 아니다.

정답 ⑤ (㉓)

- 197** 甲은 상품류 구분 제18류의 상품 전부를 지정하여 상표등록출원을 하였으나, 심사과정에서 타인의 선등록상표(이하 '인용상표'라 함)와 저촉한다는 취지의 거절이유통지서를 송달 받았으며, 이에 대한 의견서를 제출하였으나 심사관에 의해 거절결정이 내려졌다. 이에 대하여 甲은 상표등록을 위해 인용상표에 대하여 상표법 제119조(상표등록 취소심판) 제1항 제3호에 의한 불사용을 근거로 취소심판청구를 고려하고 있다. 이와 관련하여 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

12 기출

〈 참 고 〉

인용상표의 등록된 지정상품은 다음과 같다.

인용상표의 지정상품	유사군코드
등산용가방, 보스턴백, 솔더백, 핸드백(이하 'A상품군'이라 함)	G2501
우산, 골프용우산, 파라솔 (이하 'B상품군'이라 함)	G2703
가죽제 열쇠고리 (이하 'C상품군'이라 함)	G3002

- ① 甲은 A상품군과 B상품군을 취소대상 상품으로 취소심판을 청구한 후에 심리과정에서 B상품군에 대한 취소심판 청구를 취하할 수는 없다.
- ② 甲은 A상품군과 B상품군을 별개의 심판대상으로 하여 같은 날짜에 취소심판청구를 할 수 있다.
- ③ 만일 甲이 인용상표의 지정상품 전부를 지정하여 취소심판을 청구한 후 인용상표권자가 사용사실을 입증하여 기각심결이 내려지고 심결이 확정되더라도, 甲은 심결확정일 이후에 인용상표에 대하여 동일한 취소심판을 다시 청구할 수 있다.
- ④ 甲의 상표등록출원에 대한 거절결정이유가 A상품군에만 존재하는 경우라면, 인용상표에 대한 甲의 상표등록취소심판(전부취소) 청구는 B, C상품군에 속하는 상품에 대하여 심판 청구의 이해관계가 없다는 이유로 각하를 면할 수 없다.
- ⑤ 甲은 인용상표의 지정상품 중 A와 B상품군에 속하는 지정상품의 등록을 취소한다는 심판을 청구한 후 심리가 종결되기 전이라도 C상품군에 속하는 지정상품을 취소의 대상으로 추가하는 심판청구의 보정은 할 수 없다.

해설

- ① [○] 무효심판과 달리 취소심판에 있어서는 불사용취소심판을 포함하여 어떠한 취소사유를 청구이유로 하였는지와 무관하게 심판계속 중 지정상품의 일부에 대한 취하가 불가능하다.
- ② [○] 불사용취소심판은 지정상품별 일부청구가 가능하다(法 119②).
- ③ [○] 불사용취소심판에서는 심판청구일을 달리 하는 결과 등록취소를 면할 수 있는 상표의 사용행위의 기준 시점 또한 달라지므로, 양 사건이 청구원인이 동일하여 동일사실에 기초한 것이라고 보기는 어려워 후 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되는 것이 아니다.
- ④ [×] 2016년 개정으로 인하여 불사용취소심판은 이해관계 자체를 요하지 않는다.
- ⑤ [○] 제125조 제2항에 따라 청구취지는 요지변경이 불가능하므로 심판계속 중 C 상품군에 속하는 지정상품을 취소의 대상으로 추가하는 심판청구의 보정은 할 수 없다.

정답 ④

198 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

13 기출

- ① 제119조 제1항 제1호(상표권자의 고의적인 부정사용으로 인한 취소심판)나 제119조 제1항 제3호(불사용으로 인한 취소심판)는 해당 사실이 없어진 날부터 3년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다.
- ② 甲이 乙에게 상표권의 지정상품 중 일부 상품을 이전하면서 이전하는 상품과 유사한 상품의 일부를 제외하고 이전한 경우에는 누구든지 이를 이유로 상표등록취소심판을 청구할 수 있다.
- ③ 상표권의 이전이 있는 경우에는 양도인의 불사용기간이 통산되지 아니하고 양수인의 불사용기간만 고려된다.
- ④ 심판청구시에는 불사용 기간이 완성되지 아니하였으나 심판청구사건의 심리종결전에 불사용기간이 완성된 경우에는 그 상표등록은 제119조 제1항 제3호(불사용으로 인한 취소심판)에 의하여 취소 될 수 없다.
- ⑤ 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표가 등록된 경우라도 제119조 소정의 취소사유에 해당하지 않는다.

해설

- ① [x] 제119조 제1항 제3호는 제척기간이 없다.
- ② [x] 제119조 제1항 제4호는 이해관계인만이 청구할 수 있다.
- ③ [x] 이전 전 양도인의 불사용기간을 합산한다.
- ④ [○] 비록 과거에는 다툼이 있었으나 현재의 판례는 심판청구시 3년의 불사용기간이 완성되어야 하는 것으로 보고 있다. 따라서, 옳은 지문이다. 다음의 판례 참조 : 제119조 제1항 제3호는 그 문언상 등록상표를 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니한 경우에 적용되는 것이고, 피심판청구인은 그 심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 관계되는 지정상품에 사용하였음을 증명하면 그 상표등록의 취소를 면할 수 있는바(같은 조 ④), 심판청구시에는 그 불사용의 기간이 완성되지 아니하였으나 심판청구사건의 심리중에 불사용기간이 완성된 경우, 또는 심판청구시에는 등록상표를 사용하고 있었으나 심판청구 후에 사용하지 아니하여 심리종결 전에 불사용기간이 완성되는 경우 그 상표등록은 당해 심판에서는 취소될 수 없다 할 것이다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후881,898,904,911 판결).
- ⑤ [○] 2016년 개정법상으로는 구법과 달리 제34조 제1항 제21호 소정의 부등록사유로서 거절이유 및 무효사유에 해당한다. 따라서 옳은 지문이다.

정답 ④, ⑤

199 불사용취소심판에 대한 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

14 기출

- ① 본 호는 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의의 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위한 것으로, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재수단이 된다.
- ② 본 호에 의한 취소심판은 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당한 이유 없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것은 아니다.
- ③ 상표의 사용에는 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다.
- ④ 본 호에서의 '정당한 이유'에는 질병, 기타 천재지변 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률상의 규제 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품을 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우도 포함한다.
- ⑤ 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다면, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이더라도, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 것으로 볼 수 없다.

해설

- ① [○] 제119조 제1항 제3항에서는 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 불사용한 경우 상표권의 취소사유로 규정하고 있고, 이를 이유로 상표권이 취소된 경우 3년간 동일 유사 범위 내에서의 재출원을 제한하고 있다(法 34③).
- ② [○] 상표권 이전이 있는 경우 전권리자인 양도인의 불사용기간을 산입하여 불사용 기간을 계산할 수 있다.
- ③ [○] UNi SPORTS 사건, 대법원 1996.10.11. 선고 96후92 판결 등
- ④ [○] "정당한 이유"라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 **법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치** 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품을 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표불사용의 경우도 포함된다고 할 것이나, 본건 등록상표의 지정상품인 **"담배"가 그 수입에 있어서 허가 또는 지정이나 위탁을 필요로 한다는 점만으로 "정당한 이유"가 있다고 단정할 수는 없고**, 상표권자의 **귀책사유 없이** 그 수입의 허가 또는 지정이나 위탁을 받을 수 없게 되어 3년 이상 본건 등록상표를 사용할 수 없게 된 사정이 있어야만 정당한 이유가 있다고 할 것이고, 위와 같은 사유는 상표권자가 입증하여야 할 것이다(대법원 1990.6.26. 선고 89후599 판결).
- ⑤ [×] 콘티넨탈 사건, 대법원 2013.9.26. 선고 2012후2463(전합)

정답 ⑤

200 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제3항에서 불사용 등록상표의 정당한 사용에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

15 기출

- ① 등록상표의 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 않더라도 그 지정상품에 관하여 명목상 광고한 사실이 있다면 등록상표의 정당한 사용에 해당한다.
- ② ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에서는 상표권자 또는 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터 잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표지로서 인식할 수 있는지는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다.
- ③ 지정상품이 의약품인 경우 보건복지부장관의 품목별 허가를 받지 않았다 하더라도 신문지상을 통하여 1년에 한 차례씩 그 상표를 광고하였거나 국내의 일부 특정지역에서 그 등록상표를 부착한 지정상품이 판매되었다면 상표의 정당한 사용이 있었다고 볼 수 있다.
- ④ 상표권자가 등록상표 “A”를 www.A.co.kr과 같은 인터넷 주소로 웹사이트를 개설하고 있는 것만으로도 등록상표가 표시된 지정상품을 광고하였다고 볼 수 있으므로 정당한 사용에 해당한다.
- ⑤ 등록상표는 독자적으로 사용되어야 등록상표의 사용에 해당하므로 다른 상표와 함께 등록상표가 표시된 경우에는 등록상표의 사용으로 인정 되지 않는다.

해설

- ① [x] 불사용취소심판에서 상표에 대한 선전·광고행위의 경우 그 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되는 것을 전제로 하여 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있다.
- ② [○] 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 ‘일반수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표지로서 인식할 수 있는지 여부’는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(쓰비벨무스터 사건, 대법원 2013.2.28. 선고. 2012후3206 판결).
- ③ [x] 지정상품이 의약품인 경우 그 등록상표를 지정상품에 법률상 정당히 사용하기 위하여는 그 제조나 수입에 관하여 보건부장관의 품목별 허가를 받아야 하므로 그러한 허가를 받지 아니하였다면 신문지상을 통하여 1년 못미쳐 한차례씩 그 상표를 광고하였거나 국내의 일부 특수지역에서 판매되었다고 하더라도 상표의 정당한 사용이라고 볼 수 없다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240,1257 판결).
- ④ [x] 등록상표를 인터넷 주소로 하여 웹사이트를 개설한 것만으로는 등록상표의 사용이라 할 수 없다.
- ⑤ [x] 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 사용되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 ‘동일성과 독립성’을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이라 할 수 있다(UNI SPORTS 사건, 대법원 1996.10.11. 선고 96후92 판결).

정답 ②

201 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

18 기출

- ① 상표법 제119조 제1항 각호의 사유에 의하여 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우 그 상표권은 그때부터 소멸된다.
- ② 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에 있어 지정상품이 둘 이상 있는 경우 일부 지정상품에 관하여 청구할 수는 있지만 유사범위에 속하는 지정상품은 모두 포함하여 청구하여야 한다.
- ③ 상표법 제119조 제1항 제2호의 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지에 관한 판단기준은 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 동일하다.
- ④ 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판은 누구든지 청구할 수 있지만, 등록상표권의 침해자가 청구하는 것은 부당한 이익을 얻기 위한 것이므로 침해자에 의한 등록취소심판청구는 심판청구권의 남용에 해당하여 부적법하다.
- ⑤ 불사용의 상태가 상당기간 계속된 등록상표의 이전이 있는 경우, 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용에 대한 '정당한 이유'를 판단함에 있어서 당해 상표의 이전등록 이후의 사정만 참작할 것이 아니고 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사정도 함께 고려해야 한다.

해설

- ① [x] 다른 취소사유와 달리 제119조 제1항 제3호를 이유로 한 취소심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 '심판청구일'로 소급하여 소멸한다(法 119⑥). 따라서 옳지 않은 지문이다.
- ② [x] 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정하여 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있고, 등록상표의 지정상품 중 유사범위에 속하는 지정상품을 모두 포함하여 취소심판을 청구하지 않으면 심판청구가 인용되어도 심판청구인이 후에 유사상품에 관하여 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하거나 그 상표등록을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다(대법원 2013.2.15. 선고 2012후3220 판결).
- ③ [x] 제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 제119조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 제119조 제1항 제1호의 임법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다(대법원 2013.12.26. 선고 2012후1521 판결).
- ④ [x] 불사용취소심판은 누구든지 청구할 수 있는 것이고 등록상표권의 침해자라 하여도 불사용 상표를 취소시키고 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 것이라고 할 수는 없으므로, 침해자에 의한 등록취소심판 청구가 심판 청구권의 남용이라고 볼 수 없다(대법원 2001.4.24. 선고 2001후188 판결).
- ⑤ [○] 우노피자 사건, 대법원 2000.4.25. 선고 97후3920 판결.

정답 ⑤

202 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'19 기출

- ① 상표등록의 취소심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다.
- ② 불사용취소심판에 관한 상표법 제119조 제1항 제3호에서 미등록 통상사용권자의 사용은 정당한 사용이라고 할 수 없기 때문에 미등록 통상사용권자의 사용은 그 사실이 입증되어도 상표등록의 취소를 면할 수 없다.
- ③ 상표권자가 상당한 주의를 하였다고 인정되더라도 전용사용권자가 지정상품에 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 한 경우에는 상표등록이 취소된다.
- ④ 공유인 상표권의 상표권자에 대하여 상표등록의 취소심판을 청구할 경우에는 공유자 모두를 피청구인으로 청구하여야 한다.
- ⑤ 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 2년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

해설

- ① [×] 상표등록 취소심판은 누구든지 청구할 수 있음이 원칙이되, 제119조 제1항 제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다(法 119⑤).
- ② [×] 상표법상의 통상사용권자는 반드시 등록된 사용권자일 필요가 없으므로 미등록 통상사용권자의 사용도 그 사실을 입증하면 취소를 면할 수 있다.
- ③ [×] 상표권자가 상당한 주의를 한 경우 상표등록 취소를 면할 수 있다(法 119①(2)).
- ④ [○] 공유인 상표권의 상표권자에 대하여 심판을 청구할 경우에는 공유자 모두를 피청구인으로 청구하여야 한다(法 124②).
- ⑤ [×] 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 불사용한 경우이어야 한다(法 119①(3)).

정답 ④

203 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

25 기출

- ① 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에 있어서 상표권자 또는 그 사용권자가 타인 상품의 출처를 표시하기 위하여 상표를 사용한 경우 불사용을 이유로 한 상표 등록의 취소를 면하기 위한 상표의 사용에 해당하지 않는다.
- ② 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호 및 제3항에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하며, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 경우도 등록상표를 지정상품에 사용한 것으로 볼 수 있다.
- ③ 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호 및 제3항에 있어서 광고지 등에 등록상표를 표시하였다고 하더라도 상품의 출처표시로 사용된 것이 아니거나, 지정상품이 국내에서 유통되거나 유통예정을 하고 있지 않은 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다.
- ④ 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.
- ⑤ 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에서의 '정당한 이유'에는 질병 기타 천재 지변 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우 뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매 금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품을 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우도 포함한다.

- ① [○] 상표의 불사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서 상표의 사용이 인정되려면 상표권자 또는 그 사용권자가 상표를 자기 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용하여야 하고, 타인의 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용한 경우는 불사용을 이유로 한 상표 등록의 취소를 면하기 위한 상표의 사용에 해당한다고 할 수 없다(essie 사건, 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결) .
- ② [×] 제119조 제1항 제3호의 취소를 면하기 위한 등록상표의 사용은 전용권 범위 내에서의 사용(동일 범위)에 한한다. 즉, 유사 범위에서의 상표 사용행위는 제119조 제1항 제3호 규정 상의 상표 사용이 있다고 볼 수 없다.
- ③ [○] 제주소주 사건, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결
- ④ [○] 제119조 제3항
- ⑤ [○] 대법원 1990. 6. 26. 선고 89후599 판결; 한편 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후684판결은 “국세청장이 일정 시점부터 등록상표의 지정상품인 외국산 주류를 수입할 수 있는 신규의 주류수입상면허발급을 금지하였다 하더라도 기존의 주류수입상을 통하여 그 외국산 주류를 수입할 수 있는 것이므로, 국세청장이 신규의 주류수입상면허발급을 금지한 사유만으로는 법률에 의한 규제 등에 해당한다고 할 수 없어 이를 상표불사용의 정당한 이유라고 볼 수 없다.”고 판시하였다.

정답 ②

제119조 제1항 제6호

204 상표등록취소심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) 23 기출

- ① 통상사용권자가 사용허락을 받은 등록상표를 그 상표의 지정상품과 유사한 상품에 사용하여 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 한 경우에 수요자는 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제2호에 따라 해당상표에 대하여 상표등록취소심판을 청구할 자격이 있다.
- ② 甲이 2022. 12. 1.에 등록한 등록상표 사용이 乙에 대하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 파목의 부정경쟁행위를 구성하는 경우에, 그 상표에 관한 권리를 가진 자는 2023. 1. 31.에 甲의 상표에 대하여 상표등록취소심판을 제기할 수 있다.
- ③ 증명표장권자가 다른 증명표장이나 상표와 혼동방지조치를 취하면서 품질관리를 위해 직접 유통 판매하는 상품에 대하여 그 증명표장을 사용한 경우에 취소심판의 대상이 된다.
- ④ 상표법 제119조 제1항 제1호의 사유로 상표등록취소심판이 제기된 후에 상표권자가 그 상표를 포기하여 이를 등록하였더라도 계속하여 심리를 진행하여야 한다.
- ⑤ 甲은 외부 주문에 따라 생산만 하는 파운드리 회사로서 소위 팹리스(fabless) 반도체 설계 판매회사인 乙로부터 반도체 설계와 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제를 받으면서, 乙이 주문한대로만 생산한 반도체 전량을 乙에게 공급하고 있다. 이 경우 甲이 乙의 등록상표를 반도체에 표시한 상표사용행위는 특별한 사정이 없는 한 상표법 제119조 제1항 제3호에 따른 불사용취소심판에서 乙의 상표사용행위로 인정된다.

- ① [○] 제119조 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만, 동조 제1항 제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다(法 119⑤).
- ② [○] 제119조 제1항 제6호는 등록된 상표가 제92조 제2항에 해당하는 경우, 즉 그 등록이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목에 해당하는 경우 그 상표에 관한 권리를 가진 자는 그 등록일로부터 5년 이내에 심판을 청구할 수 있다. 따라서 2022. 12. 1. 에 등록된 경우 2027. 12. 1. 까지 그 상표에 관한 권리를 가진 자는 제119조 제1항 제6호의 취소심판을 청구할 수 있다. 따라서 2023. 1. 31.에 취소심판을 청구하는 것은 적법한 심판청구이다.
- ③ [○] 제119조 제1항 제9호 (나)목에서는 증명표장권자가 제3조 제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우 등록상표의 취소사유로 규정하고 있다. 따라서 증명표장권자가 직접 유통 판매하는 상품(=자기의 상품)에 대하여 그 증명표장을 사용한 경우 취소심판의 대상이 된다.
- ④ [x] 원칙적으로 상표등록취소심판 계속 중 해당 권리가 포기되어 등록된 경우(장래 소멸), 심결시를 기준으로 취소 대상이 되는 권리가 소멸되었으므로 심판청구의 이익이 없어 심판청구가 심결로서 각하되어야 한다. 따라서 제119조 제1항 제1호를 이유로 하는 취소심판 청구의 경우에도 심판 계속 중 권리가 포기되어 등록되었다면 더 이상 심판을 진행할 이익이 없으므로 부적법 각하하여야 하고 심리를 계속 할 것은 아니다. 이와 비교하여 제119조 제1항 제3호를 이유로 취소심결이 확정되는 경우 상표권은 심판 청구시로 소급 소멸하므로 심리 계속 중 상표권이 포기되었더라도 소급 소멸의 실익이 있어 심리가 계속 진행된다.
- ⑤ [○] 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단하면서도 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(송가네 냉면 사건, 대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결).

정답 ④

제6절 사용권 등록의 취소심판

120, 122②

205 상표등록의 취소심판에 관한 설명으로 옳은 것은?

21 기출

- ① 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 무효심판 또는 취소심판 등으로 소멸된 경우에 지정상품추가등록 출원을 한 출원인은 상표등록출원으로 변경할 수 있다.
- ② 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 상표권자가 상당한 주의를 하여도 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
- ③ 상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우를 사유로 하는 취소심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다.
- ④ 상표법 제120조(전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판) 제1항에 따라 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소 사유에 영향을 미치지 아니한다.
- ⑤ 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니하였음을 이유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 심결 확정일부터 소멸된다.

해설

- ① [x] 지정상품추가등록출원에 대한 등록여부결정 또는 심결이 확정되기 전이라 하여도 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 무효심판 또는 취소심판 등으로 소멸된 경우에는 상표등록출원으로 변경할 수 없다(法 44②단서).
- ② [x] 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우는 제119조 제1항 제2호에 따라 상표등록의 취소사유에 해당하나, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 상표등록취소를 면할 수 있다.
- ③ [x] 제119조 제1항 제5호의 사유로 누구든지 청구할 수 있다(法 119⑤)
- ④ [○] 제120조 제2항, 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우 취소사유에 영향을 미치는 경우는 제119조 제1항 제4호 및 제6호에 한한다.
- ⑤ [x] 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만, 제119조 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다(法 119⑥).

정답 ④

206 상표권의 권리범위 확인심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

*10 기출

- ① 상표권자(청구인)가 제쟁대상물인 확인대상표장이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 권리범위 확인심판만이 인정되고, 이해관계인이 자신이 표장이 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 권리범위 확인심판은 인정되지 않는다.
- ② 전용사용권자가 적극적 권리범위 확인심판의 청구인이 될 수 있는지 명문의 규정은 없으나 이를 인정하는 것이 판례의 입장이다.
- ③ 소극적 권리범위 확인심판에서 심판의 대상은 심판청구인이 확인을 구한 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는가의 여부이며, 심판청구인이 실제로는 확인대상표장과 다른 표장을 사용한 사실도 있다는 사정은 권리범위 확인심판의 심결에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 등록취소심판이 확정되기 이전에 상표권이 존속되는 기간 동안의 권리범위에 대한 확인심판은 소의 이익이 없으므로 취소심판 계류중인 사건에 대한 권리범위 확인심판의 청구는 부적법하다.
- ⑤ 권리범위 확인심판 청구는 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이 아니라 단순히 그 상표자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 하는 것이다.

- ① [×] 권리범위 확인심판에는 적극적 권리범위 확인심판뿐만 아니라 이해관계인이 자신의 표장이 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인심판도 인정된다.
- ② [×] 2007년 개정 상표법은 권리분쟁의 직접적 당사자인 전용사용권자의 청구인 적격을 명확히 인정하고 자 제121조에 전용사용권자를 포함시켰으므로, 적극적 권리범위 확인심판의 경우에는 상표권자 또는 전용사용권자가 명문의 규정에 따라 청구인이 된다.
- ③ [○] 소극적 권리범위 확인심판은 심판청구인이 특정한 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하는지 여부를 판단하는 것으로서, 심판청구인이 실제로는 확인대상표장과 다른 표장을 사용한 사실도 있다는 사정은 아무런 문제가 되지 않는다.
- ④ [×] 판례에 따르면 권리범위 확인심판 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로 상표권이 소멸한 후에는 그 확인의 이익이 없어 심판청구를 할 수 없다. 그러나, 취소심판이 계류 중인 사건은 아직 상표권이 소멸되기 전이므로 얼마든지 권리범위 확인심판의 청구가 가능하다(단, 만약 권리범위 확인심판의 계속 중 취소심결의 확정으로 상표권이 소멸되면, 당해 심판청구는 부적법한 것으로 심결로서 각하됨)
- ⑤ [×] 권리범위 확인심판 청구는 단순히 그 상표자체의 기술적 범위를 확인하는 사실 확정을 목적으로 하는 것이 아니라, 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이다.

정답 ③

207 상표법상 심판에 관한 설명으로 옳은 것은?

11 기출

- ① 등록상표의 권리범위를 확인하기 위한 상표권의 권리범위 확인심판은 상표권자와 전용사용권자만이 청구할 수 있다.
- ② 불사용을 이유로 하는 상표등록 취소심판의 청구인은 그 대상으로 삼은 지정상품에 관한 취소심판청구 전부를 취하할 수 있을 뿐만 아니라 일부 지정상품만을 분리하여 취하할 수 있다.
- ③ 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 대표자 또는 관리인의 이름으로 심판청구인이나 피청구인이 될 수 있다.
- ④ 상표등록취소심결의 효과는 심결시부터 장래를 향하여 발생함이 원칙이다.
- ⑤ 심판장은 무효심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.

해설

- ① [x] 상표권자·전용사용권자 또는 '이해관계인'은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다(法 121). 한편, '이해관계인'이 청구하는 권리범위 확인심판이 바로 '소극적 권리범위 확인심판'이 된다.
- ② [x] 무효심판과 달리 취소심판에 있어서는 불사용취소심판을 포함하여 어떠한 취소사유를 청구이유로 하였는지와 무관하게 심판계속 중 지정상품의 일부에 대한 취하가 불가능하다.
- ③ [x] 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 사단이나 재단의 이름으로 제60조 제1항에 따른 상표등록의 이의신청인이나 심판 또는 재심의 당사자가 될 수 있다(法 5). 따라서, 옳지 않은 지문이다. 한편, 본 지문과는 무관하나 법인 아닌 사단 또는 재단은 권리능력이 없으므로, 위 상표법 규정상 '심판 또는 재심의 당사자'는 '권리능력을 전제로 하지 않는 것'에 한한다는 것에 주의할 필요가 있다. 즉, 법인 아닌 사단 또는 재단은 권리능력이 없기에 i) 거절결정불복심판에 대한 청구인, ii) 무효(취소)심판의 피청구인, iii) 적극적 권리범위 확인심판의 청구인, iv) 소극적 권리범위 확인심판의 피청구인 등은 당연히 될 수 없다.
- ④ [x] 상표등록취소심결이 확정되면, 당해 상표권은 '심결확정시'부터 장래를 향하여 소멸함이 원칙이다. 즉, '심결시'가 아닌 '심결확정시'부터이며, 이런 유형의 지문에서 실수하지 않도록 주의할 필요가 있다.
- ⑤ [○] 제117조 제5항, 주체가 '특허심판원장'이 아니고 '심판장'임에 유의한다.

정답 ⑤

208 상표법상 권리범위 확인심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

13 기출

- ① 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 심판청구서에 등록상표와 대비될 수 있는 상표견본 및 그 사용상품목록을 첨부하여야 한다.
- ② 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상상표 및 상표가 사용되고 있는 상품에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 사용하고 있는 상표 및 그 사용상품과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 상표 및 그 사용상품과 같게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상상표 및 사용상품을 보정하는 것은 요지변경으로 허용되지 않는다.
- ③ 권리범위 확인심판은 권리범위에 속하는가의 여부에 관한 확인심판이므로 무효심판에서와 같은 제척기간은 존재하지 않으며 확인의 이익이 있는 한 상표권이 소멸한 후에도 언제나 청구할 수 있다.
- ④ 상표권의 적극적 권리범위 확인심판은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로 그 심결이 확정된 경우 제3자에게는 일사부재리의 효력이 미치지 않는다.
- ⑤ 판례에 의하면, 확인대상표장에는 실사용 상표에 있는 영어문자가 누락되어 있고 이것이 상표유사판단에 영향을 미칠 수 없는 부기적 부분에 불과하더라도 이러한 부기적 부분을 생략한 채 간략하게 표시한 확인대상표장은 실사용상표와 동일성의 범위 내에 있지 않다고 한다.

- ① [○] 제125조 제3항, 옳은 지문이다
- ② [×] 제125조 제2항 제3호에 따라 허용된다.
- ③ [×] 상표권이 소멸한 경우 확인이 이익이 없어 권리범위 확인심판이 인정되지 않는다.
- ④ [×] 일사부재리를 배제하는 명문의 규정이 없는 이상 당연히 일사부재리 효력이 미치며, 판례는 적극적 권리범위 확인심판과 소극적 권리범위 확인심판도 등록상표와 확인대상표장이 동일한 이상 동일한 심판으로 본다.
- ⑤ [×] ‘기록에 의하면, 원고가 실제로 사용하고 있는 상표는 피고가 이 사건 등록상표의 권리범위의 확인을 구한 확인대상표장에 비하여 SINCE 1758, PREMIUM, REFRESHING TASTE OF BEER, MALT BEVERAGE, BROUWERI MARTENS N.V.의 문자(시험의 지문에 표현된 영어문자가 이를 의미하는 것임)가 있고 없는 차이가 있는바, SINCE 1758, PREMIUM, REFRESHING TASTE OF BEER, MALT BEVERAGE의 문자는 모두 작은 글씨로 되고 성질을 표시하는 부기적 부분에 불과하고, BROUWERI MARTENS N.V.는 회사의 이름으로서 그 자체로는 성질을 표시하는 부분이 아니지만, 방패 모양의 테두리선 내부에 아주 작은 글씨로 기재되어 있어 그것으로 인하여 상표 유사 판단에 영향을 미칠 수는 없는 부기적 부분에 불과하다고 보아야 할 것이므로, 결국 이러한 부기적 부분을 생략한 채 간략하게 표시한 이 사건 확인대상표장은 원고의 실사용 상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표라고 봄이 상당하므로, 이 사건 심판 청구가 실제로 사용하지 않는 확인대상표장에 대한 것으로 확인의 이익이 없다고 하는 상고이유 제1점은 이유 없다(HITE 사건, 대법원 2001. 12. 27. 선고 2001후577 판결)’. 즉, 대법원은 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상표장에 실사용 상표에 있는 영어 문자가 누락되어 있어도 이는 상표 유사 판단에 영향을 미칠 수는 없는 부기적 부분에 불과하므로, 이러한 부기적 부분을 생략한 채 간략하게 표시한 확인대상표장은 실사용 상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표로서 확인의 이익이 있다고 하였다. 따라서, 옳지 않은 지문이다.

정답 ①

209 甲의 상표권 침해주장에 대해 乙은 아래와 같은 사유로 특허심판원에 소극적 권리범위 확인심판을 청구하려고 한다. 乙의 심판청구가 부적법 각하대상이 되지 않는 경우는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

15 기출

- ① 乙의 상표사용이 진정상품의 병행수입에 해당하여 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장
- ② 乙의 상표사용이 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제4호의 상표권의 효력이 제한되는 경우에 해당하므로 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장
- ③ 乙의 상표사용이 甲의 허락에 의한 통상사용권에 기초하고 있어 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장
- ④ 乙은 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)에서 규정하고 있는 선사용권이 있어 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장
- ⑤ 甲의 등록상표에 명백한 무효사유가 있어 그 상표권 행사가 권리남용에 해당하므로 종국적으로 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장

해설

① [x] 지문② 해설 참조

② [○] 권리범위 확인심판은 현존하는 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 등록상표권의 효력이 미치는 객관적 범위를 명확히 하는 것이지 특정인의 확인대상표장의 사용이 상표권자의 등록상표권을 침해하였는지 여부를 직접적인 판단의 대상으로 하는 것은 아니다. 따라서, 진정상품병행수입에 해당하는지 여부, 허락에 의한 통상사용권의 존부, 제99조 소정의 선사용권 또는 상표권자의 상표등록출원행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된다는 등의 대인적(對人的) 상표권 행사의 제한사유는 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 상표권 침해소송이 아닌 권리범위 확인심판에서 이를 심리·판단하는 것은 허용되지 않고, 나아가 최근 판례는 권리범위 확인심판의 제도적 취지에 비추어 등록무효사유의 존부도 판단의 대상이 아님을 분명히 하였다. 따라서, 소극적 권리범위 확인심판에 있어서 ②(法 90조 소정의 효력제한 사유)를 제외한 나머지 사유는 확인의 이익이 없어 부적법 각하의 대상이 된다.

③ [x] 지문② 해설 참조

④ [x] 지문② 해설 참조

⑤ [x] 지문② 해설 참조

정답 ②

210 상표법상 상표권의 권리범위 확인심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'16 기출

- ① 상표권자·전용사용권자·통상사용권자는 확인대상상표가 상표권의 권리범위에 속한다는 취지의 적극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.
- ② 권리범위 확인심판 사건에서 등록상표와 확인대상상표의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결시를 기준으로 판단한다.
- ③ 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인대상상표는 심판청구인이 자기가 사용하는 표장 등에 대하여 상표권의 효력이 미치는지를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이어서 심결이 확정되는 경우 제3자에게는 일사부재리의 효력이 미치지 않는다.
- ④ 적극적 권리범위 확인심판 사건에서 인용하는 심결이 있는 때에는 피청구인은 심결문이 송달된 날로부터 1개월 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기하여야 한다.
- ⑤ 적극적 권리범위 확인심판 사건에서 피청구인은 상표법 제99조의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리(선사용권)'를 주장할 수 있고, 심판관은 선사용권의 존부에 대해서 심리·판단하여야 한다.

해설

- ① [x] 통상사용권자는 제외된다(法 121).
- ② [○] 권리범위 확인심판에서 등록상표와 확인대상상표의 유사여부는 심결시를 기준으로 하므로, 유사판단의 전제로서의 등록상표의 식별력 유무 또한 심결시를 기준으로 한다.
- ③ [x] 권리범위 확인심판의 심결이 확정되면 일사부재리의 효력이 미친다.
- ④ [x] 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다(法 162④).
- ⑤ [x] 선사용권 등과 같은 대인적 상표권 행사의 제한사유는 권리범위 확인심판의 심리대상이 아니다(송석 사건, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결).

정답 ②

211 甲은 영업 a에 X상호를 2010년 초부터 사용하면서 집중적으로 광고하여 X상호는 2015년 말부터 저명하게 되었다. 한편, 乙은 甲의 승낙 없이 X상호와 유사한 X'상표를 b상품을 지정상품으로 하여 2016년 9월 9일에 등록출원하여 2017년 2월 20일에 설정등록 되었다. 甲은 乙의 등록상표에 대해 무효심판을 청구하면서 동시에 甲의 상호 사용이 乙의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

17 기출

- ① 乙이 상표등록출원시 X'상표의 사용 및 등록에 대하여 甲의 승낙을 얻지 않고 출원하였으므로 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제6호의 명백한 무효사유를 가지고 있다.
- ② 乙의 지정상품 b가 甲의 영업 a와 밀접한 관계에 있는 경우라도 상호와 상표는 별개이므로 甲은 乙의 등록상표 X'에 대하여 상표법 제34조 제1항 제9호를 무효사유로 주장할 수 없다.
- ③ 권리범위 확인심판에서 甲이 자신의 상호 사용이 상표법 제90조 제1항 제1호의 '상표권의 효력이 미치지 아니하는 경우'에 해당한다고 주장하더라도 이는 특허심판원의 판단사항이 아니다.
- ④ 권리범위 확인심판에서 甲이 표장의 동일·유사여부 등 다른 주장은 하지 아니하고 오로지 자신이 상표법 제99조 제2항의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'를 가지고 있다는 것만을 주장할 경우 특허심판원은 甲의 청구를 각하하는 심결을 하여야 한다.
- ⑤ 乙의 상표등록 후 甲과 乙간에 '甲이 상호X와 동일한 표장을 b상품에 대하여 상표등록출원하고, X상표등록출원에 대한 등록여부결정시까지 乙이 자신의 상표권을 포기한다'는 합의에 따라 포기등록이 이루어지더라도 甲의 출원은 등록받을 수 없다.

- ① [x] 제34조 제1항 제6호는 '상표등록출원시'가 아닌 '상표등록여부결정시'를 기준으로 하므로 비록 '상표등록출원시' 乙이 甲의 승낙을 얻지 않고 출원한 경우라 하여도 '상표등록여부결정시'까지 승낙을 얻으면 제34조 제1항 제6호의 거절이유(또는 무효사유)에 해당하지 않게되며, 나아가 제34조 제1항 제6호는 조문상 저명한 타인의 성명을 '포함'하는 경우에 적용되는 것인지 저명한 타인의 성명과 '동일·유사'해야 하는 것이 아니므로 乙이 출원한 X' 상표가 단순히 甲의 X 상호와 유사한 경우가 아니라 실질적으로 X 상호와 동일성이 인정되는 경우로서, 결과적으로 甲의 상호 X를 '포함'한 경우로 평가될 수 있는 경우라야 한다. 따라서, 상표등록출원시를 기준으로 乙의 등록상표에 제34조 제1항 제6호의 명백한 무효사유가 있다는 본 지문은 옳은 지문으로 볼 수 없다.
- ② [x] 상호의 경우에는 현실적으로 상표와의 구분이 용이하지 않고 상호로서 널리 알려진 경우 동시에 상품 또는 서비스의 출처표시로서도 널리 알려지는 경우가 대부분이라는 점에서 판례는 상호로서 주지성을 획득한 이상 제34조 제1항 제9호의 보호를 받는 인용표장으로 보고 있다(대법원 1984.1.24. 선고 83후34 판결). 따라서, 옳지 않은 지문이다.
- ③ [x] 제90조 제1항 각호는 상표권의 법정된 효력제한사유로 권리범위 확인심판의 판단대상이다. 따라서, 옳지 않은 지문이다.
- ④ [○] 허락에 의한 통상사용권의 존부, 제99조 소정의 선사용권 또는 상표권자의 상표등록출원행위가 심판 청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된다는 등의 대인적(對人的) 상표권 행사의 제한사유도 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 상표권 침해소송이 아닌 권리범위 확인심판에서 이를 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다. 따라서, 소극적 권리범위 확인심판에서 다른 주장이 없는 채로 오로지 선사용권만을 주장하는 경우 확인의 이익이 없어 부적법 각하된다(참고로 본 지문은 52회 기출문제 28번과 동일한 취지의 지문이다).
- ⑤ [x] 2016년 개정법상 제34조 제1항 제7호는 상표등록여부결정시를 기준으로 하므로 甲의 X상표등록출원에 대한 등록여부결정시까지 乙이 자신의 상표권을 포기하여 포기등록이 이루어지면, 상표등록여부결정시를 기준으로 선등록이 존재하지 않아 다른 거절이유가 없는 한 甲의 출원은 등록받을 수 있다. 따라서, 옳지 않은 지문이다.

정답 ④

212 상표법상 심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) '20 기출

- ① 권리범위 확인심판에는 형성적 효력이 인정되지 않는다.
- ② 소극적 권리범위 확인심판에서 심판대상인 문자와 도형으로 구성된 결합상표를 문자부분만으로 이루어진 상표로 변경하는 것은 확인대상표장의 동일성에 영향을 미치는 청구의 변경이므로 허용되지 않는다.
- ③ 확인대상표장을 디자인적으로 사용하는 것은 출처표시기능을 하는 상표적 사용이 아니므로 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 심판은 확인의 이익이 없다.
- ④ 피심판청구인의 상표등록출원행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것으로서 심판청구인에 대하여 상표권의 효력이 없다는 대인적인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 제기한 권리범위 확인심판은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 는 무관하므로 확인의 이익이 없다.
- ⑤ 甲의 선사용상표가 출원되지 않은 것을 기화로 乙은 甲이 상표를 사용하던 상품과 동일한 상품에 상표등록출원을 하여 상표등록을 받았는바, 甲이 자신의 사용상표와 乙의 등록상표는 표장과 그 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다고 다투지 않고 선사용권을 근거로 甲의 사용상표(확인대상표장)가 乙의 상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 제기한 심판은 확인의 이익이 없다.

해설

- ① [○] 권리범위 확인심판에서 일사부재리호 외에 다른 형성적 효력이 있는지 문제된다. 명문의 규정이 없는 이상 무효심결 등에서 인정되는 형성적 효력은 인정할 수 없다고 봄이 통설적 견해이다.
- ② [○] 확인대상표장은 청구취지의 일부를 구성하므로 그 변경은 청구취지의 변경에 해당하게 된다. 따라서 확인대상표장은 제125조 제2항 제3호의 예외를 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없으므로, 확인대상표장의 보정은 확인대상표장의 불명확한 부분을 구체화하는 등 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 확인대상표장의 동일성이 유지되는 범위(요지변경이 아닌 범위)에서만 인정된다.
- ③ [x] 상표권의 권리범위 확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용할 것이 전제되어야 할 것이므로 상표적 사용인지 여부는 권리범위 확인심판의 판단대상으로 확인이 이익이 있다.
- ④ [○] 지문⑤ 해설 참조
- ⑤ [○] 제99조 소정의 선사용권 또는 상표권자의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된다는 등의 대인적(對人的) 상표권 행사의 제한사유는 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 상표권 침해소송이 아닌 권리범위 확인심판에서 이를 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 다른 점에 대한 다툼이 없이 이를 이유로 제기한 소극적 권리범위 확인심판은 확인의 이익이 없다(송석 사건).

	관련 내용	비고
권리자에게 유효한 권리가 존재할 것	등록권에 무효·취소 사유가 있더라도 적법한 권리이다.	등록주의
사용자의 사용행위가 상표적 사용일 것	法 2①11(형식적) + 상표의 기능 발휘(실질적)	cf) 취소심판에서의 상표의 사용
등록권리의 보호범위 이내의 사용일 것	동일범위 사용 + 유사범위 사용 + 法 108①2, 3, 4	지표단은 상품은 동일범위, 法 108②
사용자에게 정당한 권원이 없을 것	사용권, 권리소진, 진정상품병행수입	데이터팩토리, 권범 심리 x
상표권 효력제한 사유에 해당하지 않을 것	제77조, 제90조, 제160조	큰 틀에서는 보호범위 내용
기타 권리남용에 해당하지 않을 것	사임당, 진한커피, KGB, 하이우드, POLO, KATANA	권범 심리 x

정답 ③

213 상표법상 권리범위 확인심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 따름)

'23 기출

- ① 업무표장권의 적극적 권리범위 확인심판사건에서 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성이 인정되는 경우에는 확인의 이익이 있다.
- ② 상표권의 권리범위 확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제4호 '상품에 대하여 관용하는 상표'에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결 시이다.
- ③ 권리범위 확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단한다.
- ④ 상표권의 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다.
- ⑤ 상표권의 적극적 권리범위 확인심판은 심결이 확정된 경우 심판의 당사자 뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 이에 따라 상표권의 효력이 미치는 범위의 권리확정을 위해 적극적 권리범위 확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서 심리·판단하는 것이 허용된다.

- ① [○] 기독교대한하나님의성회 사건, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1268 판결 [권리범위확인(상)], 업무 표장권의 적극적 권리범위 확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판청구는 부적법하나, 확인대상표장과 실사용 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다.
- ② [○] 매직블럭 사건, 대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결 [권리범위확인(상)], 제90조 제1항 제4호가 규정하고 있는 '상품에 대하여 관용하는 상표'라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것으로서, 상표권의 권리범위 확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시라고 보아야 한다.
- ③ [○] 사부 사건, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결 [권리범위확인(상)], 상표권의 권리범위 확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 이러한 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다.
- ④ [○] 리바이네스 사건, 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결 [권리범위확인(상)], 상표권의 권리범위 확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 '등록상표인 확인대상표장'에 대한 적극적 권리범위 확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다. 이때 '등록상표인 확인대상표장'에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있더라도, 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 자체와 동일하게 호칭되는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표이다.
- ⑤ [×] 상무사 사건, 대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 [권리범위확인(상)], 상표권의 적극적 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는지를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 심결이 확정된 경우 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 그런데 적극적 권리범위확인 심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 제99조의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'(이하 '선사용권'이라고 한다)를 가지고 있다는 것은 대인적(對人的)인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위 확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다.

정답 ⑤

제8절 재심

157-161

214 상표법상 재심에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

18 기출

- ① 당사자는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있으며, 재심청구는 일반재심사유와 사해심결에 관한 재심사유로 나눌 수 있다.
- ② 재심의 심리는 재심청구이유의 범위 내에서 하여야 한다. 따라서 심판관은 당사자가 주장한 사항에 대해서만 심리하여야 한다.
- ③ 대리권의 흠결을 이유로 하여 재심을 청구하는 경우에 재심청구기간은 청구인 또는 법정대리인이 심결 등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 날로부터 기산한다.
- ④ 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다.
- ⑤ 상표등록이 취소된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우 상표권의 효력은 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 선의(善意)로 해당 등록상표와 같은 상표를 그 지정상품과 같은 상품에 사용한 행위에는 미치지 아니한다.

해설

- ① [○] 재심청구는 제157조의 일반재심청구와 제158조의 사해심결에 관한 재심청구가 있다.
- ② [○] 재심의 심리는 재심청구이유의 범위 내에서 하여야 한다(法 157조 제2항 준용 민사소송법 제459조 제1항).
- ③ [×] 대리권의 흠을 이유로 하여 재심을 청구하는 경우에 재심청구기간은 청구인 또는 법정대리인이 심결 등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 날의 '다음 날'부터 기산한다(法 159②).
- ④ [○] 제161조
- ⑤ [○] 제160조

정답 ③

제8편

소송

주 · 제 · 별

리담상표법 객관식 문제집

제1절 심결 등에 대한 소

162-165

215 상표법상 심판 및 소송제도에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

*07 기출

- ① 상표등록취소심판 사유에는 이해관계인이 아닌 자가 취소심판을 청구할 수 있는 사유도 있다.
- ② 이해관계인 또는 심사관은 상표가 등록된 이후에 등록상표가 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하게 된 경우에는 무효 심판을 청구할 수 있다.
- ③ 상표권이 공유인 경우 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사 방해 배제를 위하여 공유자 중 1인이 그 심결의 취소를 구할 수 있다.
- ④ 상표등록이 무효로 된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 선의로 해당 등록상표와 같은 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용한 행위에 대하여는 회복된 상표권의 효력이 미친다.
- ⑤ 심판청구서가 심판청구방식에 위반되는 경우에는 보정명령의 대상이 되고, 만약 그 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 그 보정을 하지 아니하면 심판장은 결정으로 그 심판청구서를 각하하여야 한다.

해설

- ① [○] 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만, 제119조 제1항 제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다.(法 119⑤).
- ② [○] 상표법상의 모든 무효심판은 이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있다.
- ③ [○] 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 [권리범위확인(상)]
- ④ [×] 상표등록이 무효로 된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 선의로 해당 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용한 행위뿐만 아니라, 유사범위 내의 사용 및 간접침해행위에 대하여도 효력이 제한되므로 해당 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용한 행위에 대하여도 효력이 제한된다(法 160).
- ⑤ [○] 제127조 제1항, 제2항

정답 ④

216 상표에 관한 심판 및 소송제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

12 기출

- ① 상표등록거절결정에 대한 불복심판에서 원거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 심판관은 새로운 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 주어야 한다.
- ② 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는 그 등록상표와 동일, 유사한 상표를 사용한 바 있거나 사용하고 있는 자 또는 등록된 상표의 지정상품과 동종의 업을 영위하고 있음으로써 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자가 포함된다.
- ③ 일사부재리의 원칙에 있어서 “동일 사실(같은 사실)”이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, “동일 증거(같은 증거)”라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다는 것이 판례의 입장이다.
- ④ 손해배상의 민사본안소송이 제기된 후, 소극적 권리범위 확인심판이 제기되어 기각심결이 내려졌고 위 민사본안소송의 1심 판결이 선고되었다 하더라도 상표권 소멸 등 특별한 사정이 없는 한 권리범위 확인심판의 심결취소소송은 소의 이익이 있다.
- ⑤ 상표등록의 무효심판에서의 심결에 대한 취소소송을 담당하는 특허법원은 심결이 위법하다고 판단되면 이를 취소하고 환송하는 판결을 할 수 있을 뿐 아니라 스스로 판단하여 당해 상표의 등록을 무효화 할 수 있다.

해설

- ① [○] 거절결정불복심판의 심리범위는 원결정의 거절이유에 한정하지 아니하는바, 심리결과 원거절결정의 거절이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 반드시 거절이유를 통지하여 의견서 제출기회를 주어야 한다.
- ② [○] 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하고 있음으로써 피청구인의 상표 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말한다(대법원 2001.08.21 선고 2001후584 판결). ③ [○] 대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결
- ④ [○] 甲 회사가 乙 회사를 상대로 특허심판원에 상표권에 관한 소극적 권리범위 확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결을 하였는데, 이후 乙 회사가 위 등록상표의 상표권 침해와 관련하여 제기한 민사소송에서 甲 회사 승소판결이 선고되었고, 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 그대로 확정된 사안에서, 확정된 위 민사판결은 위 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 구속력이 없으므로 甲 회사에 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 위 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 위 심결 이후 위 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 위 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하므로, 甲 회사에 위 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 한 사례(대법원 2011.2.24. 선고 2008후4486 판결).
- ⑤ [×] 심결취소소송은 오로지 심결의 위법여부만을 판단하는 것으로서, 상표등록의 무효심판에서의 심결에 대한 취소소송을 담당하는 특허법원은 심결이 위법하다고 판단되면 이를 취소하고 환송하는 판결을 할 수 있을 뿐, 스스로 판단하여 당해 상표의 등록을 무효화 할 수는 없다.

정답 ⑤

217 상표법의 내용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) 13 기출

- ① 상표권자가 상표권에 대하여 전용사용권을 설정한 경우에는 그 범위 안에서 등록상표를 사용할 수 없지만, 금지청구권은 그대로 보유하면서 행사할 수 있다.
- ② 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 상표법 제34조 제1항 제13호의 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표’인지 여부에 대한 판단에 대하여 자백이 인정된다.
- ③ 국내에서 상표등록을 받으려는 자는 국내에서 출원된 상표를 사용하고 있거나 그 상표를 사용할 의사가 있어야 하며, 이 요건은 상표등록거절이유 및 상표등록무효사유에 해당한다.
- ④ ‘미술관경영업’을 지정서비스로 한 등록상표가 ‘미술관경영업’의 서비스 내용에 속하는 미술품 전시 서비스의 제공시 그 수요자인 관람객의 이용에 제공되는 물건인 방명록에 표시되어 국내에서 사용된 것은 상표법 제119조 제1항 제3호(불사용으로 인한 취소심판)에 있어서 그 등록상표의 정당한 사용에 해당한다.
- ⑤ 도메인 이름의 사용태양 및 그 도메인 이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래 통념상 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우 그 도메인 이름의 사용은 상표로서의 사용에 해당한다.

해설

- ① [○] 전용사용권이 설정되어 있더라도 상표권자는 침해자에 대한 침해금지청구권의 행사가 가능하다.
- ② [×] 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 주요사실에 대한 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립할 수 있지만, 자백의 대상은 사실에 한하는 것이어서, 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다. 등록상표가 구 제33조 제1항 제3호의 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'인지 여부 및 같은 법 제34조 제1항 제13호의 '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표'인지 여부는 모두 **법적 판단에 관한 사항**이므로 자백의 대상이 될 수 없다(라꾸라꾸 사건, 대법원 2006.6.2. 선고 2005후1882 판결).
- ③ [○] 제3조 제1항 본문 및 제54조 등.
- ④ [○] 백남준 미술관 사건, 대법원 2011.12.8. 선고 2010후1121 판결

	구법상 판례(백남준 미술관, 대법원 2011. 12. 8. 선고 2010후1121 판결 [등록취소(상)])
표시행위	1) 서비스 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는, 2) 해당 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 상표를 표시하는 행위
유통행위	1) 서비스 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 상표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는, 2) 서비스의 제공에 이용하는 물건에 상표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위
광고행위	"서비스에 관한" 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

- ⑤ [○] 제66조 제1항 제1호에 정한 상표권 침해가 인정될 수 있으려면 '상표의 사용'이 전제되어 야 할 것인데, 도메인이름의 등록사용의 경우에는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 '상표의 사용'으로 볼 수 있다(장수돌침대 사건, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 [한글인터넷주소사용충지등]).

정답 ②

218 상표법상의 심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

17 기출

- ① 제척기간(상표법 제122조) 경과 전에 특정한 선등록상표(X)에 근거하여 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호를 이유로 한 등록무효심판을 청구한 경우라면, 제척기간 경과 후에 그 심판절차에서 새로운 선등록상표(X')에 근거하여 등록무효를 주장하는 것도 허용된다.
- ② 상표권자가 상표법 제119조 제1항 제2호(사용권자의 부정사용으로 인한 취소)단서에서 요구되는 '상당한 주의를 하였다'고 하기 위해서는 사용권자에게 오인·혼동 행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하지만, 그렇다고 사용권자를 실질적인 지배하에 둘 정도의 주의가 요구되는 것은 아니다.
- ③ 복수의 유사상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하여, 그것이 등록상표만 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되더라도 상표법 제119조 제1항 제1호(부정사용에 의한 취소)에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수는 없다.
- ④ 등록상표의 일부 지정상품에 대한 취소심판절차에서 상표법 제119조 제1항 제3호(불사용에 의한 취소)의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송절차에서 상표법 제119조 제1항 제1호(부정사용에 의한 취소)의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수 있다.
- ⑤ 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송 계속 중에 출원인이 당해 상표출원을 취하한 경우 비록 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있었다 하더라도 그 심결의 취소를 구할 이익이 없으므로 심결취소의 소는 부적법하게 된다.

- ① [x] 제척기간 경과 전에 특정한 선등록상표에 근거하여 등록무효심판을 청구한 경우라도 제척기간 경과 후에 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 새로운 선등록상표에 근거하여 등록무효 주장을 하는 것은, 비록 새로운 선등록상표가 새로운 무효사유가 아닌 동일한 무효사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도 실질적으로는 제척기간 경과 후에 새로운 등록무효심판청구를 하는 것과 마찬가지이므로 허용되지 아니한다(장원금제 사건, 대법원 2012.2.23. 선고 2011후2275 판결).
- ② [x] 상당한 주의라 함은 오인·혼동행위를 하지 않도록 주의 경고하는 것만으로는 미흡하며, 정기적으로 상표 사용상태에 대한 보고를 받거나 상품의 품질을 검사하는 등 실질적으로 사용권자를 그 지배하에 두고 있는 것과 같은 관계의 유지를 말한다(A6, 크로커다일 사건, 특허법원 2006. 6. 29. 선고 2006허3113 판결 [등록취소(상)]).
- ③ [x] 복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다(DISCOVERY 사건, 대법원 2016.8.18. 선고 2016후663 판결).
- ④ [x] 제119조 제1항 제1호의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 제119조 제1항 제3호의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 제119조 제1항 제1호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다(KATANA GOLF 사건, 대법원 2010.9.9. 선고 2010후1213 판결).
- ⑤ [○] 심결취소소송 또한 일반 행정소송에 있어서와 마찬가지로 '소의 이익'을 필요로 하며 이때의 소의 이익이란 '심결을 취소할 법률상의 이익'을 말한다. 따라서, 거절결정불복심판에 대한 심결취소소송에서 해당 출원이 취하된 경우 심결을 취소할 법률상의 이익 자체가 소멸된 경우이므로 해당 심결취소소송은 부적법하게 된다.

정답 ⑤

제9편

국제출원 및 국제조약

리답상표법 객관식 문제집

주 · 제 · 별

- 마드리드의정서에 따른 국제출원

- 국제조약

제1장 마드리드의정서에 따른 국제출원

제1절 국제출원 일반

219 마드리드 의정서에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

03 기출

- ① 의정서의 목적은 국제등록출원이라는 절차에 의해서, 하나의 계약국내에서의 출원 또는 등록과 동일한 내용에 대하여 다른 계약국으로 보호를 확장하는 것이다.
- ② 국제출원의 지정상품은 기초출원 또는 기초등록된 표장의 지정상품의 범위 내이어야 하며, 기초출원 또는 기초등록된 표장의 지정상품을 확대할 필요가 있을 때에는 의정서에 의한 국제출원 절차를 활용할 수 없다.
- ③ 마드리드의정서에 의한 국제출원이 국제등록이 된 때부터 5년 이내에 본국의 기초출원 또는 기초등록의 일부 또는 전부에 대해 출원이 거절되거나 또는 등록이 취소·무효가 되면, 국제등록도 마찬가지로 일부 또는 전부에 대하여 취소된다. 따라서 이 경우 구제조치로서 각 지정국에서의 국내출원으로의 변경이 인정되고 있다.
- ④ 마드리드의정서에 의한 국제출원의 경우에는 번역문을 제출하여야 하는 경우가 없다.
- ⑤ 마드리드의정서에 의한 국제출원은 영어 또는 불어 중에서 본국관청이 지정 하는 언어를 사용하여야 하며, 대한민국을 본국관청으로 하는 경우에는 영어로 작성하여야 한다.

해설

- ① [○] 각 나라마다 별개의 절차를 밟아야하는 파리협약에 의한 출원에 비해 하나의 국제출원으로 여러 계약국에 출원 등의 효과를 발생시킴으로써 상표의 국제적 출원을 용이하게 하고, 상표의 국제적 보호가 필요한 시대적 요청에도 부응하기 위함이다.
- ② [○] 적법한 국제출원이기 위해서는 반드시 본국관청에 상표등록출원이나 상표등록을 전제로 하여야 한다. 따라서 이러한 기초출원의 지정상품 외의 상품에 대해서는 국제출원을 할 수 없다.
- ③ [x] 국내출원으로의 변경이 아니라 국제등록소멸일로부터 3월 이내에 동일한 상표에 대해 소멸된 국제등록의 지정상품의 범위 내에서 '재출원'하여 구제 받을 수 있으며, 이 경우 국제등록일에 출원한 것으로 본다(法 205). 또한, '국제등록이 된 때부터 5년 이내'가 아니고, '국제등록일부터 5년' 이다.
- ④ [○] 마드리드의정서에 의한 국제출원에는 국내단계 진입을 위한 번역문 제출 절차가 없다.
- ⑤ [x] 우리나라 지식재산처를 본국관청으로 하는 경우에는 국제출원서 및 국제출원에 필요한 서류를 영어로 작성하여야 한다(法 169①). 다만, 시험당시에는 맞는 지문이었으나, 2004년 4월 1일자로 마드리드 의정서에 의한 국제출원 언어에 불어, 영어 외에 스페인어가 추가되었고, 따라서 이제는 '영어, 불어, 스페인어 중 본국관청이 지정한 언어'를 사용하면 되므로 현재로서는 틀린 지문이다.

정답 ③, ⑤

220 마드리드 의정서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

05 기출

- ① 본국에서의 출원 또는 등록을 국제출원의 전제조건으로 하고 있다.
- ② 국제등록은 파리협약 제4조 D(4)에 규정된 형식요건에 부합하는 경우에만 동 협약에 의한 우선권의 이익을 향유할 수 있다.
- ③ 국제출원에 대한 거절이유통지는 국제출원 사실을 통보받은 날부터 1년 또는 해당 국가의 선언에 의해 18월 이내에 해야 한다(이의신청이 있는 경우 예외).
- ④ 본국관청은 국제출원과 관련하여 출원인에게 요구되는 수수료를 자신의 재량으로 정하고 자신의 이익으로 할 수 있다.
- ⑤ 국제출원 언어는 불어 또는 영어이다.

해설

- ① [○] 국제출원을 위해서는 기초출원 또는 기초등록이 있어야 한다.
- ② [×] 마드리드 의정서 제4조 제2항은 “모든 국제등록은 파리협약 제4조에서 규정하는 우선권을 향유하며 동조 D에서 규정하는 형식을 충족할 것을 필요로 하지 아니한다.”라고 규정하고 있는바, 국제등록은 파리협약 제4조 D(4)에 규정된 형식요건에 부합되는지 여부와 상관없이 우선권의 이익을 향유할 수 있다.
- ③ [○] 국제출원 사실을 통보받은 날이란 영역확장의 통지를 받은 날을 의미한다. 국제출원에 관한 거절이유 통지는 국제사무국이 영역확장의 통지를 한 날부터 1년 이내에 하는 것이 원칙이나 지정국의 선언에 의해 18개월 이내로 할 수 있고, 이의신청의 경우 18개월 이후에도 거절이유를 통지할 수 있다고 선언할 수 있다. 참고로, 대한민국의 경우에는 양 선언을 모두 한 상태이다.
- ④ [○] 이러한 수수료를 개별지정수수료라고 한다.
- ⑤ [×] 2004년 4월 1일자로 마드리드 의정서에 의한 국제출원 언어에 불어, 영어 외에 스페인어가 추가되었으므로 이는 틀린 지문이다.

정답 ②, ⑤

221 '표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서'에 관한 설명으로 옳은 것은? 14 기출

- ① 국제등록된 국제출원에 대하여 그 보호의 거절을 통지하고자 하는 경우 당해 지정국 관청은 영역확장의 통지일로부터 1년 이내에만 거절의 통지를 할 수 있다.
- ② 사후지정에 의하여 지정된 지정국에서의 당해 표장에 대한 보호기간은 사후지정일로부터 10년이다.
- ③ 국제등록에 열거된 지정상품의 일부취소 또는 전부취소를 한 경우 취소된 상품에 대해서는 추후에 계약국에 대한 사후지정을 할 수 없다.
- ④ 국제등록에 열거된 지정상품의 일부에 대해서는 국제등록의 명의변경을 할 수 없다.
- ⑤ 사후지정에 의하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 국제등록일에 상표등록출원된 것으로 본다.

해설

- ① [x] 영역확장의 통지일로부터 1년 또는 1년 6월 이내에 거절의 통지가 가능하다.
- ② [x] 사후지정국에서의 보호기간도 국제등록일로부터 10년이다.
- ③ [○] 국제등록의 취소는 감축이나 포기과 달리 취소의 대상 상품이 국제등록에서 영구적으로 삭제된다. 따라서, 상품의 일부취소이든 전부취소이든 취소된 범위 내에서는 추후 사후지정을 할 수 없다.
- ④ [x] 국제등록의 명의변경은 지정상품의 일부에 대하여도 가능하다.
- ⑤ [x] 사후지정일에 상표등록출원 한 것으로 본다.

정답 ③

222 마드리드 의정서에 의한 국제출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

15 기출

- ① 마드리드 의정서에 의한 국제출원은 대한민국 지식재산처를 경유하여 국제출원하거나 세계지식재산기구(WIPO) 국제사무국에 직접 국제출원할 수 있다.
- ② 마드리드 의정서에 의한 국제출원은 본인의 상표등록출원 또는 본인의 상표등록을 기초로 하여 국제출원할 수 있지만 본인의 상표등록출원 및 상표등록을 동시에 그 기초로 하여 국제출원할 수는 없다.
- ③ 국제등록명의인 또는 그 승계인은 국제등록명의를 변경할 수 있으며, 국제등록의 명의변경 등록신청서는 지식재산처장에게 제출할 수도 있고, 국제사무국에 직접 제출할 수도 있다.
- ④ 국제등록명의인은 국제등록된 지정상품의 전부에 대해서만 사후지정을 할 수 있고, 일부에 대해서는 사후지정을 할 수 없다.
- ⑤ 사후지정은 국제출원과 마찬가지로 반드시 대한민국 지식재산처를 경유하여야 하고, WIPO 국제사무국에 직접 신청할 수는 없다.

해설

- ① [x] 국제출원은 본국관청을 통해서만 출원하여야 하고, 국제사무국에 직접 제출할 수는 없다.
- ② [x] 국제출원은 20이상의 기초출원(등록)에 기초하여 출원할 수도 있고, 기초출원과 기초등록에 동시에 기초하여 출원을 할 수도 있다.
- ③ [○] 명의변경신청은 국제사무국에 직접 또는 본국관청을 통한 신청 모두 가능하다.
- ④ [x] 사후지정은 국제등록된 상품 중 '일부'만에 대한 사후지정도 가능하다.
- ⑤ [x] 사후지정신청서는 국제출원과 달리 명의인이 국제사무국에 직접 제출하거나 본국관청을 경유하여 제출할 수 있다.

	본국관청을 통해 제출	국제사무국에 직접 제출
국제출원	○	×
사후지정	○	○
존속기간의 갱신	○	○
국제등록의 명의변경	○	○
국제등록의 감축, 포기, 취소	×	○

정답 ③

223 상표법상 마드리드 의정서에 의한 국제출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

16 기출

- ① 국제등록명의인이 국제등록된 상표를 보호받고자 하는 국가를 추가로 지정하는 경우에는 국제등록된 지정상품의 전부에 대하여 사후지정을 하여야 한다.
- ② 국제상표등록출원의 상속이나 그 밖의 일반승계는 출원인이 국제사무국에 명의변경신고를 하여야 효력이 발생한다.
- ③ 국제등록명의인은 지정상품에 대하여 국제등록명을 변경하고자 할 때에는 지정상품 전부에 대하여 변경하여야 한다.
- ④ 국제등록이 소멸된 경우에 해당 국제등록의 등록명의인이 한 상표등록출원(재출원)은 소멸된 국제등록의 지정상품 및 상표와 동일·유사한 경우에만 국제등록일에 출원된 것으로 간주된다.
- ⑤ 대한민국, 미국, 일본을 지정국으로 지정한 마드리드 의정서에 의한 국제출원에 의하여 모든 지정국에서 상표권이 설정등록된 경우, 추후 국제등록의 존속기간갱신 신청은 각국의 지식재산처에 해야 한다.

해설

- ① [x] 사후지정은 국제등록된 상품 중 '일부'만에 대한 사후지정도 가능하다.
- ② [○] 국제상표등록출원의 이전은 일반승계든 특별승계든 그 원인에 관계없이 출원인이 국제사무국에 명의 변경신고를 하여야 효력이 발생한다(法 184).
- ③ [x] 국제등록명의인이나 그 승계인은 지정상품 또는 지정국의 전부 또는 일부에 대하여 국제등록의 명의를 변경할 수 있다(法 174①).
- ④ [x] 지정상품 및 상표가 '동일'한 경우에 한하여 제205조 소정의 재출원의 효과가 인정된다.
- ⑤ [x] 국제등록기초상표권의 존속기간은 국제사무국에 국제등록의 존속기간갱신신청을 하여 국제등록부를 갱신함으로써 지정국 전체에 대한 일괄 갱신이 가능하다.

정답 ②

224 마드리드 의정서에 의한 국제출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

'20 기출

- ① 국제상표등록출원의 기초가 되는 국제등록의 전부 또는 일부가 소멸된 경우에는 그 소멸된 범위에서 해당 국제상표등록출원은 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 취하된 것으로 본다.
- ② 국제등록명의인은 국제등록된 지정국을 추가로 지정하는 사후지정을 신청할 수 있고, 이 경우 국제등록된 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 사후지정을 할 수 있다.
- ③ 국제출원은 본국관청에 계속 중인 기초출원 또는 기초등록을 기초로 하여 출원하여야 한다.
- ④ 국제등록은 기초출원(등록)에 종속적이므로 기초출원일로부터 5년이 경과하기 전까지 기초출원(등록)이 실효되면 취소된다.
- ⑤ 국제출원서와 그 출원에 필요한 서류는 지식재산처장에게 도달한날부터 그 효력이 발생하며, 우편으로 제출된 경우에도 또한 같다.

해설

- ① [○] 제202조 제1항
- ② [○] 제172조, 특히 사후지정은 국제등록된 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 가능하다.
- ③ [○] 마드리드 의정서에 의한 국제출원은 기초출원이나 기초등록을 필수적으로 요한다. 2 이상의 기초출원이나 기초등록을 기초로 하여 국제출원하는 것도 가능하다.
- ④ [×] 국제등록의 효력은 기초출원(등록)에 의존하게 되는데 이를 국제등록의 종속성이라고 하고 존속기간은 '기초출원일로부터 5년'이 아니라 '국제등록일로부터 5년'이다.
- ⑤ [○] 제170조

정답 ④

제2절 지식재산처를 통한 국제출원 등

167-179

225 마드리드의정서에 의한 국제출원에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

107 기출

- ① 국제출원을 하기 위해서는 본국관청에 국제출원의 기초가 되는 기초출원 또는 기초등록이 존재하여야 한다.
- ② 대한민국 국민이거나 대한민국 내에 주소 또는 영업소를 가진 자가 한국지식재산처를 본국관청으로 하여 국제출원을 하는 경우에는 한국어로 출원서를 작성할 수 있는 이점이 있다.
- ③ 국제출원의 출원인은 본국관청이 소속된 국가의 국민이거나 당해 국가에 주소를 두고 있거나 당해 국가에 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상의营业소를 두고 있는 자이어야 한다.
- ④ 국제출원의 출원인은 하나의 기초출원 뿐 아니라 다수의 기초출원을 기초로 하여 국제출원을 할 수 있으며 또 다수의 기초출원 및 기초등록을 기초로 하여 국제출원을 할 수도 있다.
- ⑤ 국제출원의 국제등록일은 원칙적으로 본국관청이 국제출원서를 접수한 날이지만 본국관청이 국제출원서를 접수한 날부터 2월 이후에 국제사무국이 국제출원서를 접수하는 경우에는 국제사무국이 실제로 접수한 날이 국제등록일로 된다.

해설

- ① [○] 지문④ 해설 참조
- ② [x] 한국 지식재산처를 본국관청으로 하여 국제출원을 하는 경우에는 영어로 작성한 국제출원서를 제출하여야 한다.
- ③ [○] 국제출원을 하는 본국관청이 소속된 국가의 국민(법인 포함)에 해당하거나, 해당 국가에 주소를 두고 있거나 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상의 营业소(단, 주된 营业소일 필요는 없다)를 두고 있어야 한다. 기초출원(등록)이 공동명의로인 경우에는 공동명의로 국제출원을 하여야 하며, 이 경우 각각의 출원인 모두가 출원인 적격을 갖추어야 한다.
- ④ [○] 기초출원 또는 기초등록이 필수적으로 존재해야하며, 기초출원 또는 기초등록의 지정상품의 범위 내에서 국제출원을 할 수 있다. 2 이상의 기초출원이나 기초등록(출원과 등록을 혼합하는 것도 가능함)을 기초로 하여 국제출원을 하는 것도 가능하다.
- ⑤ [○] 마드리드 의정서 제3조 제(4)항 : "국제등록의 날은 국제출원이 본국관청에 접수된 날로 한다. 다만, 당해 국제출원이 그 날부터 2월 이내에 국제사무국에 접수된 경우에 한한다. 당해 기간 내에 국제출원이 접수되지 아니한 경우 국제등록의 날은 당해 국제출원이 국제사무국에 접수된 날로 한다."

정답 ②

제3절 국제상표등록출원에 관한 특례

180-204

226 마드리드의정서에 의한 국제상표등록출원의 특례에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? 08 기출

- ① 국제상표등록출원이 단체표장인 경우에는 국제사무국의 영역확장의 통지일부터 3월 이내에 상표법 제36조 제1항·제3항에 따른 서류 및 정관을 제출하여야 한다.
- ② 국제등록기초상표권의 존속기간은 국제등록의 존속기간의 갱신에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있다.
- ③ 국제상표등록출원의 출원인은 출원공고 결정전에 있어서 거절이유통지를 받은 때에 한하여 상표 및 그 지정상품을 보정할 수 있다.
- ④ 국제등록기초상표권의 이전·변경·포기에 의한 소멸 또는 존속기간의 갱신은 국제등록부에 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.
- ⑤ 국제상표등록출원에 대해서는 출원의 변경을 할 수 없다.

해설

① [△], ③ [x] 마드리드의정서에 의한 국제상표등록출원은 상표의 보정이 허용되지 않는다(法 185). 따라서, “③” 지문은 명백히 틀린지문이다. 다만, 국제상표등록출원이 단체표장인 경우에는 ‘국제사무국의 영역확장의 통지일 또는 절차보정통지를 받은 날부터 3월 이내’에 제36조 제1항·제3항에 따른 서류 및 정관을 제출하여야 하므로(상표법 시행규칙) “①”의 지문도 그 표현상 옳고 그름에 논란이 있을 수 있으나, ‘국제사무국의 영역확장의 통지일부터 3월 이내에 정관을 제출하여야 한다’는 것 자체가 옳지 않은 것이라 할 수 없고 상대적으로 “③” 지문이 정답임이 명백하므로 “①”의 지문은 옳은 지문으로 처리되었다.

② [○] 제198조 제2항

④ [○] 제196조 제1항

⑤ [○] 제186조

정답 ③

227 상표법상 국제상표등록출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

11 기출

- ① 출원의 승계는 출원인이 국제사무국에 명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.
- ② 상표법 제40조 제2항 제3호에 규정된 ‘불명료한 기재를 석명’하는 보정은 출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.
- ③ 상표법 제44조(출원의 변경)에 따른 출원의 변경 및 상표법 제45조(출원의 분할)에 따른 출원의 분할은 허용되지 아니한다.
- ④ 출원 후 출원인이 아닌 자가 정당한 사유 없이 업으로서 상표등록출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하고 있다고 인정되는 경우에는 다른 상표등록출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.
- ⑤ 심사관은 상표등록거절결정을 하고자 할 때에는 국제사무국을 통하여 그 출원인에게 거절 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

해설

- ① [○] 국제상표등록출원의 승계는 출원인이 국제사무국에 명의변경신고를 하여야 효력이 발생한다(法 184①).
- ② [○] 국제상표등록출원의 요지변경에 대하여는 제40조 제2항 제4호(상표의 부기적인 부분의 삭제)의 규정을 제외하고는 국내상표등록출원의 요지변경에 관한 규정(法 40②)이 그대로 적용된다(法 185②). 따라서, 옳은 지문이다.
- ③ [×] 국제상표등록출원에 대한 출원의 변경은 허용되지 않는다(法 186). 다만, 2023년 개정법에 따라 국제상표등록출원의 출원의 분할이 허용되게 되었다(法 187).
- ④ [×] 국제상표등록출원에는 우선심사신청이 불가능하다(法 189②).
- ⑤ [○] 국제상표등록출원에 대한 거절이유는 출원인에게 직접 통지하지 아니하고, 국제사무국을 통하여 출원인에게 통지함으로써 의견서 제출기회를 부여한다(法 190①).

정답 ③, ④

228 상표법상 국제상표등록출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

12 기출

- ① 국제상표등록출원에 대하여 출원시 특례의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 국제등록일(사후지정의 경우에는 사후지정일)부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ② 국제상표등록출원의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.
- ③ 국제등록기초상표권의 상표권자는 전용사용권자·통상사용권자 또는 질권자의 동의를 얻지 아니하면 국제등록기초상표권을 포기할 수 없다.
- ④ 재출원에 의해 설정등록된 상표에 대한 무효심판은 종전의 국제등록기초상표권에 대한 제척기간이 경과된 때에는 청구할 수 없다.
- ⑤ 국제등록기초상표권자 또는 국제상표등록출원인은 국제등록기초상표 또는 국제상표등록출원의 지정상품을 추가하는 지정상품의 추가등록을 받을 수 있다.

해설

- ① [x] 국제상표등록출원에 출원시 특례를 주장하고자 하는 경우 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 i) 국제사무국의 영역확장의 통지일부터 ii) 3월 이내에 제출하여야 한다(法 189①).
- ② [x] 국제상표등록출원의 이전은 일반승계든 특별승계든 그 원인에 관계없이 국제사무국에 명의변경신고를 하여야 효력이 발생하며, 이에 따라 국제상표등록출원의 상속 기타 일반승계가 있는 경우라도 그 취지를 지식재산처장에게 신고할 필요가 없다(法 184③).
- ③ [x] 국제등록기초상표권은 전용사용권자·통상사용권자 또는 질권자의 동의가 없어도 포기할 수 있다(法 203).
- ④ [○] 제208조, 재출원이 제197조에 따라 설정등록되었던 등록상표에 관한 것인 경우 다음과 같은 두 가지 특례가 적용된다. i) 심사의 특례(法 207); 조약에 위반된 경우를 제외하고는 등록요건을 다시 심사하지 않는다. 이에 따라, 거절이유 통지, 출원공고결정, 이의신청도 적용되지 않는다. ii) 제척기간의 특례(法 208); 제122조 제1항의 제척기간은 원등록의 제척기간이 경과되면 재출원에 의해 등록된 상표권에 대한 제척기간도 경과된 것으로 취급한다.
- ⑤ [x] 국제상표등록출원 또는 국제등록기초상표권에는 지정상품추가등록출원을 할 수 없다(法 199).

정답 ④

229 마드리드의정서에 의한 국제출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

13 기출

- ① 심사관이 출원공고결정을 할 때에 국제상표등록출원서에 기재된 지정상품에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정할 수 있다.
- ② 심사관이 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원에 대한 거절이유를 통지하는 경우에는 거절이유통지서를 상표관리인에게 송달하여야 한다.
- ③ 대한민국을 사후지정한 국제출원의 경우에는 그 사후지정이 국제등록부에 등록된 날을 상표등록출원일로 본다.
- ④ 출원공고결정등본의 송달 전에 한 국제상표등록출원에 관한 상표 또는 지정상품의 보정이 요지를 변경하는 것으로 상표권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원한 것으로 본다.
- ⑤ 국제출원을 하고자 하는 자는 영어 또는 일어로 작성한 국제출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

해설

- ① [×] 국제상표등록출원에는 직권보정의 적용이 없다(法 193②).
- ② [×] 국제사무국을 통하여 '출원인'에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 190①).
- ③ [○] 대한민국을 사후지정한 국제출원의 경우에는 그 사후지정이 국제등록부(의정서 제2조(1)의 규정에 의한 국제등록부를 말하며, 이하 '국제상표등록부'라 한다)에 등록된 날(이하 '사후지정일'이라 한다)을 이 법에 따른 상표등록출원일로 본다(法 180조 제2항 단서). 따라서, 옳은 지문이다. 다만, 조문상의 표현인 '그 사후지정이 국제등록부에 등록된 날(이하, '사후지정일'이라한다)'이란, 물리적으로 사후지정에 관한 사항을 국제상표등록부에 등재한 현실의 날짜를 의미하는 것이 아니라 괄호로 정의한 바와 같이 문자 그대로 '사후지정일'을 의미하는데, '사후지정일'은 마드리드의정서 공통규칙에 따르면 '사후지정신청서를 국제사무국에 직접 제출한 경우에는 국제사무국의 접수일이 되고, 본국관청에 제출한 경우에는 본국관청이 접수일로 보되, 다만 본국관청의 접수일로부터 2월 이후에 국제사무국이 이를 접수하면 국제사무국의 접수일'이 된다.
- ④ [×] 제185조 제3항, '상표'는 보정이 불가능하므로 지문상 '상표'가 제외되어야 한다.
- ⑤ [×] 영어로 작성하여야 한다.

정답 ③

230 국제상표등록출원의 보정에 관한 설명으로 옳은 것은?

17 기출

- ① 출원공고결정 전에 지정상품의 범위의 감축 또는 상표의 부기적인 부분의 삭제를 하는 보정은 국제상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.
- ② 상표법 제40조(출원공고결정 전의 보정)에 따른 지정상품의 보정이 오기의 정정 또는 불명료한 기재의 석명에 해당하지 아니하는 것으로 상표권 설정등록이 있는 후에 인정된 경우에는 그 국제상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원을 한 것으로 본다.
- ③ 상표권 설정등록이 있는 후에 지정상품의 보정이 지정상품의 범위의 감축에 해당하지 아니하는 것으로 인정된 경우, 그 국제상표등록출원에 관한 상표권은 무효의 대상이 된다.
- ④ 상표법 제41조(출원공고결정 후의 보정)에 따라 출원인은 의견서 제출기간 내에 최초의 국제상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.
- ⑤ 국제상표등록출원은 최초의 출원에 대한 등록여부결정 또는 심결이 확정되기 전에 통상의 단체표장등록출원으로 변경하기 위하여 보정할 수 있다.

해설

- ① [×] 국제상표등록출원은 어느 경우라도 상표에 대한 보정이 허용되지 않으므로 옳지 않은 지문이다.
- ② [○] 해당 지문은 결국 국제상표등록출원에 있어 제40조(출원공고결정 전의 보정)에 따른 보정이 요지변경으로 설정등록 후 인정된 경우에는 그 국제상표등록출원은 '보정서를 제출한 때' 상표등록출원한 것으로 보겠다는 의미인데, 국제상표등록출원에 대하여 별도의 특례가 없으면 국내법에 관한 규정을 그대로 적용하므로 옳은 지문이다.
- ③ [×] 제40조, 제41조 여부를 떠나 설정등록 후 요지변경임이 인정된 경우라 하여 상표권이 무효되는 경우는 없다. 따라서, 옳지 않은 지문이다.
- ④ [×] ①번 지문과 마찬가지로 상표에 대한 보정이 허용되지 않으므로 옳지 않은 지문이다.
- ⑤ [×] 국제상표등록출원에 대해서는 법 제44조 제1항부터 제4항까지의 규정을 적용하지 않으므로 출원의 변경이 허용되지 않는다(法 186).

정답 ②

231 마드리드 의정서에 따라 국제등록된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정(사후 지정을 포함하다)한 국제출원(이하 ‘국제상표등록출원’이라 한다)에 관한 설명으로 옳은 것은? 22 기출

- ① 국내에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자는 국제상표등록출원으로 자기의 업무표장을 등록받을 수 있다.
- ② 국제상표등록출원을 하려는 자가 상표의 부기적(附記的)인 부분을 삭제한 경우에는 상표등록출원의 요지를 변경한 것으로 볼 수 있다.
- ③ 국제상표등록출원을 하려는 자가 상표등록출원을 한 경우 증명표장등록출원으로 변경할 수 있다.
- ④ 국제상표등록출원을 하려는 자가 둘 이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우 일정 기간 내에 둘 이상의 상표등록출원으로 분할할 수 있다.
- ⑤ 국제상표등록출원을 하려는 자가 파리협약에 따른 우선권 주장을 한 경우에는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 상표등록출원의 연월일을 적은 서면, 상표 및 지정상품의 등본을 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

해설

- ① [×] 국제상표등록출원에 대해서는 업무표장에 관한 규정을 적용하지 아니한다(法 181). 이는 업무표장은 우리나라의 특유한 제도로 마드리드 의정서에는 업무표장에 대한 개념이 따로 없기 때문이다.
- ② [○] 국제상표등록출원은 상표등록출원서의 기재사항 및 상표에 대하여는 보정을 할 수 없으며, 지정상품에 대하여만 보정을 할 수 있다(法 185②③④). 따라서, 상표에 대한 보정이 있는 경우 이는 요지변경으로 볼 수 있다.
- ③ [×] 국제상표등록출원은 출원변경 제도가 적용되지 않는다(法 186).
- ④ [○] 구법상 이점이 수반되지 않는 국제상표등록출원의 분할을 허용하지 않았으나, 2023년 개정법(2024.05.01. 시행)에 따라 분할출원이 가능하게 되었다(法 187).
- ⑤ [×] 국제상표등록출원을 하려는 자가 파리협약에 따른 우선권 주장을 하는 경우에는 제46조 제4항(우선권 증명서류 제출에 관한 규정) 및 제5항(우선권 증명서류 미제출시의 효과)을 적용하지 아니한다(法 188). 즉, 국제상표등록출원에도 우선권은 인정되나, 우선권주장 증명서류는 제출이 필요 없다.

정답 ②, ④

232 마드리드 의정서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

'24 기출

- ① 마드리드 의정서에 의한 국제출원(지리적 표시 단체표장을 포함)은 기초출원이나 기초등록된 상표견본을 기초로 출원을 해야 하고, 상표의 부기적(附記的)인 부분의 삭제에 해당되는 경우에는 지정국에서 상표 견본의 보정이 허용된다.
- ② 국제상표등록출원에 대해서는 업무표장에 관한 규정을 적용하지 아니한다.
- ③ 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록출원을 통해 지리적 표시 단체표장 및 지리적표시 증명표장의 등록을 받고자 하는 자는 국제등록일(사후지정의 경우에는 사후지정일) 또는 보정통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 그 취지를 기재한 서류와 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증할 수 있는 서류를 정관 또는 규약과 함께 제출하여야 한다.
- ④ 국제출원서와 그 출원에 필요한 서류는 지식재산처장에게 도달한 날부터 그 효력이 발생하며, 우편으로 제출된 경우에도 예외 없이 동일하다.
- ⑤ 국제등록의 명의인은 국제등록된 지정국을 추가로 지정하려는 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 지식재산처장에게 사후지정을 신청할 수 있다.

해설

- ① [x] 기초출원(등록)과 국제출원의 표장은 '엄격히 동일' 하여야 한다. 따라서 유사한 경우 뿐만 아니라 부기적인 부분의 삭제·추가, 거래사회 통념상 동일한 것으로 볼 수 있는 정도의 차이가 있는 경우 등도 합치된다고 볼 수 없고, 나아가 색채도 동일하여야 한다.
- ② [○] 제181조
- ③ [x] 단체표장등록을 받으려는 자는 제36조 제1항·제3항에 따른 서류 및 정관을, 증명표장 등록을 받으려는 자는 제36조 제1항·제4항에 따른 서류를 '국제사무국이 영역확장의 통지를 한 날부터 3개월 이내 또는 제39조에 따른 보정통지를 받은 날로부터 3개월 이내'에 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 이 경우 지리적 표시 단체표장을 등록받으려는 자는 그 취지를 적은 서류와 제2조 제1항 제4호에 따른 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증할 수 있는 서류를 함께 제출하여야 한다(法 182③).
- ④ [○] 제170조
- ⑤ [○] 제172조

정답 ①, ③ (복수정답 처리됨, 2022.04.20. 개정 시행규칙 미반영 지문)

233 상표법상 국제상표등록출원 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

'26 기출

- ① 국제상표등록출원이 거절결정된 경우 출원인은 재심사를 청구하거나 거절결정불복심판을 청구하여 불복할 수 있다.
- ② 국제상표등록출원의 승계는 출원인이 국제사무국에 명의변경 신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.
- ③ 심사관은 상표등록결정을 한 국제상표등록출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 국제상표등록출원을 다시 심사할 수 있다.
- ④ 국제상표등록출원인은 상표법 제58조(손실보상청구권)에 따른 손실보상청구권의 발생을 위하여 국제상표등록출원에 관한 상표 및 지정상품과 동일한 상표 및 상품을 사용하는 자에게 출원공고 전이라도 해당 상표등록출원의 사본을 제시하며 서면으로 경고할 수 있다.
- ⑤ 국제상표등록출원인이 거절이유에 대한 의견서 제출 기간 내에 의견서를 제출하지 못한 경우 의견서 제출 기간 만료일부터 2개월 내에 상표에 관한 절차를 계속 진행할 것을 신청하고 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.

해설

- ① [×] 국제상표등록출원에는 재심사에 관한 규정이 적용되지 않는다(法 193조의2).
- ② [○] 제184조 제1항
- ③ [×] 국제상표등록출원에는 직권 재심사에 관한 규정이 적용되지 않는다(法 193조의2).
- ④ [×] 국제상표등록출원에 대하여 제58조 제1항 단서를 적용할 경우 "해당 상표등록출원의 사본"은 "해당 국제출원의 사본"으로 본다(法 192).
- ⑤ [×] 국제상표등록출원에 대해서는 제55조 제3항을 적용하지 아니한다(法 190②).

정답 ②

제2장 국제조약

234 무역관련 지적재산권에 관한 협정(WTO/TRIPs)상 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

11 기출

- ① 회원국은 상표의 실제 사용을 등록출원의 요건(condition for filing an application for registration)으로 할 수 있다.
- ② 회원국은 등록요건(condition of registration)으로서 표지가 시각적으로 인식 가능할 것을 요구할 수 있다.
- ③ 제3자가 등록상표권자의 허락 없이 등록상표와 동일 또는 유사한 표지를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상업상 사용하여 혼동 가능성을 초래하는 경우, 등록상표권자는 배타적인 사용금지청구권을 가진다.
- ④ 동일한 상품이나 서비스에 대하여 동일한 표지를 사용하는 경우 혼동 가능성이 있는 것으로 추정한다.
- ⑤ 출원일부터 3년의 기간이 만료되기 전에 의도했던 사용이 이루어지지 아니하였다는 이유만으로 출원이 거절되어서는 아니 된다.

해설

- ① [x] 회원국은 사용을 등록요건으로 할 수 있다. 그러나 상표의 실제사용이 등록출원의 요건(조건)이 되어서는 아니된다(TRIPs 제15조 제3항).
- ② [O] 회원국은 등록의 요건으로 표장이 시각적으로 인식 가능할 것을 요구할 수 있다(TRIPs 제15조 제1항).
- ③ [O] TRIPs 제16조 제1항
- ④ [O] TRIPs 제16조 제1항
- ⑤ [O] TRIPs 제15조 제3항 후단

정답 ①

235 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

'20 기출

- ① 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs 협정)상 상표 불사용으로 인하여 상표등록을 취소하기 위한 계속적인 불사용의 최소기간은 3년이다.
- ② 국내에 영업소가 없는 외국인은 그 외국인이 속하는 국가에서 우리나라 국민에게 그 국민과 같은 조건으로 상표권을 인정하는 경우에 상표권이나 상표에 관한 권리를 누릴 수 있다.
- ③ 국내에 주소가 없는 외국인은 우리나라가 그 외국인에 대하여 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 같은 조건으로 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우에 상표권이나 상표에 관한 권리를 누릴 수 있다.
- ④ 국내에 주소가 없는 외국인은 우리나라와 그 외국인이 속하는 국가 사이에 체결된 자유무역협정에서 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우에 상표권이나 상표에 관한 권리를 누릴 수 있다.
- ⑤ 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs 협정)은 회원국의 자율적 결정사항으로 상표권의 강제사용권을 인정하고 있다.

해설

- ① [○] 등록을 유지하기 위해 상표의 사용이 요구되는 경우에는 불사용에 대한 정당한 이유가 없는 한, 적어도 3년간의 계속적인 불사용 이후에만 취소될 수 있다(TRIPs 19).
- ② [○] 제27조(외국인의 권리능력) 제1호 내지 제3호.
- ③ [○] 제27조(외국인의 권리능력) 제1호 내지 제3호.
- ④ [○] 제27조(외국인의 권리능력) 제1호 내지 제3호.
- ⑤ [×] 상표의 사용권 및 양도에 관한 요건은 각국의 재량에 따라 정할 수 있으나, 상표의 강제사용권은 허용되지 아니하며 상표의 양도는 반드시 영업과 함께 이루어질 필요는 없다(TRIPs 21).

정답 ⑤

제10편

상표 외의 권리

주 · 제 · 별

리담상표법 객관식 문제집

제1절 단체표장

236 다음의 상표 이외의 표장에 대한 설명 중 논란의 여지 없이 옳은 것은?

03 기출

- ① 상품과 서비스간에는 출처의 오인·혼동의 우려가 있을 수 없다.
- ② 상표등록출원과 단체표장등록출원 상호간에 출원변경이 허용된다.
- ③ 업무표장권은 지식재산처장의 허가를 받는 경우에 양도할 수 있다.
- ④ 단체표장권에 대해서는 전용사용권을 설정할 수 없다.
- ⑤ 단체표장권자는 단체의 영업에 관한 상품에 사용하기 위하여 스스로 단체표장을 사용할 수 있다.

해설

- ① [×] 표장이 동일·유사하고, 상품과 서비스업 사이에 동종성이 있는 경우 출처의 오인·혼동의 우려가 있다.
- ② [○] 2007년 개정에 따라 상표등록출원과 지리적 표시 단체표장을 제외한 단체표장등록출원 상호간에도 출원변경이 허용된다(法 44①).
- ③ [×] 업무표장권은 업무와 함께 양도하는 경우에 한해 양도 할 수 있다(法 93④).
- ④ [○] 제95조 제2항, 논란의 여지 없이 전용사용권을 설정할 수 없다.
- ⑤ [○] 단체표장의 정의규정에 대한 2005년 개정에 따라 논란의 여지 없이 단체표장권자는 스스로 단체표장을 사용할 수 있다.

정답 ②, ④, ⑤

237 상표등록의 취소심판에 관한 설명으로 옳은 것은?

04 기출

- ① 상표등록의 취소심판은 이해관계인이 아니더라도 누구든지 이를 청구할 수 있다.
- ② 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ③ 단체표장에 있어서 소속단체원이 정관의 규정에 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 하였음을 사유로 하는 상표등록의 취소심판은 그 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다.
- ④ 상표등록의 취소심판은 상표권이 소멸된 후에도 이를 청구할 실익이 있다.
- ⑤ 상표등록의 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 때에는 인용심결을 하여서는 아니 된다.

해설

- ① [×] 제119조 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만, 제1항 제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다(法 119⑤).
- ② [×] 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만, 제119조 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다(法 119⑥).
- ③ [○] 제119조 제1항 제7호 가목에 해당하는 경우로 이 경우에는 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이라는 제척기간이 적용된다(法 122②).
- ④ [×] 취소심판에 있어서 확정심결의 효과는 장래효 또는 심판청구일로부터 소급소멸(法 119①③)이므로 상표권이 소멸된 후에는 취소심판을 청구할 실익이 없다.
- ⑤ [×] 이와 같은 경우에 해당하는 취소사유는 제119조 제1항 제4호와 제6호이며, 나머지 취소사유는 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 인용심결을 한다(法 119④).

정답 ③

제2절 증명표장

238 증명표장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

17 기출

- ① 단체표장과 달리 증명표장은 법인뿐만 아니라 개인도 출원하여 등록받을 수 있다.
- ② 상표·단체표장 또는 업무표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 상표 등과 동일·유사한 표장을 지정상품의 동일·유사여부와 상관없이 증명표장으로 등록받을 수 없다.
- ③ 증명표장등록출원의 지정상품은 「증명의 대상」과 「증명의 내용」이 함께 기재되어야 하며, 그 중 어느 하나가 기재되어 있지 않거나 그 기재가 불명확한 경우 실무상 상표법 제38조(1상표1출원) 제1항의 거절이유를 적용하고 있다.
- ④ 증명표장은 정관에서 정한 기준을 충족한 자이면 누구나 사용할 수 있으므로 증명표장권자도 정관에서 정한 기준을 충족하면 자기의 영업에 관한 상품에 이를 사용할 수 있다.
- ⑤ 증명표장등록출원에 있어 표장의 동일·유사여부는 증명표장은 물론 상표·업무표장·단체표장 등과의 유사여부를 함께 고려하여 판단하여야 한다.

해설

- ① [○] 단체표장은 법인만이 권리주체가 될 수 있음과 비교하여, 증명표장은 개인 또는 법인 모두 권리의 주체가 될 수 있다.
- ② [○] 제3조 제4항, 특히, 2016년 개정으로 인하여 '지정상품의 동일·유사와 상관없이' 등록받을 수 없음에 유의하여야 한다.
- ③ [○] 상표심사기준 제7부 제3장 3.2
- ④ [x] 증명표장은 그 특성상 증명표장권자 스스로 증명표장을 자기의 상품이나 서비스에 사용하는 것은 허용되지 아니하며, 상표법은 제3조 제3항 단서 및 제119조 제1항 제9호 나목을 통하여 증명표장권자의 사용을 인정하지 않는다.
- ⑤ [○] 단체표장, 증명표장 및 업무표장에 대하여는 특별한 규정이 없으면 상표의 규정이 적용되므로(法 2③), 권리의 형식에 얽매이지 않고 등록요건 또는 보호범위 판단을 위해 상표의 유사여부를 판단한다.

정답 ④

제3절 지리적표시 단체표장

239 지리적 표시 단체표장에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

09 기출

- ① 지리적 표시 단체표장은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장이다.
- ② 둘 이상의 지리적 표시 등록단체표장이 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 경우, 그 중 늦게 출원하여 등록받은 단체표장권자 및 그 소속단체원에게 지리적 출처에 대하여 수요자로 하여금 혼동을 초래하지 아니하도록 하는 표시를 하여야 할 의무가 있다.
- ③ 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 있다.
- ④ 지리적 표시 단체표장등록을 받은 자가 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우에는 누구든지 그 지리적 표시 단체표장등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표에 대하여는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.

해설

- ① [○] 제2조 제1항 제6호
- ② [×] 둘 이상의 지리적 표시 등록단체표장이 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 경우 각 단체표장권자와 그 소속 단체원은 지리적 출처에 대하여 수요자가 혼동하지 아니하도록 하는 표시를 등록단체표장과 함께 사용하여야 한다(法 223). 따라서, 늦게 출원하여 등록받은 자에 한하지 않고 양자 모두 혼동방지 표시를 할 의무가 있다.
- ③ [○] 제34조 제1항 제8호
- ④ [○] 제119조 제1항 제8호 가목
- ⑤ [○] 제90조 제2항 제2호

정답 ②

240 사단법인 진도홍주연합회는 지정상품인 “홍주”에 대하여 “진도홍주”를 지리적 표시 단체 표장으로 등록받았다. 사단법인 진도홍주연합회의 지리적 표시 단체표장권의 효력에 관한 설명으로 옳은 것은?

10 기출

- ① 사단법인 진도홍주연합회는 등록된 “진도홍주”의 출원일 이전에 선출원에 의하여 등록된 상표인 “곰표 진도홍주”의 상표권자 또는 전용사용권자인 목포의 홍주 생산자가 지정상품인 “홍주”에 대하여 등록 지리적 표시 단체표장인 “진도홍주”를 사용하는 것을 금지할 수 없다.
- ② 사단법인 진도홍주연합회는 정당한 권한없는 타인이 등록된 “진도홍주”를 지정상품인 “홍주”뿐만 아니라 그 유사상품인 “소주”에 대하여 사용하는 것도 금지할 수 있다.
- ③ 사단법인 진도홍주연합회는 정당한 권한없는 타인이 등록된 “진도홍주”와 유사한 상표인 “신 진도홍주”를 지정상품인 “홍주”뿐만 아니라 그 유사상품인 “소주”에 사용하는 것도 금지할 수 있다.
- ④ 진도에서 홍주를 생산하는 업자인 홍길동이 진도에서 전통적으로 내려오는 비법과 재료를 그대로 사용하여 제조한 “홍주”에 대하여 “코끼리표 진도홍주”라는 상표를 표시하여 판매하는 경우 사단법인 진도홍주연합회는 지리적 표시 단체표장권을 주장하여 그 사용을 금지할 수 없다.
- ⑤ 제주도의 어느 한 지명인 “진도”(실제 있는 지명이 아니라 가정해 본 지명이다)가 홍주라는 상품에 대하여 지리적 표시에 해당한다면, 사단법인 진도홍주연합회는 제주도 진도에서 그 전통방식에 따라 홍주를 생산하는 업자가 “제주도 진도홍주”라고 상표를 사용하는 것을 금지할 수 있다.

해설

- ① [×] 선출원에 의하여 등록된 상표인 “곰표 진도홍주”의 상표권자 또는 전용사용권자가 그 등록상표인 “곰표 진도홍주”를 “홍주”에 사용하는 경우에는 제90조 제2항 제4호에 따라 침해가 아니나, “진도홍주”를 사용하는 경우에는 제90조 제2항 제4호의 적용이 없고, 지리적 표시 단체표장권은 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장 및 현저한 지리적 명칭에도 그 효력이 미치며, 문제에서 “목포”의 홍주 생산자라 하였으므로 지리적 표시의 정당한 생산자로서 자유 사용이 가능하다는 제90조 제2항 제3호의 항변도 불가하므로 사단법인 진도홍주연합회는 그 사용을 금지시킬 수 있다.
- ② [×] 지문③ 해설 참조
- ③ [×] 지리적 표시 단체표장권은 오로지 동일하거나 동일하다고 인식된 상품에 한하여 소극적 효력이 미치므로 옳지 않은 지문이다.
- ④ [○] 비록 표장이 유사하고, 상품이 동일하여 침해가 성립될 수 있으나, 진도에서 홍주를 생산하는 업자인 홍길동은 제90조 제2항 제3호에 따라 지리적 표시의 해당상품에 대한 정당한 생산자로서 자유 사용이 가능하다. 따라서 옳은 지문이다.
- ⑤ [×] 동음이의어 지리적 표시 상호 간은 소극적 효력이 미치지 아니하므로(法 90②3, 108②1호), 옳지 못한 지문이다.

정답 ④

241 상표법상 지리적 표시 또는 지리적 표시 단체표장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 11 기출

- ① 세계무역기구 회원국 내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 포도주 또는 증류주에 사용하려는 상표의 경우, 당해 지리적 표시의 정당한 사용자는 그 해당 상품을 지정상품으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.
- ② 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하게 할 목적으로 소지하는 행위는 그 지리적 표시 단체표장권을 침해한 것으로 본다.
- ③ 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없다.
- ④ 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 표장으로 2 이상의 지리적 표시 단체 표장등록출원이 있는 경우, 먼저 출원한 자만이 등록을 받을 수 있다.
- ⑤ 지리적 표시 단체표장을 등록받고자 하는 자는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관 외에 지리적 표시의 정의에 일치함을 증명할 수 있는 서류를 지리적 표시 단체표장등록출원서에 첨부하여야 한다.

해설

- ① [○] 제34조 제1항 제16호 단서
- ② [○] 제108조 제2항 제2호
- ③ [○] 제34조 제1항 제14호
- ④ [×] 제35조 제1항 및 제2항의 규정(선출원주의)은 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 표장으로 둘 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원이 있는 경우 적용하지 않는다(法 35⑥).
- ⑤ [○] 제36조 제5항

정답 ④

242 지리적 표시 단체표장등록의 무효심판 사유 또는 취소심판 사유 중 어느 하나에도 해당되지 않는 것은?

14 기출

- ① 지리적 표시 단체표장권자가 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지한 경우
- ② 원산지 국가에서 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시를 더 이상 보호하지 않게 된 경우
- ③ 등록출원 당시 산지표시(상표법 제33조 제1항 제3호) 또는 현저한 지리적 명칭(동법 제33조 제1항 제4호)에 해당하는 것이었다는 사실이 밝혀진 경우
- ④ 지리적 표시 단체표장권자가 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에 대하여 단체의 가입을 허용한 경우
- ⑤ 지리적 표시 단체표장을 사용할 수 있는 자 중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록단체표장을 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않은 경우

해설

- ① [○] 제119조 제1항 제8호 가목 소정의 취소사유이다.
- ② [○] 제117조 제1항 제7호 소정의 후발적 무효사유이다.
- ③ [×] 제33조 제3항에 따라 지리적 표시 단체표장은 제33조 제1항 제3호 중 산지표시 및 제33조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭에 해당한다 하여도 지리적 표시 단체표장 등록이 가능하다.
- ④ [○] 제119조 제1항 제8호 가목 (후단) 소정의 취소사유이다.
- ⑤ [○] 제119조 제1항 제3호에 따른 취소사유이다.

정답 ③

243 상표법상 지리적 표시 단체표장에 관한 설명으로 옳은 것은?

19 기출

- ① 지리적 표시 단체표장에서 지리적 표시는 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 전적으로 특정지역에서 비롯된 경우에만 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다.
- ② 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 판매하는 자만으로 구성된 법인이 직접 사용하기 위한 표장에 대해 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.
- ③ 서비스에 대해 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.
- ④ 지리적 표시 단체표장등록출원은 상표등록출원으로 출원의 변경을 할 수 없다.
- ⑤ 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 제조하는 자가 직접 사용하기 위한 표장에 대해 개인을 출원인으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.

해설

① [x] '지리적 표시'란 '상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에만 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시'를 말한다(法 2조 제1항 제4호). 그러나 해당 지역의 지리적 환경이 타지역에서는 볼 수 없는 배타성까지를 가져야 하는 것은 아니고, 나아가 전적으로 특정지역에 비롯된 경우에만 인정되는 것으로 보기도 어려우므로 틀린 지문이다.

※ 다만, 그렇다 하여 상품의 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 다른 지역에서 비롯된 경우 해당 특정 지역에 대한 지리적 표시로 인정될 수는 없다는 점에서 본 지문은 관점에 따라 국어적 해석으로는 OX에 대한 논란이 있을 수도 있으나, 위 조문상의 정의규정에 '만'이 없다는 점과 지문의 취지가 결국 배타성 등을 요하는 것은 아니라는 점을 묻는 것으로 볼 수 있어 이의신청까지 문제될 만한 것은 아닌 것으로 판단됨, 본 지문은 시험적으로 보면 결국 조문 표현에는 없는 '만' 등을 넣는 방법으로 조문을 살짝 틀어서 출제한 것으로 조문표현상 틀린 지문으로 처리 될 수 밖에 없음.

② [x] 지리적 표시 단체표장의 출원인 적격과 관련하여 현행법은 구법의 "그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자[만으로] 구성된 법인"에서 '만으로' 부분을 삭제하여 유통·판매를 하는 법인도 지리적 표시 단체표장의 출원인인 법인의 단체원이 될 수 있도록 출원인 적격을 완화하였다(시행일: 2018. 7. 18.). 다만, 유통·판매하는 자들도 지표단 권리주체인 법인의 구성원이 될 수 있다는 의미이지, '유통·판매하는 자만으로 구성된 법인'이 지표단의 등록을 받을 수 있는 것은 아니다.

③ [x] 지리적 표시가 사용되는 상품의 경우에는 서비스 또는 서비스에 관련된 물품을 포함하지 아니하므로(法 2①1), 서비스에 대해서는 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 없다.

④ [○] 지리적 표시에 관한 출원(지표단, 지표증)과 업무표장에 관한 출원은 출원 변경의 대상이 아니다(法 44①).

⑤ [x] 지리적 표시 단체표장을 개인이 등록받을 수 있는 경우는 없다. 이와 비교하여 지리적 표시 증명표장은 법인 뿐만 아니라 개인도 등록받을 수 있다.

정답 ④

제4절 업무표장

244 업무표장에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

19 기출

- ① 업무표장 등록을 받은 자는 해당 업무표장과 유사한 표장을 증명표장으로 등록받을 수 있다.
- ② 업무표장등록출원은 해당 업무와 함께 양도하지 않더라도 양도할 수 있다.
- ③ 업무표장권에 대해 질권을 설정할 수 있다.
- ④ 업무표장등록출원은 상표등록출원으로 변경할 수 있다.
- ⑤ 업무표장권에 대해 전용사용권을 설정할 수 없다.

해설

- ① [×] 상표·단체표장 또는 업무표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 상표 등과 동일·유사한 표장을 증명표장으로 등록받을 수 없다(法 3④).
- ② [×] 업무표장등록출원 또는 업무표장권은 이를 양도할 수 없다. 다만, 해당 업무와 함께 양도하는 경우에는 양도할 수 있다(法 48⑥, 93④).
- ③ [×] 지문⑤ 해설 참조.
- ④ [×] 제44조 제1항.
- ⑤ [○] 업무표장권에 대한 사용권 또는 업무표장권을 목적으로 하는 질권은 설정할 수 없다(法 95②, 97⑤, 93⑧).

정답 ⑤

저 자 소 개

김 | 인 | 배

저자약력

- 문성고등학교 졸업
- 한양대학교 토목공학과 졸업
- 제46회 변리사시험 합격
- (주)이지팩스 근무
- 특허법인 주원 파트너 변리사
- 한빛지적소유권센터 상표&디자인 전임강사
- 지식재산처 디자인보호법 전문위원
- 한국발명진흥회 IPAT 출제위원
- 대한변리사회 연수위원
- 지식재산처 국제재식재산연수원 신규·중견심사관
과정 디자인보호법 담당강사
- 서울지식재산센터 디자인보호법 강사
- 경기지식재산센터 디자인보호법 강사
- 강원지식재산센터 디자인보호법 강사
- 울산지식재산센터 디자인보호법 강사
- 충주지식재산센터 디자인보호법 강사
- 제주지식재산센터 디자인보호법 강사
- 서울예술대학교 예술과 법 강사
- 계원예술대학교 디자인과 모방 강사
- 건국대학교 디자인학부 강사
- 연세대학교 디자인학부 강사
- 성균관대학교 디자인대학원 강사
- 리담변리사학원 상표&디자인 전임강사

주요저서

- 도해 디자인보호법 《2010, ㈜한빛지적소유권센터》
- THE DESIGN LAW 2019 《2019, ㈜한빛지적소유권센터》
- Limdam DESIGN LAW 2023 《2023, ㈜한빛지적소유권센터》
- EZ 객관식 디자인보호법 《2014, ㈜한빛지적소유권센터》
- 중소기업이 알아야 할 특허법 《2013, 대한상공회의소》
- Insight+ 디자인보호법 《2016, ㈜한빛지적소유권센터》
- Insight+ 디자인보호법 서브노트 《2015, ㈜한빛지적소유권센터》
- Insight+ 객관식 디자인보호법 《2016, ㈜한빛지적소유권센터》
- 理智 디자인보호법 《2019, ㈜한빛지적소유권센터》
- 理智 객관식 디자인보호법 《2019, ㈜한빛지적소유권센터》
- 리담 객관식 디자인보호법 《2023, ㈜한빛지적소유권센터》
- 리담디자인보호법 2차 서브노트 《2023, ㈜한빛지적소유권센터》
- 리담디자인보호법 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담디자인보호법 강의노트 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담디자인보호법 서브노트 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담디자인보호법 조문정리 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담디자인보호법 조문 스터디 키트 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담디자인보호법 진도별 OX 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담디자인보호법 객관식 문제집 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담 객관식 상표법 《㈜한빛지적재산권센터》
- 리담상표법&디자인보호법 기출문제집
《2025, ㈜한빛지적재산권센터》
- 리담상표법 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담상표법 서브노트 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담상표법 강의노트 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담상표법 진도별 OX 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담상표법 조문정리 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담상표법 조문 스터디 키트 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담상표법 판례 《2026, 리담지식재산교육원》
- 리담상표법 객관식 문제집 《2026, 리담지식재산교육원》

저자 이메일 : ibkim@joowonpat.com

저자 김인배

발행처 리담지식재산교육원

등록 제2026-000065호

理談 상표법 객관식 문제집(주제별)

2023년	6월	12일	제	1	판	발행
2024년	5월	24일	제	2	판	발행
2025년	8월	21일	제	3	판	발행
2026년	9월	18일	제	4	판	발행